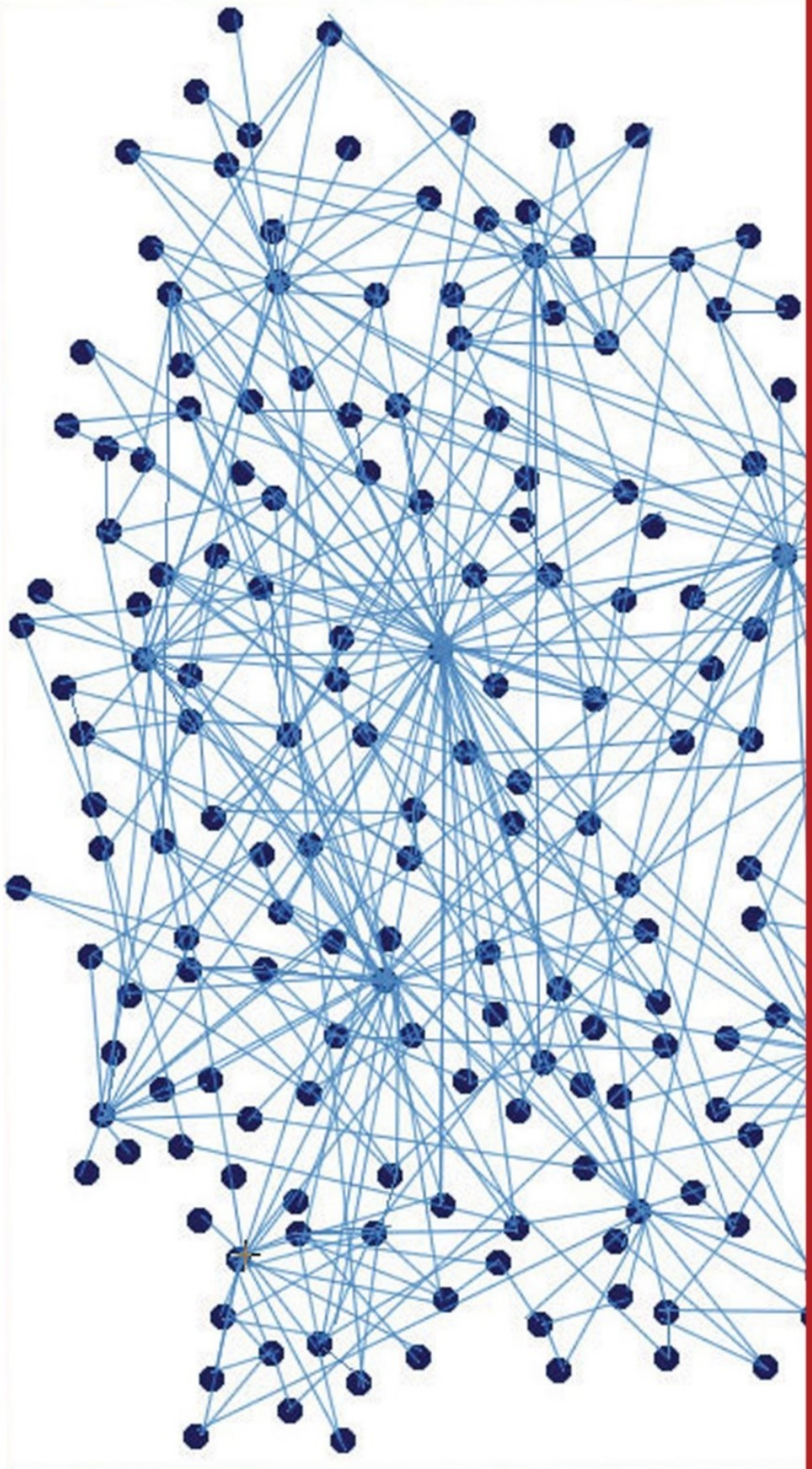
Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. NOZIONE, OGGETTO, CARATTERI, ORIGINI E SVILUPPO DEL DIRITTO COMMERCIALE 3

2. SVILUPPO STORICO DEL DIRITTO COMMERCIALE: DAGLI STATI NAZIONALI AL CODICE CIVILE DEL 1942 7

3. DAL SISTEMA DEL CODICE CIVILE DEL 1942 AL NUOVO DIRITTO COMMERCIALE INTERNAZIONALE. 11

BIBLIOGRAFIA 14

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Nozione, oggetto, caratteri, origini e sviluppo del diritto commerciale

L'ordinamento giuridico italiano può essere suddiviso astrattamente in norme di diritto pubblico e norme di diritto privato, adottando quale criterio distintivo il carattere pubblico o privato del soggetto che opera all'interno dell'ordinamento stesso (fatta salve i casi in cui un soggetto di carattere pubblico operi nelle vesti di "soggetto di diritto privato" e dovendosi applicare in tal caso le norme privatistiche).

Il diritto privato è costituito da norme rivolte a regolare i comportamenti di soggetti che sono indipendenti e distinti rispetto agli organi statuali.

Il diritto commerciale è l'insieme delle norme destinate a regolare l'organizzazione e l'attività dell'imprenditore, soggetto indipendente e distinto dagli organi statutali; pertanto, tale diritto è parte del diritto privato. Si tratta però di norme particolari di diritto privato, poiché possono essere applicate esclusivamente ai soggetti che rivestono la qualità giuridica di imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 e seguenti del codice civile italiano.

Le norme del codice civile del 1942 devono però essere lette ed interpretate alla luce degli articoli 41 e 42 della Costituzione.

L'articolo 41 Cost., affermando che "l'iniziativa economica privata è libera", afferma il principio per il quale ciascun soggetto privato può organizzare ed esercitare qualsiasi tipologia di attività indirizzata alla produzione di merci o allo scambio di servizi.

Tale principio può essere sacrificato nei soli casi in cui l'attività esercitata si ponga in contrasto con l'utilità sociale, possa recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.

Da una diversa prospettiva di lettura, si potrebbe affermare che per importanza di principi, dopo la sicurezza, la libertà e la dignità della persona umana e l'utilità sociale dell'attività svolta, può essere annoverata la libertà di iniziativa economica privata.

L'articolo 42 Costituzione, invece, conferisce al diritto di proprietà un carattere fondamentale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Non si può fare a meno di ricordare come la certezza della titolarità del diritto di proprietà sia alla base della corretta circolazione dei beni sul mercato e del loro impiego produttivo.

Quanto enunciato da questi articoli è il frutto della scelta politica effettuata dall'assemblea costituente di aderire al modello di sviluppo basato sull'economia di mercato, nel quale gli operatori economici, esercitando la propria attività imprenditoriale, oltre a soddisfare un interesse proprio, contribuiscono a soddisfare altresì interessi di tipo collettivo.

La scelta di tale modello di sviluppo e l'interpretazione data degli articoli del testo costituente, ben si comprendono se si pensa all'altro possibile modello di sviluppo economico che la storia presentava all'assemblea costituente, vale a dire l'economia collettiva, nel quale però l'iniziativa economica è pubblica ed i mezzi di produzione sono di proprietà collettiva.

Il diritto commerciale, come si è detto, regola il "comportamento" dei soggetti qualificabili come imprenditori. Tale "comportamento" si può concretizza:

1. nell'attività necessaria per costituire e mantenere l'operatività dell'impresa intesa quale "soggetto-organismo": l'impresa è innanzitutto un soggetto con una capacità giuridica ed una responsabilità patrimoniale tipicamente caratterizzata a seconda della forma societaria adottata. Come affermato da autorevole dottrina, vi è un sistema di norme che "*da' rilievo giuridico all'unità teleologica dei singoli atti di impresa*" (cfr. G.F. CAMPOBASSO, "*Diritto commerciale 1*", pag. 3, ed. VI, UTET Giuridica, 2010);
2. nell'attività di relazione tra l'impresa ed altri soggetti ad essa esterna: la ratio della disciplina normativa è quella di favorire l'operatività degli imprenditori, il legislatore pertanto si pone come obiettivo di creare un ambiente giuridico dove i beni possano essere scambiati con sicurezza e velocità e dove sia altresì garantita la tutela del credito.

L'attribuzione della qualifica giuridica di imprenditore comporta quindi l'applicazione di una normativa specifica, che risponde alla necessità di tutela determinata dalla peculiarità di tale *status* giuridico. Il diritto commerciale è quindi il diritto privato delle imprese.

È un diritto a carattere speciale poiché i principi fondanti ai quali è ispirata la disciplina sono esclusivi e comuni ai soggetti qualificabili giuridicamente come imprenditore.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È un diritto che tende all'uniformità internazionale: ciò si spiega in quanto è rinvenibile una comunione di interessi fondamentali tra gli imprenditori, indipendentemente da dove esercitano la loro attività. Inoltre, lo sviluppo della tecnologia e la conseguente possibilità di vedere la propria "piazza di mercato" estendersi fino a coincidere con l'intero globo, ha portato l'affermarsi ed il consolidarsi di una prassi commerciale internazionale.

Il diritto commerciale contemporaneo è il risultato della evoluzione di un fenomeno, le cui origini si fanno risalire al basso Medioevo (XII secolo), nel quale all'organizzazione feudale in declino, si sostituì il sistema Comunale; rifiorirono i traffici commerciali e presero vita le Corporazioni di Arti e Mestieri.

Il panorama giuridico di quell'epoca era caratterizzato dalla vigenza del diritto comune (civile giustinianeo e canonico), rispetto al quale il diritto commerciale si pose come diritto speciale.

L'attività commerciale necessita di norme giuridiche che garantiscano e favoriscano la celerità dei traffici e la certezza del diritto, condizioni che non potevano essere garantite dal diritto comune vigente.

Questa nuova disciplina, nata dalla pratica, dall'esercizio dell'attività mercantile e artigianale, trovava applicazione nelle fasi patologiche dei rapporti, grazie ad organi giudicanti formati esclusivamente da mercanti ed artigiani che ben conoscevano la prassi e gli usi che regolavano la vita economia e giuridica della propria corporazione.

Le fonti del diritto mercantile si ampliarono aggiungendo alla prassi ed agli usi mercantili (consuetudini) le pronunce "giurisprudenziali".

Questi tribunali di carattere professionale aumentarono col tempo la propria capacità di giurisdizione, pronunciandosi anche sulle controversie mercantili tra mercanti (anche non iscritti alla Corporazione) e non mercanti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'evoluzione della disciplina culminò nella metà del XVI secolo con la lex mercatoria (o ius mercatorum) i cui caratteri peculiari si possono così enucleare:

a) la distinzione e la contrapposizione al diritto civile;
b) il principio della libertà delle forme (contrapposto alla solennità delle forme negoziali dettata dal diritto comune e dal diritto canonico);
c) la tutela rafforzata per il creditore: "*il debitore deve pagare puntualmente alla scadenza e non può ottenere dal giudice dilazioni; i debiti scaduti producono automaticamente interessi; non è consentita la datio in solutum; se gli obbligati sono più, essi si presumono obbligati in solido*" (cfr. G.F. Campobasso, "*Diritto commerciale 1*", pag. 5, ed. VI, UTET Giuridica, 2010).

Tale esperienza giuridica diede vita a:

- la società in nome collettivo;
- la società in accomandita semplice;
- la procedura fallimentare che adottò il criterio della ***par condicio creditorum***, per la quale tutti i creditori partecipano alla ripartizione dell'attivo fallimentare e sopportano l'insolvenza del debitore proporzionalmente ai crediti vantati (mentre nel diritto comune vigeva, per i medesimi fini, il differente principio della "priorità temporale" del credito).

Il diritto mercantile si affermò pertanto come diritto di classe in quanto espressione dell'autonomo ceto mercantile, senza però che tale diritto venisse piegato di fronte agli interessi del ceto mercantile.

Come ricorda infatti autorevole dottrina, "*la saggezza tuttavia dell'elaborazione del diritto commerciale e dell'opera di quanti lo applicavano giudizialmente fu quella del superamento dell'interesse di classe*" (cfr. G.F. CAMPOBASSO, *op. cit.*, in nota 3, ASCARELLI, Corso, 21 e 22).

Si può affermare, inoltre, che il diritto commerciale assunse carattere universale in considerazione della sua vasta applicazione geografica, come conseguenza della diffusione dei traffici commerciali in tutta Europa.

Si ribadisce inoltre il carattere specifico di tale diritto, legato alla professione mercantile.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Sviluppo storico del diritto commerciale: dagli stati nazionali al codice civile del 1942

Il diritto commerciale del XVI secolo subì nuovi cambiamenti in considerazione della nascita degli Stati nazionali europei e dell'interventismo degli stessi nella vita economica (periodo mercantilista), ponendo fine all'autonomia normativa delle corporazioni mercantili.

Nel disegno politico dei Regni Nazionali dell'epoca, l'intervento in campo economico costituiva un diretto riflesso dell'interesse dei monarchi ad affermare la propria potenza sullo scenario nazionale ed internazionale.

A titolo esemplificativo del carattere statale e nazionale acquisito dal diritto commerciale, si ricordi l'"*Ordonnance sul le commerce*" (1673) e l'"*Ordonnance de la marine*" (1681) emesse da Re Luigi XIV in Francia, primi esempi di legislazione organica di diritto commerciale.

Conseguenza naturale di questa nuova prospettiva, fu il passaggio della giurisdizione mercantile sotto la giurisdizione statale.

Si costituirono tribunali di commercio (statali), distinti e speciali rispetto ai tribunali civili.

In tale scenario politico ed economico si possono rinvenire le origini delle moderne Società per Azioni (si pensi a titolo esemplificativo alla Compagnia delle Indie, costituita per concessione regia), nelle quali si afferma il principio della responsabilità limitata dei soci e la suddivisione del capitale in azioni; nascono le prime borse valori ed i primi brevetti "industriali".

Il diritto commerciale subì però nuove trasformazioni con l'avvento della codificazione.

La Rivoluzione francese, abbattendo il sistema corporativistico, lasciò lo spazio per l'affermazione del principio di libera iniziativa in campo economico, il venir meno dei privilegi di classe.

Prese forma lo Stato liberale.

Con la grande opera codificatoria francese dell''800, di matrice napoleonica, si affermò il fondamentale diritto di proprietà, che trovò il suo posto nella successiva codificazione di matrice italiana.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Su esempio della codificazione napoleonica, infatti, il Regno d'Italia unificato produsse per emanazione regia nel 1865 il codice civile ed un distinto codice di commercio, quest'ultimo poi sostituito da quello del 1882.

Fu nel 1888 che nell'Italia dell'epoca si soppressero i Tribunali di commercio; la giurisdizione commerciale fu assorbita dai Tribunali civili (a differenza dell'ordinamento giuridico francese nel quale permane ancora oggi la distinzione tra la giurisdizione civile e quella commerciale).

Vi è però una ulteriore evoluzione nell'applicazione del diritto commerciale, conseguente all'evolversi della tecnica ed all'avvento della rivoluzione industriale: gli operatori economici non annoverarono solo mercanti ed artigiani, ma fecero irruzione sullo scenario economico gli industriali ed i banchieri.

Il codice di commercio italiano (1882) adottò una nuova impostazione: al criterio soggettivo - l'appartenenza al ceto mercantile - utilizzato per delineare l'applicabilità di tale disciplina si sostituì il criterio oggettivo: è commerciante chi compie abitualmente atti di commercio (art. 8 cod. comm. 1882).

L'esercizio abituale di atti di commercio costituì il nuovo criterio oggettivo che distingueva la figura del commerciante dal privato.

L'articolo 3 del codice di commercio (1882) enunciava a titolo esemplificativo circa una ventina di tipologie di atti di commercio, eterogenee tra loro, quali gli industriali, i banchieri, le imprese di spettacoli pubblici, le imprese editrici, tipografiche o librarie, le imprese di trasporto di persone o di cose per terra o acqua.

Il risultato pratico fu quello di sottoporre attività non propriamente commerciali al medesimo statuto professionale delle attività propriamente commerciali, assoggettandole agli obblighi di tenuta dei libri contabili, alla eventuale procedura fallimentare ed ai regimi di pubblicità dalla legge prescritti (fatta eccezione per artigiani ed agricoltori).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il diritto commerciale trovava altresì applicazione qualora i rapporti tra privati ricadessero:

1. negli atti elencati dall'art. 3 del codice del commercio (1882), anche se compiuto occasionalmente ed anche se nessuna delle parti è commerciante (atti oggettivi di commercio);
2. negli atti compiuti da un commerciante nell'esercizio della propria attività (art. 4 cod. comm. 1882) (atti soggettivi di commercio);
3. in qualsiasi atto qualificabile giuridicamente come commerciale anche solo per una parte (art. 54 cod. comm.) (atto unilaterale di commercio).

Per gli enti pubblici si escluse la possibilità di essere qualificati come "commercianti", pur potendo operare secondo le norme del diritto commerciale (art. 7 cod. comm. 1882).

Durante la vigenza dei due codici, civile e commerciale, la disciplina delle obbligazioni seguì un doppio binario: le obbligazioni civili e le obbligazioni commerciali, ispirate a principi differenti, che ricalcavano la differenza tra il diritto comune e lex mercatoria, il primo favorendo maggiormente la figura del debitore, il secondo avendo come obiettivo la celere circolazione dei beni e la tutela del credito.

Alla luce però della onnicomprensività caratterizzante gli atti di commercio, la applicazione della disciplina delle obbligazioni commerciali si estese alla maggior parte degli operatori di mercato (industriali, commerciante e cittadino-acquirente).

L'evoluzione del diritto commerciale codicistico culminò in Italia con il codice civile del 1942, con il quale si unificò la materia di diritto civile e la materia di diritto commerciale, sostituendo sia il codice civile del 1865, sia quello di commercio del 1882.

Il diritto commerciale conserva ad oggi alcune caratteristiche fondamentali dell'evoluzione codicistica:

- l'imprenditore è la figura giuridica paradigmatica: sostituisce la figura del commerciante e rende obsoleto il criterio distintivo degli atti di commercio, che è pertanto abbandonato;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- a qualsiasi attività di impresa è applicabile una disciplina giuridica generale, relegando in secondo piano la divisione tra industria e commercio, agricoltura ed artigianato, attività che ricadono nella più ampia categoria delle attività di impresa;
- si delinea pertanto uno **statuto tipico generale dell'imprenditore (**costituito dalla definizione unica di imprenditore, indipendentemente dal campo merceologico nel quale opera, dalle discipline dell'azienda (artt. 2555-2562 c.c.), dei segni distintivi dell'imprenditore (artt. 2563-2574 c.c.) e della concorrenza e dei consorzi (artt. 2595-2620 c.c.)**)** ed uno **statuto tipico speciale dell'imprenditore commerciale (**l'imprenditore commerciale è in rapporto di *species* a *genus* dello statuto generale dell'imprenditore. Lo statuto speciale dell'imprenditore commerciale include le discipline relative al registro delle imprese (art. 2188-2202 c.c.), alle scritture contabili (artt. 2214-2220 c.c.), alla rappresentanza commerciale (artt. 2203-2213 c.c.) ed all'assoggettamento delle procedure fallimentare e concorsuale).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Dal sistema del codice civile del 1942 al nuovo diritto commerciale internazionale

Con l'entrata in vigore del Codice Civile del 1942, scomparve il doppio binario delle obbligazioni civili e delle obbligazioni commerciali.

La generale disciplina codicistica è pertanto applicabile a qualsiasi rapporto giuridico intercorso tra privati, siano essi imprenditori o meno.

Si assistette però al cosiddetto fenomeno della "commercializzazione del diritto privato": stante la bontà dei principi e delle soluzioni portate dalla disciplina giuridica di stampo commerciale, maggiormente rispondenti alle esigenze giuridico-economiche del tempo, queste vennero adottate per disciplinare i rapporti etichettati in precedenza come puramente civili.

Ferma restando la soppressione dell'ordinamento corporativo fascista e l'abrogazione delle norme contenute negli articoli da 2088 a 2092, il codice civile rimane comunque caratterizzato dalla presenza di norme che si applicano esclusivamente agli imprenditori in quanto tali e non applicabili ad altri soggetti.

L'evoluzione del diritto commerciale non si è interrotta nell'epoca contemporanea, ed anzi si è arricchito di altre fonti di produzione, di matrice non codicistica.

In particolare, si segnala la proliferazione di leggi speciali, tra le quali in particolare si ricorda (salvo successive modifiche legislative):

- R. D. n. 267 del 16 marzo 1942 – Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa (così come modificato dal D. Lgs. n. 5/006 e dal D. Lgs. n. 169/2007);
- Lg. n. 287 del 10 ottobre 1990 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Lg. n. 259, del 14 luglio 1993 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNIDROIT sul leasing finanziario internazionale, fatta a Ottawa il 28 maggio 1988;
- D. Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 – Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- D. Lgs. n. 58, del 24 febbraio 1998 – Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- Lg. n. 129 del 6 maggio 2004 – Norme per la disciplina dell'affiliazione commerciale (*franchising*);
- D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005 – Codice della proprietà industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273;
- D. Lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 – Codice delle assicurazioni private.

Altra fonte del diritto commerciale, però a carattere sovranazionale, è rinvenibile nel sistema giuridico dell'Unione Europea.

I trattati comunitari, infatti, prevedono una disciplina volta a non falsare la concorrenza nel mercato comune, direttamente applicabile nei confronti delle singole imprese nazionali.

Tale sistema giuridico sovranazionale esercita un'opera di armonizzazione degli ordinamenti giuridici nazionali grazie all'emanazione dei regolamenti e di direttive comunitarie, fonti di diritto alle quali gli Stati membri devono adeguarsi (fatta salve, in determinati casi, l'efficacia diretta delle norme europee).

Tale processo di armonizzazione coinvolge anche il diritto commerciale.

A titolo esemplificativo si possono citare (salvo successive modifiche):

- D. Lgs. n. 108 del 30 maggio 2008 – Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali;
- D. Lgs. n. 170 del 21 maggio 2004 – Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria;
- Lg. n. 180 dell'11 novembre 2011 – Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Altro fenomeno, del quale non si può fare a meno di accennare, è la conclusione di affare mediante strumentazioni elettroniche e l'utilizzo della rete internet, il quale sta dando vita ad un diritto digitale che interesserà anche il diritto commerciale (23).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Grazie al fenomeno della globalizzazione che ha caratterizzato il finire della seconda metà del XX° secolo e non accenna ad interrompersi nel XXI° secolo, il diritto commerciale ha riaffermato il suo carattere universale.

Con la globalizzazione le multinazionali diventano gli attori principali dell'opera di universalizzazione del diritto commerciale: imprenditori e aziende dal carattere complesso possono operare in più ordinamenti giuridici nazionali.

Tale fatto ha contribuito allo sviluppo di organi giudicanti internazionali (arbitrati internazionali), nei quali i soggetti giudicanti sono esperti del diritto internazionale degli affari. E' opportuno osservare come tali organi giudicanti si differenziano pertanto dalla figura del giudice quale portavoce della legge dello Stato.

Trattati e intese conclusi tra Stati extra U.E. contribuiscono inoltre ad arricchire la normativa del diritto commerciale.

Nonostante l'evoluzione delle tecniche e delle modalità con le quali gli imprenditori contemporanei esercitano la propria attività e l'emergere del mercato globale, i capisaldi sui quali si fonda la specialità della disciplina commerciale sono rimasti i medesimi dell'età basso medioevale: celerità e sicurezza nei traffici e tutela del credito.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

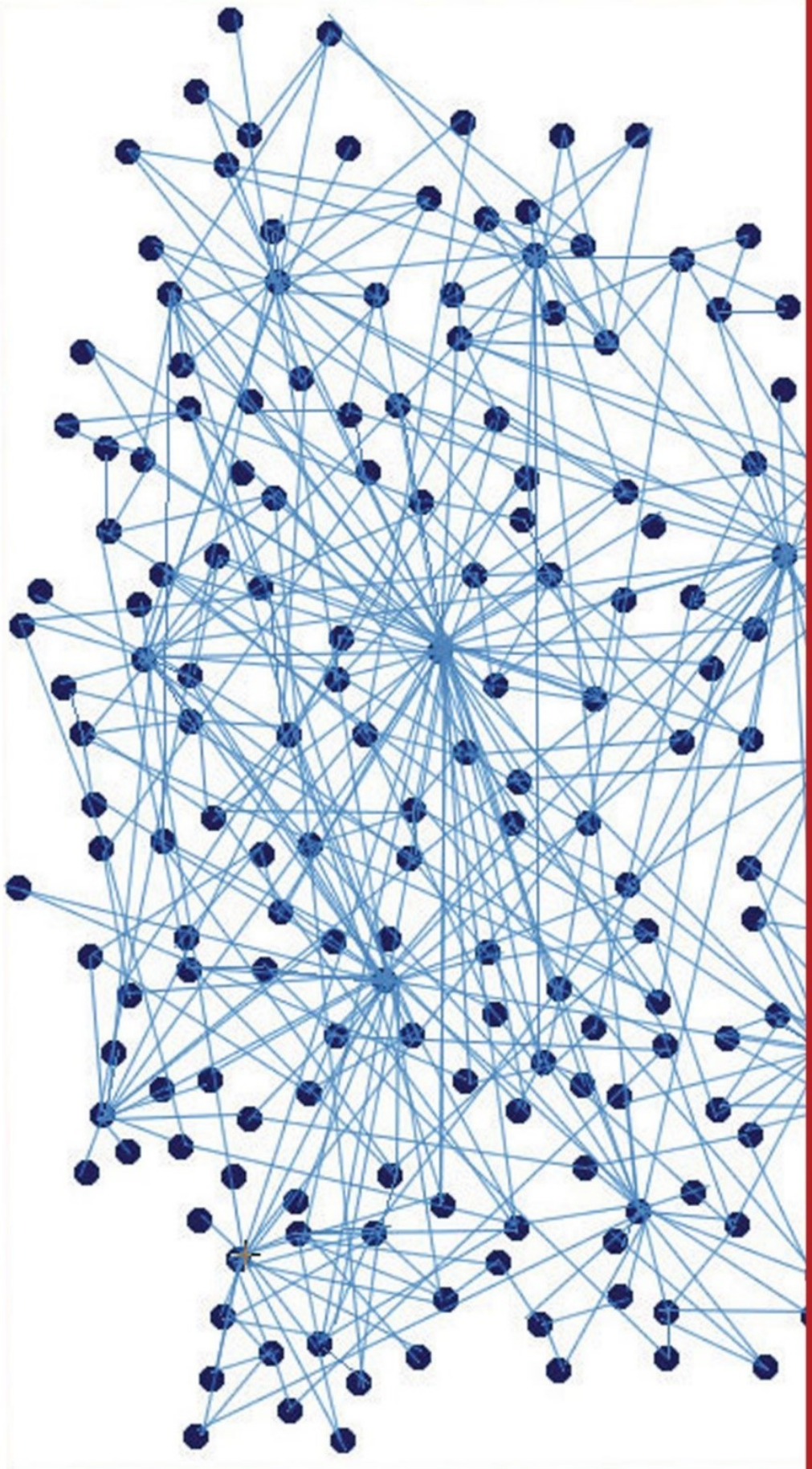
- "LEX MERCATORIA" - Francesco GALGANO, edito Il Mulino, BOLOGNA.
- "MERCANTI E SOCIETA' TRA MERCANTI" - Umberto SANTARELLI, edito G. Giappichelli Editore, Torino.
- CODIFICAZIONE E CULTURA GIURIDICA" - Riccardo FERRANTE, edito G. Giappichelli Editore, Torino.
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 1 DIRITTO DELL'IMPRESA" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA NOZIONE GENERALE DI IMPRENDITORE, L'ATTIVITÀ PRODUTTIVA, L'ORGANIZZAZIONE 3

2. ECONOMICITÀ, PROFESSIONALITÀ, ATTIVITÀ DI IMPRESA E SCOPO DI LUCRO 6

3. LE CATEGORIE DI IMPRENDITORI. IMPRESA E PROFESSIONI INTELLETTUALI. L'IMPRESA PER CONTO PROPRIO 9

BIBLIOGRAFIA 12

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La nozione generale di imprenditore, l'attività produttiva, l'organizzazione

Ai sensi dell'articolo 2082 c.c. l'imprenditore è colui che esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e/o di servizi.

La funzione di tale definizione è quella di indicare i requisiti minimi e necessari affinché ad un soggetto possa essere applicata la disciplina giuridica dell'imprenditore.

È necessario sottolineare però come i requisiti indicati dall'articolo 2082 c.c. siano rilevanti ai fini della qualificazione dell'imprenditore secondo la nozione civilistica (relatività della nozione di imprenditore), vale a dire ai soli fini della applicazione della norma di diritto privato, differenziandosi quindi dalla nozione di imprenditore delineata – ad esempio – dal diritto tributario.

Si trattano di seguito i requisiti necessari per definire la figura giuridica dell'imprenditore ai sensi dell'art. 2082 c.c.

Il primo requisito necessario è costituito dallo svolgimento da parte di un soggetto di una attività produttiva: una serie di atti finalizzata alla produzione di beni o allo scambio di servizi (che costituisce altresì l'impresa), risultando del tutto irrilevante il settore merceologico nel quale si opera (eccezion fatta per le professioni intellettuali).

Non rileva ai fini della integrazione di tale requisito che sussista l'attività di godimento o di amministrazione dei beni.

Il mero godimento dei beni non è sufficiente a realizzare il requisito di attività produttiva, risolvendosi invece nella mera percezione dei frutti dei beni; si pensi alla locazione di un bene immobile dal quale il proprietario percepisca i canoni di locazione.

Al contrario, l'attività di un albergatore – qualora sia anche proprietario dell'immobile adibito ad albergo - è qualificabile come attività produttiva poiché il godimento dell'immobile è integrato dalla fornitura di altri servizi, come quello di ristorazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il requisito dello svolgimento di una attività produttiva sussiste inoltre in caso di attività di amministrazione del proprio patrimonio, concretizzandosi nell'attività di investimento, che possono essere le più varie, o nell'attività di concessione di finanziamenti a terzi.

Si precisa che, nel caso in cui si aggiunga a tale attività il carattere della professionalità e della organizzazione, allora è possibile qualificarla giuridicamente come impresa (i.e. società di investimento e società finanziarie).

Il secondo requisito enunciato dall'art. 2082 c.c. è l'organizzazione, intesa quale attività di coordinazione di atti preordinati al raggiungimento di un obiettivo.

L'imprenditore pertanto creerà un insieme di procedure a carattere complesso, che costituisce un vero e proprio apparato nel quale fare confluire i fattori produttivi capitale e lavoro (proprio o altrui).

Di tale complessità il legislatore prende atto e pone l'imprenditore a direzione dell'azienda (artt. 2086 e 2094 c.c.), la quale viene definita dall'art. 2555 c.c. quale complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Si ritiene che il requisito dell'organizzazione possa essere validamente integrato anche quando abbia ad oggetto esclusivamente capitale e lavoro propri.

Il requisito dell'organizzazione si ritiene sussistente qualora la coordinazione abbia ad oggetto i propri capitali ed il proprio lavoro intellettuale, nel qual caso non si può fare a meno di sottolineare come l'organizzazione possa avere un carattere immateriale, non tangibile.

L'evoluzione delle tecnologie ha innovato le modalità con le quali i fattori produttivi possono essere impiegati e in alcuni casi l'unico fattore produttivo utilizzato è l'esclusivo lavoro personale del soggetto agente (autoorganizzazione e difetto di eteroorganizzazione).

Non verrebbero in questo caso impiegati né lavoro altrui, né capitali (propri o altrui).

La questione della realizzazione del requisito dell'organizzazione si era già posta in passato con riferimento ai prestatori autonomi di opera manuale, si pensi al classico esempio dell'idraulico o dell'elettricista.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sino ad oggi si è sempre escluso che la semplice organizzazione del proprio lavoro ai fini produttivi possa essere qualificata come organizzazione di tipo imprenditoriale.

In difetto di eteroorganizzazione si nega l'esistenza dell'impresa in senso giuridico.

Non sarebbe inoltre possibile qualificare tale fatto come piccola impresa, essendo quest'ultima organizzata prevalentemente con il lavoro proprio ed altresì con il lavoro dei propri famigliari che costituisce comunque fattore produttivo eteroorganizzato.

Una ulteriore conferma a sostegno di tale tesi è rintracciabile nelle norme codicistiche che non prevedono il requisito dell'organizzazione per il lavoratore autonomo (art. 2222 c.c.).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Economicità, professionalità, attività di impresa e scopo di lucro

Il terzo requisito dell'attività imprenditoriale è il suo carattere economico.

Esso deve essere interpretato come metodo con il quale l'attività produttiva viene svolta, non potendo essere considerato un solo sinonimo di attività produttiva.

Il metodo è economico se è finalizzato ad ottenere una remunerazione dei fattori produttivi impiegati, tali da eguagliare i costi sostenuti per operare.

La cosiddetta "copertura dei costi con i ricavi", che si oggettivizza nella autosufficienza dell'attività produttiva, è il nucleo del metodo economico con il quale l'imprenditore opera.

Va da sé che la qualifica di imprenditore non venga meno nel caso in cui, nonostante l'attività d'impresa sia svolta con metodo economico, a fine anno si realizzi una perdita e non un utile.

È invece da escludere la qualifica giuridica di imprenditore nel caso in cui un soggetto privato o pubblico produca beni o scambi servizi che vengano forniti:

- gratuitamente;
- a prezzo politico; nel qual caso i costi non saranno coperti dai ricavi.

Il quarto requisito dell'attività imprenditoriale è la *professionalità*.

Il carattere della professionalità è da intendersi quale abitualità ad operare in un determinato settore economico.

Tale stabilità giustifica l'applicazione della disciplina d'impresa a chi opera nel mondo degli affari.

Il predetto requisito non esige però che l'attività imprenditoriale sia svolta in continuità, senza alcuna interruzione.

Si pensi alle attività produttive di tipo stagionale, per le quali è intrinseco nella loro natura lo svolgimento delle stesse con cadenza periodica.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si ritiene pertanto sufficiente, affinché si realizzi il carattere della professionalità nelle attività stagionali, che vi sia il ripetersi costante delle attività produttive secondo le cadenze naturali delle stesse.

La verificazione di tale requisito, inoltre, non esige neppure il carattere esclusivo della attività produttiva esercitata e nemmeno che questa sia l'attività principalmente esercitata.

Può quindi essere esercitato da parte di un soggetto più di una attività d'impresa contemporaneamente; si pensi ad un imprenditore che eserciti sia una attività agricola, sia una attività commerciale.

Con specifico riferimento, invece, all'attività produttiva che si sostanzi nel compimento di un unico affare, tale attività assume carattere professionale se il so esercizio implica il compimento di azioni tra loro coordinate e complesse, nonché l'utilizzo di un apparato produttivo idoneo ad escludere il carattere occasionale dei singoli atti economici; si pensi ad esempio all'attività produttiva dell'imprenditore edile.

Oltre ai requisiti enunciati dall'articolo 2082 c.c., gli interpreti si sono domandati se sia possibile individuare un ulteriore criterio nella definizione giuridica di imprenditore: lo scopo di lucro ovvero l'intento di conseguire un guadagno, con la conseguenza che i ricavi dovrebbero quindi essere necessariamente maggiori dei costi.

È consolidato l'orientamento secondo il quale, ai fini della qualifica giuridica di imprenditore nei termini codicistici, debba preferirsi il criterio del metodo economico a quello lucrativo, afferma quindi che lo scopo di lucro non è un requisito essenziale dell'impresa.

Ciò anche in considerazione del fatto che la nozione di imprenditore è unitaria ed è comprensiva sia dell'impresa pubblica, sia dell'impresa privata.

L'impresa pubblica, pur operando con metodo economico, non necessariamente opera a scopo di lucro.

Una simile osservazione è valida altresì per le società cooperative, la cui attività è caratterizzata dal fine mutualistico.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si osservi inoltre come alle cosiddette imprese sociali sia fato divieto ex lege di distribuire utili – in qualsiasi forma – ai soci, agli amministratori, ai partecipanti, ai lavoratori ed ai collaboratori.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Le categorie di imprenditori. Impresa e professioni intellettuali. L'impresa per conto proprio

Gli interpreti hanno individuato diverse categorie di imprenditori a seconda dell'oggetto dell'impresa, delle dimensioni della stessa, della natura del soggetto che la esercita.

Utilizzando quale criterio distintivo l'oggetto dell'impresa è possibile distinguere:

- l'imprenditore commerciale; che opera generalmente nelle attività produttive legale all'industria, al commercio, ai trasporti, all'attività bancaria, alle imprese assicurative;
- l'impresa agricola, la cui definizione è data dall'art. 2135 c.c.

Una parte della dottrina individua altresì un *tertium genus* di impresa, quella civile, nella quale ricomprendono le imprese che non sono qualificabili né come commerciali né come civili; in realtà secondo l'orientamento predominante non vi sono ulteriori categorie di imprese oltre a quelle previste dalla legge (impresa agricola e impresa commerciale).

A seconda delle dimensioni dell'impresa si può individuare invece un imprenditore medio grande ed un piccolo imprenditore.

La funzione del piccolo imprenditore è quella di esonerarlo dall'applicazione della disciplina relativa all'imprenditore commerciale.

Utilizzando quale criterio distintivo la prevalenza del proprio lavoro e di quello famigliare rispetto agli altri fattori produttivi nell'esercizio dell'attività d'impresa è possibile distinguere il piccolo imprenditore (art. 2082 c.c.), dall'imprenditore commerciale.

Utilizzando invece quale criterio distintivo la natura giuridica del soggetto titolare dell'impresa è possibile distinguere:

- l'impresa individuale;
- l'impresa societaria;
- l'impresa pubblica.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Vi sono poi alcune attività per le quali la qualifica di imprenditore è esclusa in principio dal legislatore.

È il caso delle professioni intellettuali.

Tale esclusione si ricava dalla lettura a contrario dell'art. 2238 c.c.

L'esonero è il frutto di una scelta del legislatore, ispirata dalla considerazione sociale che tradizionalmente caratterizza le professioni intellettuali.

È il caso di osservare come alcune professioni intellettuali siano protette o riservate dal legislatore, il quale prevede per l'accesso alle stesse il superamento di una prova di abilitazione o di un concorso, nonché l'iscrizione negli albi professionali (art. 2291 c.c.), a corollario di ciò è fatto espresso divieto di esercizio di tali professioni ai non iscritti in tali albi (art. 2231 c.c.).

Deve comunque ammettersi la possibilità per chi esercita una professione intellettuale di esercitarla in un contesto aziendale.

Si pensi al medico chirurgo che opera in una struttura sanitaria privata.

In tale caso il medico non acquisisce la qualifica di imprenditore commerciale a condizione che il suo ruolo all'interno della struttura organizzativa implichi il solo esercizio della professione medica.

Se gli venisse affidato un differente ruolo, con mansioni non meramente strumentali all'attività d'impresa e relative invece all'attività di coordinamento e controllo dei fattori produttivi, il libero professionista sarebbe qualificato imprenditore commerciale.

Una particolare questione giuridica è posta dalla cosiddetta impresa in senso proprio, esercitata da colui che produca beni o servizi destinati ad uso o consumo personale.

L'opinione prevalente in dottrina è quella di non qualificare giuridicamente come impresa l'attività esercitata da chi produce beni o servizi destinati al proprio uso o consumo personale.

Non bisogna cadere poi nella tentazione di qualificare impresa in senso proprio fenomeni giuridici che hanno tutt'altra natura.

Si pensi ad esempio alla cooperativa edilizia, per la quale è da escludere che si tratti di una impresa per conto proprio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La cooperativa edilizia è una impresa che ha una propria personalità giuridica distinta dai soci che saranno i futuri assegnatari degli immobili, in base alle convenzioni che regolano i rapporti giuridici tra la cooperativa edilizia ed i soci stessi.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

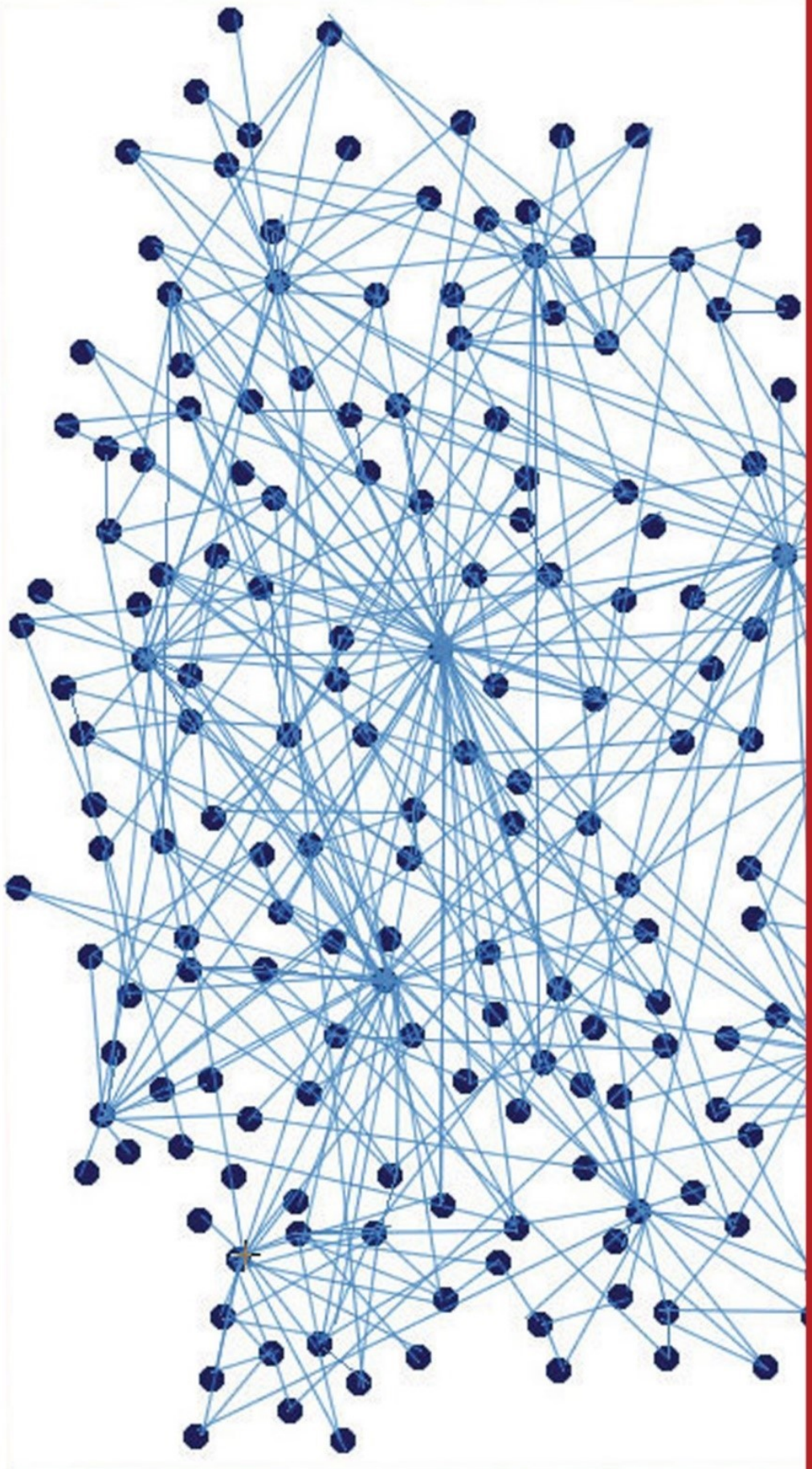
- "Diritto commerciale – vol. 1 diritto dell'impresa" – G. F. Campobasso, edito Utet, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "Diritto commerciale – a cura di Marco Cian", edito G. Giappichelli editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL PICCOLO IMPRENDITORE 3
2. L'IMPRENDITORE COMMERCIALE 7
3. INIZIO E FINE DELL'IMPRESA 9
BIBLIOGRAFIA 14

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il piccolo imprenditore

L'articolo 2083 c.c. definisce i piccoli imprenditori come i coltivatori del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano una attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia.

Il piccolo imprenditore è sottoposto allo statuto generale dell'imprenditore (fatta eccezione per quanto disposto dall'art. 1330 c.c.).

Il legislatore ha caratterizzato però lo statuto del piccolo imprenditore prevedendo che:

- sia esonerato dall'obbligo di tenere le scritture contabili, anche se eserciti una attività commerciale (art. 2214, terzo comma c.c.);
- sia esonerato dall'assoggettamento al fallimento ed alle procedure concorsuali (art. 2221 c.c.);
- che l'iscrizione nel registro delle imprese abbia funzione di pubblicità notizia (ex art. 8 legge n. 580/1993 in deroga all'art. 2202 c.c.).

Lo statuto del piccolo imprenditore ha quindi la funzione di restringere l'ambito di applicazione dello statuto dell'imprenditore commerciale.

Tornando all'analisi della nozione di piccolo imprenditore, ai fini della applicazione delle norme del sistema codicistico, si osserva quanto segue.

L'art. 2083 c.c. indica espressamente come piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani ed i piccoli commercianti.

Tali soggetti potrebbero facilmente essere ricompresi in altre categorie imprenditoriali.

Il criterio che permette di distinguere se questi afferiscano o meno alla categoria del piccolo imprenditore è la "prevalenza del lavoro proprio e famigliare" rispetto all'impiego degli altri fattori produttivi.

Il legislatore, oltre a citare espressamente ed a titolo esemplificativo queste tre attività, nel definire il piccolo imprenditore delinea una categoria residuale aperta alla quale possono

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

accedere tutti coloro che esercitano una attività professionale organizzata con la prevalenza del lavoro proprio e famigliare.

Il criterio della prevalenza si può intendere in due diverse accezioni:

- prevalenza quantitativo-aritmetica: l'imprenditore deve prestare il proprio lavoro nell'impresa; nell'attività esercitata il suo apporto lavorativo e quello dei suoi famigliari deve essere un fattore determinante in senso quantitativo se confrontato con il lavoro di altri soggetti che operano nella medesima azienda, deve essere determinante in senso quantitativo anche rispetto ai capitali investiti (chi investe ingenti capitali nell'impresa non è piccolo imprenditore);
- prevalenza qualitativa-funzionale: per la quale è necessario verificare se l'apporto personale dell'imprenditore e dei suoi famigliari sia determinante nell'organizzazione dell'impresa e sia in grado di caratterizzare qualitativamente beni e servizi prodotti (classico esempio ne è l'orafo d'arte, il quale lavora metalli preziosi forniti da terzi).

Con riguardo, invece, alle norme di legge speciale, il piccolo imprenditore trovava una definizione nella legge fallimentare, nella versione del testo originario, la quale ne escludeva la fallibilità.

La formulazione originaria del Regio Decreto n. 267/1942 (legge fallimentare), affermava: "*sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, i quali sono stati riconosciuti, in sede di accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, titolari di un reddito inferiore al minimo imponibile. Quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta essere stato investito un capitale non superiore a lire novecentomila*".

Era esclusa la possibilità per le società commerciali di essere qualificate giuridicamente come piccolo imprenditore.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La disciplina fallimentare individuava quali criteri determinanti per l'attribuzione della qualifica di piccolo imprenditore grandezze di tipo contabile:

- il reddito inferiore al minimo imponibile, con riferimento alle norme tributarie allora vigenti;
- il capitale investito non superiore a lire novecentomila.

Il primo dei criteri citati è stato soppresso poiché l'imposta di ricchezza mobile, al quale il criterio era ancorato, è stata sostituita dall'IRPEF.

Il secondo criterio citato, invece, è stato dichiarato incostituzionale nel 1989 sulla base di un contesto economico di svalutazione monetaria che faceva venir meno la idoneità di tale parametro a svolgere la funzione per la quale il legislatore lo aveva previsto.

Anche la previsione normativa per la quale le società commerciali non potevano essere considerate piccoli imprenditori venne meno.

La nuova formulazione della legge fallimentare, alla luce delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 5/2006 e successivamente dal D. Lgs. n. 169/2007, ha comunque confermato la scelta del legislatore originario di ancorare la fallibilità dell'imprenditore a parametri numerici, senza ammettere distinzioni circa il carattere commerciale o la qualificazione di "piccolo" imprenditore.

Ai sensi della vigente normativa fallimentare non sono passibili di fallimento o ad altre procedure concorsuali gli imprenditori commerciali che "*dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:*

a) *aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;*
b) *aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;*
c) *avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.*

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

[La legge precisa che] *I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della Giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento*".

Non si può fare a meno di sottolineare come ai sensi della vigente disciplina le società commerciali possono non essere passibili di fallimento se presentano congiuntamente i criteri di cui all'art. 1 della legge fallimentare vigente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. L'imprenditore commerciale

È imprenditore commerciale chi esercita una o più delle attività elencate dall'art. 2195, primo comma c.c., ovvero una attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, una attività di intermediazione nello scambio di beni, una attività di trasporto (per terra, acqua o aria), di tipo bancario o assicurativo o ancora – categoria residuale - le attività ausiliare di quelle già elencate, che si possono esemplificare nell'attività di agenzia, marketing, commissione, pubblicità etc.

Il nucleo forte che contraddistingue l'impresa commerciale da quella agricola è costituito dalle attività di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 2195, primo comma c.c.:

- l'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- l'attività intermediaria nella circolazione dei beni (intesa quale sinonimo di attività di scambio).

Si afferma pertanto che il carattere industriale e la funzione di intermediazione nella circolazione dei beni delinea il carattere commerciale dell'impresa.

Parte della dottrina individua oltre alle categorie di impresa agricola e di impresa commerciale un *tertium genus*: l'impresa civile.

Tale figura giuridica avrebbe la sua disciplina nel solo statuto generale dell'imprenditore, sarebbe esclusa dalla disciplina dell'impresa commerciale, quindi non sarebbe passibile di fallimento.

In merito alla ammissione dell'esistenza di tale *tertium genus*, la dottrina è divisa.

Secondo i fautori della tesi favorevole a tale ipotesi, l'ammissione della esistenza dell'impresa civile riposerebbe sull'interpretazione del requisito dell'industrialità come impiego di materie prime e loro trasformazione in beni nuovi ad opera dell'uomo.

Si pensi, ad esempio, alla impresa mineraria nella quale si ha produzione di beni senza trasformare la materia prima.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I fautori della tesi contraria, che è quella prevalente, fonda il proprio ragionamento sull'interpretazione del requisito dell'industrialità quale "attività non agricola", arrivando quindi ad affermare che l'imprenditore commerciale è quello non agricolo.

Si deve pertanto propendere per l'esclusione dell'impresa civile.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Inizio e fine dell'impresa

Quale è il momento nel quale un soggetto acquista la qualifica di imprenditore?

La qualità di imprenditore si acquista con l'effettivo inizio dell'esercizio dell'attività d'impresa (principio di effettività).

L'effettivo inizio dell'attività di impresa non si configura con:

- la richiesta di autorizzazioni amministrative;
- l'iscrizione in albi;
- l'iscrizione in registri, compreso quello delle imprese.

L'effettivo inizio dell'attività d'impresa, concretizzato con l'esercizio dell'attività gestoria, si verifica anche se si opera in violazione delle norme amministrative abilitanti.

Il principio dell'effettività vale per le persone fisiche, gli enti pubblici e privati.

Un discorso specifico deve essere fatto per le società.

Per queste, infatti, lo svolgimento dell'attività d'impresa costituisce la naturale ragione della loro costituzione.

Potrebbe quindi esserci la tentazione di affermare che, a fronte di tale specificità, non sarebbe necessario accertare in concreto l'inizio dell'attività d'impresa.

La dottrina è però attenta nell'osservare come la costituzione della società non sia altro che la dichiarazione programmatica della volontà di iniziare un'attività imprenditoriale.

Si ritiene inoltre di dovere osservare come l'articolo 2082 c.c. subordini l'acquisto della qualifica di imprenditore all'esercizio dell'attività d'impresa.

La dottrina pertanto afferma pertanto che il principio dell'effettività trova applicazione anche con riguardo alle società.

È necessario quindi individuare nel caso concreto quando sussiste l'effettivo inizio dell'attività d'impresa.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il compimento degli atti tipici dell'attività imprenditoriale può essere preceduto da una fase organizzativa, consistente nella conclusione di contratti di locazione dei locali ad uso commerciale o di contratti di lavoro subordinato, ma in alcuni casi tale fase può mancare.

Nel caso in cui esista una stabile organizzazione aziendale (ad esempio un negozio) è sufficiente un solo atto di esercizio dell'attività imprenditoriale per determinare l'effettivo inizio dell'attività d'impresa.

Quando, invece, manca una stabile organizzazione aziendale (ne è un esempio l'attività dell'agente di commercio) è necessaria la ripetizione temporale degli atti di impresa funzionalmente coordinati tra loro per affermare che l'attività è esercitata in maniera professionale (se l'attività fosse svolta occasionalmente verrebbe meno il carattere della professionalità che contraddistingue l'attività dell'imprenditore ex art. 2082 c.c.).

Gli interpreti si sono interrogati sulla possibilità che un soggetto acquisisca la qualità di imprenditore durante la fase preliminare di organizzazione ed in particolar modo prima del compimento del primo atto di gestione.

Gli interpreti hanno dato risposta affermativa a tale questione.

Essi osservano infatti che l'organizzazione della produzione è attività tipicamente imprenditoriale esercitata al fine della produzione di beni e servizi, pone inoltre esigenze di tutela del credito non minori rispetto agli atti di esercizio normalmente compiuti nell'attività d'impresa.

Gli atti di organizzazione pertanto sono atti di impresa, equiparati dagli interpreti agli atti di gestione non preceduti dalla fase organizzativa ed assurgono a criteri di valutazione per verifica della sussistenza del carattere della professionalità ex art. 2082 c.c.

Si osserva quindi che il compimento di atti di organizzazione, il cui fine evidente è quello di addivenire ad un determinato fine produttivo, comporta l'acquisto della qualità di imprenditore.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Non si può fare a meno di osservare come un atto di organizzazione compiuto da una persona fisica possa non essere sufficiente per determinare l'acquisto della qualifica di imprenditore, dovendo avverarsi contemporaneamente due condizioni:

- che vi sia la coordinazione funzionale degli atti di organizzazione compiuti;
- che tali atti siano espressione della volontà di intraprendere l'esercizio professionale di una attività produttiva.

Con riguardo, invece, agli atti organizzativi compiuti da una società, la dottrina ritiene integrato l'inizio effettivo dell'attività imprenditoriale - e l'acquisizione della qualifica di imprenditore – con il compimento anche di un solo atto organizzativo particolarmente qualificante.

Evento antitetico rispetto all'inizio della vita dell'impresa è la sua fine.

La fine dell'attività imprenditoriale è in genere preceduta da una attività di liquidazione, che costituisce ancora esercizio dell'attività di impresa.

La fase di liquidazione si conclude con la disgregazione del complesso aziendale, la quale segna l'irrevocabilità della cessazione.

Annosa fu la questione relativa alla determinazione del momento di cessazione dell'attività imprenditoriale della società, se questa potesse avvenire antecedentemente alla cancellazione dal registro delle imprese o dovesse essere coincidente a tale atto.

La disciplina fallimentare, art. 10 del R.D. n. 247/1942, nella sua versione originaria non contribuiva alla soluzione di tale quesito, prevedendo che l'imprenditore potesse essere dichiarato fallito "*entro un anno dalla cessazione dell'impresa*".

Gli interpreti per i quali la società diventava imprenditore a seguito della sola costituzione, affermavano che tale qualifica veniva meno esclusivamente a seguito della cancellazione dal Registro delle Imprese. Bisogna però considerare come presupposto della cancellazione dal registro delle imprese fosse l'integrale pagamento dei creditori sociali. In alcuni casi, però, alcuni creditori (fisco ed enti previdenziali o assistenziali) avanzavano pretese successivamente alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La Giurisprudenza era granitica nel sostenere la tesi per la quale una società, benché cancellata dal Registro Imprese, dovesse ritenersi esistente ed esposta al fallimento fino al pagamento dell'ultimo debito (al contrario dell'imprenditore individuale, per il quale il totale pagamento dei debiti d'impresa non era necessario per cessare l'attività imprenditoriale).

La Corte costituzionale intervenne dichiarando incostituzionale l'art. 10 Lg. Fall. perché non prevedeva che il termine annuale decorresse sia per le società e sia per le imprese individuali dal momento della cancellazione dal registro.

Le soluzioni alle dispute dottrinarie sorte da tale questione e l'orientamento espresso della Corte Costituzionale, sono confluite nella riforma della disciplina fallimentare.

L'art. 10 R.D. n. 247/1942 riformato ed attualmente vigente, così dispone: "*gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione del registro delle imprese, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.*

In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del primo comma".

Il legislatore ha sentito l'esigenza di fissare un fatto oggettivo (la cancellazione dal registro delle imprese) dal quale far decorrere il termine utile per ottenere la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore debitore, il quale non può dimostrare di avere cessato l'attività imprenditoriale prima della cancellazione (per anticipare il decorso del termine, nemmeno se si tratti di persona fisica).

Si osserva però come tale termine non può decorrere per le società irregolari, non iscritte nel Registro delle Imprese, e neppure per le società occulte, le quali potranno essere dichiarate fallite senza limiti di tempo finché sussistono debiti insoluti.

Del pari l'imprenditore persona fisica non iscritta al Registro delle Imprese è esposto al fallimento sino a quando permangono debiti d'impresa non pagati.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È il caso di precisare che, con riguardo alle categorie dell'imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese e degli imprenditori collettivi cancellati d'ufficio dal registro delle imprese, affinché decorra il termine di un anno di cui all'art. 10, primo comma legge fallimentare, è necessario che sussista contemporaneamente alla cancellazione la cessazione dell'attività d'impresa (disgregazione del complesso aziendale).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

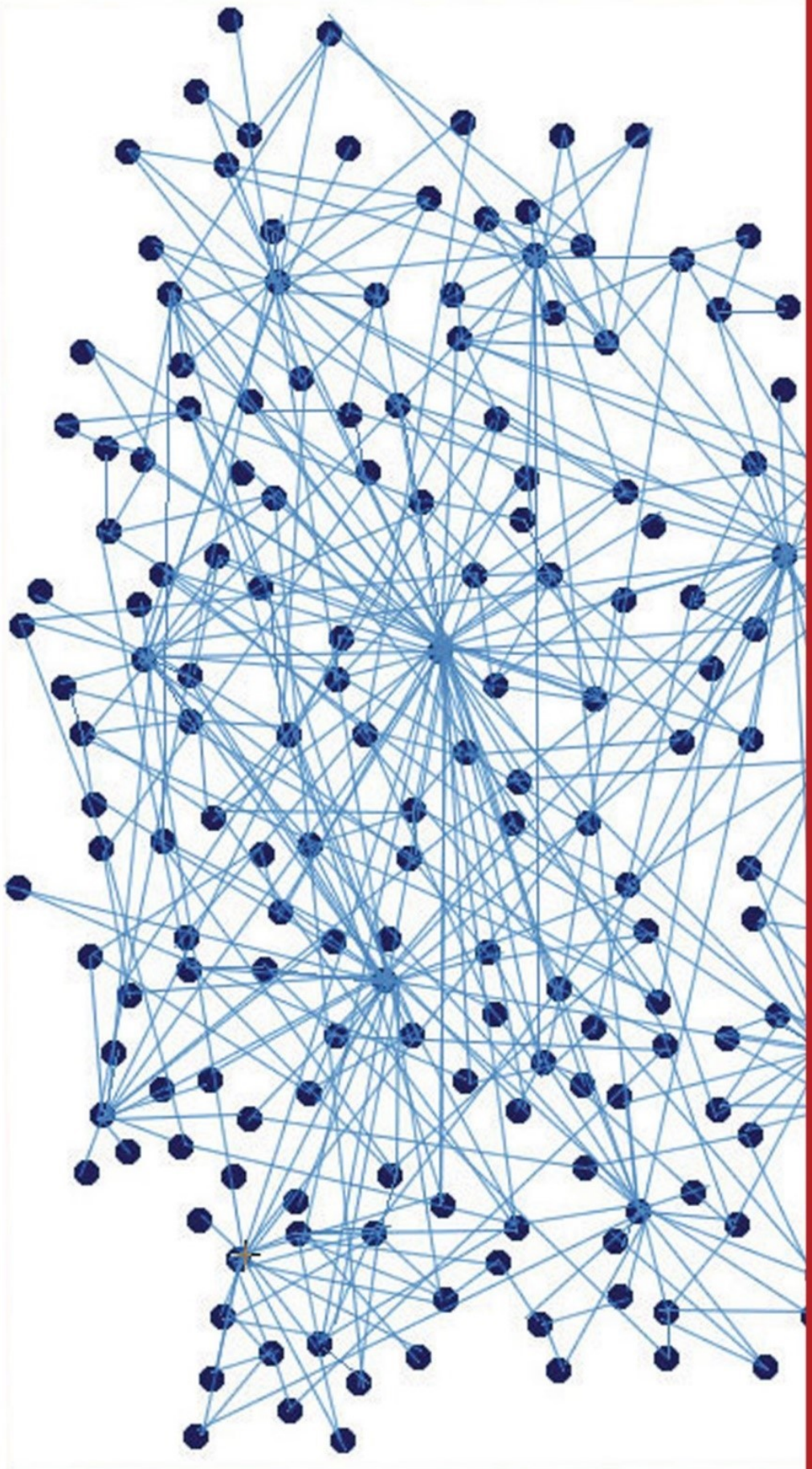
- "Diritto commerciale – vol. 1 diritto dell'impresa" – G. F. Campobasso, edito Utet, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "Diritto commerciale – a cura di Marco Cian", edito g. Giappichelli editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA NOZIONE DI IMPRENDITORE AGRICOLO 3
2. LE ATTIVITÀ AGRICOLE PER CONNESSIONE 7
BIBLIOGRAFIA 9

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La nozione di imprenditore agricolo

La definizione dell'imprenditore agricolo è enunciata dall'art. 2135 c.c.

All'interno del sistema codicistico, tale definizione ha la funzione di restringere l'ambito di applicazione della disciplina dell'imprenditore commerciale ed in particolare:

- esonera l'imprenditore dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili (ex art. 2214 c.c.);
- esonera l'imprenditore dall'assoggettamento al fallimento[1].

La qualifica giuridica di imprenditore agricolo, secondo la enunciazione originaria dell'art. 2135 c.c., poteva essere assunta da chi esercitava una delle seguenti attività:

- la coltivazione del fondo;
- la selvicoltura;
- l'allevamento di animali;
- le attività connesse all'agricoltura, quali le attività dirette alla trasformazione o alla alienazione dei prodotti agricoli, se rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura.

La figura dell'imprenditore agricolo al quale il legislatore del 1942 si riferiva, caratterizzato dal mero sfruttamento della produttività naturale del suolo, risulta essere ad oggi anacronistica.

Dal 1942 ad oggi l'attività agricola è stata interessata da una fase di industrializzazione crescente: ha attratto ingenti investimenti, ponendo quindi non pochi problemi con riguardo alla questione della tutela del credito; le tecniche di coltura e di allevamento si sono evolute, fino a giungere alla possibilità di creare colture artificiali o fuori terra e ad allevare animali in batteria.

[1] Si segnala la recente Sentenza della Corte di Cassazione, n. 7328 del 10 aprile 2015, che in merito alla questione della fallibilità dell'imprenditore agricolo così si esprime: "*Su piano specificamente fallimentare si è chiarito che è qualificabile come attività agricola quella diretta alla coltivazione del fondo e costituente forma di sfruttamento del fattore terra, sia pure con l'ausilio delle moderne tecnologie, nonché quella connessa a tale coltivazione, che si inserisca nel ciclo dell'economia agricola; ha invece carattere commerciale o industriale ed è, quindi, soggetta al fallimento, se esercitata sotto forma di impresa grande e media, quell'attività che, oltre ad essere idonea a soddisfare esigenze connesse alla produzione agricola, risponda a scopi commerciali o industriali e realizzi utilità del tutto indipendenti dall'impresa agricola o, comunque, prevalenti rispetto ad essa. (Sez. 1, Sentenza n. 6853 del 24/03/2011, Rv. 617391; Sez. 1, Sentenza n. 10527 del 23/10/1998, Rv. 520013). Ciò vale, però, con la precisazione che,* ***ai fini della soggezione al fallimento, la qualificazione di un'attività d'impresa commerciale o agricola va operata alla stregua delle norme del codice civile e della legge fallimentare****, e non attraverso il richiamo a norme di settore, quali quelle fiscali o quelle contributive – che apprestano alla stessa attività una qualificazione di impresa agricola non suscettibile di generale applicazione, in quanto rispondente alle particolari finalità dei rispettivi ordinamenti (Sez. 1, Sentenza n. 10527 del 23/10/1998, Rv. 520014)*".

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Gli operatori del diritto, pertanto, si trovarono ad affrontare il problema della compatibilità tra la speciale disciplina dell'imprenditore agricolo dettata dal codice civile e l'attuale esercizio dell'attività agricola meccanizzata, industrializzata anche a seguito delle politiche di sviluppo messe in atto dall'Unione Europea.

Si delinearono due tesi contrapposte:

- la prima, per la quale ogni forma di produzione fondata sullo svolgimento di un ciclo biologico naturale avrebbe costituito esercizio dell'attività agricola, indipendentemente dal metodo di coltivazione ed allevamento utilizzato;
- la seconda, per la quale lo sfruttamento della terra da parte dell'imprenditore agricolo doveva rimanere centrale, tesi che avrebbe portato alla conseguenza di applicare la disciplina dell'imprenditore commerciale a chi avesse prodotto animali o vegetali senza l'ausilio del fattore terra (i.e. coltivazioni artificiali e allevamenti in batteria).

Il legislatore italiano, nel riformare l'art. 2135 c.c. con il D. Lgs. N. 228/2001, ha aderito alla prima tesi esposta, ponendo però la questione -tutt'ora aperta- della conciliabilità delle caratteristiche fattuali del nuovo imprenditore agricolo con il persistere dell'esonero dallo stesso dal fallimento.

Le attività di allevamento di specie animali in batteria e la produzione artificiale di specie vegetali richiedono ingenti investimenti di capitali e sottopongono all'attenzione degli operatori economici e del diritto la questione della minore tutela dei creditori rispetto ai creditori di un imprenditore commerciale (che è passibile di fallimento).

L'attuale art. 2135 c.c., pur ribadendo che per attività agricola si intende la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse, esplicita al secondo comma la tesi per la quale si intendono per tali attività quelle "*dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzino o possono utilizzare* (quindi in accezione meramente facoltativa e non necessaria) *il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine*".

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Alla luce della riforma dell'art. 2135 c.c. si può affermare che l'attività agricola che ha ad oggetto la produzione di specie vegetali e animali, quand'anche si svolga senza lo sfruttamento della terra e dei suoi prodotti, è qualificabile come essenziale.

Passando in rassegna ciascuna delle attività agricole essenziali, si può osservare quanto segue.

Con riguardo alla coltivazione del fondo, in questa categoria possono essere annoverate l'orticoltura, la floricoltura, la produzione di ortaggi e frutta in coltivazione idroponica ed aeroponica.

Si ricorda come sia oggetto di specifica disciplina normativa:

- l'attività di coltivazione di funghi, legge n. 126 del 5 aprile 1985;
- l'attività di coltivazione e commercio dei tartufi, Legge n. 752 del 16 dicembre 1985, Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commerci odei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

Con riguardo alla selvicoltura, quale attività di cura del bosco con la finalità di ottenerne i prodotti, si ricorda come non possa essere ricompresa in tale attività l'estrazione di legname qualora non sia accompagnata dalla coltivazione dell'area boschiva.

Con riguardo all'allevamento di animali, invece, si ribadisce come l'attività di allevamento di animali in batteria sia considerata attività agricola essenziale.

L'attività agricola essenziale di allevamento di specie animali si può svolgere:

- per ottenere carne, latte, lana o utilizzare gli animali come forza lavoro;
- per ottenere cavalli da corsa;
- per ottenere animali da pelliccia;
- per ottenere, selezionare e addestrare razze canine (attività cinotecnica).

Dall'attività essenzialmente agricola di allevamento di animali differisce l'attività a carattere commerciale relativa all'acquisto di animali all'ingrosso con la mera finalità di rivendita (funzione di intermediazione) non è considerata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si ricorda, inoltre, come alcune attività di allevamento di specie animali sia stata oggetto di specifica disciplina normativa:

- la Legge n. 313 del 24 dicembre 2004 disciplina l'apicoltura;
- la Legge n. 102 del 5 febbraio 1992 disciplina l'acquacoltura (allevamento di pesci e mitili).

Specifica disciplina normativa è stata altresì prevista per l'imprenditore ittico ovvero colui che esercita "*l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci*" (ex art. 2, D. Lgs. N. 226/2001 e successive modifiche).

Si osserva inoltre come l'imprenditore ittico sia stato equiparato all'imprenditore agricolo che esercita attività agricola principale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Le attività agricole per connessione

A corollario delle attività agricole essenziali, il legislatore ha enucleato le attività agricole per connessione, che possono sono così distinte:

- attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali;
- attività esercitate dall'imprenditore agricolo dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, nelle quali il legislatore ricomprende altresì le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge (Legge n. 96 del 20 febbraio 2006, che ha sostituito la Legge n. 730 del 5 dicembre 1985).

  È innegabile come tali attività abbiano fattualmente un carattere commerciale.

In considerazione però del fatto che tali attività connesse siano lo sviluppo naturale della attività agricola esercitata dal medesimo imprenditore fa sì che questi non venga qualificato altresì come imprenditore commerciale, escludendo pertanto l'applicazione della relativa disciplina e venendo meno la possibilità dell'imprenditore di essere assoggettato al fallimento.

Al fine di determinare se un'attività sia realmente connessa a quella agricola, si possono adottare due criteri, che devono coesistere:

- la connessione soggettiva;
- la connessione oggettiva (criterio della prevalenza).

L'attività esercitata è connessa soggettivamente se l'imprenditore che la esercita sia già qualificato giuridicamente quale imprenditore agricolo e l'attività connessa svolta sia coerente con quella agricola principale.

È pertanto di carattere commerciale la attività di vendita di prodotti agricoli altrui.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si segnala inoltre che, con la finalità di favorire l'aggregazione tra agricoltori, il D. Lgs. n. 228/2001, art. 1, comma secondo, afferma "*si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico*".

Con riguardo, invece, alla connessione oggettiva, nella disciplina previgente occorreva verificare se le attività di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli rientrassero nell'esercizio normale dell'agricoltura, o se tali attività fossero qualificabili come accessorie rispetto all'attività agricola necessaria o principale.

Attualmente il criterio della connessione oggettiva è diversamente inteso.

Infatti, al fine di considerare un'attività di trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli come connessa oggettivamente all'attività agricola principale, è necessario che l'attività di trasformazione ed alienazione abbia ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola principale; inoltre si considerano connesse le attività dirette alla fornitura di beni o servii mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Si possono definire prodotti ottenuti prevalentemente dall'esercizio dell'attività agricola principale quelli per la cui attività di produzione costituiscono fattori determinanti (secondo un termine quantitativo e qualitativo) le attrezzature o le risorse dell'azienda agricola.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

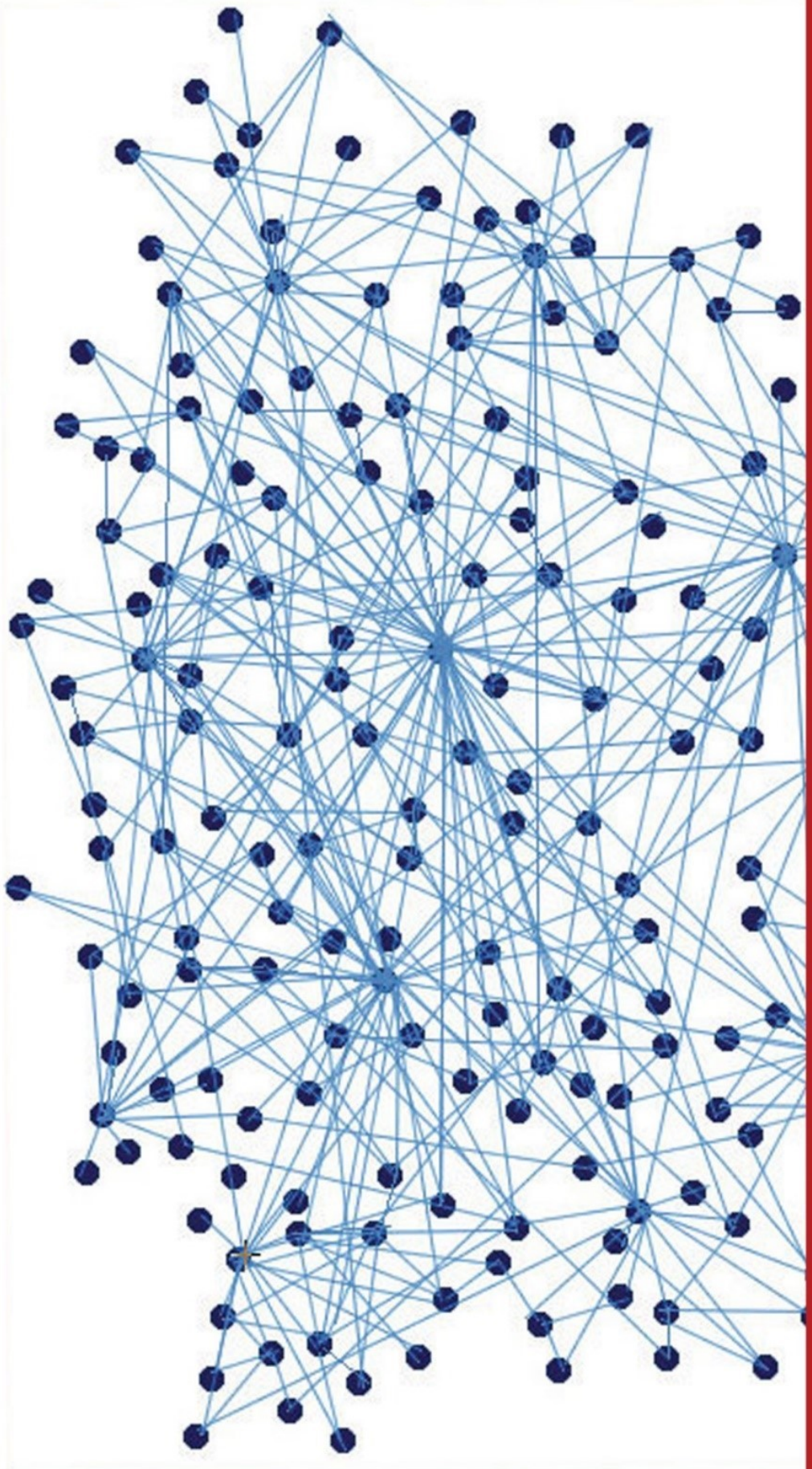
- "Diritto commerciale – vol. 1 diritto dell'impresa" – G. F. Campobasso, edito Utet, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "Diritto commerciale – a cura di Marco Cian", edito G. Giappichelli editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE 3
2. LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE: LA PUBBLICITÀ LEGALE 4
3. LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE: LA TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI 8
4. LO STATUTO DELL'IMPRENDITORE COMMERCIALE: LA RAPPRESENTANZA COMMERCIALE 10
BIBLIOGRAFIA 13

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

L'imprenditore commerciale (art. 2195 c.c.) è sottoposto ad una specifica disciplina codicistica, definita come Statuto Speciale dell'imprenditore commerciale.

Ai fini di questa lezione ne verranno trattati tre:

- la pubblicità legale;
- l'obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- la rappresentanza commerciale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Lo statuto dell'imprenditore commerciale: la pubblicità legale

L'esercizio dell'attività d'impresa implica che l'imprenditore si relazioni con altri imprenditori ed operatori economici al fine di concludere i propri affari.

Vi è quindi la necessità per chi opera sul mercato di reperire informazioni attendibili relative ai soggetti con in quali si intende concludere affari.

Il legislatore ha risposto a tale esigenza istituendo il Registro delle Imprese: un sistema di pubblicità legale nel quale confluiscono parte degli atti e dei fatti che riguardano l'imprenditore commerciale.

Tali atti o fatti, in quanto conoscibili dai terzi tramite la semplice consultazione – anche telematica - del Registro delle Imprese, sono ad essi opponibili.

L'odierno Registro delle Imprese è frutto della attuazione della disciplina normativa elaborata dal legislatore sul finire degli anni Novanta con il D.P.R. n. 581/1995 - Regolamento di attuazione dell'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993 n. 580, in materia di istituzione del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c.

Attualmente la gestione del Registro delle Imprese è affidata alle Camere di Commercio.

Il Registro è composto da una sezione ordinaria e dalle sezioni speciali.

L'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese è prevista per:

- imprenditori individuali commerciali (non piccoli);
- consorzi;
- cooperative;
- gruppi europei di interesse economico;
- società di persone (s.n.c. e s.a.s.);
- società di capitali (s.r.l., S.p.A., s.a.p.a.);
- enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività economica;
- società costituite all'estero con sede amministrativa o secondaria sul territorio italiano.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'iscrizione nelle sezioni speciali del Registro delle imprese è prevista per:

- piccoli imprenditori;
- società semplici agricole;
- società semplici non agricole;
- società tra avvocati;
- società od enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette (art. 2497 bis, secondo comma c.c.).

Sono altresì iscritti nelle sezioni speciali gli imprenditori artigiani, salvo siano qualificabili come piccoli imprenditori, nel qual caso sono tenuti all'iscrizione nella sezione ordinaria.

Il legislatore indica quali sono gli atti soggetti a registrazione agli articoli 2196, 2197, 2198, 2200 c.c., nonché nel D.P.R. 581/1995.

Tali atti, pur differenziandosi a seconda della tipologia di impresa che deve procedere alla iscrizione, riguardano comunque:

- la individuazione dell'imprenditore e dell'impresa (inizio e fine attività, denominazione, sede sociale, oggetto);
- la struttura e l'organizzazione della società (atto costitutivo, modificazioni, nomina e revoca amministratori, cessione quote).

Si sottolinea come possono essere registrati presso il Registro delle Imprese solo ed esclusivamente gli atti la cui iscrizione è prevista per legge.

L'iscrizione al Registro delle Imprese può avvenire a seguito di domanda dell'interessato (art. 2189 c.c., 11 D.P.R. 581/1995) oppure ex officio nei casi determinati dalla legge (art. 2190 c.c., 16 D.P.R. 581/1995).

Il legislatore ha previsto che l'iscrizione debba essere fatta al Registro delle Imprese presso l'ufficio della camera di commercio della provincia nella quale l'imprenditore ha sede.

Come per l'iscrizione anche la cancellazione può essere disposta d'ufficio.

Ciò avviene nel caso in cui l'imprenditore abbia cessato l'attività e non provveda spontaneamente alla cancellazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A procedere alle iscrizioni ed alle cancellazioni (anche ex officio) è preposto l'Ufficio del Registro.

Esso ha la precipua funzione di effettuare un controllo di legalità formale sugli atti o i fatti sottoposti alla sua attenzione: la documentazione depositata deve apparire regolare e gli atti ed i fatti ivi dedotti devono essere veri ed esistenti.

All'ufficio del Registro non è invece attribuito il dovere di effettuare un controllo di legalità sostanziale, consistente a titolo esemplificativo nella verifica e nel riscontro delle cause di nullità dell'atto.

Qualora all'Ufficio del Registro sia presentato per l'iscrizione un atto societario sottoposto a controllo notarile di legalità, l'obbligo di verifica è adempiuto con il controllo del rispetto della sola regolarità formale della documentazione presentata.

All'iscrizione di un atto presso il Registro delle Imprese possono seguire differenti effetti giuridici.

Innanzitutto, si osserva come l'iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese assolve alla funzione di pubblicità legale, avendo la finalità di rendere conoscibili i dati indicati.
In alcuni casi a tale funzione si affianca l'effetto giuridico di:

- pubblicità dichiarativa: l'atto o il fatto registrato è opponibile a chiunque dal momento della iscrizione al Registro. Ne consegue che i terzi non potranno addurre l'ignoranza di tale fatto o atto per impedire che gli effetti di questo operino nei propri confronti. Se un atto o un fatto non viene iscritto nel Registro, tale atto o fatto non è opponibile ai terzi con il quale l'imprenditore ha concluso affari. È fatta salva la possibilità dell'imprenditore di provare che i terzi fossero a conoscenza dell'atto o fatto al momento della conclusione dell'affare;
- pubblicità costitutiva: si esplica nei soli casi espressamente previsti dalla legge. Paradigmatica è l'iscrizione della S.p.A. nel Registro delle Imprese, costituendone l'iscrizione l'atto con il quale viene giuridicamente ad esistenza;
- pubblicità normativa: l'iscrizione è il presupposto per l'applicazione di un determinato regime giuridico; ne è un esempio l'iscrizione nel Registro delle Imprese delle s.n.c. e delle

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

s.a.s. In mancanza di iscrizione le s.n.c. e le s.a.s. assumono un carattere irregolare: poiché l'applicazione del regime patrimoniale proprio subordinato alla iscrizione presso il Registro delle Imprese, in difetto deve essere applicato il regime patrimoniale della società semplice.

L'iscrizione nelle sezioni speciali ha la mera funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia: non ha l'effetto di rendere opponibile ai terzi il fatto.

Costituisce eccezione a tale regola l'iscrizione alle sezioni speciali del Registro delle Imprese di imprenditori agricoli, anche piccoli, società semplici esercenti attività agricola, per i quali il legislatore ha previsto che l'iscrizione abbia gli effetti della pubblicità legale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Lo statuto dell'imprenditore commerciale: la tenuta delle scritture contabili

Le scritture contabili sono i documenti che contengono i dati quantitativi e monetari generati dai singoli atti d'impresa; esse confluiscono nella rappresentazione della situazione patrimoniale dell'imprenditore e del risultato economico dell'anno di riferimento.

Le scritture contabili, infatti, hanno la precipua funzione di creare informazioni circa l'andamento economico dell'attività d'impresa, in termini quantitativi e monetari; contribuiscono poi a rendere efficiente l'organizzazione e la gestione dell'impresa.

Il legislatore prevede che l'imprenditore commerciale tenga obbligatoriamente il libro giornale ed il libro degli inventari, conservi la corrispondenza commerciale in originale (se ricevuta), in copia (se inviata) e tenga le scritture contabili richieste dalla natura e dalla dimensione dell'impresa (art. 2214 c.c.).

Il libro giornale è il registro nel quale sono annotate giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio d'impresa dell'anno in corso (art. 2216 c.c.).

È caratterizzato pertanto dalla analiticità e dal rispetto dell'ordine cronologico delle annotazioni.

Il libro degli inventari, redatto all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, contiene l'indicazione e la valutazione delle attività e delle passività relative all'impresa nonché di quelle dell'imprenditore anche se estranee all'attività d'impresa (art. 2217 c.c.).

A chiusura dell'inventario vi è il bilancio.

Il bilancio è il riassunto contabile relativo ad un solo anno dell'esercizio dell'attività imprenditoriale, composto dallo stato patrimoniale e dal conto economico.

Tale riassunto deve essere caratterizzato da una rappresentazione evidente e veritiera dell'attività imprenditoriale svolta.

La disciplina generale di riferimento per la corretta redazione del bilancio è quella dettata dal legislatore per le S.p.A. agli artt. 2423-2435 bis c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A seconda della natura e delle dimensioni dell'impresa, oltre alle scritture contabili obbligatorie, occorrerà tenere altre scritture contabili, quali, a titolo esemplificativo, il libro mastro, nel quale le operazioni sono registrate in base alla tipologia (i.e. per cliente), il libro cassa, nel quale sono registrate le entrate e le uscite di denaro contante, il libro magazzino, che registra entrate e uscite di merci.

Le scritture contabili debbono essere tenute secondo i criteri di ordinata contabilità, senza spazi in bianco, interlinee e trasporti in margine. Non possono essere fatte abrasioni; le cancellazioni sono ammesse solo se risulta leggibile ciò che viene cancellato (art. 2219 c.c.).

I documenti contabili debbono essere conservati per dieci anni dalla ultima annotazione effettuata (art. 2220 c.c.).

La corretta tenuta delle scritture contabili è condizione necessaria affinché queste possano assumere efficacia probatoria nel caso in cui sia l'imprenditore che le tiene a volerle produrre in giudizio a proprio favore.

Tale regola opera nel solo caso in cui si tratti di controversia avente ad oggetto un rapporto sorto nell'esercizio dell'attività d'impresa e che la controparte sia un altro imprenditore. Resta comunque salva la facoltà del giudice di apprezzare il valore probatorio di tali scritture contabili.

Al contrario, il terzo può sempre utilizzare come prova a proprio favore le scritture contabili dell'imprenditore, non rilevando che queste siano correttamente tenute o meno.

In sede di procedimento il giudice ha il potere di richiedere d'ufficio o su istanza di parte la esibizione delle scritture contabili (art. 2711, comma primo c.c.) al fine di estrarre le sole registrazioni relative alla causa pendente, dovendo riconoscersi la protezione del segreto aziendale come interesse meritevole di tutela da parte del legislatore.

Il giudice può ordinare la comunicazione integrale dei libri, delle scritture contabili e della corrispondenza solo nelle controversie relative allo scioglimento della società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte (art. 2711, secondo comma c.c.).

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Lo statuto dell'imprenditore commerciale: la rappresentanza commerciale

Nell'esercizio dell'attività d'impresa, l'imprenditore si avvale di collaboratori, i quali concludono affari con terzi in nome e per conto dell'imprenditore stesso.

Preliminarmente è il caso di osservare come il fenomeno della rappresentanza commerciale si pone come disciplina speciale rispetto alla rappresentanza civile (art. 1387 c.c. e seguenti).

Infatti, quando il fenomeno della rappresentanza prende vita nell'esercizio dell'attività d'impresa, ai sensi del richiamo effettuato dall'art. 1400 c.c., l'applicazione della disciplina della rappresentanza civile è sostituita dalla rappresentanza commerciale (art. 2203 c.c. s.s.).

La rappresentanza civilistica trova applicazione residuale nel solo caso di un collaboratore esterno alla organizzazione dell'imprenditore che compia atti per conto dell'imprenditore commerciale stesso.

Gli ausiliari interni all'organizzazione dell'imprenditore (institore, procuratore e commesso) operano quindi secondo le regole proprie della rappresentanza commerciale.

Essi sono investiti del potere di rappresentanza in conseguenza della posizione da essi rivestita all'interno della organizzazione aziendale.

In altre parole, la capacità di detti ausiliari di vincolare l'imprenditore per mezzo degli atti da essi compiuti è la naturale e diretta conseguenza del ruolo da essi occupato all'interno dell'organizzazione aziendale.

La prima figura ausiliaria dell'imprenditore è l'institore.

L'institore è colui che è preposto dal titolare all'esercizio di una impresa commerciale o di una sua sede secondaria o di un ramo d'azienda.

L'institore è investito di un potere di rappresentanza generale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'art. 2205 c.c. l'institore è tenuto, insieme con l'imprenditore, ad osservare le disposizioni riguardanti l'iscrizione nel registro delle imprese ed alla tenuta delle scritture contabili. In caso di fallimento l'institore è passibile di sanzioni penali.

Ai sensi dell'art. 2204 c.c., l'institore può compiere tutti gli atti pertinenti l'esercizio d'impresa, fatta salve le limitazioni contenute nella procura.

Solo se vi è espressamente autorizzato può alienare o ipotecare beni del preponente.

All'institore spetta poi la rappresentanza processuale (attiva e passiva) per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell'esercizio dell'impresa a cui è preposto, potendo stare in giudizio quale attore o convenuto.

L'institore è personalmente obbligato verso il terzo se omette di fargli conoscere che egli opera per il preponente; al terzo è data la possibilità di agire sia contro il preponente sia contro l'institore per gli atti pertinenti l'esercizio d'impresa a cui è preposto l'ausiliario (art. 2208 c.c.).

Il legislatore prevede che la procura con sottoscrizione del preponente autenticata sia depositata per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

In difetto la rappresentanza è generale e le eventuali limitazioni non sono opponibili a terzi, salvo si riesca a fornire la prova che questi fossero a conoscenza dei limiti della rappresentanza al momento della conclusione dell'affare (art. 2206 c.c.).

Il medesimo regime pubblicitario è previsto per la modifica e la revoca dei poteri dell'institore.

La seconda figura di ausiliario interno dell'imprenditore è il procuratore (art. 2209 c.c.).

Si tratta di un ausiliario di grado e con poteri minori rispetto all'institore, non essendo a capo dell'impresa e neppure di una sede secondaria.

Il suo potere rappresentativo si esplica esclusivamente in un settore operativo (i.e. il direttore del personale, il direttore dell'ufficio acquisti).

Il codice civile esaurisce la disciplina giuridica di tale ausiliario con l'art. 2209 c.c., che richiama espressamente i soli articoli 2206 e 2207 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Escludendo automaticamente l'applicabilità degli altri articoli relativi alla disciplina dell'institore, il legislatore consegue l'effetto di limitare i poteri e restringere gli obblighi del procuratore.

La terza figura di ausiliare interno dell'imprenditore è il commesso (artt. 2210-2213 c.c.).

Ai commessi è affidata la mansione esecutiva e materiale che li pone in relazione con i terzi. Si tratta di un potere ancora più limitato rispetto a quello dei procuratori.

Salvo autorizzazione espressa i commessi non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti (salvo quelli d'uso), non possono derogare alle clausole generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa, non possono esigere il prezzo della vendita fuori dai locali commerciali a cui sono preposti (salvo consegna di quietanza firmata dall'imprenditore).

Ai commessi, con riguardo agli affari da questi conclusi, è riconosciuta la legittimazione a ricevere le dichiarazioni che riguardano l'esecuzione dei contratti ed i reclami relativi alle inadempienze contrattuali, nonché a richiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

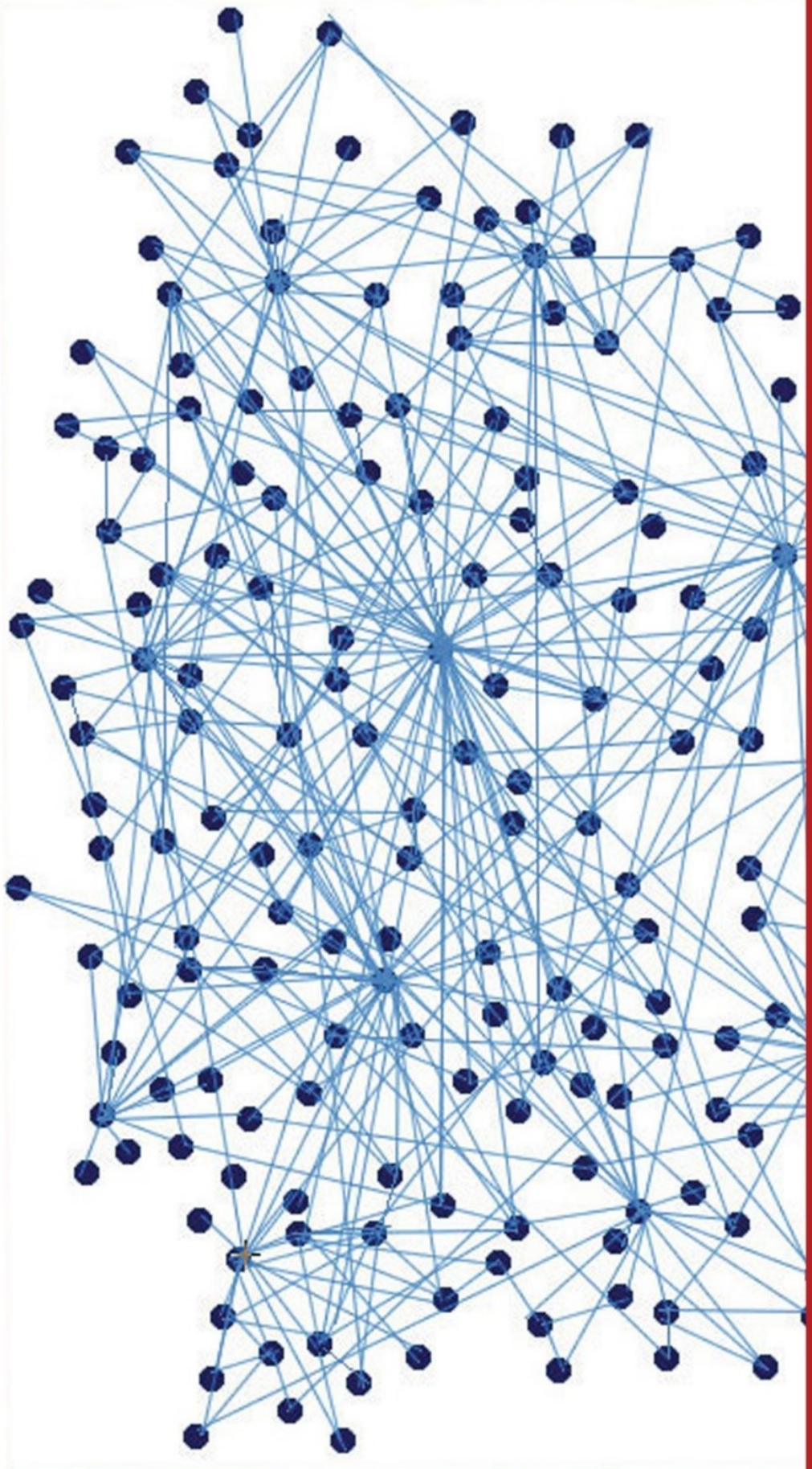
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 1 DIRITTO DELL'IMPRESA" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. L'AZIENDA NOZIONI FONDAMENTALI 3
2. IL TRASFERIMENTO D'AZIENDA 6
3. I SEGNI DISTINTIVI 10
BIBLIOGRAFIA 13

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. L'azienda nozioni fondamentali

L'articolo 2555 c.c. definisce l'azienda come il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Si deve sottolineare il carattere fondamentale che riveste l'attività di organizzazione dei vari elementi produttivi ad opera dell'imprenditore, attività di coordinamento svolta con l'univoco scopo di esercitare l'attività d'impresa.

Pertanto, si può parlare di azienda come una unità di tipo funzionale.

Si osserva infatti come l'azienda, intesa quale complesso di beni organizzato al fine della produzione, ha la capacità di produrre utilità nuova che è qualitativamente maggiore rispetto alla mera somma della utilità dei fattori produttivi singolarmente considerati.

Proprio per tale motivo il regime giuridico del trasferimento dell'azienda è ispirato dalla finalità di favorire la conservazione dell'unità economica dell'azienda, avuto riguardo al mantenimento dell'efficienza e della funzionalità dei complessi produttivi.

La disciplina per il trasferimento d'azienda è dettata dagli articoli 2556-2562 c.c.

I beni aziendali sono l'oggetto dell'attività organizzativa dell'imprenditore.

Costituiscono beni aziendali i beni effettivamente destinati dall'imprenditore allo svolgimento dell'attività d'impresa.

I beni aziendali possono essere anche di proprietà di terzi, si pensi al riguardo ai macchinari ottenuti con contratto di leasing.

Non sono beni aziendali, invece, i beni dell'imprenditore che non sono effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività imprenditoriale.

Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nella nozione di bene aziendale è compreso ogni elemento patrimoniale facente capo all'imprenditore nell'esercizio dell'attività d'impresa che può costituire oggetto di tutela giuridica.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Alla luce di questo orientamento, che tende ad estendere la nozione di bene aziendale, sarebbero così qualificabili:

- i servizi;
- tutti i rapporti contrattuali stipulati per l'esercizio dell'impresa;
- i crediti verso i clienti;
- i debiti verso i fornitori;
- l'avviamento.

Autorevole dottrina (Gian Franco Campobasso nell'opera di cui alla bibliografia) ritiene però che tale orientamento sia da disattendere, dovendosi preferire l'adozione di una nozione di bene aziendale ristretta e riferibile ai soli beni così definibili ai sensi dell'articolo 810 c.c.

Si è avuto modo di menzionare l'avviamento.

L'avviamento non è di per sé un bene in senso stretto, è definibile come una valutazione contabile del valore dell'azienda che è oggetto di tutela giuridica ai sensi dell'art. 2426 n. 6 e dell'art. 2557 c.c.

Tale valore contabile monetario è costituito dalla maggiore utilità che i fattori produttivi organizzati al fine della produzione riescono a creare (avviamento oggettivo).

L'abilità dell'imprenditore di creare e conservare i clienti è definibile come avviamento soggettivo.

La dottrina si è a lungo interrogata sulla natura giuridica dell'azienda, dividendosi tra sostenitori della teoria unitaria e sostenitori della teoria atomistica.

I sostenitori della teoria unitaria concepiscono l'azienda come "un unico bene" nuovo e diverso rispetto ai singoli beni organizzati che la compongono.

L'evoluzione di tale prospettiva ha portato i fautori di tale tesi alla affermazione della natura dell'azienda quale universalità di beni. L'imprenditore pertanto potrebbe vantare un diritto di proprietà unitario sull'azienda oltre ai diritti reali ed obbligatori vantati sui singoli beni che compongono l'azienda.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

I sostenitori della teoria atomistica, invece, intendono l'azienda come una pluralità di beni tra loro funzionalmente organizzati. L'imprenditore vanterebbe pertanto i diritti reali ed obbligatori sui singoli beni che compongono l'azienda.

Dalla lettura del dato normativo portato dall'art. 2556, primo comma c.c., il quale effettua un richiamo al criterio delle "forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda" al fine di individuare la forma ad substantiam per il contratto di trasferimento d'azienda, si ritiene di dover propendere per la scelta della teoria atomistica come teoria-parametro generalmente applicabile.

È necessario però rilevare come il legislatore non abbia potuto fare a meno, in alcune occasioni, di riconoscere la necessità di tutelare l'azienda come unità funzionale, si pensi infatti alla disciplina dell'usufrutto d'azienda (art. 2561 c.c.) e al divieto di concorrenza al quale è soggetto l'alienate dell'azienda (art. 2557 c.c.).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il trasferimento d'azienda

L'azienda può essere oggetto di atti di disposizione: può essere venduta, donata, conferita in società, può essere concessa in affitto.

Il trasferimento può avere ad oggetto anche un singolo bene dell'azienda o singoli beni aziendali. In questo ultimo caso è necessario verificare se l'operazione non costituisca in realtà un trasferimento d'azienda.

Non si può fare a meno di sottolineare come il trasferimento d'azienda si realizza anche con la cessione di un ramo d'azienda, purché si tratti di un ramo (potenzialmente o effettivamente) operativo.

Al fine di qualificare l'operazione economica posta in essere come trasferimento d'azienda è necessario guardare al risultato concretamente realizzato, mentre è del tutto irrilevante il nome giuridico che alla operazione viene dato.

Al fine di realizzare il trasferimento d'impresa è sufficiente che i beni ceduti siano anche solo potenzialmente idonei ad essere utilizzati per l'esercizio d'impresa.

Non è necessario cedere la totalità dei beni aziendali, purché la mancata alienazione di alcuni beni non comporti la menomazione dell'unità funzionale dell'azienda.

Tutte le volte in cui l'operazione di cessione costituisce trasferimento dell'azienda, si applicherà la disciplina di cui agli articoli 2556-2562 c.c.

L'art. 2556 c.c. disciplina la forma dei contratti di cessione d'azienda, relativamente alle imprese soggette a registrazione.

La forma richiesta per la validità del negozio è quella stabilita dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o in alternativa quella richiesta dalla legge per la particolare natura del contratto.

Il codice civile prevede la forma scritta ad probationem solo per le imprese soggette a registrazione (eccetto per le piccole imprese, le imprese agricole individuali o costituite in forma semplice).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quando la forma di un negozio è richiesta ad probationem, il mancato rispetto di tale requisito non inficia la validità del negozio, ma comporta per le parti che lo hanno concluso la impossibilità di avvalersi della prova per testi per dimostrare l'esistenza del contratto (art. 2725 primo comma c.c.).

L'art. 2556, secondo comma c.c. prevede che, ai fini della registrazione presso il Registro delle Imprese, per i contratti di cui al primo comma del medesimo articolo si utilizzi la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.

Il contratto deve poi essere depositato entro trenta giorni dalla stipula presso il Registro delle Imprese.

L'atto di trasferimento dell'azienda produce effetti secondo quanto stabilito nel regolamento contrattuale nonché secondo quanto disposto ex lege.

Le norme che esplicano la loro efficacia, indipendentemente da quanto previsto nel regolamento contrattuale, sono:

- art. 2557 c.c., il divieto di concorrenza dell'alienante;
- art. 2558 c.c., la successione nei contratti;
- art. 2559 c.c., la cessione dei crediti relativa all'azienda ceduta;
- art. 2560 c.c. la responsabilità patrimoniale relativa ai debiti dell'azienda ceduta.

Con riguardo al divieto di concorrenza (art. 2557 c.c.), l'alienante deve astenersi per un periodo di cinque anni dal trasferimento dall'iniziare una nuova impresa che per oggetto, ubicazione o altre circostanze sia idoneo a sviare la clientela dall'azienda ceduta.

La ratio della norma consiste nel tutelare l'avviamento dell'azienda ceduta.

Le parti possono concordare una clausola di divieto di concorrenza più rigida, purché:

1) non impedisca ogni attività professionale all'alienante;
2) il divieto non superi i cinque anni: qualora sia pattuito un termine maggiore o non sia pattuito termine affatto, questo è determinato in 5 anni.

L'articolo 2557 c.c. è applicabile alle aziende agricole per le attività ad esse connesse, quanto rispetto ad esse sia possibile uno sviamento di clientela.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Con riguardo, invece, all'aspetto della successione nei contratti aziendali, risulta con tutta evidenza la necessità e l'interesse del cessionario al mantenimento dell'unità economica dell'azienda.

Ai sensi dell'art. 2558 c.c. il cessionario, infatti, subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, che non abbiano carattere personale, fatto salvo il patto contrario.

Il consenso del terzo non è necessario perché si trasferisca il rapporto contrattuale in capo al cessionario, differentemente da quanto previsto dall'art. 1406 c.c. nella successione nei contratti in ambito civile (strettamente inteso), per il quale la successione nei contratti è subordinata al consenso della controparte.

Per ovviare alla situazione passiva della controparte che vede cambiare il soggetto contraente, indipendentemente dalla sua volontà, il legislatore attribuisce il diritto di recesso del predetto contraente entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, qualora sussista una giusta causa e fatta salve la responsabilità dell'alienante.

La giusta causa può concretizzarsi nella scelta da parte dell'imprenditore alienante di cedere l'azienda ad un soggetto che non disponga delle garanzie patrimoniali necessarie per far fronte agli adempimenti delle obbligazioni contrattuali succedute.

È opportuno osservare che l'art. 2558 c.c. disciplina esclusivamente la successione dei contratti a carattere "non personale".

In caso di successione di contratti a carattere personale nel trasferimento d'azienda, trova applicazione la disciplina strettamente civilistica dell'art. 1406 c.c. e seguenti; tali contratti potranno essere trasferiti esclusivamente con una pattuizione tra cedente e cessionario ed il consenso espresso del terzo contraente ceduto.

Sono contratti a carattere personale quelli nei quali l'identità e la qualità dell'imprenditore cedente sono state in concreto determinati dal consenso del terzo contraente, da accertarsi caso per caso. Il contratto a carattere personale non deve essere qui identificato con la figura giuridica dei contratti intuitu personae (i.e. mandato ed agenzia).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il fenomeno della successione nei contratti presuppone che nessuna delle parti contraenti abbia già adempiuto alla propria prestazione dedotta in contratto.

Nel caso in cui l'imprenditore alienante abbia adempiuto, il cessionario si trova in posizione di credito verso il terzo.

Quando, invece, ad avere adempiuto sia stato il terzo, il cessionario si trova in una posizione di debito.

Ai sensi dell'art. 2559 c.c. la cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta ha effetto nei confronti dei terzi dal momento della iscrizione del trasferimento del Registro delle Imprese. [E' opportuno osservare come nel caso in cui l'azienda trasferita non sia soggetta all'iscrizione nel Registro delle Imprese, allora si applicherà la disciplina comune della cessione dei crediti (art. 1260 c.c. e seguenti)].

L'iscrizione nel Registro delle imprese dell'atto di trasferimento rende superflua la notifica al debitore, stante la conoscibilità del trasferimento per mezzo della consultazione del Registro, e non viene richiesta neppure l'accettazione del debitore ceduto, avendo già questi ottenuto in precedenza l'adempimento della prestazione a suo favore dedotta in contratto.

Qualora il debitore ceduto paghi in buona fede all'alienante è liberato: il suo debito si estingue.

Con riferimento ai debiti aziendali (art. 2560 c.c.), l'alienante non è liberato dai debiti contratti anteriormente al trasferimento dell'azienda.

È necessario, infatti, il consenso espresso dei creditori alla liberazione dell'alienante per i crediti sorti anteriormente alla cessione.

Inoltre, in caso di azienda commerciale risponde dei predetti debiti anche il cessionario a condizione che essi risultino dai libri contabili obbligatori.

Con riguardo alla sorte dei debiti e crediti aziendali nei rapporti tra cedente e cessionario, in assenza di una indicazione legislativa, alcuni interpreti ritengono che non vi sia un passaggio automatico dei debiti e dei crediti, mentre una parte minoritaria della dottrina sostiene la soluzione opposta.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. I segni distintivi

I segni distintivi dell'imprenditore sono la ditta, l'insegna ed il marchio.

I segni distintivi permettono all'imprenditore di essere individuato dai clienti sul mercato, nel quale gli operatori economici esercitano la propria attività in un regime concorrenziale.

A fronte delle caratteristiche del mercato aperto alla concorrenza, il legislatore ha dettato la disciplina dei segni distintivi dell'imprenditore in considerazione di alcuni principi comuni:

- l'imprenditore è libero nella scelta dei propri segni distintivi, con il limite del rispetto dei criteri oggettivi della verità, della novità e della capacità distintiva;
- il diritto all'uso dei segni distintivi è esclusivo;
- la trasferibilità dei segni distintivi deve essere effettuata ai sensi di legge.

Il primo segno distintivo in esame è la ditta (art. 2563 c.c. s.s.).

La ditta è il nome commerciale dell'imprenditore, scelto da questi per esercitare l'attività d'impresa. È segno distintivo necessario: se non è espressa una scelta in merito dall'imprenditore, coincide con il suo nome civile.

La libera scelta dell'imprenditore nella individuazione della ditta è limitata dai principi di verità e novità.

Il principio della verità assume diverso contenuto se si tratta di ditta originaria o di ditta derivata.

La ditta originaria deve contenere almeno il cognome o in alternativa la sigla dell'imprenditore, il quale può completare poi liberamente la propria ditta.

Quando un imprenditore trasferisce la ditta da lui formata ad un altro imprenditore congiuntamente all'azienda si realizza in fenomeno della ditta derivata (art. 2565 c.c.).

In questo caso l'imprenditore cessionario non è obbligato da alcuna norma di legge a modificare o integrare la ditta ed alla luce del principio di verità la ditta derivata assume quindi un carattere storico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'art. 2564 c.c. se la ditta è uguale o simile a quella usata da un altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Il dettato normativo è da leggere alla luce del principio di esclusività della ditta stessa.

Qualsiasi imprenditore adotti una ditta simile può essere costretto a modificarla ai sensi dell'art. 2564 c.c. anche quando la ditta usata per seconda corrisponda al nome civile dell'imprenditore.

Per risolvere un conflitto tra ditte simili e determinare quale debba essere modificata, si utilizza il criterio temporale, dovendo essere riconosciuto il diritto d'uso esclusivo della ditta all'imprenditore che per primo l'ha utilizzata.

Qualora il conflitto sia relativo a ditte simili di imprese commerciali, ai sensi dell'art. 2564 c.c., il criterio dirimente non è legato all'individuazione dell'anteriore utilizzo della ditta, ma è collegato alla priorità temporale dell'iscrizione della ditta nel Registro delle Imprese.

La ditta non può circolare indipendentemente dall'azienda.

Ai sensi dell'art. 2565 c.c. la ditta non può essere trasferita separatamente all'azienda.

Nel caso in cui il trasferimento avvenga per atto tra vivi è necessario il consenso espresso dell'alienante, se invece avviene mortis causa si trasmette al successore salvo diverse disposizioni testamentarie.

Si ammette inoltre che la ditta può essere trasferita quando oggetto della cessione è il solo ramo d'azienda purché dotato di unità organica.

La ditta differisce poi dalla ragione sociale e dalla denominazione sociale.

Queste, infatti, svolgono la stessa funzione svolta dal nome civile della persona fisica e servono ad individuare le società come soggetti di diritto e non come enti esercenti attività d'impresa.

Si osservi come di ragione sociale si parli con riguardo alle società di persone e di denominazione sociale per le società di capitali e cooperative.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'insegna contraddistingue i locali d'impresa (lo stabilimento, il negozio) ed è disciplinata dall'art. 2564 primo comma c.c., per richiamo espresso dall'art. 2568 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

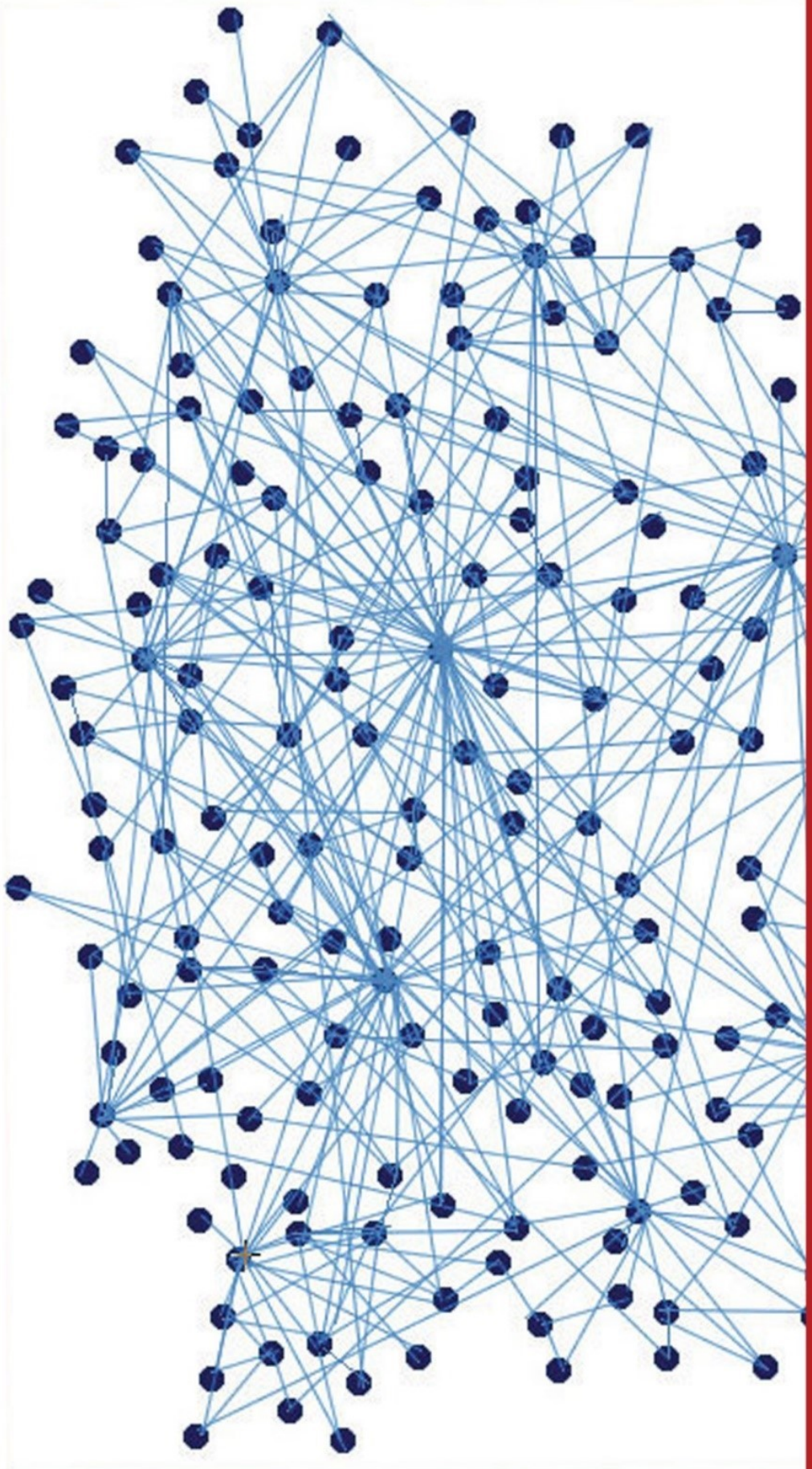
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 1 DIRITTO DELL'IMPRESA" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. NOZIONE DI SOCIETÀ, CONFERIMENTI E CAPITALE SOCIALE 3
2. SCOPO ED OGGETTO DELLA SOCIETÀ 7
3. CARATTERI GENERALI DISTINTIVI DELLA SOCIETÀ 9
BIBLIOGRAFIA 12

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Nozione di società, conferimenti e capitale sociale

Le società sono organizzazioni create dalla autonomia privata per l'esercizio di una attività produttiva e costituiscono strutture tipiche previste dall'ordinamento per l'esercizio collettivo dell'attività imprenditoriale.

Ai sensi dell'art. 2247 c.c. la società è il contratto con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili; con la precisazione che il legislatore ha previsto espressamente che S.r.l. e S.p.A. possano essere costituire da un unico socio.

L'ordinamento giuridico italiano prevede otto tipi di società:

- la società semplice (artt. 2251-2290 c.c.);
- la società in nome collettivo (s.n.c. – artt. 2291-2312 c.c.);
- la società in accomandita semplice (s.a.s. – artt. 2313 – 2324 c.c.);
- la società per azioni (S.p.A. – artt. 2325 – 2451 c.c.);
- la società in accomandita per azioni (S.a.p.a. – artt. 2452-2461 c.c.);
- la società a responsabilità limitata (S.r.l. – artt. 2462 – 2483 c.c.);
- la società cooperativa (artt. 2511 – 2545 octies c.c.);
- la società mutua assicuratrice (artt. 2546 – 2548 c.c.).

Si qualificano poi società di persone la società semplice, la s.n.c., la s.a.s.

Si qualificano, invece, società di capitali la S.p.A., la S.a.p.a. e la S.r.l.

Il diritto comunitario ha introdotto due ulteriori modelli organizzativi societari: la società europea e la società cooperativa europea.

Esaminando il profilo contrattuale delle società si può affermare che queste rientrano nella categoria dei contratti associativi o con comunione di scopo.

Il contratto associativo o con comunione di scopo si caratterizza poiché l'avverarsi di un unico fatto giuridico soddisfa tutti i contraenti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si differenzia pertanto dal contratto a prestazioni corrispettive nel quale l'adempimento ad opera di una sola delle parti contrattuali non è sufficiente a soddisfare l'interesse di tutti.

Nei contratti associativi le prestazioni dei contraenti possono essere di varia natura e di diverso valore economico, ciò si spiega col fatto che tali prestazioni non sono destinate ad essere "scambiate" tra di loro secondo un rapporto di correspettività.

Il fine del compimento delle prestazioni a cui si sono obbligati le parti del contratto sociale è l'acquisto della partecipazione sociale.

Il contratto associativo è un contratto tendenzialmente plurilaterale ed aperto: durante lo svolgimento del rapporto il numero delle parti può variare in aumento o in diminuzione, ma ciò non comporta lo scioglimento del contratto originario.

Si deve sottolineare come il contratto di società non esaurisca la sua funzione nella mera esecuzione delle prestazioni alle quali i soci si sono obbligati.

La finalità della stipula del contratto sociale è porre le basi organizzative della futura attività comune ed individuare le caratteristiche delle modalità di partecipazione all'esercizio di tale attività ed al suo risultato.

Nella definizione di contratto sociale dettata dal legislatore all'art. 2247 c.c. è possibile individuare i caratteri essenziali dello stesso, utilizzando tre parametri: i conferimenti, il comune esercizio dell'attività imprenditoriale, il fine della divisione degli utili.

I conferimenti sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio sociale iniziale, capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell'attività d'impresa.

L'oggetto e l'ammontare dei conferimenti può essere il più vario.

L'art. 2247 c.c. indica come possibili oggetti di conferimenti "beni o servizi", il dettato normativo deve essere interpretato nel senso per il quale può essere oggetto di conferimenti ciò che è suscettibile di valutazione economica (i.e.: denaro, beni immobili, lavoro).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Non si può fare a meno di osservare però come la disciplina dei conferimenti si caratterizza a seconda del tipo di organizzazione societaria presa in esame; esempio paradigmatico ne è la disciplina dei conferimenti nelle S.p.A., i quali non possono consistere in prestazioni d'opera o servizi ai sensi dell'art. 2342, quarto comma c.c.

All'inizio della vita dell'impresa i conferimenti coincidono con il patrimonio sociale.

Il patrimonio sociale è però costituito dall'insieme dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società.

Il bilancio d'esercizio ha la funzione di "fotografare" annualmente la consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio sociale.

Le componenti attive del patrimonio sociale, tra cui compaiono i conferimenti, è la garanzia principale dei creditori sociali nel caso in cui di tali crediti rispondano altresì i soci con il patrimonio personale (società di persone), mentre è garanzia esclusiva dei creditori sociali se i creditori sociali non possano rivalersi sul patrimonio personale dei soci.

Il capitale sociale (nominale) è una entità numerica che corrisponde al valore monetario dei conferimenti, come determinato nell'atto costitutivo della società.

Il capitale sociale può essere diminuito od aumentato solo con modifica dell'atto costitutivo.

Esso assolve a due funzioni:

- funzione vincolistica: come si è detto il capitale sociale rappresenta il valore monetario dei conferimenti apportati dai soci. Questi ultimi, con il contratto sociale si sono impegnati a non disporre liberamente dei conferimenti per tutta la durata della società, essendo beni o servizi destinati all'esercizio d'impresa;
- funzione organizzativa: costituisce il parametro per accertare se la società ha conseguito uni utile o una perdita d'esercizio. Si consegue un utile se le attività risultano maggiori del risultato della somma di capitale sociale e passività, viceversa il risultato economico sarà una perdita.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il capitale sociale è inoltre un criterio di attribuzione di situazioni soggettive relative ai soci di carattere patrimoniale – parametro per la distribuzione di utili e determinazione della quota di liquidazione – e di carattere amministrativo – diritto di voto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Scopo ed oggetto della società

L'oggetto sociale è l'esplicazione dell'attività economica per il cui esercizio è stata costituita la società. È elemento essenziale dell'atto costitutivo che può essere modificato esclusivamente con le modalità indicate dalla legge.

Deve consistere nello svolgimento di una attività produttiva ovvero a contenuto patrimoniale, esercitata con metodo economico, finalizzata alla produzione e scambio di beni o servizi.

Requisito fondamentale perché si concretizzi giuridicamente la società è che l'attività produttiva sia esercitata in comune tra i soci.

Tale requisito deve essere inteso in senso oggettivo: deve sussistere la preordinazione alla realizzazione di un risultato unitario e comune, vale a dire giuridicamente imputabile alla compagine sociale unitariamente intesa. A corollario di tale principio chi agisce nei rapporti con i terzi deve essere abilitato ad operare in nome e per conto della società.

L'art. 2247 c.c. determina la divisione degli utili quale scopo ultimo della società (scopo lucrativo). Lo scopo lucrativo è tipico delle società di persone e delle società di capitali, altresì nominate società lucrative. Il lucro può essere oggettivo (la realizzazione di un utile o profitto) o soggettivo (la distribuzione dell'utile ai soci).

La società può essere altresì costituita per raggiungere uno scopo mutualistico od uno scopo consortile.

Lo scopo mutualistico è tipico delle società cooperative (art. 2511 c.c. e seguenti).

Tale fine consiste nel fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle che i soci otterrebbero sul mercato. E' comunque indubbio che la società cooperativa operi con metodo economico e che il vantaggio patrimoniale sia conseguito non dalla società in se', bensì dal socio direttamente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La società creata con finalità consortili (art. 2615 ter c.c.) è tenuta ad operare con metodo economico e realizza uno scopo economico dei soci costituito da un particolare vantaggio patrimoniale degli imprenditori consorziati, quali ad esempio la sopportazione di minori costi per la realizzazione di una opera.

La regola generale è quella per la quale le società sono costituite con scopo di lucro.

Vi sono casi espressamente previsti dal legislatore, nei quali è fatto divieto alle società il perseguimento di uno scopo di lucro: S.p.A. costituite per la gestione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari (art. 61 T.U.F.), società per la gestione accentrata di strumenti finanziari (art. 80 T.U.F.), l'impresa sociale (d. Lgs. n. 155 del 24.03.2006).

Gli interpreti ritengono inammissibile l'esistenza della società di mero godimento.

L'art. 2248 c.c. prevede infatti che la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose sia regolata dalle norme sulla comunione e non da quelle delle società.

La ratio è di limitare l'ambito di applicazione della disciplina del regime patrimoniale delle società alle sole situazioni in cui i beni sono destinati allo svolgimento di una attività produttiva. Se si ritenesse ammissibile la possibilità di configurare la società di mero godimento, potrebbe derivarne un abuso ai danni dei creditori.

Gli interpreti ritengono illegittime, pertanto, le società immobiliari di comodo, ovvero quelle società il cui patrimonio attivo è costituito esclusivamente dagli immobili conferiti dai soci e la cui attività d'impresa di esaurisce nel concedere gli immobili in locazione senza produrre alcun servizio ulteriore.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Caratteri generali distintivi della società

Il legislatore ha previsto otto modelli legali differenti di società.

Le società si possono distinguere secondo altri criteri in lucrative e società mutualistiche.

Nella categoria delle società lucrative è possibile distinguere società semplici e società commerciali, società alle quali è attribuita la personalità giuridica e società che ne sono prive, società di capitali e società di persone.

Il codice del 1942 attribuisce personalità giuridica alle società di capitale ed alle società cooperative.

La società di persone, invece, sono prive di personalità giuridica, è però riconosciuta loro un certo grado di autonomia patrimoniale seppur imperfetta, a differenza delle società di capitali che si contraddistinguono per l'autonomia patrimoniale perfetta della quale godono; inoltre sono state dotate di soggettività giuridica, ovvero costituiscono degli autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici.

Il legislatore nel tipizzare i modelli organizzativi societari ha voluto perseguire un obiettivo di politica economica preciso: favorire la creazione delle imprese societarie.

Tale obiettivo è stato perseguito prevedendo:

- un trattamento preferenziale per i creditori sociali, rispetto ai creditori personali dei soci; il patrimonio sociale è infatti garanzia patrimoniale per i soli creditori sociali;
- per contro il patrimonio personale dei singoli soci è aggredibile dai soli creditori personali dei soci.

Tali previsioni si realizzano attraverso il riconoscimento della personalità giuridica a determinate società, attribuzione in forza della quale la società è soggetto diverso, distinto dai soci.

Ne consegue che la società, in quanto avente personalità giuridica attribuitale dal legislatore in determinati casi, gode di autonomia patrimoniale perfetta (società di capitali).

Ciò non implica però il totale esonero di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il legislatore prevede, infatti, che in alcuni casi sussista la responsabilità patrimoniale sussidiaria:

- dell'unico azionista (art. 2325, secondo comma c.c.);
- dell'unico quotista di società a responsabilità limitata (art. 2462, secondo comma c.c.);
- dei soci accomandatari dell'accomandita per azioni (art. 2452 c.c.).

Per quanto concerne le società di persone, si può osservare che il legislatore le abbia configurate come prive di personalità giuridica e con autonomia patrimoniale imperfetta.

L'autonomia patrimoniale imperfetta si concretizza nel fatto dell'impresa di avere un patrimonio distinto da quello personale dei soci, pur potendo i creditori sociali aggredire – nelle modalità indicate dalla legge – anche il patrimonio personale dei soci.

Presupposto necessario per poter aggredire il patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili è l'infruttuosità del tentativo dei creditori sociali di soddisfarsi aggredendo il patrimonio sociale.

Inoltre, si osservi che, per converso, i creditori personali dei soci non possono soddisfare il loro diritto di credito sul patrimonio sociale; possono invece far valere le loro pretese sugli utili spettanti al socio debitore e compiere atti conservativi sulla quota societaria in liquidazione ex art. 2270 primo comma c.c. (fatto salve quanto previsto dal medesimo articolo al comma secondo, nonché dall'art. 2307 c.c.).

La società di persone è quindi oggettivamente un centro di imputazione di rapporti giuridici, ma si ribadisce come non possa esserle riconosciuta personalità giuridica.

Dal punto di vista fattuale, pertanto, i beni sociali debbono essere considerati beni in comproprietà dei soci, mentre le obbligazioni sociali debbono essere considerate obbligazioni collettive proprie dei soci: la responsabilità personale ed illimitata degli stessi si atteggia pertanto come responsabilità per debito proprio.

Dal punto di vista giuridico, invece, si può riaffermare che la società di persone è centro di imputazione di rapporti giuridici il cui dato normativo di riferimento è l'art. 2266, primo comma c.c., che ha un proprio nome ed una sede differenti da quelli dei soci.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'art. 2249 c.c. l'imprenditore può scegliere il modello organizzativo societario che preferisce tra tutti quelli tipici previsti dal codice del 1942 qualora l'attività esercitata non sia commerciale.

Nel caso in cui l'attività d'impresa abbia carattere commerciale, è preclusa all'imprenditore la scelta del tipo società semplice.

Nel caso, invece, in cui non sia stata effettuata dall'imprenditore la scelta del modello organizzativo tipo da adottare, se l'attività esercitata non ha carattere commerciale, si applica di default la disciplina della società semplice (art. 2249, secondo comma c.c.); se l'attività esercitata ha carattere commerciale, si applica di default la disciplina della società in nome collettivo.

Ogni tipo di organizzazione societaria la cui disciplina è fissata dal legislatore permette comunque alle parti di introdurre nel contratto sociale clausole che non siano in contrasto con la disciplina dichiarata inderogabile e dettata dalle norme di legge.

In caso di incompatibilità di una clausola inserita dalle parti con le norme di legge dichiarate inderogabili, la clausola pattizia contraria è affetta da nullità parziale ex art. 1419, secondo comma c.c. e trova applicazione quando dettato in merito dalla disciplina generale del tipo organizzativo societario di riferimento.

È esclusa dall'ordinamento giuridico la possibilità di creare una società che non corrisponda ai modelli organizzativi tipici previsti dal legislatore.

L'ordinamento non ammette società atipiche, che sono affette da nullità, in considerazione della necessaria tutela dell'affidamento ingenerato nel terzo che conclude affari con le società e l'interesse generale al regolare svolgimento dell'attività economica sul mercato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

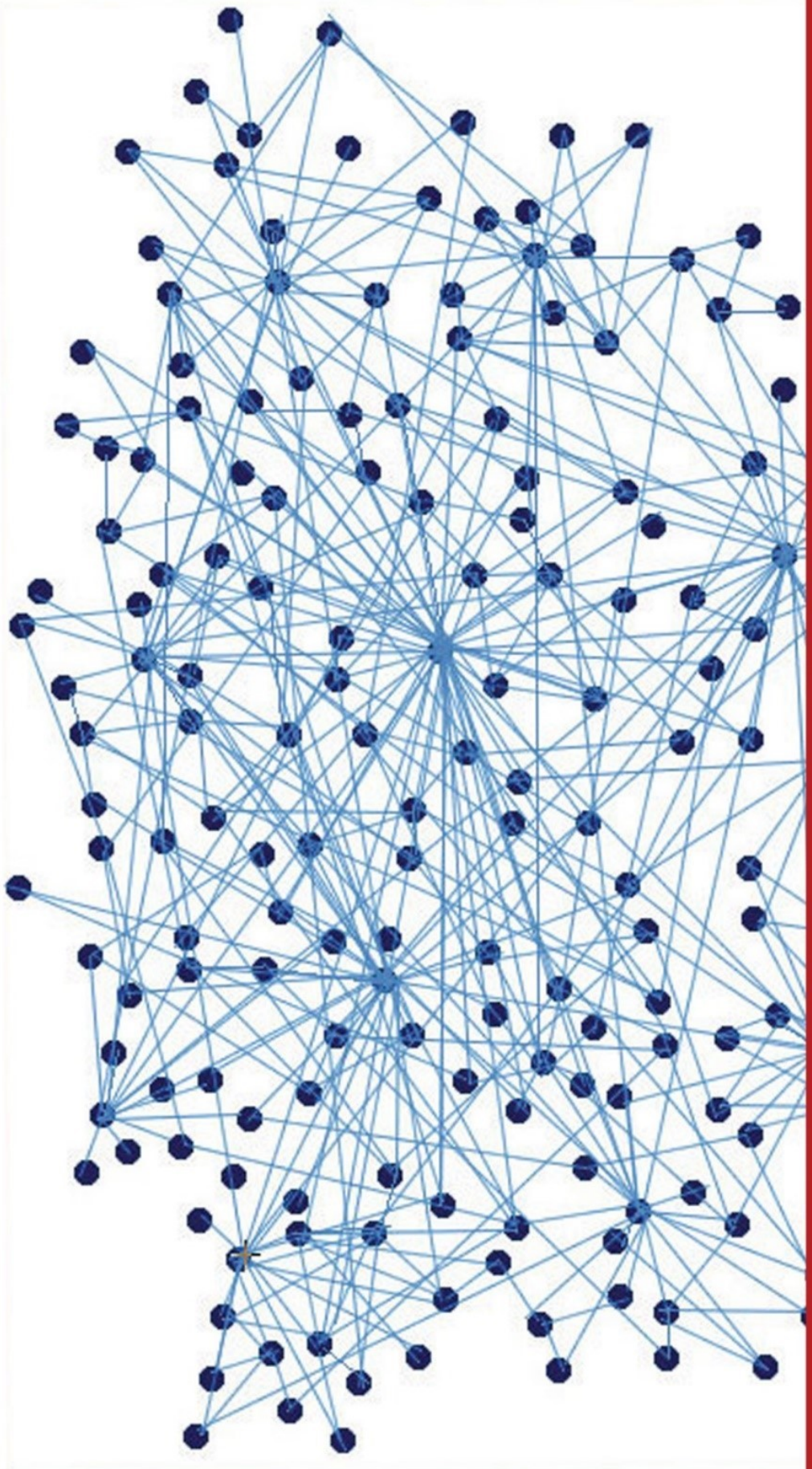
- "Diritto commerciale – vol. 2 diritto delle società'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, TORINO (ultima edizione aggiornata).
- "Diritto commerciale – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LE SOCIETÀ DI PERSONE: NOZIONE, TIPOLOGIE E COSTITUZIONE 3
2. I CONFERIMENTI 6
3. IL CAPITALE SOCIALE ED IL DIRITTO AGLI UTILI 8
BIBLIOGRAFIA 10

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Le società di persone: nozione, tipologie e costituzione

La categoria delle società di persone è composta dalla società semplice, dalla società in nome collettivo, dalla società in accomandita semplice.

Le società di persone si caratterizzano per la mancanza di personalità giuridica (pur avendo esse una soggettività giuridica), che il legislatore riconosce espressamente alle sole società di capitali e per la responsabilità solidale e illimitata dei soci in relazione alle obbligazioni sociali.

Il legislatore riconosce una parziale autonomia patrimoniale delle società di persone mediante la configurazione di un beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale, pur se variamente disciplinato nei diversi tipi di società di persone.

La società semplice è disciplinata dal codice civile agli articoli 2251-2290 c.c.

La società semplice può esercitare esclusivamente una attività non commerciale.

La disciplina della società semplice è il paradigma giuridico dell'attività imprenditoriale non commerciale, nel caso in cui le parti non optino una determinata tipologia societaria.

È inoltre il prototipo normativo delle società di persone; infatti, per espresso richiamo normativo, la disciplina della società semplice è applicabile anche alla società in nome collettivo ed alla società in accomandita semplice (artt. 2293 e 2315 c.c.).

Per quanto concerne la costituzione di una società semplice, l'art. 2251 c.c. non richiede alcun requisito di forma, fatta eccezione per quello richiesto dalla natura dei beni conferiti.

Con riguardo, invece, alla iscrizione al Registro delle Imprese, si osserva come nel sistema originario del 1942 il legislatore non avesse previsto l'assolvimento di alcun obbligo di registrazione per tale tipo di società. Per la validità della sua costituzione il legislatore non ha posto alcun requisito di iscrizione presso il Registro delle Imprese.

A seguito della prima riforma del Registro delle Imprese è stata introdotta l'iscrizione delle società semplici (art. 8, quarto comma Legge 580/1993, ora art. 2 D.P.R. 558/1999).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La legge 580/1993 stabiliva che l'iscrizione avvenisse nella sezione speciale e fosse priva di effetti giuridici dichiarativi, assolvendo alla sola funzione di certificazione anagrafica e pubblicità notizia. Il D. Lgs. n. 228/2001 ha invece innovato la norma citata, prevedendo che l'iscrizione al Registro delle Imprese di società semplici esercenti attività agricola assolva alla funzione di pubblicità legale (efficacia dichiarativa ex art. 2193 c.c.).

Sussiste pertanto per tale tipo di società una disciplina relativa alla iscrizione del Registro delle Imprese a doppio binario.

La società in nome collettivo (s.n.c.) è disciplinata dal codice civile agli articoli 2291-2312 c.c.

Questo tipo di società può essere adottato sia per esercitare attività commerciale, sia non commerciale.

La disciplina della società in nome collettivo costituisce il paradigma giuridico dell'attività imprenditoriale commerciale, nel caso in cui le parti non scelgano espressamente la tipologia societaria.

Per quanto concerne la costituzione di una s.n.c. il codice prevede determinati requisiti di forma e di procedura relativa alla iscrizione presso il Registro delle Imprese (artt. 2295-2296 e 2297 c.c.). È necessario, infatti, che il contratto sociale, il cui contenuto minimo è indicato dall'art. 2295 c.c., abbia la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, poiché tale forma è necessaria per poter essere iscritto presso il Registro delle Imprese.

La mancata iscrizione al Registro delle Imprese della s.n.c. o la mancata redazione dell'atto costitutivo (ferma l'applicazione dell'art. 2251 c.c.) non comporta l'inesistenza della società stessa, ma l'irregolarità della medesima e l'applicazione della disciplina dettata per la società semplice ai sensi dell'art. 2297 c.c. che, per alcuni aspetti è meno favorevole per i soci nei rapporti patrimoniali tra società e terzi.

Il contenuto dell'atto costitutivo delle s.n.c. è dettato dall'art. 2295 c.c., il quale deve contenere espressamente: il cognome ed il nome dei soci, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, la ragione sociale, i soci ai quali è attribuita l'amministrazione e la

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

rappresentanza della società, la sede legale della società e le eventuali sedi secondarie, l'oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio, il valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione, le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera, le norme secondo le quali gli utili debbono essere ripartiti e la quota spettante a ciascun socio di utili e di perdite, la durata della società.

Poiché per la costituzione di una società di persone non è necessario un atto a forma scritta, il perfezionamento del contratto sociale può avvenire anche per fatti concludenti. In tale caso la dottrina parla di società di fatto.

La società di fatto se esercita attività non commerciale è regolata dalla disciplina delle società semplici, se esercita attività commerciale dalla disciplina delle s.n.c. irregolari.

La società di fatto esercente attività commerciale è esposta al fallimento, che comporta altresì il fallimento dei soci palesi ed occulti, ovvero dei soci la cui esistenza è scoperta successivamente al fallimento.

Un particolare caso applicativo che merita attenzione è la partecipazione di società di capitali a società di persone. Una società di capitali può diventare socio di una società di persone ai sensi dell'art. 2361 c.c., secondo comma, per il quale "l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella notai integrativa del bilancio", e art. 111-duodecies disp. Att. c.c. per il quale se i soci illimitatamente responsabili sono società di capitali (aventi quindi soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale perfetta), le s.n.c. e le s.a.s. debbono redigere, se sussistono i presupposti di legge, il bilancio secondo le norme previste per le S.p.A. ed il bilancio consolidato.

La società in accomandita semplice (s.a.s.) è disciplinata dagli articoli 2313-2314 c.c. trova la sua specificità nel fatto di avere due categorie di soci: il socio accomandatario ed il socio accomandante. I soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio personale per le obbligazioni sociali. I soci accomandanti, invece, rispondono delle obbligazioni sociali limitatamente alla quota conferita.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. I conferimenti

L'obbligo di conferimento è necessario per l'acquisto della qualità di socio.

I soci normalmente determinano contrattualmente i conferimenti dovuti da ciascuno, ma in caso di silenzio delle parti, si presume che debbano essere effettuati in denaro ed in parti uguali per l'ammontare necessario al conseguimento dell'oggetto sociale (ai sensi dell'art. 2342, primo comma c.c. e dell'art. 2253, secondo comma c.c.).

Nelle società di persone il conferimento può avere ad oggetto qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica ed utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, che sia un bene, del denaro o l'attività lavorativa del socio, nonché dalla prestazione di garanzie a favore della società.

Il conferimento può avere ad oggetto dei beni in proprietà.

In tal caso, ai sensi dell'art. 2254, primo comma c.c., la garanzia dovuta dal socio e il passaggio dei rischi sono regolati dalle norme sulla vendita. Il socio è pertanto tenuto alla garanzia per vizi ed evizione della cosa (articoli 1490 e 1483-1484 c.c.).

Si osserva, inoltre, come il perimento del bene oggetto del conferimento prima che questa sia passata in proprietà alla società, può comportare l'esclusione del socio (art. 2286, terzo comma c.c.).

Per converso se il conferimento ha ad oggetto dei beni in godimento, ai sensi dell'art. 2254 secondo comma c.c., il rischio delle cose conferite in godimento restano ovviamente a carico del socio e le garanzie per il godimento delle stesse da parte della società sono disciplinate dalle norme sulla locazione.

Se il bene conferito è un credito, ai sensi dell'art. 2255 c.c., il socio conferente risponde dell'insolvenza del creditore nel limite del valore del conferimento, in difetto può essere escluso dalla società.

Come sopra accennato, il conferimento può avere ad oggetto la propria attività lavorativa.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il socio d'opera non è lavoratore subordinato.

L'attività lavorativa svolta viene ricompensata dalla partecipazione ai guadagni della società, sopportando il rischio di impresa, poiché il risultato economico dell'esercizio può consistere anche in una perdita.

Inoltre, nel caso di impossibilità sopravvenuta che impedisca lo svolgimento dell'attività lavorativa, il socio può essere escluso dalla società (art. 2301, secondo comma c.c.).

In caso di scioglimento della società, il socio d'opera è parificato al socio conferente servizi.

È previsto che questi soci partecipino alla ripartizione dell'attivo patrimoniale rimanente dopo il rimborso del valore nominale delle quote dei soci conferenti beni, denaro e crediti. Discussa tra gli interpreti è la questione relativa all'imputabilità a capitale del valore del conferimento d'opera.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il capitale sociale ed il diritto agli utili

Il capitale sociale è il valore monetario dei conferimenti apportati dai soci e si identifica all'inizio dell'esercizio d'impresa con il patrimonio sociale (che con il tempo si arricchirà di altri elementi finanziari attivi).

Il capitale sociale è quindi vincolato all'esercizio dell'attività d'impresa, non potendone disporre i soci fino al momento dello scioglimento del contratto sociale. In particolare, la riduzione del capitale sociale ex art. 2306 c.c. non può avvenire prima dei tre mesi dall'iscrizione della deliberazione di riduzione di capitale presso il Registro delle Imprese; entro tale termine è attribuita la facoltà ai creditori sociali anteriori all'iscrizione della delibera di proporre opposizione.

La riduzione di capitale sociale può avvenire attraverso il rimborso ai soci delle quote pagate o dalla liberazione dei soci dall'obbligo di effettuare ulteriori versamenti.

Inoltre, nel caso in cui il risultato economico d'esercizio conseguito sia una perdita, di tale entità da intaccare il capitale sociale, allora il legislatore condiziona l'eventuale distribuzione di successivi utili alla reintegrazione od alla riduzione in misura corrispondente del capitale (art. 2303, secondo comma c.c.).

Il legislatore prevede poi che la ripartizione di somme tra soci avvenga in caso di utili realmente conseguiti (art. 2303, primo comma c.c.).

L'articolo 2265 c.c. sanziona con la nullità qualsiasi patto con il quale uno o più soci siano esclusi da ogni partecipazione agli utili od alle perdite (patto leonino).

Questo è l'unico limite posto ai soci nella determinazione della ripartizione del risultato economico d'esercizio.

In caso di nullità ex art. 2265 c.c., sopperisce alla invalidità della disciplina convenzionale l'applicazione dell'art. 2263 c.c., per il quale il criterio di ripartizione tra i soci del risultato economico d'esercizio - sia utile, sia perdita - si determina in maniera proporzionale ai conferimenti; se il valore di questi non è determinato, si presumono in parti uguali. Se il

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

conferimento consiste nella prestazione di attività lavorativa, con valore non determinato nel contratto sociale, il giudice determina la quota spettante al socio d'opera secondo equità.

Quanto invece al diritto di percepire gli utili, si osserva come generalmente il risultato economico d'esercizio, se utile o perdita, sia rilevato a seguito della redazione del bilancio d'esercizio che deve essere approvato. Per le società semplici il legislatore prevede nell'art. 2262 l'approvazione del rendiconto.

In ogni caso, dall'approvazione del documento contabile dal quale risulti il risultato economico dell'esercizio, se positivo, i soci hanno diritto alla distribuzione dello stesso.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

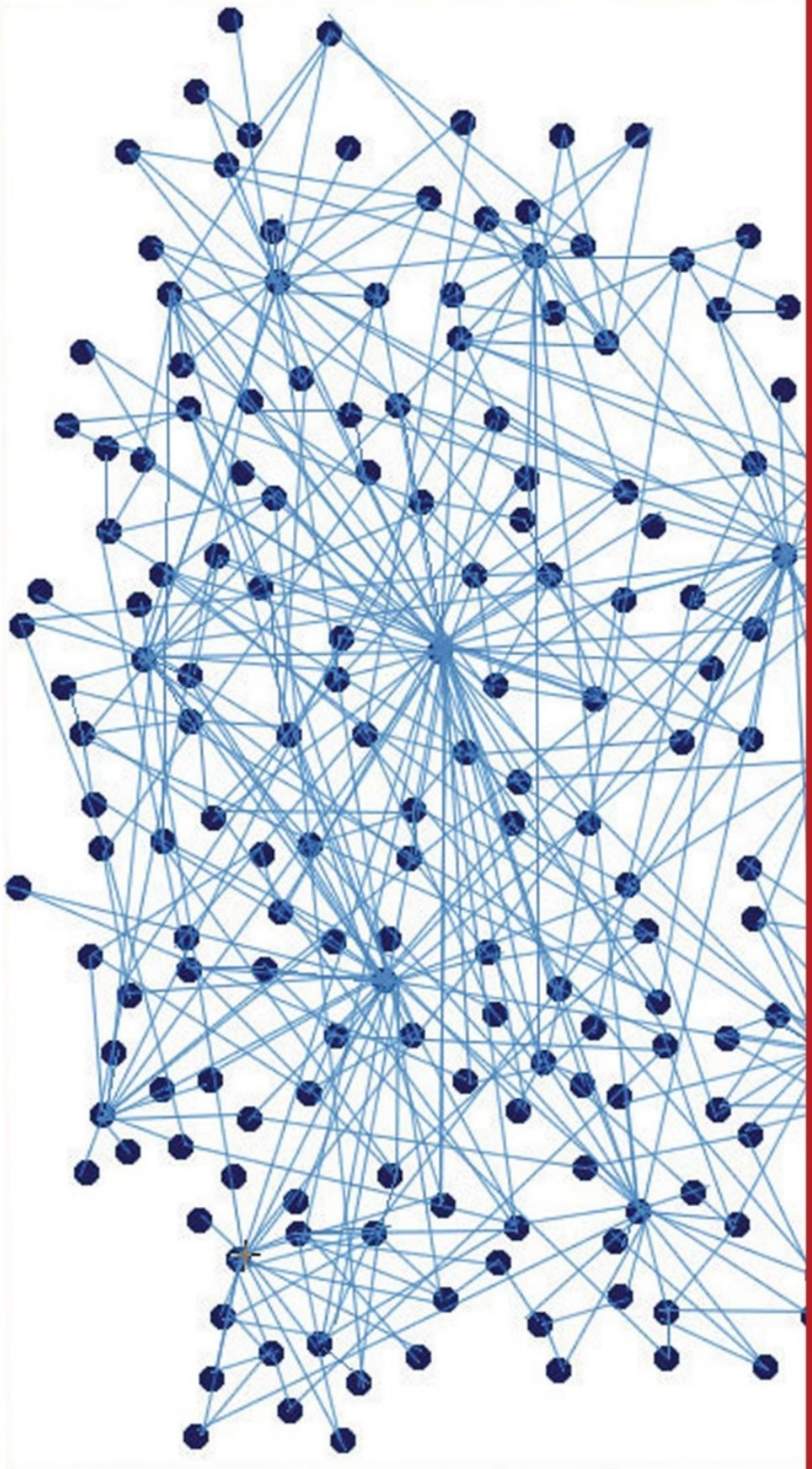
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LE SOCIETÀ DI PERSONE: POSIZIONE DEI CREDITORI 3
2. LE SOCIETÀ DI PERSONE: AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA 6
3. LE MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO 10
BIBLIOGRAFIA 11

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Le società di persone: posizione dei creditori

Le società di persone non godono della cosiddetta autonomia patrimoniale perfetta, per la quale delle obbligazioni sociali risponde la sola società con il suo patrimonio.

Nelle società di persone, infatti, il primo patrimonio sul quale si possono soddisfare i creditori della società è quello sociale, se questo però risulta insufficiente a soddisfare i creditori sociali, questi si possono rivalere sul patrimonio personale dei soci.

I soci sono illimitatamente e solidalmente responsabili delle obbligazioni sociali con la società.

Per quanto concerne la società semplice, al generale principio di responsabilità illimitata e solidale dei soci per le obbligazioni sociali è possibile apportare una deroga con riferimento ai soci che per i quali viene esclusa la rappresentanza sociale ovvero la possibilità di compiere atti in nome e per conto della società. Si tratta però di limitazioni ed esclusioni che debbono essere portate a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o non saranno opponibili ai terzi (art. 2267 c.c.).

Per quanto concerne le s.n.c., ai sensi dell'art. 2291 c.c., i soci rispondono illimitatamente e solidalmente con la società per le obbligazioni sociali. Qualsiasi deroga convenzionale a tale principio è invalida e non ha effetto nei confronti dei terzi.

In caso di ingresso nella compagine sociale di una società semplice o di una s.n.c. di un nuovo socio, questi è responsabile patrimonialmente anche dei debiti della società sorti anteriormente al suo ingresso (art. 2269 c.c.).

In caso di scioglimento del vincolo sociale con riferimento ad un solo socio, nelle società semplici e nelle s.n.c. irregolari, ai sensi dell'art. 2290 c.c., l'ex socio o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno dello scioglimento del vincolo contrattuale. Tale fatto deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, in difetto non è opponibile ai terzi che lo hanno ignorato senza colpa.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In caso di scioglimento del vincolo sociale con riferimento ad un solo socio di s.n.c. regolare, questo fatto è soggetto al regime di pubblicità legale delle modificazioni dell'atto costituivo ex art. 2300 c.c. Dal momento della registrazione nel Registro delle Imprese della modifica dell'atto costitutivo per scioglimento del vincolo sociale nei confronti di un solo socio, tale fatto giuridico sarà opponibile a tutti, anche a coloro che lo ignorano. Alla luce del riconoscimento dell'efficacia di pubblicità legale all'iscrizione nel Registro delle imprese della società semplice esercente attività agricola, medesima soluzione deve essere adottata nel caso di scioglimento del vincolo sociale con riferimento ad un solo socio.

Dal momento dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese dello scioglimento del rapporto sociale relativamente ad un socio, decorre il termine annuale per richiedere la dichiarazione di fallimento dello stesso.

Si è già anticipato di come i soci siano illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali e di come la loro garanzia patrimoniale sia sussidiaria, dovendo prima i creditori sociali tentare invano di soddisfare i propri diritti creditori aggredendo il patrimonio sociale. Tale principio è denominato beneficio di preventiva escussione.

Il funzionamento di tale principio differisce però nelle società semplici (e s.n.c. irregolari) dalle s.n.c. (regolari).

In particolare, nelle società semplici (e s.n.c. irregolari), il creditore sociale può chiedere il pagamento di quanto dovuto al socio illimitatamente responsabile, sarà quest'ultimo a decidere se avvalersi della preventiva escussione, indicando al creditore i beni sui quali potrà soddisfarsi (ex art. 2268 c.c.).

Per le s.n.c. regolari, invece, affinché un creditore sociale possa aggredire il patrimonio personale dei soci, tutti illimitatamente e solidalmente responsabili con la società per le obbligazioni sociali, è necessario che tenti previamente l'escussione del patrimonio sociale. La preventiva escussione può venire meno in tal caso solo se vi siano elementi oggettivi che rendano evidentemente inutile l'esperimento dell'esecuzione del patrimonio sociale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il creditore personale del socio di una società di persone non potrà aggredire il patrimonio sociale per soddisfarsi; se è al contempo creditore debitore della società non potrà operare alcuna compensazione tra il credito personale del socio ed il debito verso la società.

Al creditore personale del socio (art. 2270, primo comma c.c.) di società semplice e di s.n.c. è però riconosciuta la possibilità di far valere il proprio diritto creditorio sugli utili spettanti al socio e compiere atti conservativi sulla quota sociale del socio stesso in sede di liquidazione.

Nel caso di società semplici e di s.n.c. irregolari, ai sensi dell'art. 2270, secondo comma c.c., se i beni del socio-debitore risultano essere insufficienti a soddisfare il debito personale dello stesso, il creditore personale può chiedere la liquidazione della quota sociale, che deve essere compiuta entro tre mesi decorrenti dalla proposizione di tale domanda a meno che non sia deliberato lo scioglimento della società.

In caso di creditore personale di socio di s.n.c. regolare, questi non è legittimato a richiedere la liquidazione della quota sociale del socio-debitore finché dura la società.

L'eventuale proroga della società non può però pregiudicare i diritti dei creditori particolari del socio, il quale è legittimato ex art. 2307 c.c. a proporre opposizione alla proroga entro tre mesi dalla iscrizione presso il Registro delle Imprese della deliberazione di proroga.

In caso di accoglimento della domanda, entro il termine di tre mesi dalla notificazione della sentenza, la società deve liquidare la quota al socio debitore dell'opponente.

In caso di proroga tacita, ciascun socio può recedere dalla società dando preavviso (ex art. 2285 c.c.) e il creditore particolare del socio può chiedere la liquidazione della quota del suo debitore a norma dell'art. 2270 c.c., cioè dimostrando l'insufficienza dei beni personali del socio debitore ai fini della soddisfazione del credito vantato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Le società di persone: amministrazione e rappresentanza

La disciplina codicistica della società semplice e della s.n.c. è caratterizzata dall'essenzialità e dalla derogabilità per volontà delle parti.

Si tratta di una disciplina essenziale in quanto fissa due principi di fondo:

- ad ogni socio illimitatamente responsabile è attribuito il potere di amministrazione e rappresentanza;
- le modificazioni del contratto sociale possono essere se vi acconsentono tutti i soci.

Tale modello è derogabile poiché il legislatore, in considerazione della personale responsabilità patrimoniale dei soci per le obbligazioni sociali (seppur in via sussidiaria), ha ritenuto opportuno lasciare nella disponibilità delle parti la modellazione del funzionamento della società.

In particolare, per quanto concerne l'attività di amministrazione, che si concretizza nella capacità di decidere di compiere atti realizzativi dell'oggetto sociale dell'impresa e che ha pertanto una efficacia interna all'azienda, questa può essere disgiunta o congiunta.

Il modello legale dell'amministrazione è disgiuntivo (ex art. 2257 c.c.). In tale caso ciascun socio amministratore può compiere autonomamente tutte le operazioni ricomprese nell'oggetto sociale, non essendo necessario il consenso o il parare degli altri soci amministratori. A questi ultimi è però riconosciuto il rimedio del diritto di opposizione, che deve però essere esercitato antecedentemente al compimento dell'atto gestorio. L'effetto è di bloccare il potere dell'amministratore in merito al compimento dell'operazione opposta. Sulla fondatezza dell'opposizione si decide poi a maggioranza dei soci, calcolata con riferimento al criterio quantitativo per la ripartizione degli utili tra i soci (art. 2257, terzo comma c.c.).

Metodo alternativo per la soluzione dei conflitti tra gli amministratori, la cui adozione deve però essere fatta nell'atto costitutivo con apposita clausola di arbitraggio, è l'arbitrato. Con tale metodo si attribuisce il potere di decidere in merito al conflitto tra amministratori ad un soggetto terzo (monosoggettivo o plurisoggettivo).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La decisione dell'arbitro è vincolante. Le modalità di impugnazione di tale decisione possono essere previste in atto costitutivo, in difetto di tale previsione la decisione dell'arbitro è impugnabile ex art. 1349, secondo comma c.c. (mala fede).

L'atto costitutivo può derogare al modello di amministrazione disgiuntiva e prevederne il carattere congiuntivo.

Con l'adozione di tale modello è necessario il consenso di tutti i soci per il compimento degli atti elencati in oggetto sociale. Può essere previsto in atto costitutivo che per il compimento di alcuni atti sia sufficiente la maggioranza dei soci amministratori, calcolata proporzionalmente al criterio di ripartizione degli utili. In assenza di tale specifica previsione è però necessaria l'unanimità.

L'art. 2258, terzo comma c.c. prevede però, come correttivo la possibilità per gli amministratori di compiere atti singolarmente nel caso in cui sia urgente evitare un danno alla società.

Il potere di rappresentanza differisce dal potere di amministrazione in quanto i suoi effetti si esplicano all'esterno dell'azienda. È infatti il potere di agire nei confronti dei terzi, in nome e per conto della società: i diritti e gli obblighi sono assunti a mezzo del rappresentante dalla società stessa (ex art. 2266, primo comma c.c.).

Il modello legale (articoli 2266, secondo comma e 2298 c.c.) prevede l'attribuzione dell'amministrazione e del potere di rappresentanza agli stessi soggetti e concernono tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, siano di ordinaria o di straordinaria amministrazione, nonché la rappresentanza processuale della società, sia attiva (citare in giudizio), sia passiva (essere convenuti in giudizio).

L'atto costitutivo può prevedere una diversa distribuzione dei poteri amministrativi e di rappresentanza, dissociando soggettivamente il potere amministrativo da quello gestorio; può inoltre indicare modalità di esercizio di tali poteri differenti da quelle dal modello legale, che devono però essere specificamente indicati in atto costitutivo.

Tali deroghe devono però essere portate alla conoscenza dei terzi con idonee modalità, affinché possano essere ad essi opponibili.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per le s.n.c. (e per le società semplici esercenti attività agricola) tale esigenza di pubblicità è soddisfatta dalla pubblicità legale dell'iscrizione dell'atto costitutivo e delle sue modifiche relative alla limitazione del potere amministrativo e di rappresentanza nel Registro delle Imprese.

In difetto di iscrizione delle limitazioni di tali poteri nel Registro delle Imprese, esse non sono opponibili ai terzi, che in questo caso fanno affidamento sulla corrispondenza del modello di amministrazione e rappresentanza della società al modello legale. Resta salva la possibilità di provare la conoscenza da parte dei terzi delle limitazioni ai poteri di rappresentanza.

Per quanto concerne le società semplici non agricole, invece, si osserva come le limitazioni originarie siano sempre opponibili ai terzi, mentre le limitazioni successive e le eventuali modificazioni dei poteri di rappresentanza debbono essere portate alla conoscenza dei terzi con mezzi idonei, in difetto non sono loro opponibili, salva comunque la possibilità di fornire la prova che ne fossero a conoscenza.

L'amministrazione è attribuita dal legislatore al socio illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali. Tale regime legale è però derogabile dalla volontà delle parti, pertanto accanto ai soci amministratori vi saranno soci non amministratori.

Gli amministratori possono essere nominati con atto costitutivo o si può indicare nello stesso che gli amministratori verranno nominati con atto separato e successivo.

La revoca degli amministratori nominati con atto costitutivo non ha effetto se non ricorre la giusta causa (art. 2259 primo comma c.c.). L'amministratore revocato potrà adire il Tribunale competente al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza della giusta causa ed il diritto al reintegro nella carica.

La revoca dell'amministratore nominato con atto costitutivo comporta la modifica dello stesso ed è soggetto quindi al voto unanime dei soci, salvo diversa pattuizione sociale.

Ai sensi dell'art. 2259 secondo comma c.c. l'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme sul mandato. Il legislatore attribuisce inoltre a ciascun socio la possibilità di adire il Tribunale competente al fine di ottenere la revoca dell'amministratore per giusta causa (art. 2259 terzo comma c.c.).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La dottrina si è interrogata sull'ammissibilità della nomina ad amministratore di soggetti estranei alla compagine sociale.

Tale domanda trova risposta negativa con riferimento alla società in accomandita semplice (art. 2318 secondo comma c.c.).

In considerazione della responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soci della s.n.c., che opera indipendentemente dalla attribuzione o meno dei poteri amministrativi, nonché dell'assenza di una previsione normativa che obblighi i soci ad amministrare direttamente, si deve rispondere affermativamente a tale questione (con riferimento alle s.n.c.). L'amministratore non socio è sempre revocabile ad nutum (senza giusta causa) anche se nominato con atto costitutivo ed è obbligato a rispettare le direttive dei soci, nell'interesse dei quali può compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale.

Ai soci ai quali non è attribuito il potere amministrativo della società, il legislatore riconosce un potere di controllo sull'attività gestoria: hanno infatti diritto ad ottenere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari, di consultare i relativi documenti e di ottenere il rendiconto degli affari conclusi.

Ai singoli soci non amministratori non spetta ovviamente alcun diritto di impartire direttive vincolanti i soci amministratori relativamente alla conduzione dell'attività sociale. Con riguardo, invece, al gruppo di soci amministratori si osserva come questo possa indirizzare le decisioni dell'amministratore unico nominato con atto separato, poiché tale carica può essergli revocata dal gruppo di amministratori non soci anche in assenza di una giusta causa.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Le modificazioni dell'atto costitutivo

Ai sensi dell'art. 2252 c.c. l'atto costitutivo può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, è fatta salva una diversa pattuizione nell'atto costitutivo.

Il cambiamento della composizione della compagine sociale rientra tra i casi di modificazione dell'atto costitutivo. I fatti che integrano tale cambiamento sono causati dal trasferimento della quota per atti tra vivi o a causa di morte (successione).

Nulla vieta che il consenso al trasferimento della quota sia dato antecedentemente al verificarsi del fatto che porta al trasferimento stesso: ne è un esempio la clausola statutaria che permette libera cessione della quota per atto tra vivi oppure la continuità della società con gli eredi del defunto. La mancata contestazione da parte dei soci dell'esercizio dei diritti di cui alla quota societaria da parte degli eredi o del cessionario equivale, quanto agli effetti, ad un consenso prestato al trasferimento della quota medesima.

Per le s.n.c. (come per le società semplici esercenti attività agricole) è previsto che le modificazioni dell'atto costitutivo seguano il particolare regime della pubblicità legale del Registro delle Imprese ai fini però della opponibilità ai terzi. Si osserva quindi che le modificazioni dell'atto costitutivo sono comunque perfezionate ed efficaci anche in difetto di iscrizione nel Registro Imprese (salvo espressa previsione di legge in senso contrario).

L'atto costitutivo talvolta, come nel caso di trasformazione in società in società di capitali, deroga al regime legale del voto unanime per addivenire alle modifiche dello stesso e sostituisce il più agevole criterio del voto a maggioranza.

La previsione del voto a maggioranza è comunque contemperata dall'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede, nonché dal rispetto della parità di trattamento tra soci.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

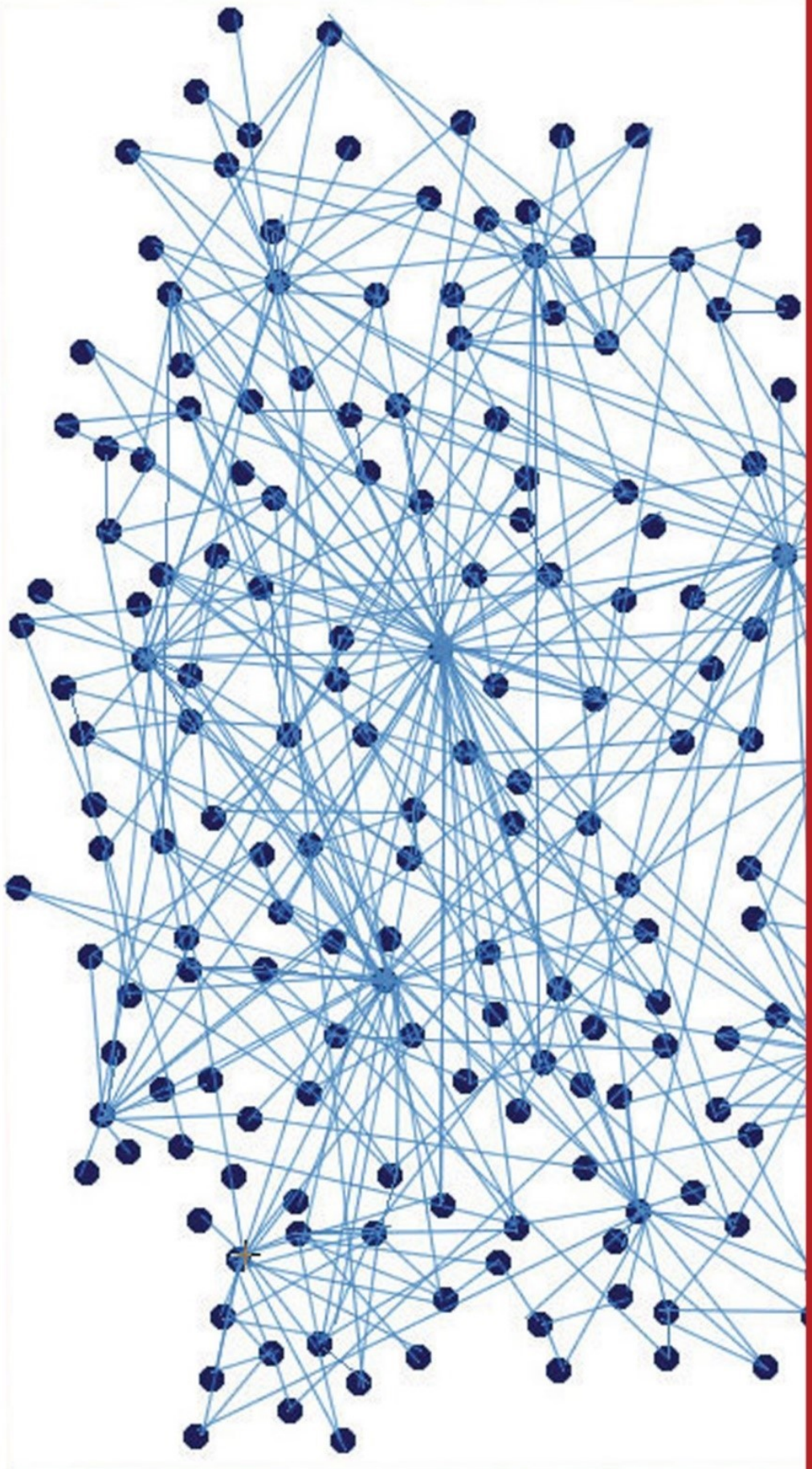
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LO SCIOGLIMENTO DEL SINGOLO RAPPORTO SOCIALE E MORTE DEL SOCIO 3
2. IL RECESSO DEL SOCIO E L'ESCLUSIONE DEL SOCIO 5
3. LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ 8
BIBLIOGRAFIA 11

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Lo scioglimento del singolo rapporto sociale e morte del socio

Evento modificativo del contratto sociale è lo scioglimento dello stesso con riferimento ad uno o più soci a causa di morte, recesso od esclusione.

In tali casi il principio di conservazione della società fa sì che il contratto sociale in capo agli altri soci non venga meno ed è rimessa alla volontà di questi la scelta di dare continuazione al vincolo sociale o scioglierlo.

Il codice civile prevede che anche nel caso estremo in cui la compagine sociale venga meno e resti un solo socio operi il principio di conservazione della società: la società non viene sciolta se entro i sei mesi viene ricostituita la pluralità sociale (art. 2272, n. 4 c.c.).

La ratio della norma è quella di conservare per quanto possibile i valori produttivi costituiti da una impresa operante.

Nell'evenienza della morte del socio il vincolo sociale si scioglie ex lege e sorge un diritto di credito degli eredi ad ottenere la liquidazione della relativa quota a carico della società entro il termine di sei mesi (artt 2284 e 2289).

Se i soci superstiti non sono disposti a sopportare l'ingresso nella società degli eredi del socio defunto, hanno comunque due alternative tra le quali scegliere entro sei mesi dall'accadimento del fatto.

La prima è costituita dallo scioglimento della società, in tale caso gli eredi del socio defunto dovranno attendere il termine delle operazioni di liquidazione della società al fine di partecipare alla ripartizione dell'attivo residuo.

La seconda alternativa è di continuare la società con gli eredi, ammesso però che i soci siano tutti concordi e vi acconsentano anche gli eredi. In tal caso la fonte del loro diritto sarà un atto tra vivi (contratto societario) e non mortis causa (a seguito di successione).

La quota societaria è attribuita agli eredi in proporzione ai diritti ereditari loro spettanti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sono ricorrenti nella prassi la previsione di alcune clausole che regolano la trasmissione della partecipazione sociale.

La prima è la clausola di consolidazione, per la quale si dispone in atto costitutivo o atto successivo che la quota del socio defunto viene attribuita agli altri soci, mentre agli eredi viene corrisposto il valore economico della partecipazione societaria.

La seconda è la clausola di continuazione, per la quale in atto costitutivo o in un atto successivo si dispone che a seguito dell'evento morte del socio gli eredi subentrino automaticamente al defunto nella partecipazione societaria. In tale caso sono escluse di conseguenza la liquidazione della quota e lo scioglimento della società.

La clausola di continuazione può essere di tre tipi:

- facoltativa: vincola i soli soci superstiti e lascia liberi gli eredi circa la determinazione della loro volontà tra la scelta di diventare soci o richiedere la liquidazione della quota;
- obbligatoria: gli eredi hanno l'obbligo di diventare soci e devono prestare a tal fine il loro consenso, in caso di inadempimento dovranno risarcire alla compagine sociale i danni derivanti;
- automatica (o clausola di successione): l'acquisto della qualità di socio è subordinata all'accettazione dell'eredità e si acquista con la qualità di erede, non essendo necessaria altra manifestazione di volontà.

La legittimità delle clausole del secondo e del terzo tipo è negata da alcuni interpreti, sulla base di un eventuale contrasto con il divieto dei patti successori e con il principio per cui l'acquisto della responsabilità illimitata necessita di un espresso consenso.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il recesso del socio e l'esclusione del socio

Il singolo socio può decidere di sciogliere unilateralmente il vincolo sociale che lo lega alla società con l'espressione della sua volontà, con l'esercizio del diritto di recesso (art. 2285 c.c.). Se la società è costituita a tempo indeterminato (o per la durata della vita di uno dei soci), ogni socio può recedere dal contratto societario in qualsiasi momento e non è necessario che ricorra una giusta causa (recesso ad nutum).

Deve essere però esercitato nel rispetto del termine di preavviso, fissato ai sensi dell'art. 2285, terzo comma c.c. in tre mesi, al termine del quale il recesso esplica i suoi effetti.

L'atto costitutivo o un documento successivo possono prevedere delle cause che legittimano l'esercizio del diritto di recesso o lo condizionano al verificarsi di una giusta causa, che consiste solitamente in un fatto ad opera di un socio di una gravità tale da minare la fiducia nello stesso. Il diritto di recesso per giusta causa è previsto per le società costituite a tempo determinato, può essere però previsto anche per società costituite a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità di recedere ad nutum negli altri casi (col rispetto del termine di preavviso).

La giusta causa consiste, per la giurisprudenza, nel verificarsi di situazioni tali da compromettere il rapporto di collaborazione e di fiducia tra i casi. Secondo la dottrina rileverebbero anche le circostanze soggettive inerenti la persona del singolo socio (malattia, trasferimento della residenza per esigenze di lavoro, ecc…).

Il recesso per giusta causa ha effetto dal momento del suo esercizio, differenziandosi pertanto dal recesso ad nutum i cui effetti si esplicano esperito il termine di tre mesi di preavviso.

I soci possono prevedere convenzionalmente ulteriori ipotesi di recesso, ma non possono in alcun modo derogare alla disciplina legale ex art. 2285 c.c.

Il vicolo sociale relativo al singolo socio può venire meno anche per cause di diritto ex art. 2288 c.c. o per volontà degli altri soci ex art. 2286 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

È escluso di diritto il socio che sia stato dichiarato fallito o la cui quota sia stata liquidata ai sensi dell'art. 2270 c.c. su domanda di un creditore personale. In tali casi l'esclusione opera ex lege ed ovviamente non è previsto alcun rimedio giuridico al riguardo.

Il socio può essere escluso per volontà dei soci (ai quali è rimessa la decisione in merito) qualora sussista una delle seguenti cause:

- il socio sia gravemente inadempiente con riguardo agli obblighi di legge o agli obblighi derivanti dal contratto sociale;
- il socio sia stato interdetto o inabilitato;
- il socio sia stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione –anche temporanea- dai pubblici uffici;
- il socio che a titolo di conferimento presta la propria opera o il godimento di una cosa e per impossibilità sopravvenuta non possa prestare la propria opera o sia perito il bene dato in godimento per causa non imputabile agli amministratori;
- il socio che si è obbligato a dare a titolo di conferimento la proprietà di una cosa e questa è perita prima che la proprietà sia passata alla società.

In tali casi la decisione dell'esclusione motivata è deliberata a maggioranza numerica per teste dei soci, non contando ovviamente il socio della cui esclusione si decide. La deliberazione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Questo termine di preavviso è altresì funzionale alla proposizione da parte del socio escluso della proposizione in giudizio della opposizione a tale delibera; il Tribunale infatti può sospenderne l'esecuzione.

L'autorità giudiziaria è chiamata inoltre a decidere in merito all'esclusione di un socio quando la compagine sociale è composta da due soli soci. In questo caso alla proposizione della domanda giudiziale è chiamato il socio che ha interesse all'esclusione dell'altro. L'esclusione ha effetto quando la sentenza del Tribunale è passata in giudicato. Si osserva però come contrattualmente i soci possano deferire tale decisione ad un arbitro prevedendo la cosiddetta clausola compromissoria.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le modalità di liquidazione della quota del singolo socio sono indicate dall'art. 2289 c.c. È previsto che la liquidazione della quota sia effettuato con la corresponsione di una somma di denaro equivalente al valore economico della partecipazione sociale.

Il valore economico della quota è calcolato tenendo presente il valore della situazione patrimoniale della società, attribuendo ai beni il loro valore effettivo e tenuto conto dell'avviamento, degli utili e delle perdite sulle operazioni, nel giorno in cui si verifica lo scioglimento. Non si tiene pertanto conto del valore della società come risultante dal bilancio d'esercizio, che, ad esempio riporta indicati alcune poste finanziarie attive, tra i quali a titolo esemplificativo i crediti, non secondo un valore effettivo, ma secondo un criterio prudenziale.

Il pagamento della quota del socio uscente deve essergli corrisposta entro sei mesi decorrenti dal giorno in cui si verifica lo scioglimento del rapporto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Lo scioglimento della società

Lo scioglimento della società e regolato dagli articoli 2272 e seguenti del codice civile.

L'articolo 2272 c.c. prevede quali cause di scioglimento operanti di diritto al momento nel quale si verificano:

- il decorso del termine previsto in atto costitutivo;
- il conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- la volontà di tutti i soci di sciogliere la società;
- la mancata ricostituzione della pluralità di soci entro i sei mesi dal venire meno della stessa;
- tutte le altre cause previste dal contratto sociale.

La società può essere tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando i soci continuano a compiere le operazioni sociali nonostante sia decorso il tempo di durata previsto in atto costitutivo (ex art. 2273 c.c.).

Al verificarsi di una qualsiasi causa di scioglimento, la società entra nella fase di liquidazione. Attraverso tale fase si provvede al soddisfacimento dei creditori sociali e, se residua dell'attivo, alla sua distribuzione ai soci.

In capo agli amministratori residua il potere di amministrare con riguardo agli affari urgenti, fino a quando non sono presi i provvedimenti necessari alla liquidazione (art. 2274 c.c.).

Il contratto sociale può prevedere le modalità di liquidazione del patrimonio sociale, in difetto della previsione di tale clausola contrattuale, la liquidazione può avvenire nelle modalità concordate dai soci. Se manca altresì il raggiungimento di una volontà comune dei soci sul punto, i soci devono nominare un liquidatore.

In mancanza di accordo su tale punto il liquidatore è nominato dal Tribunale.

I liquidatori possono essere revocati per volontà di tutti i soci ed in ogni caso dal Tribunale per giusta causa su domanda di uno o più soci.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'art. 2276 c.c. gli obblighi e la responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni stabilite per gli amministratori, se non diversamente previsto dalle norme codicistiche (artt. 2277-2283 c.c.) o dal contratto sociale.

I liquidatori possono compiere gli atti necessari per la liquidazione della società e, se non disposto diversamente dai soci, possono vendere anche in blocco i beni sociali, fare transazioni e compromessi. I liquidatori hanno la rappresentanza processuale della società. I liquidatori non possono invece compiere nuove operazioni, in tal caso sono responsabili patrimonialmente e solidalmente per gli affari intrapresi.

Non possono inoltre distribuire i beni sociali fino a quando non siano stati pagati i creditori sociali o non siano state accantonate le somme per farlo.

Se i soci non hanno effettuato il versamento dei conferimenti ancora dovuti, vi sono tenuti al fine di provvedere al pagamento dei debiti sociali se il patrimonio sociale non è sufficiente. I beni conferiti in godimento sono restituiti ai conferenti.

Se tali beni sono periti o si sono deteriorati per causa imputabile agli amministratori è attribuito ai conferenti il diritto di risarcimento del danno a carico del patrimonio sociale.

Ai sensi dell'art. 2282 c.c., estinti i debiti sociali, l'attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti e l'eventuale eccedenza è ripartita tra i soci secondo il medesimo criterio della distribuzione degli utili.

Se il conferimento ha avuto ad oggetto beni diversi dal denaro, la valutazione dello stesso è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto, in difetto della previsione contrattuale è effettuata secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti.

Per le s.n.c. la disciplina dello scioglimento della società è integrato dagli articoli da 2308-2311 c.c. In particolare, tra le cause di scioglimento della società elencate vi è anche la dichiarazione di fallimento (salvo l'attività esercitata non abbia carattere commerciale).

Si osserva inoltre come ai sensi dell'art. 2311 c.c. i liquidatori della s.n.c. debbano redigere il bilancio finale e proporre ai soci il piano di riparto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il bilancio sottoscritto dai liquidatori ed il piano di riparto debbono essere comunicati a mezzo raccomandata ai soci. A questi ultimi è attribuito il diritto di impugnare il bilancio ed il piano di riparto entro un termine di due mesi dalla comunicazione.

Trascorso tale periodo senza che l'impugnazione sia stata proposta, il bilancio ed il piano di riparto si intendono approvati. Con l'approvazione del bilancio i liquidatori sono liberati di fronte ai soci.

I liquidatori chiedono poi la cancellazione della società dal Registro Imprese.

Dal momento della cancellazione della società dal Registro Imprese, i creditori sociali che sono rimasti non soddisfatti possono far valere i loro diritti nei confronti dei soci che rispondono solidalmente ed illimitatamente delle obbligazioni sociali con il proprio patrimonio personale. Se tale insoddisfazione è dipesa dai liquidatori, i creditori sociali possono rivalersi anche verso di questi.

Si ricorda inoltre come entro un anno dalla cancellazione della s.n.c. sia possibile domandarne il fallimento ai sensi dell'art. 10 della Legge Fallimentare (d. Lgs. n.5/2006).

Se la società in nome collettivo è irregolare, ovvero non è mai stata registrata presso il Registro delle Imprese, queste possono essere dichiarate fallite senza limiti di tempo dopo la cessazione dell'attività d'impresa.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

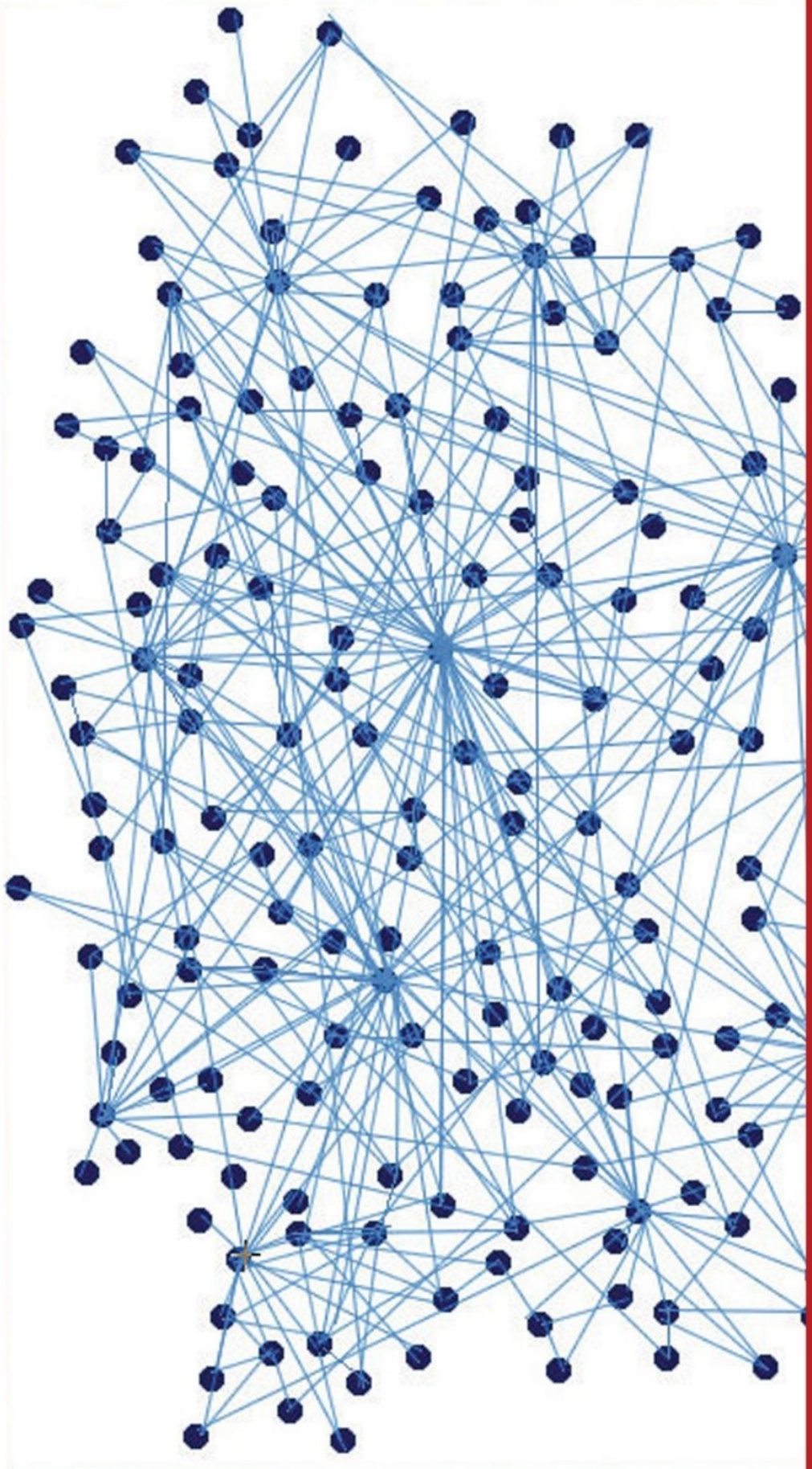
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CARATTERI GENERALI 3

2. L'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ ED I POTERI DEL SOCIO ACCOMANDANTE 5

3. LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE E LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA IRREGOLARE 7

BIBLIOGRAFIA 9

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Caratteri generali

La società in accomandita semplice (artt. 231-2324 c.c.) è una società di persone che si caratterizza per la presenza di due categorie di soci: i soci accomandanti ed i soci accomandatari.

I soci accomandanti sono responsabili per le obbligazioni sociali limitatamente alla sola quota conferita. I creditori sociali non possono vantare pretese alcune invece circa la quota di conferimento promessa e mai versata dai soci accomandanti.

I soci accomandatari, invece, sono responsabili solidalmente e illimitatamente con il proprio patrimonio personale per le obbligazioni sociali. E' attribuita esclusivamente a questi l'amministrazione della società.

La funzione della società in accomandita semplice è quella di consentire la formazione di una società nella quale l'interesse di parte della compagine sociale (soci accomandatari) coincide con la gestione personale dell'impresa ed interesse di altra parte dei soci è quella di ottenere dal finanziamento dell'impresa una remunerazione del capitale investito (soci accomandanti), rischiando il solo la quota conferita e senza doversi occupare personalmente della gestione dell'impresa.

Con tale tipo di società di persone è possibile esercitare attività commerciale esimendo però i soci accomandanti dalla procedura fallimentare.

Si osserva innanzitutto come alle società in accomandita semplice (s.a.s.) sia applicabile la disciplina delle società in nome collettivo (artt. 2291-2312 c.c.) in quanto compatibili.

L'atto costitutivo è soggetto alla iscrizione nel Registro delle Imprese.

Con tale registrazione alla società è applicabile il regime legale proprio dettato dagli articoli 2313-2324 c.c., in difetto, invece, la società è irregolare e seppur validamente costituita delle obbligazioni sociali saranno ritenuti responsabili tutti i soci personalmente ed illimitatamente ai sensi dell'art. 2297 c.c. ad eccezione dei soci accomandanti i quali rispondono limitatamente alla loro quota, salvo abbiano partecipato alle operazioni sociali (art. 2317 c.c.).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In atto costitutivo devono essere indicati espressamente i soci accomandatari ed i soci accomandanti (art. 2316 c.c.).

In particolare, il nome di almeno un socio accomandatario deve comparire nella ragione sociale della s.a.s.; non possono comparire nella ragione sociale della società i soci accomandanti, al fine di non indurre in errore i terzi che entrano in contatto con la società.

Ai sensi dell'art. 2314 secondo comma c.c. il socio accomandante il quale consente che il suo nome sia inserito nella ragione sociale, risponde illimitatamente e solidalmente nei confronti dei terzi con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali.

Tale fatto non esplica invece effetti interni alla società, non comportando l'attribuzione dei poteri amministrativi al socio accomandante che dia l'assenso all'inserimento del proprio nome nella ragione sociale. I poteri amministrativi restano prerogativa dei soci accomandatari.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. L'amministrazione della società ed i poteri del socio accomandante

Ai sensi dell'art. 2318, secondo comma c.c., l'amministrazione della s.a.s. può essere conferita esclusivamente ai soci accomandatari.

La nomina degli amministratori può essere indicata in atto costitutivo o con atto successivo, in tale ultimo caso sono applicabili le norme dettate dal codice civile in tema di mandato.

Nel caso di nomina con atto separato ed in ogni caso in difetto di nomina in atto costitutivo, l'art. 2319 c.c. prevede che per la nomina e la revoca degli amministratori sia necessario il consenso dei soci accomandatari e l'approvazione di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale sottoscritto da tale categoria di soci.

È fatto divieto al socio accomandante di compiere atti di amministrazione, di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. In difetto di tale astensione, il socio accomandante assume la responsabilità patrimoniale illimitata solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

Tale fatto costituisce inoltre grave inadempienza delle obbligazioni che derivano dal contratto sociale, potendo determinare l'esclusione del socio dalla società ai sensi dell'art. 2286 c.c.

Il divieto di immistione del socio accomandante nella gestione della società è temperato dalla previsione per la quale tale categoria di soci può:

- prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori; è esclusa la possibilità che i soci accomandanti prestino la propria opera in autonomia;
- solo se consentito dall'atto costitutivo: dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni, compiere atti di ispezione e di sorveglianza (art. 2320 secondo comma c.c.).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'art. 2320 terzo comma c.c. ai soci accomandanti è riconosciuto sempre il diritto:

- avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite;
- di controllare l'esattezza dei documenti contabili citati al punto precedente, avvalendosi anche della consultazione dei libri e degli altri documenti della società.

Carattere peculiare acquista la disciplina del trasferimento delle quote sociali di socio accomandante e di socio accomandatario.

Il trasferimento della quota del socio accomandatario può avvenire con il solo consenso di tutti i soci costituenti la compagine sociale. In caso di trasmissione per morte del socio accomandatario sarà necessario il consenso dei soci superstiti ed il consenso degli eredi.

Il trasferimento della quota del socio accomandante è invece subordinato negli atti tra vivi dal consenso di tutti i soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale, al contrario, negli atti mortis causa la quota del socio accomandante è liberamente trasferibile, e quindi non è necessario il consenso dei soci.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Lo scioglimento della società in accomandita semplice e la società in accomandita irregolare

La disciplina delle cause di scioglimento della società in accomandita semplice è dettata dall'art. 2323 c.c.

Tale articolo richiama espressamente quali cause di scioglimento della s.a.s. l'art. 2308 c.c., relativo alle cause di scioglimento della società in nome collettivo, il quale a sua volta richiama espressamente l'articolo 2272 c.c.

In considerazione della necessaria sussistenza nella s.a.s. delle due categorie di socio accomandatario e di socio accomandante, il predetto articolo prevede che nel caso in cui la compagine sociale risulti formata solo da soci accomandatari o accomandanti, il contratto sociale si sciolga se entro sei mesi dal verificarsi di tale fatto non sia sostituito il socio della categoria venuta meno.

In particolare, nel caso in cui vengano a mancare tutti gli accomandatari, per il periodo semestrale gli accomandanti nominano un amministratore provvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, tale amministratore non assume però la qualità di socio accomandatario.

Da ciò consegue che non sarà responsabile per le obbligazioni sociali, eccetto nel caso in cui sia un socio accomandante e compia atti di straordinaria amministrazione.

Nel caso in cui entro i sei mesi non sia ricostituita la categoria del socio mancante ed in difetto di messa in liquidazione della società, se la rimanente compagine sociale è formata da almeno due soci, la società diventa una società in nome collettivo irregolare.

Per quanto concerne il procedimento di liquidazione e le modalità di cancellazione della società dal Registro delle Imprese, per espresso richiamo effettuato dall'art. 2315 c.c., è applicabile alla s.a.s. la disciplina dettata per le società in nome collettivo dagli articoli 2309-2312 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si precisa però che ai sensi dell'art. 2312 c.c., una volta cancellata la società dal Registro delle Imprese, i creditori insoddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci accomandanti nei limiti di quanto da questi ricevuto in liquidazione.

La società in accomandita semplice il cui atto costitutivo non è stato iscritto nel Registro delle Imprese, è irregolare.

Ai sensi dell'art. 2317 c.c., fino a quando la società non è iscritta nel Registro delle Imprese ed opera sotto una denominazione sociale che esplicita la scelta della forma organizzativa di s.a.s., ai rapporti tra la società ed i terzi si applica la disciplina prevista dall'art. 2297 c.c., resta salva la responsabilità patrimoniale limitata dei soci accomandanti alla quota conferita per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

I soci accomandanti diventano illimitatamente responsabili delle obbligazioni sociali nel solo caso in cui abbiano preso parte a tali operazioni.

Il divieto di immistione del socio accomandante nella s.a.s. irregolare ha carattere assoluto.

Nemmeno il rilascio di una procura speciale per singoli affari sarebbe in questo caso sufficiente ad esonerare l'accomandante dalla responsabilità illimitata verso i terzi per le obbligazioni sociali.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

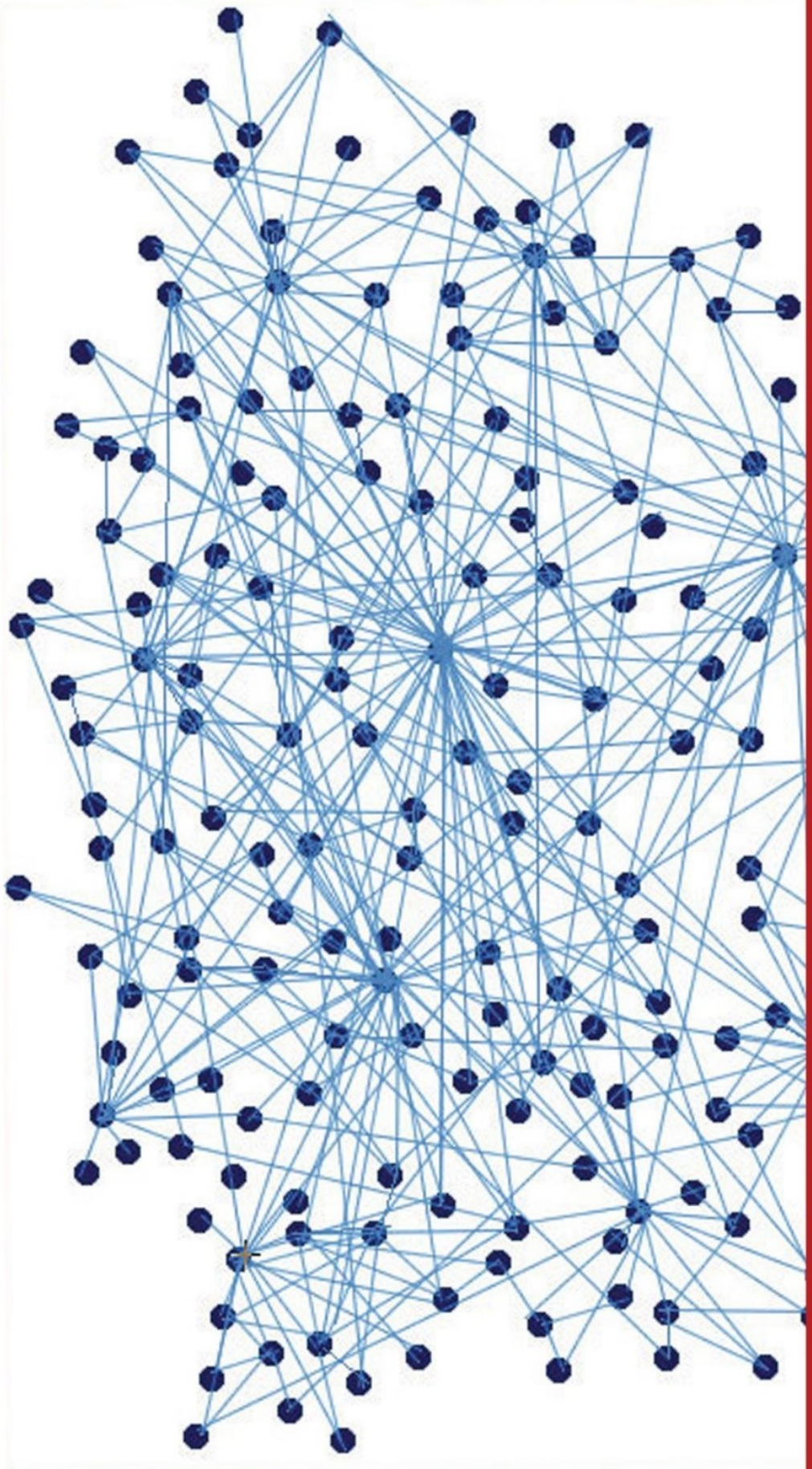
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. NOZIONI E CARATTERISTICHE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI 3
2. I DIVERSI MODELLI DI SOCIETÀ PER AZIONI 5
3. I PRINCIPALI INTERVENTI LEGISLATIVI 7
BIBLIOGRAFIA 9

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Nozioni e caratteristiche della società per azioni

La società per azioni (S.p.A.) costituisce il paradigma della società di capitali.

La S.p.A. è dotata di autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il proprio patrimonio.

In ciò si distingue dalla società in accomandita per azioni, nella quale i soci accomandatari sono responsabili solidalmente e personalmente con la società per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

Nella S.p.A. la partecipazione sociale è costituita da azioni. In ciò si distingue dalle S.r.l., le cui partecipazioni sociali sono costituite da quote che in alcun modo possono essere rappresentate da azioni.

I caratteri essenziali della S.p.A. si possono così sintetizzare: l'ordinamento le riconosce personalità giuridica, gode di autonomia patrimoniale perfetta e la responsabilità patrimoniale dei soci è circoscritta alla partecipazione societaria, ha una organizzazione corporativa, le quote di partecipazione sono costituite dalle azioni.

La conseguenza immediata dell'attribuzione di personalità giuridica alla S.p.A. consiste nel distinguere la società dai suoi soci come soggetto di diritto. E' la società ad essere qualificata come imprenditore, oggetto di applicazione del diritto di impresa, non i suoi soci.

La società gode di autonomia patrimoniale perfetta: il patrimonio della società è esclusivo di questa ed il patrimonio personale dei soci non costituisce garanzia sussidiaria per l'adempimento delle obbligazioni sociali.

Delle obbligazioni contratte dalla società è responsabile la S.p.A. medesima.

Per quanto riguarda i soci, il rischio d'impresa grava esclusivamente sulle partecipazioni da loro possedute (azioni).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In conseguenza del fatto che il patrimonio della S.p.A. costituisce l'unica garanzia per l'adempimento delle obbligazioni sociali, il legislatore ha predisposto una particolare disciplina per garantire la consistenza del patrimonio sociale, nonché puntuali norme relative alla informativa periodica patrimoniale ed economica della società.

Il legislatore ha inoltre previsto che la S.p.A. abbia una struttura corporativa, vale a dire siano presenti necessariamente alcuni organi: l'assemblea, l'organo di gestione e l'organo di controllo.

La distinzione tra tali organi della società e le persone dei soci permane; infatti, non essendo affidato ai soci alcun potere diretto amministrativo o di controllo, possono contribuire esclusivamente con l'esercizio del diritto di voto in assemblea alla designazione dei membri degli organi amministrativi e di controllo.

I componenti di questi organi, che si ribadisce sono distinti dalle persone dei soci, sono responsabili personalmente – sia civilmente, sia penalmente -dei danni cagionati alla società a seguito della violazione dei doveri caratterizzanti l'esercizio delle rispettive funzioni.

Ultimo dato giuridico tipico della S.p.A. è la partecipazione sociale costituita da azioni.

L'art. 2348, primo comma c.c. enuncia il principio per il quale le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti (resta salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo).

La determinazione del numero di azioni avviene secondo la logica matematica per la quale il capitale sociale sottoscritto viene diviso per il valore predeterminato delle azioni.

Astraendo le qualità dell'azione dalla persona del socio è garantita la libera trasferibilità del titolo e ne viene agevolata la circolazione, nel qual caso trova applicazione la disciplina dei titoli di credito.

Si sottolinea inoltre come l'omogeneità delle azioni, che porta ad affermare il carattere fungibile del bene, fa sì che tale partecipazione sia particolarmente adatta ad essere trasferita nel mercato di borsa valori.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. I diversi modelli di società per azioni

Alla luce di quanto fino ad ora osservato è evidente come la S.p.A. sia il modello organizzativo societario più adeguato per le imprese di grandi dimensioni.

La S.p.A. infatti dà l'opportunità agli imprenditori di attrarre grandi quantità di capitali sul mercato, grazie anche agli investimenti dei piccoli risparmiatori, che sono incentivati ad investire in partecipazioni azionarie remunerativi e facilmente trasferibili sul mercato. Inoltre, è da sottolineare come il trasferimento delle partecipazioni azionarie da risparmiatore a risparmiatore non sia di detrimento agli interessi imprenditoriali della S.p.A., non influendo infatti sull'operatività dell'impresa.

Nella pratica si riscontra però come le S.p.A. di grandi dimensioni che ricorrono al pubblico risparmio per la raccolta del capitale di rischio è una eccezione e non una regola.

Nella maggior parte dei casi le S.p.A. che operano nel contesto economico hanno una ristretta base azionaria ed hanno dimensioni medio-piccole.

Non si può affermare che si tratti di un fenomeno patologico o di abuso del modello legale, il legislatore consente tramite l'esercizio della autonomia statutaria di "cucire su misura" dell'azienda la società per azioni.

Ciò comporta ovviamente l'utilizzazione di un modello legale per assolvere a esigenze economiche differenti con la conseguenza di rilevare problematiche peculiari per ciascuna situazione esaminata.

Nelle S.p.A. a base azionaria ristretta la questione problematica ha ad oggetto la tutela dei soci di minoranza nonché dei creditori soggetti a possibili abusi dei soci che detengono la maggioranza del capitale, il cui voto sarà stato determinante per l'elezione degli amministratori.

Nelle S.p.A. che invece fanno ricorso al pubblico risparmio la situazione che si presenta è rovesciata. Ci saranno infatti pochi azionisti imprenditori attivi e competenti a fronte di una massa di azionisti investitori detentori di partecipazioni parcellizzate.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Questi ultimi azionisti sono generalmente disinteressati alla vita societaria, ne consegue che fisiologicamente vi sarà un gruppo minoritario di controllo, costituito dagli azionisti imprenditori, che saranno determinanti per la nomina degli organi necessari della società e costituiranno loro espressione.

Non si può fare a meno di sottolineare come in un contesto così delineato, gli strumenti previsti dal legislatore di autotutela dei soci contro gli abusi della maggioranza, restano del tutto inoperativi in difetto di interesse da parte di chi dovrebbe azionarli.

In tale contesto gli interessi da tutelare sono altresì di carattere pubblico: garantire il corretto funzionamento dell'intero mercato azionario e tutelare il pubblico indifferenziato dei potenziali investitori.

Dopo la riforma avvenuta con il D. Lgs. 6/2003 la disciplina delle S.p.A. si può schematizzare con la vigenza di alcune regole valide per tutte le S.p.A., norme relative alle società chiuse (che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), norme applicabili esclusivamente alle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio (di conseguenza applicabili anche alle società non quotate con azionariato diffuso ed alle società quotate – ferma restando l'applicazione alternativa di leggi speciali), norme applicabili alle sole società quotate.

In conseguenza della disciplina legislativa così delineata è possibile distinguere all'interno del tipo organizzativo societario S.p.A. tre sottotipi organizzativi: la società chiusa, la società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio e la società quotata.

La categoria delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio comprendono le società con azioni quotate e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante (ex art. 2325 bis c.c.).

La ratio della differente disciplina dettata per questo tipo di S.p.A. è quella di agevolare la transizione da società chiusa a società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, che comporta la applicazione della disciplina del T.U.F., maggiormente rigorosa rispetto alla disciplina delle società non quotate.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. I principali interventi legislativi

La disciplina delle S.p.A. si è evoluta dalla concezione originaria del 1942 sia sulla spinta della necessità di colmare le lacune del codice stesso, sia per dare attuazione alle direttive comunitarie volte alla armonizzazione della disciplina nazionale delle società di capitali.

Il primo intervento legislativo di rilievo è costituito dalla legge 216/1974 e successivi decreti delegati del 1975, con il quale è introdotta la società quotata, istituisce la CONSOB, organo di controllo pubblico alla quale è affidato il compito di garantire la completezza e la veridicità dell'informazione societaria e sulla scia del medesimo intento legislativo si introduce l'obbligo di certificazione del bilancio da parte di una società di revisione autonoma.

Inoltre, a fronte della riconosciuta esistenza di categorie di investitori il cui obiettivo è ottenere un profitto disinteressandosi però delle vicende societarie, il legislatore introduce le azioni di risparmio, una categoria di azioni prive di diritto di voto e caratterizzate da una più alta remunerazione patrimoniale.

Alla tutela degli azionisti investitori si affianca la consapevolezza da parte del legislatore di prevedere norme volte a garantire l'efficienza e la trasparenza del mercato di capitale di rischio. A partire dal 1983 vengono introdotti nell'ordinamento giuridico le S.I.M. (società di intermediazione mobiliare), organismi di investimento collettivo quali fondi comuni, fondi pensione, S.I.C.A.V. – società di investimento a capitale variabile - nonché peculiari norme relative alla offerta al pubblico di valori mobiliari e di trasferimento di partecipazioni di controllo di società quotate.

È però nel 1998 che il legislatore introduce il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.) – D. Lg.s n. 58 del 24 febbraio 1998, entrato in vigore il primo luglio 1998, data dalla quale la previgente normativa in materia non è stata più applicata.

L'obiettivo principale di tale riforma si può sintetizzare nello stimolare l'afflusso del risparmio gestito dagli investitori istituzionali nazionali ed esteri (quali fondi comuni, fondi pensione, società di assicurazione) che svolgono un ruolo di minoranza attiva nelle società partecipate attraverso l'esercizio di voto e degli altri diritti riconosciuti alle minoranze.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Chiude – per il momento – l'escursus dell'evoluzione legislativa della materia in oggetto la riforma D. Lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003, con il quale si è rinnovata la disciplina generale delle società di capitali.

Obiettivo di tale riforma è stata la semplificazione della disciplina delle società di capitali e – dotando le stesse di una maggiore autonomia statutaria – rendere più competitive le imprese italiane favorendone anche l'accesso ai mercati nazionali ed internazionali di capitali.

Tra le varie innovazioni apportate dal legislatore, si segnala in questa sede l'introduzione della S.p.A. unipersonale a responsabilità limitata, la previsione di nuove categorie speciali di azioni, la separazione del controllo sull'amministrazione dalla revisione legale dei conti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

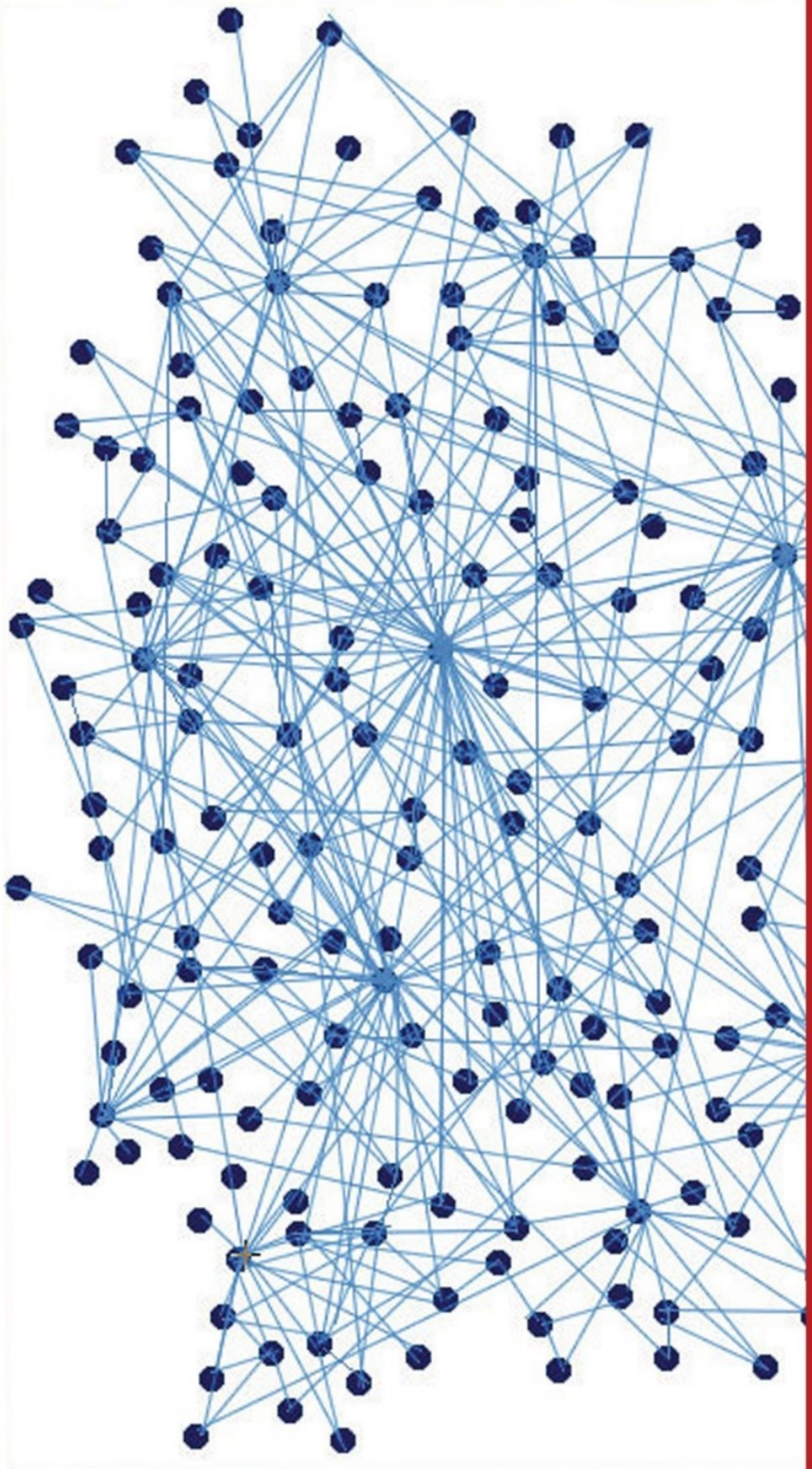
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. L'ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO 3
2. IL CONTROLLO NOTARILE E L'ISCRIZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE .. 5
3. LE OPERAZIONI COMPIUTE PRIMA DELL'ISCRIZIONE 6
BIBLIOGRAFIA 8

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. L'atto costitutivo e lo statuto

Nel procedimento di costituzione della S.p.A. è possibile individuare due fasi: la stipula dell'atto costitutivo che prende la forma dell'atto pubblico e la iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.

Con l'espletamento di tale ultima formalità la S.p.A. acquista personalità giuridica e viene ad esistenza.

Si osserva come sia stata abolita la fase di omologazione dell'atto costitutivo da parte dell'autorità giudiziaria e sia stata demandata al Notaio la funzione di controllo dell'atto.

La S.p.A. può essere costituita per contratto o per atto unilaterale ad opera di un solo socio fondatore.

Ai sensi dell'art. 2328 secondo comma c.c. l'atto costitutivo deve prendere la forma dell'atto pubblico, in difetto di tale requisito la sanzione comminata è la nullità ex art. 2332 primo comma c.c.

Quanto al profilo del contenuto, l'art. 2328 secondo comma c.c. lo esplicita analiticamente; in questa sede si richiama integralmente il contenuto dell'articolo citato omettendone la mera ripetizione.

Si osserva però come l'indicazione dell'oggetto abbia particolare rilievo giuridico in quanto in conseguenza della tipologia di attività economica svolta può trovare applicazione una particolare disciplina giuridica.

Con riguardo invece alla durata della società, la disciplina attualmente vigente ammette che la società si possa costituire a tempo indeterminato.

Il contenuto dell'atto costitutivo è arricchito da quanto previsto nel cosiddetto statuto, il quale ha ad oggetto le norme relative al funzionamento della società.

Ai sensi dell'art. 2328 terzo comma c.c. lo statuto è parte integrante dell'atto costitutivo, ne consegue che anch'esso deve essere redatto in forma di atto pubblico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'art. 2328 ultimo comma c.c. in caso di contrasto tra clausole dell'atto costitutivo e statutarie prevalgono queste ultime.

Il capitale minimo necessario per la costituzione di una S.p.A. è stato fissato dal legislatore nella somma di euro 50.000,00, salvo la previsione di leggi speciali che indicano un ammontare minimo di capitale sociale più elevato in considerazione della peculiarità della attività imprenditoriale esercitata (i.e.: società bancarie e finanziarie artt. 14 e 106 T.U.B., società di gestione del risparmio art. 34 T.U.F., società di intermediazione immobiliare art .19 T.U.F.).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il controllo notarile e l'iscrizione dell'atto costitutivo nel registro delle imprese

Benché la S.p.A. acquisti personalità giuridica con la sola iscrizione dell'atto costitutivo presso il Registro delle Imprese, il legislatore riconosce all'atto una certa efficacia prima della iscrizione.

Innanzitutto, l'atto costitutivo che ha natura contrattuale vincola le parti sino al momento della iscrizione dell'atto costitutivo presso il Registro delle Imprese, salvo risulti successivamente che non si possa costituire la società per fatti estranei alla loro volontà.

Prova ne è il fatto che la somma relativa ai conferimenti da effettuarsi in denaro depositata ai sensi di legge su un conto corrente anteriormente al momento dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese resta vincolata fino al momento della predetta iscrizione.

Al deposito dell'atto costitutivo, invece, è obbligato a procedervi il Notaio entro venti giorni dalla data di stipula.

L'ufficio competente a ricevere tale deposito è il Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della società.

Nel caso in cui a tale obbligo il Notaio non provveda, è compito degli amministratori supplire a questa mancanza, in difetto ogni socio può provvedervi a spese della società.

In questa sede si dà atto del fatto che l'obbligatorietà del giudizio di omologazione del tribunale in sede di costituzione è stato soppresso dal legislatore nel 2000.

Il controllo di legalità è pertanto affidato al Notaio che redige l'atto costitutivo.

Il controllo di legalità riveste sia la forma, sia la sostanza dell'atto, poiché è volto ad accertare la conformità dell'atto costitutivo alla disciplina normativa.

Da quanto esposto consegue che nel caso in cui il Notaio accerti che l'atto costitutivo della S.p.A. si ponga in contrasto con l'ordine pubblico, il buon costume o norme relative alla disciplina della S.p.A. aventi carattere imperativo, il Notaio dovrà rifiutare di procedere all'iscrizione presso il Registro delle Imprese.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Le operazioni compiute prima dell'iscrizione

Qualora il controllo di legalità abbia un esito positivo, il Notaio redige l'atto costitutivo e procede alla richiesta di iscrizione presso il Registro delle Imprese, che svolge un controllo di regolarità formale della documentazione.

Come si è già avuto modo di affermare, con l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese la società acquista personalità giuridica (art. 2331 primo comma c.c.).

Prima di tale iscrizione è vietata l'emissione di azioni.

Inoltre, non possono essere oggetto di offerta al pubblico, salvo il caso in cui la costituzione della società avvenga per pubblica sottoscrizione ai sensi dell'art. 2331 quinto comma c.c.

Il trasferimento della partecipazione azionaria prima dell'iscrizione segue le regole della cessione del contratto.

Si osserva come ai sensi dell'art .2331 secondo comma c.c. delle operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione siano illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito.

Nel caso di costituzione di S.p.A. per pubblica sottoscrizione i promotori sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni contratte per costituire la società.

La responsabilità per tali operazioni è poi a carico dell'unico socio fondatore, in caso di pluralità di soci fondatori, ricade tra quelli che hanno autorizzato o consentito il compimento dell'operazione (art. 2331 secondo comma c.c.).

La società è responsabile per le sole operazioni necessarie per la costituzione qualora l'atto costitutivo abbia previsto che tali spese siano a carico della società, indicandone l'importo totale approssimativo.

È lasciata alla libera determinazione della società se accollarsi o meno le spese sostenute e non necessarie per la costituzione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In tal caso, infatti, l'operazione deve essere approvata, anche se non esplicitamente, affinché la società ne risponda patrimonialmente, ferma restando la responsabilità patrimoniale dei soggetti agenti e configurando l'ipotesi di accollo cumulativo ex art. 2331 terzo comma c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

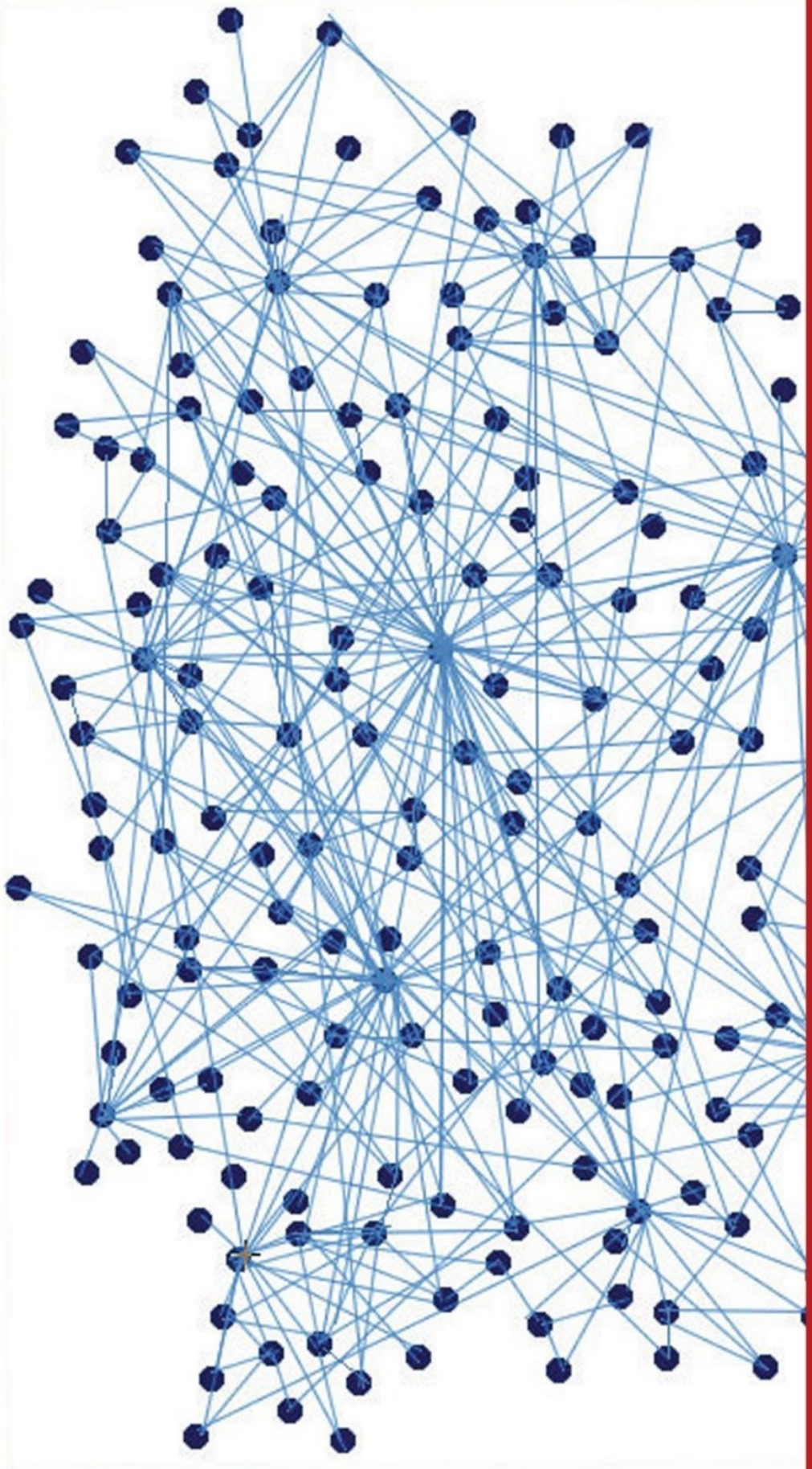
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA NULLITÀ DELLA SOCIETÀ PER AZIONI 3
2. I CONFERIMENTI: DEFINIZIONE GENERALE E CONFERIMENTI IN DENARO 4
3. I CONFERIMENTI DIVERSI DAL DENARO 6
4. GLI ACQUISTI PERICOLOSI 8
BIBLIOGRAFIA 10

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La nullità della società per azioni

L'atto costitutivo della S.p.A. nella fase anteriore alla sua iscrizione nel Registro delle imprese e un contratto che produce effetti esclusivamente tra le parti e segue la disciplina generale dei contratti di diritto privato. In particolare, con riguardo ai casi di nullità dello stesso, trova applicazione la disciplina dettata dagli articoli 1418 ss. C.c., resta salva l'applicazione delle norme di cui agli articoli 1420 e 1446 c.c.

Qualora il contratto affetto da nullità sia già stato iscritto nel Registro delle Imprese trova applicazione la specifica disciplina dettata dall'art. 2332 c.c., la quale sanziona tale invalidità con lo scioglimento della società (la quale, si ricorda, è venuta ad esistenza ed ha acquisito personalità giuridica con l'iscrizione presso il Registro delle Imprese).

Le cause della nullità della società sono tipiche e consistono:

- nella mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico;
- nella illiceità dell'oggetto sociale;
- nella mancanza nell'atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazione della società o i conferimenti o l'ammontare del capitale sociale o l'oggetto sociale.

La nullità della società può essere dichiarata solamente in forza di provvedimento dell'autorità giudiziaria.

La sentenza di dichiarazione della nullità della S.p.A. pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della stessa successivi all'iscrizione del provvedimento nel Registro delle Imprese.

Non ha quindi effetto retroattivo. Opera esclusivamente per il futuro (ex nunc).

Inoltre, i soci non sono liberati dall'obbligo di effettuare i conferimenti fino a quando i creditori sociali non sono soddisfatti.

La sentenza dichiarativa di nullità della S.p.A. nomina i liquidatori.

Lo scioglimento della società segue poi la normale disciplina dello scioglimento della S.p.A.

Ai sensi dell'art. 2332, quinto comma c.c. la nullità della S.p.A. è sanabile.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. I conferimenti: definizione generale e conferimenti in denaro

I conferimenti sono i contributi dei soci che costituiscono il patrimonio iniziale della società. La loro funzione è di fornire alla società l'iniziale patrimonio di rischio indispensabile allo svolgimento dell'attività d'impresa.

La disciplina dei conferimenti nelle S.p.A. è stata elaborata dal legislatore con due obiettivi: garantire l'effettivo versamento dei conferimenti promesso dai soci e garantire che il valore assegnato dai soci ai conferimenti sia reale e veritiero e che non si concretizzi la situazione per la quale i conferimenti sono inferiori all'ammontare del capitale sociale. Tale situazione trarrebbe in inganno i creditori, per il quali il capitale sociale costituisce una garanzia primaria di adempimento delle obbligazioni assunte dalla S.p.A.

Nel caso di conferimenti costituiti da somme di denaro, il legislatore dispone che dei conferimenti in denaro, prima della iscrizione della società nel Registro delle Imprese, sia versata una quota non inferiore al 25% degli stessi e, nel caso di società unipersonale, dell'intero ammontare.

Ciò al fine di evitare che la società costituita disponga esclusivamente di crediti verso i soci.

Si sottolinea poi come le azioni non interamente liberate siano trasferibili, a condizione che siano nominative e che dal titolo risultino i versamenti ancora dovuti (art. 2354 terzo comma n. 4 c.c.).

In caso di trasferimento di tali titoli, l'obbligo di versamento dei conferimenti residui è a carico sia del cessionario che del cedente il titolo azionario (art. 2356 c.c.).

La responsabilità del cedente è però sussidiaria e temporanea, permane infatti per tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci.

Il legislatore prevede poi una particolare disciplina per il caso di mora del socio con riguardo al pagamento delle quote dovute.

Ai sensi dell'art. 2344 c.c. la società può vendere coattivamente le azioni del socio moroso.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La procedura inizia con la pubblicazione della diffida ad adempiere rivolta al socio moroso nella Gazzetta Ufficiale. Decorsi quindici giorni da tale pubblicazione, in difetto di adempimento del socio, gli amministratori offrono le azioni agli altri soci in proporzione della loro partecipazione e per un prezzo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti.

In mancanza di offerte le azioni possono essere vendute a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati. Se la vendita non ha esito positivo, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse. Resta salvo il risarcimento di maggiori danni.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. I conferimenti diversi dal denaro

La disciplina dei conferimenti nella S.p.A. si differenzia da quella delle società di persone in quanto non tutti i conferimenti diversi dal denaro sono ammessi.

La ratio è da ricercare nel fatto che nella S.p.A. l'unica fonte di garanzia per gli adempimenti degli obblighi sociali è il patrimonio sociale.

Non è possibile, pertanto, conferire nella S.p.A. la prestazione di opera e servizi.

Per quanto riguarda invece il conferimento di beni in natura o di crediti, il legislatore richiede che le azioni corrispondenti a tali conferimenti siano integralmente liberate al momento della sottoscrizione (ex art. 2342 terzo comma c.c.).

I conferimenti diversi dal denaro sono oggetto di un procedimento di valutazione, il quale ha la finalità di evitare che sia sopravvalutato il valore degli stessi, deve infatti essere attribuito loro il valore reale.

È a carico del socio conferente un bene diverso dal denaro l'obbligo di presentare una relazione giurata di stima, elaborata da un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società.

L'esperto ha il compito di attestare che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sopraprezzo. La relazione di stima deve essere allegata all'atto costitutivo, con il quale resta depositato presso il Registro delle Imprese.

Entro centottanta giorni dalla costituzione della società, gli amministratori devono controllare le relazioni di stima e verificare il valore dei conferimenti.

Se sussistono motivi fondati, gli amministratori debbono provvedere alla revisione della stima ed i titoli azionari corrispondenti non possono essere ceduti.

Si osserva però che, nel caso in cui il valore del conferimento in natura risulti già da altre fonti o criteri in modo attendibile, il procedimento di stima viene meno (art. 2343-ter c.c.)

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Un esempio ne è il conferimento di titoli quotati nel mercato dei capitali (azioni ed obbligazioni).

Resta comunque salva la possibilità per gli amministratori di richiedere una nuova valutazione dei conferimenti in natura nel caso in cui ritengano inattendibile il valore a questi attribuito. Si pensi al caso dell'esperto che ha redatto la relazione di stima, ma non vantasse i requisiti di professionalità ed indipendenza necessari per redigere una relazione oggettiva.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Gli acquisti pericolosi

Si è riscontrato nella pratica come l'acquisto da parte della società di beni appartenenti ad alcuni soggetti, in primis i soci, nascondesse in realtà il conferimento di beni diversi dal denaro con un meccanismo giuridico elusivo del procedimento di stima.

Attualmente è in vigore una particolare procedura di autorizzazione relativa agli acquisti della società di beni o crediti appartenenti a promotori, fondatori, soci ed amministratori.

È infatti necessario che il corrispettivo pattuito sia pari o superiore al decimo del capitale sociale e che l'acquisto sia compiuto nei due anni dall'iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

L'acquisto è sottoposto alla preventiva autorizzazione della assemblea ordinaria.

Il cedente deve presentare inoltre una relazione o la documentazione che comprovi il fatto che il bene non ha un valore inferiore al corrispettivo pattuito, evitando così il pericolo di sopravvalutazione del bene.

La delibera, alla quale è allegata la relazione di stima o documentazione alternativa, è sopposta al regime di pubblicità legale.

La disciplina appena descritta non è applicabile in alcuni casi specifici di esenzione.

Il primo caso di esenzione è costitutivo dagli acquisti che si compiono sui mercati regolamentati o sotto il controllo della autorità giudiziaria o amministrativa, va da sè infatti che in tali casi il prezzo di acquisto è quello ufficiale ed in ogni caso sottoposto a controllo.

Vi è esenzione altresì nel caso di acquisti effettuati a condizioni normali nell'ambito delle operazioni correnti della società, eseguite cioè nella gestione ordinaria dell'impresa.

Ai sensi dell'art. 2345 c.c. l'atto costitutivo della società può prevedere l'obbligo per i soci di effettuare prestazioni accessorie e diverse dall'apporto in denaro.

La prestazione accessoria può avere ad oggetto la prestazione di attività lavorativa o professionale, l'obbligo di effettuare forniture periodiche di materie o di merci.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dalla peculiarità di tali prestazioni consegue che le relative azioni con prestazioni accessorie sono nominative e non possono essere cedute in difetto del consenso degli amministratori.

Salva diversa previsione statutaria, gli obblighi accessori possono essere modificati esclusivamente con il consenso unanime dei soci.

Gli interpreti ritengono che l'adempimento di tali prestazioni accessorie si risolva nell'adempimento di obbligazioni sociali, con l'applicazione della relativa disciplina (per esempio l'art. 2344 c.c.).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

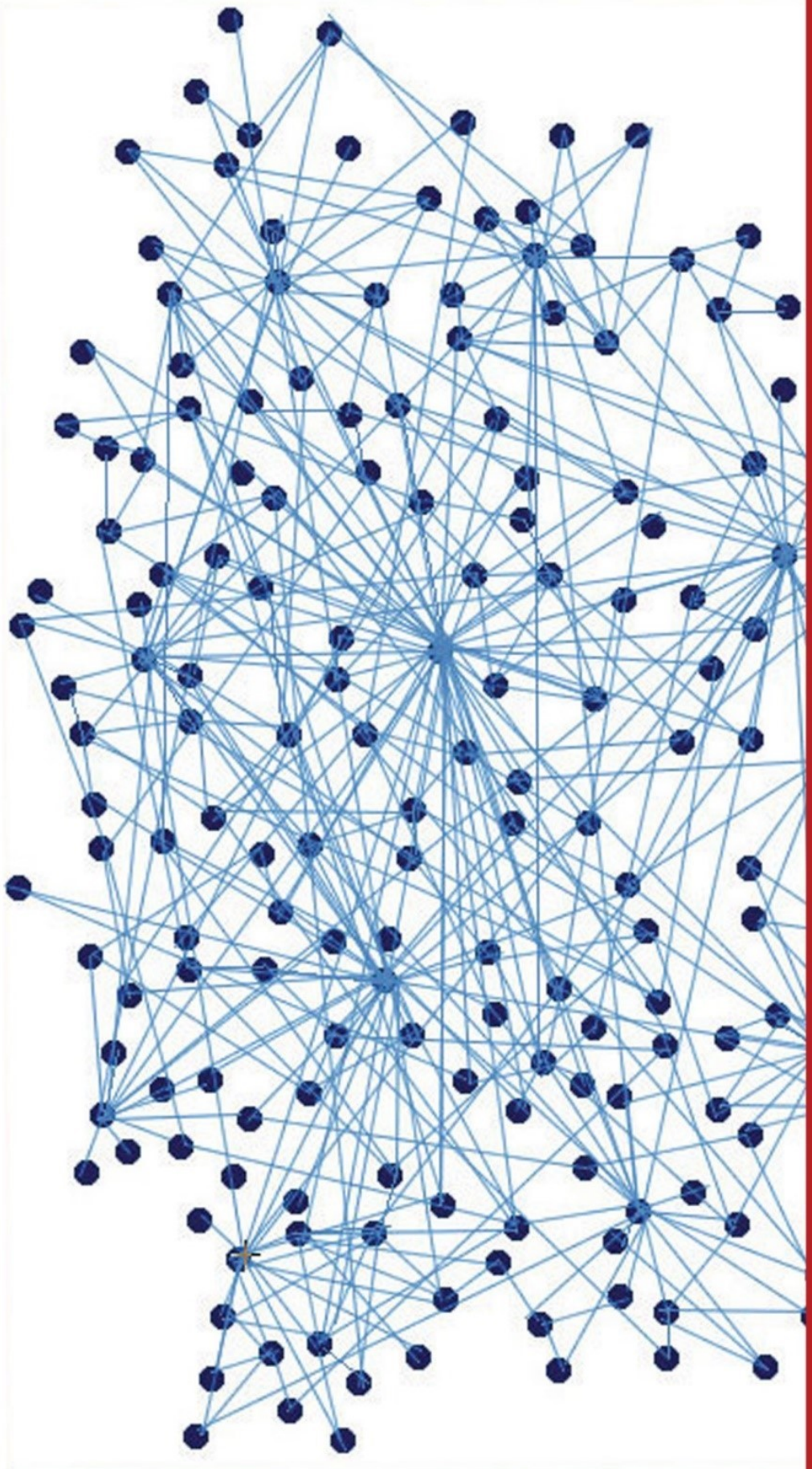
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LE AZIONI: NOZIONE, CARATTERI ESSENZIALI E VALORE 3
2. INDIVISIBILITÀ ED AUTONOMIA DELLE AZIONI 5
3. IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DELLE AZIONI 6
BIBLIOGRAFIA 7

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Le azioni: nozione, caratteri essenziali e valore

La quota di partecipazione dei soci nella S.p.A. consiste nelle azioni.

Il capitale sociale delle S.p.A. è costituito da un numero predeterminato di azioni, le quali hanno identico valore economico e sono dotate di identici diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti ai soci nei confronti della società.

L'azione è indivisibile.

Ai sensi dell'art. 2347 c.c. l'azione può essere oggetto di comproprietà, ma i comproprietari devono eleggere un rappresentante comune legittimato ad esercitare i diritti derivanti dalla partecipazione sociale.

Si osserva poi come ogni singola azione attribuisca al titolare della stessa un nucleo di diritti patrimoniale ed amministrativi che possono essere esercitati nei confronti della società. L'azionista che sottoscriva più azioni è titolare quindi dei diritti derivanti dalla sottoscrizione di ogni singola azione e non di una singola quota di partecipazione sociale.

Ogni singola azione è liberamente ed autonomamente trasferibile.

Il principio per il quale le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono uguali diritti è fissato dall'art. 2348, primo comma c.c.

Nelle azioni può essere indicato o meno il valore nominale.

Il valore nominale delle azioni è la frazione di capitale sociale rappresentata ed espressa in valore monetario.

Ai sensi dell'art. 2328 secondo comma n. 5 c.c., lo statuto deve prevedere in caso di azioni con valore nominale il capitale sottoscritto, le modalità di emissione e circolazione.

Una modifica del valore nominale di tale tipo di azioni può richiede la modificazione dell'atto costitutivo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In caso di azioni che non contengono il valore nominale, lo statuto indica il solo capitale sottoscritto ed il numero delle azioni emesse. Il capitale sociale da ciascuna rappresentato è comunque individuabile dal risultato espresso in percentuale della divisione del capitale sociale ed il numero di azioni.

Ai sensi dell'art. 2346 terzo comma c.c., infatti, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che a questo si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

Alle azioni, inoltre, è attribuibile un valore di bilancio, calcolabile dividendo il patrimonio netto della società per il numero di azioni, di conseguenza è sottoposto al variare nel tempo.

Il valore di mercato, invece, è quello che risulta dai listini ufficiali dei mercati regolamentati nel caso in cui le azioni siano quotate.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Indivisibilità ed autonomia delle azioni

L'azione è l'unità minima di partecipazione della S.p.A. pertanto è indivisibile.

Come si è già avuto modo di osservare, nel caso di comproprietà azionaria di una sola azione, deve essere eletto ai sensi dell'art. 2347 c.c. un rappresentante comune, al fine di prevenire eventuali pregiudizi alla società.

In difetto di nomina del rappresentante comune, il legislatore prevede che le dichiarazioni fatte dalla società ad uno dei comproprietari siano efficaci nei confronti di tutti.

Per converso, gli interpreti ritengono che in tale situazione sia precluso l'esercizio dei diritti sociali attribuiti dall'azione.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2347 c.c., i comproprietari dell'azione rispondono solidalmente delle obbligazioni da essa derivanti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il principio di uguaglianza delle azioni

Ciascuna azione attribuisce al suo titolare diritti amministrativi, diritti patrimoniali e diritti complessi.

Tra i diritti amministrativi possono essere annoverati a titolo esemplificativo: il diritto di intervento e di voto nelle assemblee, il diritto di impugnare le delibere assembleari invalide ed il diritto di esaminare determinati libri sociali.

Tra i diritti patrimoniali possono essere annoverati a titolo esemplificativo: il diritto agli utili ed il diritto alla quota di liquidazione.

I diritti complessi hanno un contenuto sia amministrativo sia patrimoniale, si possono annoverare a titolo esemplificativo: il diritto di opzione, il diritto alla assegnazione di azioni gratuite ed il diritto di recesso.

Il principio di uguaglianza dei diritti attribuiti dalle azioni è affermato dal primo comma dell'art. 2348 c.c. Ne è un principio complementare l'uguaglianza del valore delle azioni.

Nell'ottica di delineare la disciplina generale delle azioni, è necessario però tenere in considerazione quanto disposto dall'art. 2348 secondo comma c.c., il quale permette la creazione di categorie fornite di diritti diversi.

Tale previsione si coordina con quanto fino ad ora descritto osservando come l'uguaglianza di diritti attribuiti dalle azioni e l'uguaglianza del valore delle stesse debbano essere criteri rispettati per ciascuna categoria di azioni.

Si può parlare in tal caso di uguaglianza relativa. Coesistono pertanto azioni ordinarie e azioni di categoria o speciali.

L'uguaglianza assume inoltre carattere oggettivo e non soggettivo poiché omogenei sono i diritti che ciascuna azione attribuisce, il punto di vista non è quindi alla totalità dei diritti dei quali dispone un soggetto in conseguenza della titolarità delle diverse azioni costituenti la partecipazione azionaria globale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

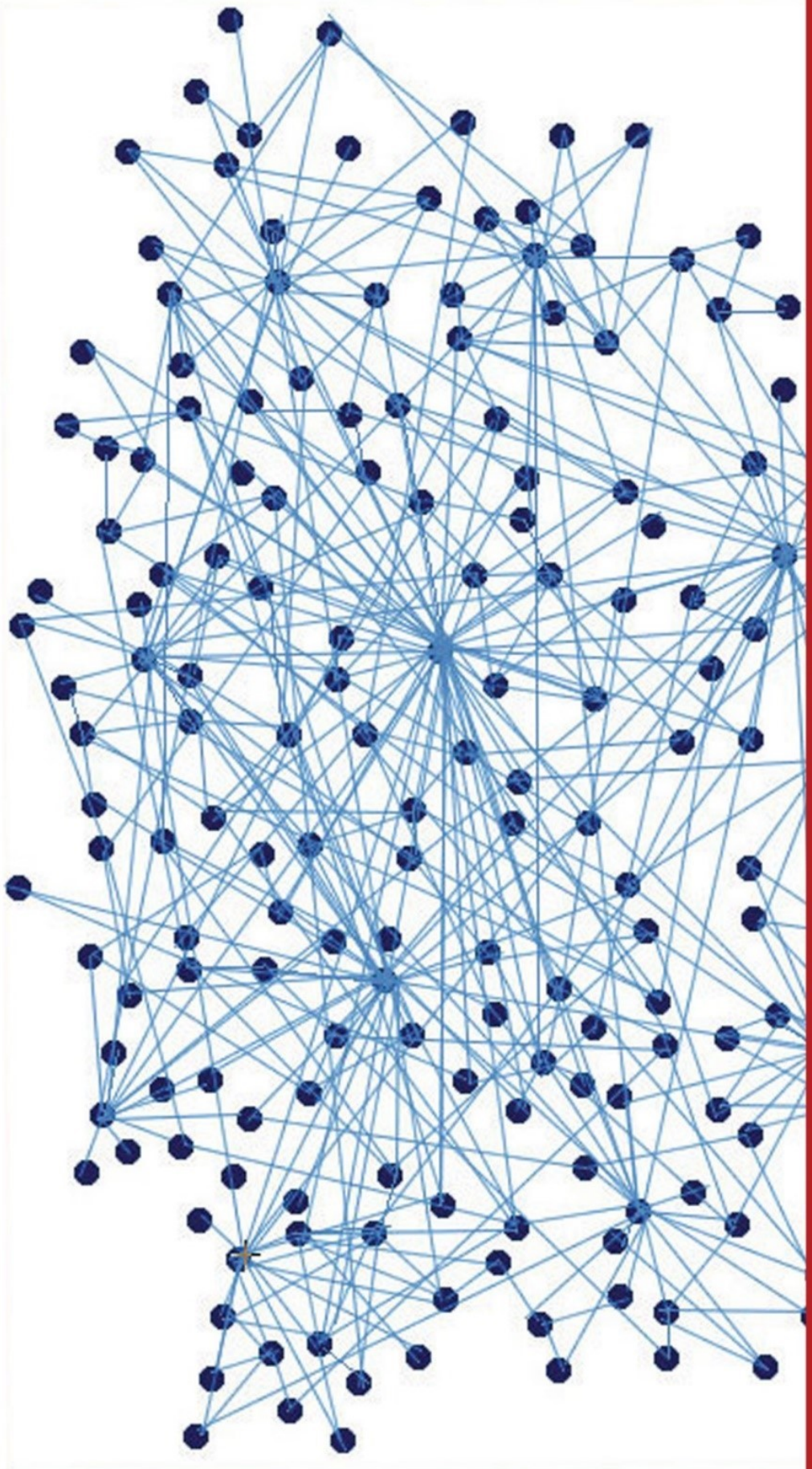
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. AZIONI ORDINARIE E AZIONI SPECIALI 3
2. CONTENUTO DELLA PARTECIPAZIONE AZIONARIA 4
3. AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI 6
BIBLIOGRAFIA 7

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Azioni ordinarie e azioni speciali

Le azioni ordinarie sono quelle che attribuiscono al titolare i diritti tipici della disciplina legale.

Le azioni speciali, per converso, attribuiscono al titolare diritti diversi da quelli tipici della disciplina legale.

Dalla coesistenza di azioni ordinarie ed azioni speciali consegue una differente posizione di interesse degli azionisti. Ne deriva pertanto una peculiare organizzazione degli organi della società, che devono essere altresì rappresentativi degli azionisti speciali.

Inoltre, le deliberazioni assembleari (generali) che pregiudicano i diritti di una categoria di azionisti speciali, devono essere altresì approvate dalla assemblea speciale della categoria di azionisti interessata.

Se le azioni speciali non sono quotate, si applica la disciplina prevista dall'art. 2376 c.c. relativa alle assemblee straordinarie.

Se le azioni speciali sono quotate trova applicazione la disciplina dell'organizzazione degli azionisti di risparmio (T.U.F. art. 147-bis) per i quali il legislatore ha indicato un quorum assembleare più basso e la nomina di un rappresentante della categoria azionaria.

Il legislatore pertanto tutela gli azionisti speciali in quanto categoria omogenea e non quali singoli azionisti (salvo diritti inderogabili considerati tali dall'ordinamento).

La delibera dell'assemblea di categoria viene invece meno quando ad essere pregiudicati sono i diritti di tutti gli azionisti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Contenuto della partecipazione azionaria

Ai sensi dell'art. 2348 secondo e terzo comma c.c. il legislatore legittima la possibilità di creare, con lo statuto o con successive modificazioni dello stesso, categorie di azioni fornire diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite.

In questo caso la società può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie, nei limiti imposti dalla legge.

Il legislatore ha poi introdotto, con i relativi contrappesi, la possibilità di creare azioni a voto plurimo.

La creazione di tale categoria di azioni è stata introdotta nell'ordinamento con la modifica dell'art. 2351 c.c. a seguito del D.L. 91/2014 convertito con Lg. 116/2014.

L'attuale art. 2351 quarto comma c.c. prevede che "salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti".

Tale disciplina è applicabile alle società non quotate nei mercati regolamentati, al contrario le società quotate non possono emettere azioni a voto plurimo.

Se la S.p.A. ha emesso azioni a voto plurimo prima di essere ammessa alla quotazione, tali azioni sono state validamente emesse e permangono.

Le società quotate possono prevedere nello statuto le azioni a voto maggioritario: è attribuito ai soci titolari di azioni da un periodo non inferiore ai ventiquattro mesi una maggiorazione del voto, fino ad un massimo di due voti per ciascuna azione posseduta in tale periodo. Il criterio scriminante non è quindi la creazione di una categoria azionaria speciale, ma il periodo di tempo di titolarità dell'azione, indipendentemente dalla sua categoria.

Si osserva però come la maggiorazione di voto non possa essere prevista dalle società quotate che abbiano conservato azioni a voto plurimo emesse prima dell'ammissione alla quotazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Una categoria di azioni speciale è costituita invece dalle azioni privilegiate, le quali attribuiscono ai loro titolari un diritto di preferenza nella distribuzione degli utili o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della società.

Non essendo dettata dal legislatore una disciplina avente ad oggetto la natura e la misura del privilegio, unico limite sistematico è costituito dal divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c.

Ai sensi dell'art. 2348 secondo comma c.c. è altresì ammesso dall'ordinamento la possibilità di emettere azioni postergate nelle perdite: esempio ne è la previsione statutaria per la quale in sede di liquidazione della società tali categorie di azioni saranno rimborsate anteriormente alle azioni ordinarie.

L'ordinamento ammette poi l'emissione di azioni correlate: si tratta di azioni che attribuiscono diritti patrimoniali con riguardo al risultato economico di un determinato settore dell'attività imprenditoriale, senza che sia necessario dare vita a patrimoni separati destinati ad uno specifico affare.

Sia per le S.p.A. quotate, sia per le S.p.A. non quotate è possibile prevedere la limitazione dei diritti di voto ad una misura massima nonché il cosiddetto voto scalare (attribuzione del diritto di voto in maniera proporzionale alla capitale sociale posseduto), relativamente alla partecipazione azionaria di un soggetto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Azioni e strumenti finanziari partecipativi

Gli strumenti finanziari partecipativi si differenziano dalle azioni in quanto sono stati introdotti per far affluire nella azienda gli apporti che non possono essere acquisiti dalla società sotto la forma dei conferimenti.

Costituiscono altresì una alternativa alle azioni a favore dei prestatori di lavoro (art. 2349 secondo comma c.c.).

Gli apporti effettuati dai titolari degli strumenti finanziari partecipativi per loro natura non sono sottoposti alla disciplina dei conferimenti.

Ai sensi dell'art. 2351 quinto comma c.c. possono attribuire un diritto di voto su argomenti specificamente indicati e, solo se previsto statutariamente, può essere attribuita la possibilità di nominare un componente indipendente del C.D.A. o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

Se è previsto che per tali strumenti finanziari partecipativi il rimborso del capitale, è applicabile la disciplina delle obbligazioni. Tali strumenti concorrono pertanto al calcolo dei limiti matematici fissati dall'art. 2412 c.c.

Deve inoltre essere formata una organizzazione di categoria dei titolari di tali strumenti finanziari partecipativi.

Se gli strumenti finanziari partecipativi attribuiscono anche diritti amministrativi, allora si applica la disciplina delle assemblee speciali ex art. 2376 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

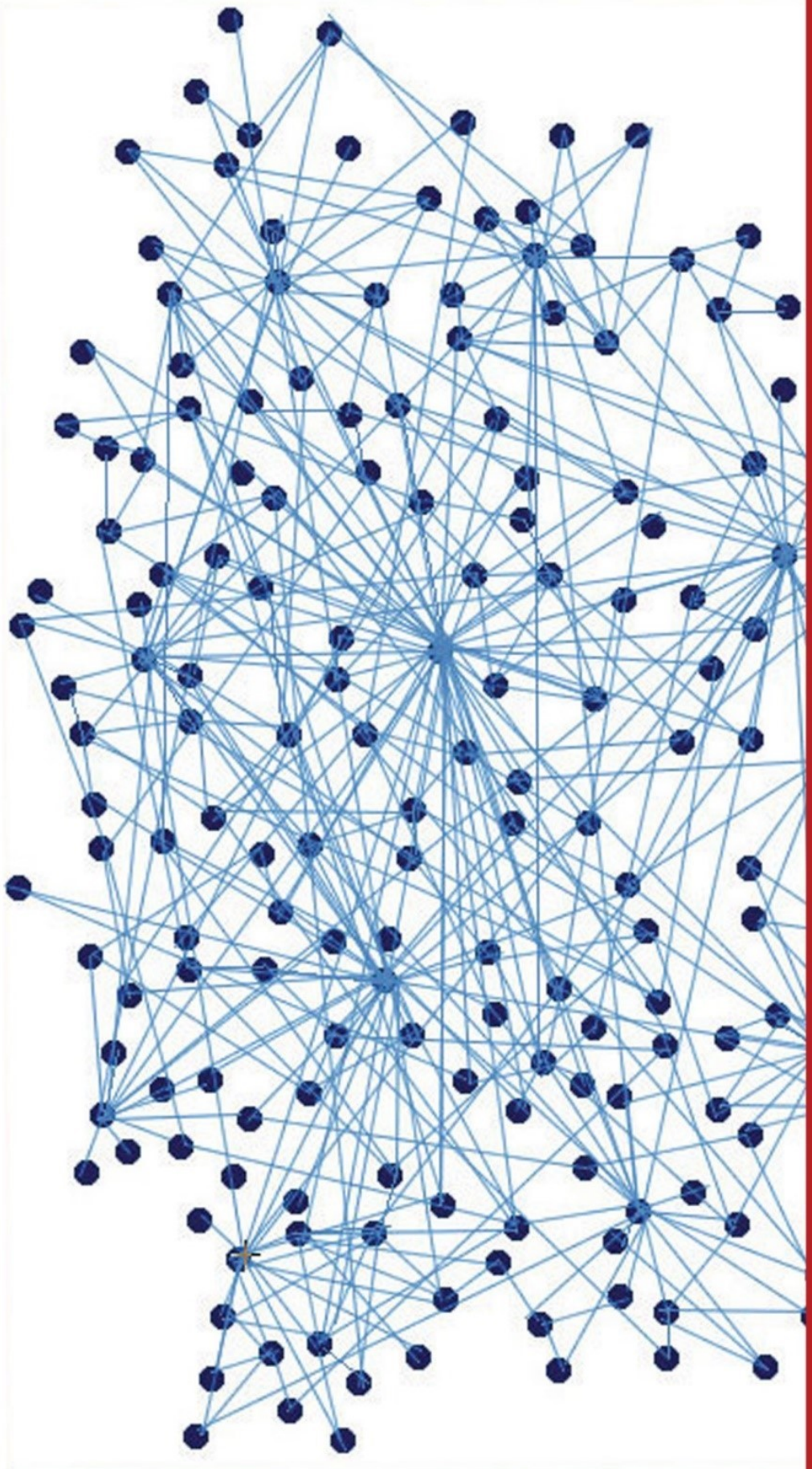
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. PRINCIPI REGOLATORI IL TRASFERIMENTO DELLE AZIONI 3
2. I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE AZIONI 6
3. L'ACQUISTO DELLE AZIONI PROPRIE 8
BIBLIOGRAFIA 10

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Principi regolatori il trasferimento delle azioni

Le azioni possono essere nominative o al portatore.

Vige nel nostro ordinamento la nominatività obbligatoria dei titoli azionari (R.d.L. n. 1148/1941), fatta eccezione per le azioni di risparmio, le società di investimento a capitale variabile, la società di investimento a capitale fisso; infatti, in questi le azioni possono essere nominative o al portatore a scelta dell'azionista.

La circolazione delle azioni nominative è disciplinata dal R.d.L. n. 1148/1941 e dal successivo regolamento emanato con R.D. n. 239/1942 c.c.

Il codice civile disciplina altresì i titoli di credito nominativi ex articoli 2021-2027.

Si dà atto del fatto che il legislatore ha avuto modo di aggiornare la disciplina con alcuni interventi legislativi.

Innanzitutto, le azioni nominative sono intestate ad una persona fisica o giuridica e deve risultare dal libro dei soci, tenuto dalla società emittente.

Il trasferimento del titolo nominativo può avvenire con due modalità, la prima è il transfert, poco utilizzata nella pratica poiché più onerosa rispetto alla seconda modalità: il trasferimento mediante girata.

Con il trasferimento mediante girata l'alienante annota il trasferimento sul titolo, mentre l'annotazione da eseguirsi sul libro dei soci è effettuata dall'acquirente solo quando voglia esercitare i diritti sociali. Pertanto, prima dell'annotazione sul libro dei soci il titolo può essere trasferito innumerevoli volte.

La girata per essere valida deve contenere la data, il nome del giratario (non può essere fatta in bianco), se l'azione non è interamente liberata deve essere sottoscritta da un garante ed anche dal giratario.

La girata deve essere poi autenticata dal Notaio o da un agente di cambio o da una banca autorizzata o da una S.I.M.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si osserva poi come l'evoluzione della disciplina abbia portato il legislatore a prevedere che la preventiva annotazione nel libro dei soci non sia può necessaria al fine di esercitare i diritti sociali derivanti dai titoli azionari se il giratario dimostra di essere possessore in base ad una serie continua di girate.

La S.p.A. è comunque obbligata ad aggiornare il libro dei soci, alla cui compilazione è attribuito un mero valore informativo.

Il trasferimento delle azioni al portatore, invece, avviene mediante semplice consegna del titolo all'acquirente, il quale è legittimato ad esercitare i relativi diritti a fronte della presentazione del titolo alla S.p.A.

L'evoluzione della tecnologia ha però portato al fenomeno della cosiddetta dematerializzazione dei titoli: l'azione abbandona la forma del documento cartaceo e si trasforma in una informazione contabile che viene scambiata sul mercato per mezzo di registrazioni informatiche contabili.

La disciplina relativa alla dematerializzazione dei titoli azionari e delle modalità di circolazione è contenuta nel T.U.F. ed oggetto di regolamentazione da parte della CONSOB e della Banca d'Italia.

In ogni caso è applicabile la disciplina codicistica relativa ai titoli di credito.

Le azioni possono inoltre essere oggetto di usufrutto, pegno, misure cautelari ed esecutive, quali sequestro giudiziario o conservativo e pignoramento).

Ai sensi dell'art. 3 primo comma del R.D. 239/1942 la costituzione di pegno o usufrutto su azioni nominative si concretizza nella annotazione del vincolo sul titolo e nel libro dei soci, a cura della società emittente.

Il pegno può altresì costituirsi mediante consegna del titolo girato con clausola "in garanzia", ma in difetto di annotazione sul libro dei soci non è opponibile alla società.

Ai sensi dell'art. 2352 c.c. se l'azione è oggetto di pegno o usufrutto, il diritto di voto spetta al creditore pignoratizio o all'usufruttuario, salvo pattuizione contraria.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Qualora le azioni oggetto di usufrutto o pegno attribuiscano un diritto di opzione, questo spetta al socio.

In caso di aumento di capitale sociale ex art. 2442 c.c. pegno ed usufrutto si estendono anche alle azioni di nuova emissione.

I diritti amministrativi diversi da quelli previsti dall'art. 2352 c.c. spettano nel caso di pegno ed usufrutto sia al socio sia al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. I limiti alla circolazione delle azioni

L'ordinamento sancisce la libera trasferibilità delle azioni.

Vi sono però alcune eccezioni a tale regola, previste espressamente dal legislatore:

- Ai sensi dell'art. 2343 terzo comma c.c. le azioni liberate con conferimenti diversi dal denaro non possono essere trasferite prima del controllo della valutazione;
- Ai sensi dell'art. 2345 secondo comma c.c. le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del C.D.A.;
- Ai sensi dell'art. 3 secondo comma Lg. 1966/1939 le azioni delle società fiduciarie e di revisione non sono trasferibili in difetto del consenso del C.D.A.;
- Una disciplina particolare è dettata con riferimento al trasferimento delle partecipazioni rilevanti o di controllo.

Oltre ai limiti legali possono esservi limiti convenzionali, pattuiti dai soci e possono risultare o dall'atto costitutivo o da patti parasociali (al di fuori dell'atto costitutivo).

L'art. 2355 bis c.c. legittima la pattuizione di un limite al trasferimento o vietare lo stesso con riguardo alle azioni nominative e quelle non emesse, valevole per un periodo non superiore ai cinque anni dalla costituzione della società o dal momento in cui il divieto viene introdotto.

Può essere altresì introdotta una clausola di prelazione: si obbliga il socio cedente ad offrire le azioni preventivamente agli altri soci e di preferirli a parità di condizioni.

Un altro tipo di clausola che può essere introdotta è la clausola di gradimento.

Il gradimento può essere legato al possesso di determinati requisiti da parte del socio cessionario oppure al placet di un organo sociale (solitamente il C.D.A.); in caso di mero gradimento la clausola è ammissibile a condizione che venga previsto il diritto di recesso o un obbligo di acquisto delle azioni a carico della società o dei soci.

Ai sensi dell'art. 2437 sexies c.c. è legittimata la previsione statutaria per la quale è attribuito alla società o ad alcuni soci un potere di riscatto dei titoli azionari al verificarsi di alcuni eventi (quale ad esempio la morte di un socio).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'introduzione o la soppressione delle clausole sopra citate avviene mediante delibera dell'assemblea straordinaria.

Se nulla prevede lo statuto, in questo caso ai soci che non hanno concorso alla approvazione della delibera è riconosciuto il diritto di recesso (art. 2347 secondo comma lett. b).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. L'acquisto delle azioni proprie

L'acquisto delle azioni da parte della società emittente è una operazione che può realizzare nella pratica una riduzione del capitale sociale sottratta all'applicazione dell'art. 2445 c.c.

Per altro verso l'acquisto di azioni proprie può concretizzarsi nell'investimento delle eccedenze patrimoniali disponibili della società e se la società è quotata in borsa, tale operazione può influire positivamente sul valore economico del titolo azionario ed evitare operazioni speculative.

Il legislatore richiede però il rispetto di alcune condizioni per l'acquisto delle azioni proprie:

- Le somme utilizzate nell'acquisto non possono superare l'importo degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- Le azioni da acquistare devono essere interamente liberate;
- L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea ordinaria;
- Il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere il quinto del capitale sociale, tenuto conto anche delle azioni possedute da società controllate, tale condizione è richiesta per la sola società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio.

Le società con azioni quotate in borsa devono altresì rispettare le ulteriori norme relative all'acquisto di azioni proprie fissate dalla CONSOB, nonché dalla normativa comunitaria.

Nel caso in cui la società proceda all'acquisto delle azioni proprie in violazione della normativa, le operazioni di acquisto sono valide, ma devono essere cedute entro un anno ed in difetto la società deve procedere sollecitamente al loro annullamento ed alla relativa riduzione di capitale sociale.

È attribuita la responsabilità penale agli amministratori che abbiano proceduto all'acquisto di azioni proprie in difetto delle condizioni sopra citate (ex art. 2628 primo comma c.c. e 172 T.U.F.).

Il legislatore prevede poi dei casi nei quali non trova applicazione l'art. 2357 c.c.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tali casi sono indicati dall'art. 2357 bis c.c., ovvero quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:

- in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di riduzione del capitale sociale da attuarsi mediante riscatto e annullamento di azioni;
- a titolo gratuito, nel caso di azioni interamente liberate;
- per effetto di successione universale o di fusione o di scissione;
- in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempre che si tratti di azioni interamente liberate.

Si osserva poi come ai sensi dell'art. 2361 primo comma c.c. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è consentita, nonostante lo statuto lo preveda, se, per la misura e per l'oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l'oggetto sociale determinato dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 2362 secondo comma c.c. l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle stesse deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

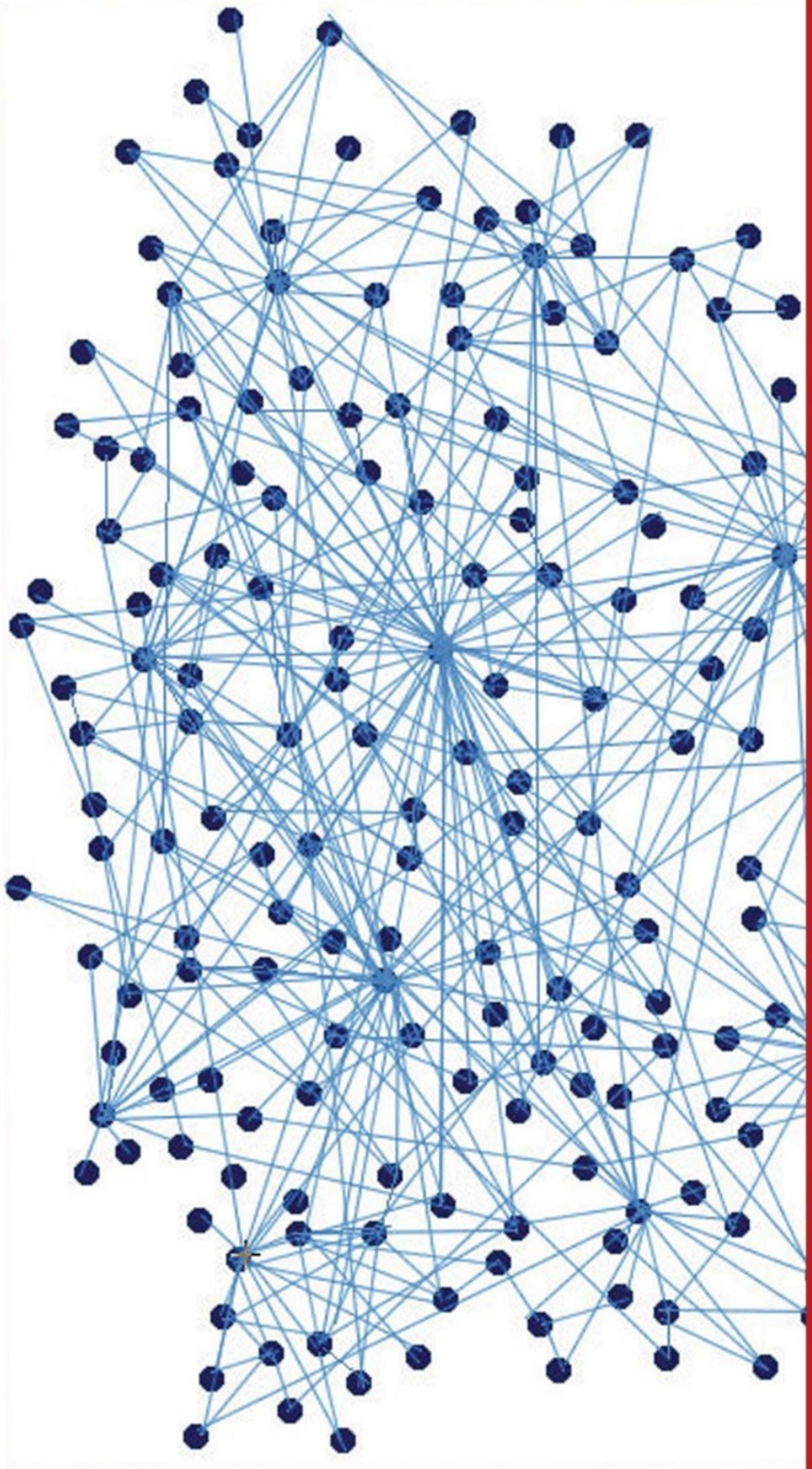
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. GLI ORGANI DELLA S.P.A. E LA NOZIONE DI ASSEMBLEA 3
2. LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA 5
3. LA COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA 7
BIBLIOGRAFIA 9

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Gli organi della S.p.A. e la nozione di assemblea

La S.p.A. ha un carattere corporativo in quanto per il suo funzionamento necessita della compresenza di tre organi: l'assemblea dei soci, la cui funzione è deliberativa, l'organo amministrativo, la cui funzione è di gestire l'impresa, e l'organo di controllo interno, la cui funzione è di controllare sulla amministrazione della società.

A tale modello si aggiunge il cosiddetto sistema dualistico ed il sistema monistico.

Nel sistema dualistico l'amministrazione ed il controllo sono esercitati da un consiglio di sorveglianza, nominato dall'assemblea, e da un consiglio di gestione, nominato dal consiglio di sorveglianza.

Nel sistema monistico l'amministrazione è affidata al C.D.A. (nominato dall'assemblea) ed il controllo è affidato al comitato per il controllo sulla gestione.

Il controllo contabile esterno è previsto sia per il sistema dualistico, sia per il sistema monistico.

I soci della società costituiscono l'organo denominato assemblea.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria assolve ai seguenti compiti:

- Approva il bilancio;
- Nomina e revoca gli amministratori, i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, se previsto anche il soggetto a cui è stata affidata la revisione legale dei conti;
- Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- Delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- Delibera in merito alla materia attribuita dalla legge alla competenza dell'assemblea e sulle autorizzazioni richieste dallo statuto per il compimento degli atti da parte degli amministratori;
- Ai sensi dell'art. 2364 primo comma c.c. approva il regolamento dei lavori assembleari se previsto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il codice civile prevede espressamente le diverse competenze dell'assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza ex art. 2364 c.c. e nelle società con consiglio di sorveglianza ex art. 2364 bis c.c.

Inoltre, si osserva come si delinei la competenza residuale della assemblea ordinaria per tutte le materie per le quali non è espressamente prevista dal legislatore la deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Ai sensi dell'art. 2365 primo comma c.c., l'assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sulle modificazioni dello statuto; sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Si osserva come nel caso in cui la società abbia emesso solamente azioni ordinarie, l'assemblea sarà unica e generale.

Nel caso in cui, invece, la società abbia emesso differenti categorie di azioni alla assemblea generale si affiancheranno tante assemblee speciali quante sono le categorie di azioni non ordinarie emesse.

Se non è stata prevista convenzionalmente una disciplina per le assemblee speciali, nel caso di società non quotate si applicherà la disciplina legale prevista per l'assemblea straordinaria, nel caso di società quotata si applicherà invece la disciplina legale dell'assemblea degli azionisti di risparmio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La convocazione dell'assemblea

Ai sensi dell'art. 2366 primo comma c.c. l'assemblea è convocata dall'amministratore unico o dal C.D.A. (previa deliberazione) o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il legislatore prevede poi alcune materie per le quali l'assemblea deve essere convocata obbligatoriamente:

- L'acquisto di azioni proprie ex art. 2357 c.c.;
- Nomina e revoca degli organi della società ex art. 2364 secondo comma c.c.;
- Su richiesta dei soci che rappresentano la percentuale del capitale sociale ex art. 2367 primo comma c.c. (previsione la cui ratio sta nella tutela delle minoranze);
- Se all'assemblea ordinaria in prima convocazione non si raggiunge il quorum costitutivo ex art. 2369 primo comma c.c.;
- Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti ex art. 2386 secondo comma c.c.;
- In caso di nomina di nuovi sindaci per completare il collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 terzo comma c.c.;
- In caso di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo dello stesso ex art. 2446 primo comma c.c.;
- In caso di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale ex art. 2447 c.c.

Ai sensi dell'art. 2363 c.c. l'assemblea è convocata nel comune in cui ha sede la società, salvo diversa disposizione statutaria.

Le modalità di convocazione ed il contenuto dell'avviso di convocazione cambiano a seconda che la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio o meno.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'art. 2366 secondo comma c.c. le società non quotate devono pubblicare l'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea; se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Nelle società che fanno ricorso al mercato di rischio le modalità di pubblicazione dell'avviso sono definite dalle leggi speciali.

In questa sede è sufficiente osservare come i termini previsti per la pubblicazione dell'avviso di convocazione delle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio siano generalmente più ampi (trenta giorni di preavviso) e l'avviso di convocazione non venga pubblicato in Gazzetta Ufficiale, bensì sul sito internet della società, salvo altri termini e modalità indicate dalla Consob.

I temi da trattare nell'assemblea sono riassunti nel cosiddetto ordine del giorno.

L'ordine del giorno ha una sua valenza giuridica precipua: individua l'oggetto della competenza di deliberazione dell'assemblea, alla quale in quel giorno sarà sottratta la possibilità di deliberare su temi diversi da quelli indicati.

Gli interpreti ritengono sia consentito deliberare su temi strettamente correlati in quanto accessori a quelli indicati in ordine del giorno.

Ai sensi dell'art. 2366 quarto comma c.c., in mancanza delle formalità previste per la convocazione, l'assemblea è considerata regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Si tratta della cosiddetta assemblea totalitaria.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La costituzione dell'assemblea

L'assemblea è validamente costituita se sono presenti nel giorno fissato per la convocazione i soci che rappresentano una determinata quota del capitale sociale.

L'assemblea assume una delibera valida se votano a favore del tema proposto dall'ordine del giorno i soci che rappresentano una determinata quota del capitale sociale.

Per quanto concerne il calcolo del quorum costitutivo sono escluse dal computo le azioni prive di diritto di voto, sono computate invece le azioni il cui voto sia occasionalmente sospeso.

Per quanto concerne il calcolo del quorum deliberativo non sono computate le azioni il cui voto sia occasionalmente sospeso e neppure le azioni di chi versi in una situazione di conflitto di interessi ed abbia dichiarato di astenersi dal voto.

Nel caso di azioni a voto maggiorato, le stesse sono computate sia per quanto concerne i quorum, sia per il calcolo del capitale sociale rappresentato.

Con riguardo all'assemblea ordinaria in prima convocazione il quorum costitutivo è raggiunto con la presenza dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale con diritto di voto nella stessa assemblea.

Il relativo quorum deliberativo è della maggioranza assoluta (la metà più uno) delle azioni che hanno preso parte alla votazione.

Con riguardo all'assemblea ordinaria in seconda convocazione non è richiesto il raggiungimento di un quorum costitutivo e le delibere sono adottate con la maggioranza delle azioni i cui soci hanno preso parte alla votazione.

Per quanto concerne l'assemblea straordinaria, i quorum variano a seconda che si tratti di società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio o no.

In prima convocazione l'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il con il voto favorevole degli azionisti rappresentanti i due terzi del capitale sociale rappresentato in assemblea (ex art. 2369 terzo comma c.c.).

Per quanto concerne invece le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il quorum costitutivo in prima convocazione ha come limite inferiore almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione più di un terzo.

Il quorum deliberativo per quanto riguarda l'assemblea straordinaria è del voto favorevole espresso da almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione.

Si osserva come lo statuto possa modificare solo in aumento le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria (prima convocazione) e straordinaria.

Lo statuto, inoltre, può stabilire norme speciali per la nomina di cariche sociali.

Se lo statuto prevede convocazioni successive dell'assemblea ordinaria o straordinaria (dalla terza in avanti) si applicano le disposizioni della seconda convocazione.

Qualora le convocazioni dell'assemblea straordinaria successive siano previste per S.p.A. che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, il legislatore prevede che il quorum costitutivo scenda ad almeno un quinto del capitale sociale, invariato è invece il quorum deliberativo.

Si dà atto però del fatto che nelle S.p.A. che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio è un'opzione l'adozione del sistema di maggioranze a pluralità di convocazioni.

Salvo diversa opzione statutaria, infatti, il modello legale prevede che le assemblee in questione si svolgano in unica convocazione alla quale è applicata la maggioranza più bassa prevista dal sistema con più convocazioni, consistenti nelle maggioranze richieste per l'assemblea ordinaria in seconda convocazione e per quella straordinaria nelle convocazioni successive alla seconda, fatte salve le previsioni legali e statutarie che richiedono l'applicazione di maggioranze più elevate per l'approvazione di particolari deliberazioni.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

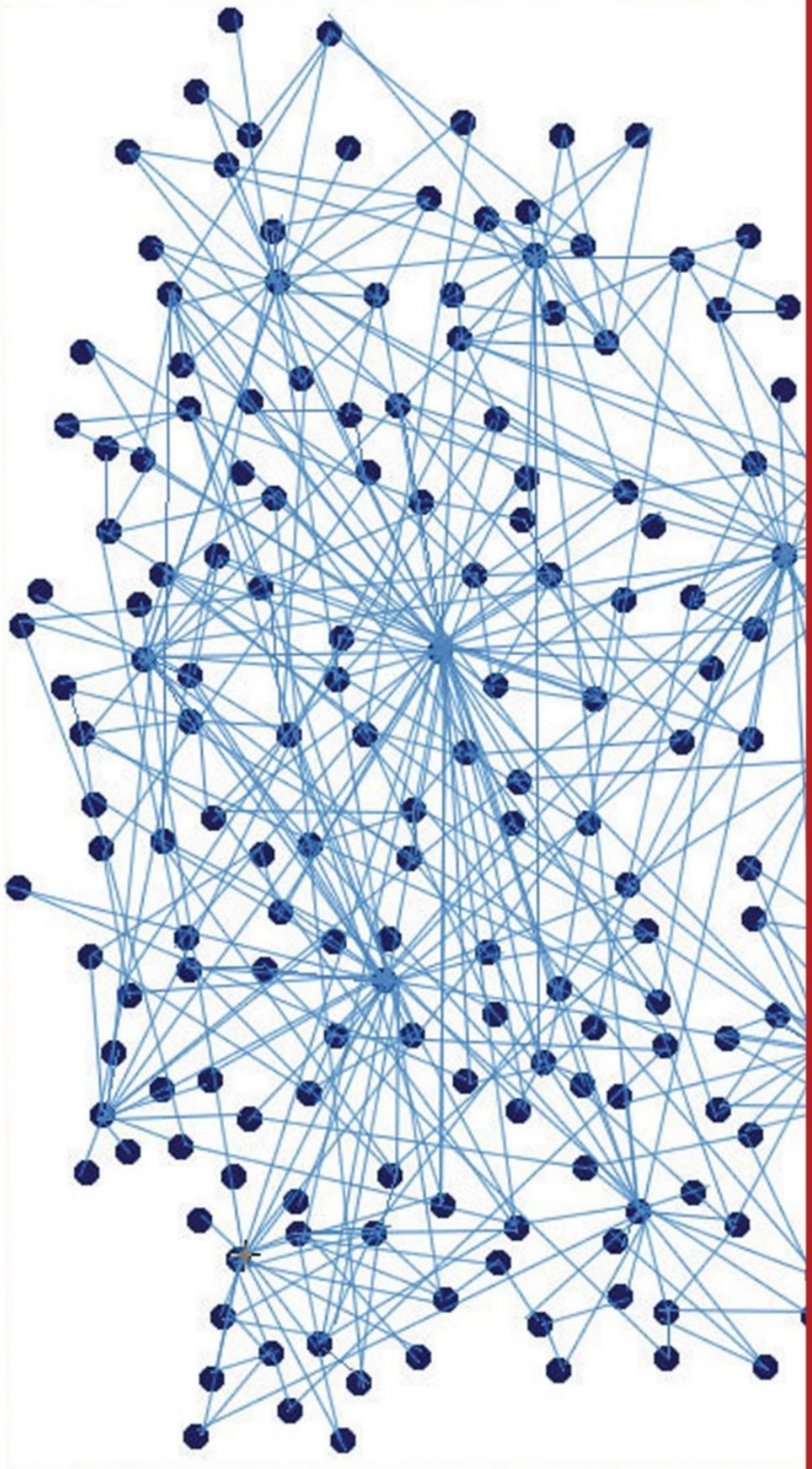
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL DIRITTO DI INTERVENTO E IL DIRITTO DI VOTO 3
2. LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA 5
3. LA RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA NELLE SOCIETÀ QUOTATE 7
BIBLIOGRAFIA 10

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il diritto di intervento e il diritto di voto

Il diritto di intervento è la possibilità per i soci di partecipare all'assemblea.

Sono legittimati ad intervenire in assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto:

- Gli azionisti con diritto di voto;
- I soggetti che pur non essendo soci hanno diritto di voto, quali ad esempio l'usufruttuario ed il creditore pignoratizio.

Possono intervenire inoltre gli azionisti ai quali il diritto di voto spetta, ma è stato sospeso, poiché il legislatore computa le loro azioni nel quorum costitutivo ex art. 2368 c.c.

Da quanto esposto consegue che non è legittimato ad intervenire l'azionista senza diritto di voto, quale è l'azionista di risparmio.

Ne è una eccezione il socio le cui azioni sono oggetto di pegno o di usufrutto, il quale è legittimato.

Sono legittimati altresì a partecipare in assemblea:

- i componenti degli organi di amministrazione e di controllo;
- i rappresentanti comuni degli azionisti di risparmio, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari di partecipazione ad uno specifico affare.

La sussistenza della legittimazione ad intervenire in assemblea deve essere verificata.

Le modalità di tale verifica si differenziano a seconda che la società sia non quotata o meno.

Per le società non quotate il diritto di intervento in assemblea deve sussistere il giorno dell'adunanza e la prova della sussistenza di tale diritto avviene tramite l'esibizione del certificato azionario o in caso di dematerializzazione del titolo tramite la certificazione comunicata alla società dall'intermediario che gestisce tali titoli.

Al fine di evitare manovre speculative e cambi di maggioranze, ai sensi dell'art. 2370 secondo comma c.c., lo statuto può obbligare gli azionisti al preventivo deposito delle azioni presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

entro il quale debbono essere depositate e prevedendo un periodo nel quale non possono essere ritirate prima che l'assemblea si sia svolta.

Lo stesso può essere previsto in caso di dematerializzazione del titolo azionario, con la differenza che il termine è relativo non al materiale deposito bensì alla registrazione contabile.

Per quanto concerne le società con azioni quotate sui mercati regolamentati l'esigenza di verificare la legittimazione all'intervento è una esigenza maggiormente avvertita in considerazione della velocità con la quale la titolarità di tali azioni può essere trasferita e delle ricadute che ciò può avere sulla approvazione o meno di una delibera.

Il legislatore ha pertanto imposto che tale legittimità corrisponda alla titolarità dell'azione nel settimo giorno feriale precedente l'adunanza.

Gli intermediari finanziari hanno l'obbligo di comunicare alla società la titolarità dell'azione che risulta al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea.

Corollario è la previsione per la quale le azioni sono alienabili anche dopo la data assunta come riferimento della verifica della titolarità ed in quanto norma imperativa una eventuale previsione statutaria contraria non avrebbe efficacia.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La rappresentanza in assemblea

Gli azionisti possono partecipare all'assemblea in prima persona o tramite un rappresentante.

La rappresentanza in assemblea svolge la funzione di far partecipare indirettamente i piccoli azionisti alla vita societaria e consente il raggiungimento delle maggioranze previste nel caso di scarsa generale partecipazione.

Al fine però di evitare l'abuso della rappresentanza in assemblea, il legislatore ha previsto una specifica disciplina.

Si dà atto del fatto che per le società quotate la rappresentanza in assemblea è disciplinata dalla legge speciale.

In questa sede è intenzione delineare invece la disciplina codicistica, rivolta pertanto alle altre categorie di S.p.A.

L'articolo di riferimento è il 2372 c.c. il quale prevede che coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in assemblea.

Tale previsione può essere derogata dallo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e delle società cooperative.

La rappresentanza deve essere conferita per scritto ed i documenti relativi debbono essere conservati dalla società.

Nelle società che fanno ricorso al mercato di capitale di rischio la rappresentanza può essere conferita solo per singole assemblee, ma non può essere in tale caso conferita per procura generale o se conferita da una società, associazione, fondazione o altro ente collettivo o istituzione ad un proprio dipendente.

La delega non può essere rilasciata in bianco (senza il nome del rappresentante) e la sostituzione del rappresentante può avvenire solo se nella delega è indicato il sostituto.

La delega è sempre revocabile.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sotto il profilo soggettivo, non può essere delegato come rappresentante:

- un membro degli organi amministrativi o di controllo;
- ad un dipendente della società;
- alla società controllata o ad un membro degli organi amministrativi o di controllo o ad un dipendente della stessa.

Il legislatore ha previsto inoltre un limite numerico: il medesimo rappresentante non può essere delegato da:

- più di venti soci se la società fa ricorso al mercato di capitale di rischio;
- più di cinquanta soci se la società ha capitale non superiore ad euro 5.000.000,00;
- più di 100 soci se la società ha capitale compreso tra euro 5.000.000,00 ed euro 25.000.000,00;
- più di 200 soci se la società ha capitale superiore a 25.000.000,00 di euro.

I limiti relativi al profilo soggettivo del rappresentante nonché i limiti numerici indicati si applicano anche nel caso di girata delle azioni per procura, mentre non si applicano alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati, fatta eccezione per le società cooperative.

Il legislatore fa espressamente salve l'applicazione dell'art. 2539 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La rappresentanza in assemblea nelle società quotate

La disciplina della rappresentanza in assemblea nelle società quotate è stata oggetto di riforma a seguito del D. Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010 che ha dato attuazione alla direttiva comunitaria 2007/36/CE.

Si osserva infatti come sia stata rinnovata la disciplina del T.U.F. ed in particolare:

- si è previsto il conferimento della delega elettronica secondo modalità stabilite dallo statuto;
- salvo diversa disposizione statutaria la società ha l'obbligo di individuare per ogni assemblea un soggetto al quale gli azionisti possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte od alcune delle proposte all'ordine del giorno, senza sostenere spesa alcuna. Il legislatore demanda alla CONSOB la creazione della normativa regolamentare disciplinante il conferimento di tale delega al rappresentante individuato dalla società ed i casi in cui può agire in maniera difforme dalla delega;
- è stato previsto a carico del rappresentante debba comunicare per scritto al socio le circostanze dalle quali scaturisce un di conflitto di interessi con riguardo alla persona del rappresentante stesso; nel caso de quo la delega del socio deve essere particolareggiata ed il delegato deve attenersi strettamente a quanto contenuto nella delega senza possibilità di deroga.

Per le società quotate sussistono poi due meccanismi che hanno la finalità di raccogliere le deleghe di voto: la sollecitazione e la raccolta di deleghe, la cui disciplina si trova agli articoli 136-144 T.U.F.

La sollecitazione consiste nella domanda rivolta dai promotori ad un numero di azionisti maggiore di duecento di conferire ai promotori stessi le deleghe di voto in merito a specifiche proposte di voto oppure accompagnata da indicazioni idonee ad influenzare il voto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il promotore diffonde un prospetto ed un modulo di delega, il cui contenuto è a carattere informativo ed è rivolto ovviamente all'azionista, il quale potrà votare tramite il rappresentante in maniera consapevole.

Tale carattere informativo è fondamentale ed è tutelato dall'ordinamento giuridico il quale prevedere che l'azionista possa far valere la responsabilità del promotore in difetto di adeguata informazione.

È demandata alla CONSOB la competenza di regolare le modalità concrete con le quali deve svolgersi la sollecitazione, inoltre può sanzionare con la sospensione o porre il divieto di esercitare tale attività in caso di violazione della disciplina legislativa e regolamentare.

Si osserva poi come la delega possa essere conferita:

- esclusivamente per singole assemblee già convocate;
- anche solo per alcune delle proposte di voto indicate nel modulo di delega;
- anche solo per alcune materie all'ordine del giorno.

Il promotore è libero di accettare o meno deleghe difformi alle proposte.

È invece previsto l'obbligo della società emittente di accettare deleghe difformi a quanto proposto in caso di sollecitazioni dalla stessa proposte.

Il promotore quindi esercita il voto per delega; è validamente esercitato il voto dal sostituto del promotore se la circostanza della sostituzione e la persona del sostituto sono espressamente indicati nel modulo di delega e nel prospetto di sollecitazione.

Alternativa alla sollecitazione è la raccolta delle deleghe.

Nella raccolta delle deleghe il "promotore" è l'associazione degli azionisti, i destinatari sono i propri associati.

Il fine è quello di dare voce ai piccoli azionisti.

Il legislatore distingue nettamente il fenomeno della sollecitazione da quello della raccolta delle deleghe.

A differenza della sollecitazione la raccolta delle deleghe è caratterizzata da una procedura più semplice.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Al fine però di sottrarsi all'applicazione della disciplina legale della sollecitazione, in capo alle associazioni degli azionisti debbono sussistere alcuni requisiti:

- devono esserci almeno cinquanta azionisti persone fisiche;
- ciascuno dei predetti azionisti deve detenere un quantitativo di azioni minore o uguale allo 0,1% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

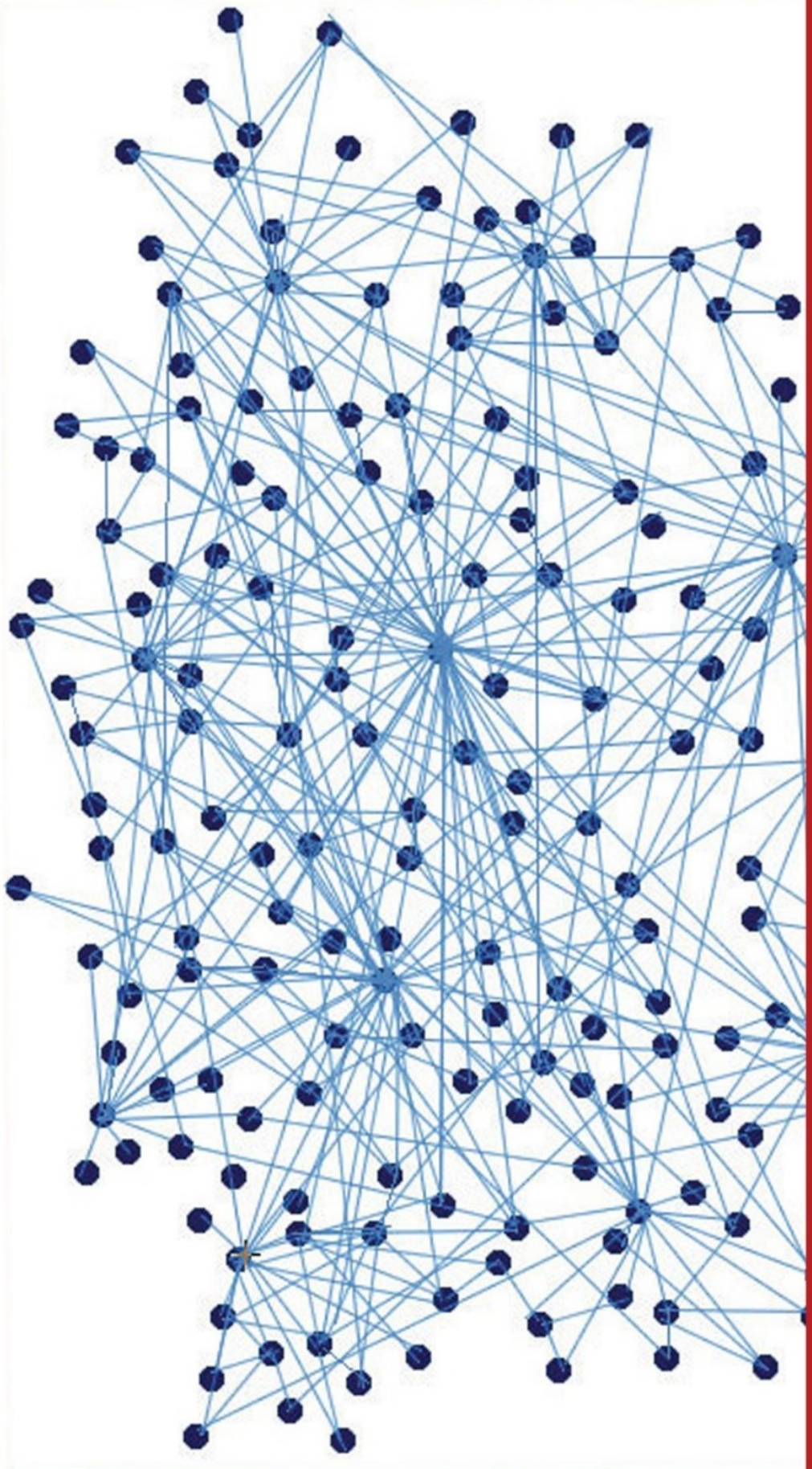
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA 3
2. IL CONFLITTO DI INTERESSI 5
3. I SINDACATI DI VOTO 6
BIBLIOGRAFIA 7

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Lo svolgimento dell'assemblea

Ai sensi dell'art. 2371 c.c. l'assemblea è presieduta dalla persona indicata nello statuto o, in mancanza, da quella eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Il legislatore tace in merito a come debba essere disciplinato il dibattito assembleare.

È però certo che ogni partecipante abbia diritto di esprimere il proprio parare in discussione. Il comportamento di ciascun partecipante non deve turbare lo svolgimento regolare ed i lavori dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2374 c.c. i soci intervenuti che rappresentano un terzo del capitale rappresentato nell'assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'assemblea sia rinviata a non oltre cinque giorni. Tale diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

Il legislatore tace altresì con riguardo alle modalità di votazione assembleari (alzata di mano, acclamazione, schede). Può cambiare pertanto anche di volta in volta.

Gli interpreti escludono però l'ammissibilità della votazione con scrutinio segreto a fronte della necessità di identificare i soci in conflitto di interessi ed i soci dissenzienti legittimati alla impugnazione della delibera assembleare ed all'esercizio del diritto di recesso (artt. 2373, 2377 e 2437 c.c.).

Ai sensi dell'art. 2375 c.c., le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Deve inoltre indicare le modalità ed il risultato della votazione e deve consentire l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Qualora i soci lo richiedano, nel verbale debbono essere riassunte le loro dichiarazioni pertinenti l'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

La redazione del verbale deve avvenire senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il conflitto di interessi

Il conflitto di interessi in sede assembleare si configura quando il soggetto al quale è attribuito il diritto di voto, con riferimento ad una determinata materia, può esprimere un interesse esterno alla società.

Vi sono casi in cui la legge riconosce oggettivamente la sussistenza del conflitto di interessi, in particolare relativamente alle società quotate riconosce il conflitto di interessi in capo a:

- Soggetti che esercitano il controllo sulla società;
- Membri degli organi amministrativi e di controllo e dipendenti della società;
- Società controllanti, controllate o collegate ed i loro membri degli organi amministrativi o di controllo o dipendenti delle stesse.

Nelle società quotate vige il principio di trasparenza delle situazioni di conflitto.

Nelle società non quotate, invece, ai sensi dell'art. 2373 c.c. la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro che abbiano – per conto proprio o di terzi – un interesse in conflitto con quello della società è impugnabile a norma dell'art. 2377 c.c. se tale deliberazione possa cagionare un danno alla società.

È fatto divieto agli amministratori di votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità ed ai componenti del consiglio di gestione di votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina, la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglianza.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. I sindacati di voto

I sindacati di voto sono patti (parasociali) con i quali alcuni soci si obbligano a concordare il voto che esprimeranno in assemblea.

La funzione di tali patti consiste nel dare un indirizzo univoco all'azione dei soci e nel caso in cui costituiscano il gruppo di comando conferisce stabilità alla condotta sociale.

Nel caso in cui tale patto sia invece espressione dei soci di minoranza consente una migliore difesa degli interessi di minoranza.

Gli interpreti si sono a lungo interrogati sulla validità dei sindacati di voto.

In tale sede si ritiene sufficiente osservare come il legislatore abbia individuato come interesse da tutelare la necessità di trasparenza delle situazioni di potere che concorrono a determinare la votazione.

Il legislatore ha pertanto provveduto ad intervenire sulla materia regolando la durata dei sindacati di voto ed assicurando adeguata pubblicità agli accordi.

Per quanto riguarda le società non quotate, la disciplina dei sindacati di voto o patti parasociali è definita dall'art. 2341 bis c.c.

La durata degli stessi è fissata dal legislatore nel massimo di cinque anni e quand'anche fosse stipulato un termine maggiore questo è ridotto a quello di legge.

È legittimo il rinnovo del patto alla scadenza.

Se il patto è contratto a tempo indeterminato è attribuito ad ogni socio il diritto di recedere con preavviso di centottanta giorni.

È esclusa l'applicazione di tale articolo ai patti strumentali ad accordi di collaborazione nella produzione o nello scambio di beni o servizi e relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

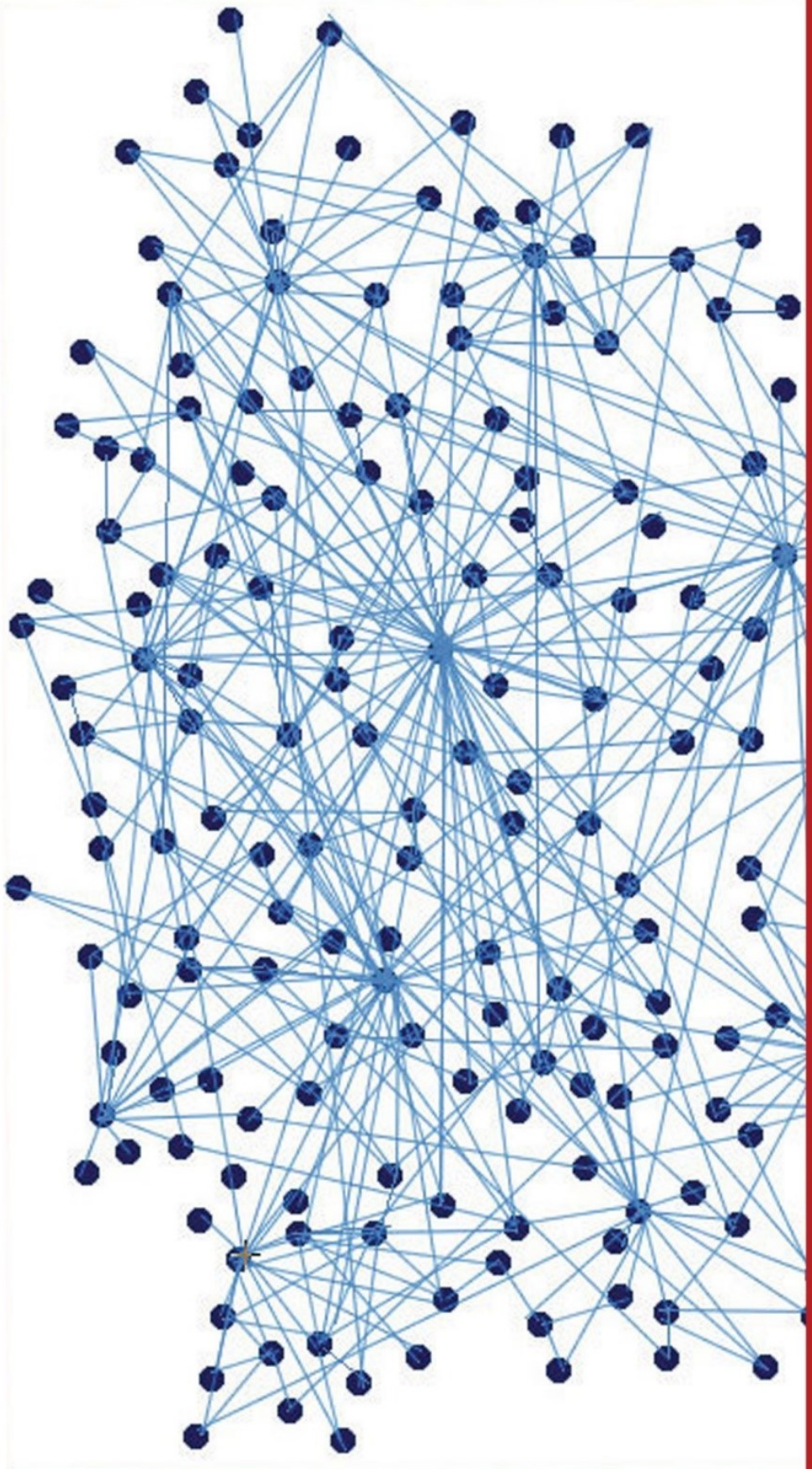
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. L'INVALIDITÀ DELLE DELIBERE ASSEMBLEARI 3
2. IL REGIME DELL'IMPUGNAZIONE 4
3. LE DELIBERE ASSEMBLEARI NULLE 6
BIBLIOGRAFIA 8

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. L'invalidità delle delibere assembleari

La delibera assembleare è invalida se è stata adottata in violazione delle norme relative:

- Al procedimento assembleare;
- Ai vizi che riguardano il contenuto della delibera.

La delibera impugnabile può essere nulla o annullabile.

Nel sistema legislativo previgente, il quale poneva al centro della ratio della norma la disciplina di certezza e la stabilità delle delibere assembleari, la nullità della delibera era prevista in casi eccezionalmente gravi, mentre la annullabilità costituiva la figura generale.

La giurisprudenza elaborò la categoria delle delibere inesistenti, ovvero le delibere carenti dei requisiti minimi necessari affinché il documento possa essere qualificato come delibera assembleare.

Con la riforma del 2003 il legislatore ha ridisegnato la disciplina delle invalidità delle delibere assembleari che si articola ancora nella categoria nullità – annullabilità della delibera.

L'art. 2377 c.c. disciplina le delibere annullabili.

Sono annullabili ex art. 2377 secondo comma c.c. le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto.

Il legislatore esclude poi che in alcuni casi la delibera possa essere annullata:

- Per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ex art. 2368 e 2369 c.c.;
- Per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio; salvo il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti al fine del raggiungimento della maggioranza richiesta;
- Per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il regime dell'impugnazione

Ai sensi dell'art. 2377 c.c., le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate dai soci assenti, dissenzienti od astenuti, dagli amministratori, dal consiglio di sorveglianza e dal collegio sindacale.

L'impugnazione può essere proposta dai soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ed il cinque per cento nelle altre; lo statuto può ridurre o escludere tale requisito.

Per l'impugnazione delle deliberazioni delle assemblee speciali tali percentuali sono riferite al capitale rappresentato dalle azioni della categoria.

I soci che rappresentano la parte di capitale indicata al comma terzo dell'art. 2377 c.c. e quelli che privi di voto non sono legittimati a proporre l'impugnativa hanno diritto al risarcimento del danno ad essi cagionato dalla non conformità della deliberazione alla legge od allo statuto.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, se è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese il termine decorre dall'iscrizione.

L'azione di annullamento deve essere proposta davanti al tribunale del luogo dove ha sede la società.

La disciplina del procedimento è disciplinata nel codice civile dall'art. 2378, ai sensi del quale il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'art. 2377c.c.

Contestualmente al far valere la invalidità della delibera assembleare può essere richiesta la sospensione della stessa non seguendo più automaticamente alla proposizione dell'azione.

L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci.

Obbliga inoltre gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la loro responsabilità.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sono fatti salvi i diritti acquisiti in buona fede dai terzi in base agli atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'annullamento della deliberazione non può avere luogo se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

Restano salvi i diritti acquisiti dai terzi sulla base della deliberazione sostituita.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Le delibere assembleari nulle

La disciplina della nullità delle deliberazioni è disciplinata dall'art. 2379 c.c., al quale fa seguito la disciplina della sanatoria della nullità ex art. 2379 bis c.c.

Sono nulle le delibere il cui oggetto sociale sia impossibile od illecito in conseguenza della violazione di norme imperative, dell'ordine pubblico o del buon costume.

Cause di nullità della delibera sono altresì la mancata convocazione dell'assemblea, la mancanza del verbale.

La convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea.

Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell'assemblea o dal presidente del C.D.A. o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.

Con riguardo agli effetti della delibera nulla questa è inefficace ed è fatto obbligo agli amministratori di non attuarla.

La delibera nulla però può essere sanata retroattivamente per effetto della sostituzione della stessa con altra delibera valida.

Le delibere nulle sono impugnabili entro il termine di tre anni decorrente dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell'assemblea.

Solo le delibere affette da nullità che riguardano la modifica dell'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili sono impugnabili senza limiti di tempo.

Il legislatore ha inoltre dettato all'art. 2379 ter c.c. la particolare disciplina relativa alla invalidità delle deliberazioni di aumento o di riduzione del capitale e della emissione di obbligazioni, ai sensi del quale il termine per impugnare tali delibere è di centottanta giorni decorrenti dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese e in caso di mancata

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

convocazione di novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento di capitale non può essere pronunciata dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'attestazione che l'aumento è stato eseguito anche parzialmente (ex art. 2444 c.c.).

L'invalidità della delibera di riduzione del capitale ex art. 2445 c.c. o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che sia stata anche solo parzialmente eseguita.

È fatta salve il diritto al risarcimento del danno ai soci ed ai terzi.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

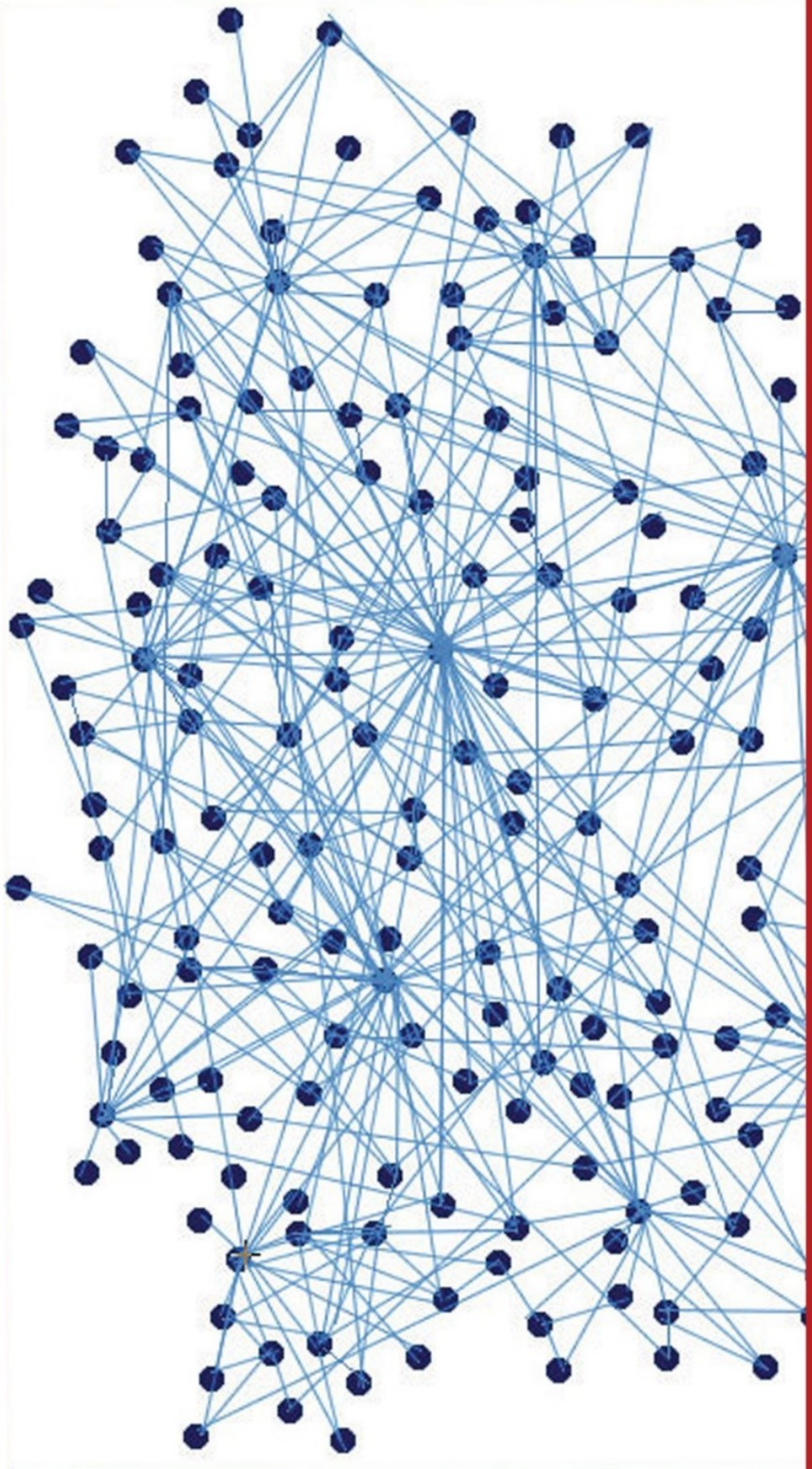
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. STRUTTURA E FUNZIONI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO 3
2. NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI 4
3. REQUISITI DEGLI AMMINISTRATORI E CAUSE DI INELEGGIBILITÀ 5
BIBLIOGRAFIA 7

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Struttura e funzioni dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo nel sistema tradizionale in caso di S.p.A. non quotata può avere un amministratore unico o un consiglio di amministrazione. Le società quotate, invece, debbono avere un amministratore plurisoggettivo in quanto deve essere nominato almeno un amministratore da parte dei soci di minoranza ed un amministratore indipendente.

Il C.D.A. può prevedere al suo interno la creazione del comitato esecutivo e degli amministratori delegati, potendo adeguare pertanto l'organizzazione alle necessità dell'attività d'impresa.

Agli amministratori spetta in via esclusiva la gestione dell'impresa sociale e compiono le operazioni necessarie per attuare l'oggetto sociale ex art. 2380 bis c.c.

Il rapporto tra amministratori e assemblea è delineato dal combinato disposto degli articoli 2364 n. 5 e 2380 bis primo comma c.c.

Mentre l'assemblea dei soci è competente a prendere decisioni solo ed esclusivamente per le materie indicate dalla legge, gli amministratori hanno una competenza gestoria generale comprendente tutti gli atti che non siano oggetto di competenza assembleare.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Nomina degli amministratori

L'atto costitutivo prevede la nomina dei primi amministratori.

La nomina dei successivi amministratori spetta all'assemblea ordinaria.

Ai sensi dell'art. 2368 primo comma c.c. per la nomina delle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.

Il codice civile ex art. 2369 quarto comma c.c. fa espresso divieto di prevedere statutariamente un quorum deliberativo maggiore rispetto a quello normale stabilito per l'assemblea ordinaria di seconda convocazione.

È legittima la clausola statutaria che prevede un quorum deliberativo inferiore alla norma.

Si è affermato nella pratica il cosiddetto voto di lista.

Due o più liste di candidati sono presentate ed ogni socio può votare per una sola lista.

I posti nel C.D.A. sono distribuiti in proporzione ai voti riportati da ciascuna lista secondo l'ordine di preferenza dei candidati.

Nelle società quotate, con il fine di garantire agli azionisti di minoranza qualcuno che li rappresenti nel C.D.A., il legislatore ha previsto espressamente il voto di lista ed almeno un componente del C.D.A. deve essere un rappresentante della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Dal luglio 2012 il legislatore richiede il rispetto della cosiddetta quota rosa nel C.D.A. delle società quotate, garantendo una rappresentanza femminile seppur minima in tale organo.

È però lo statuto che fissa il numero degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2380 bis comma quarto c.c. se lo statuto non stabilisce il numero degli amministratori, ma ne indica solo il numero massimo e minimo, la determinazione spetta alla assemblea.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Requisiti degli amministratori e cause di ineleggibilità

Ai sensi dell'art. 2387 c.c. lo statuto può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di speciali requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Le cause di ineleggibilità e di decadenza sono tipiche e sono indicate dall'art. 2382 c.c.

Ai sensi del predetto articolo, non può essere nominato amministratore e se nominato decade dal suo ufficio:

- L'interdetto;
- L'inabilitato;
- Il fallito;
- Chi è condannato ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica (art. 2383 secondo comma c.c.).

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente sono rieleggibili.

Oltre alla scadenza del termine del mandato vi sono altre cause di cessazione dalla carica:

- La revoca assembleare;
- La rinuncia da parte dell'amministratore;
- La decadenza dell'ufficio;
- La morte.

Ai sensi dell'art. 2385 secondo comma c.c. la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto solo dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito. Si verifica pertanto la cosiddetta prorogatio, per la quale gli amministratori rimangono in carica sino all'accettazione della nomina da parte dei nuovi amministratori.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'art. 2386 primo comma c.c., se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

L'art. 2386 quarto comma c.c. legittima la clausola statutaria "simul stabunt, simul cadent", per la quale a seguito della cessazione di taluni amministratori cessa l'intero C.D.A.

In tal caso l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può, in tal caso, prevedere quanto disposto dall'art. 2386, quinto comma c.c.

Nel caso di cessazione dall'incarico dall'amministratore unico o di tutti i componenti del C.D.A., l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio debba essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può nel frattempo compiere gli atti di ordinaria amministrazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

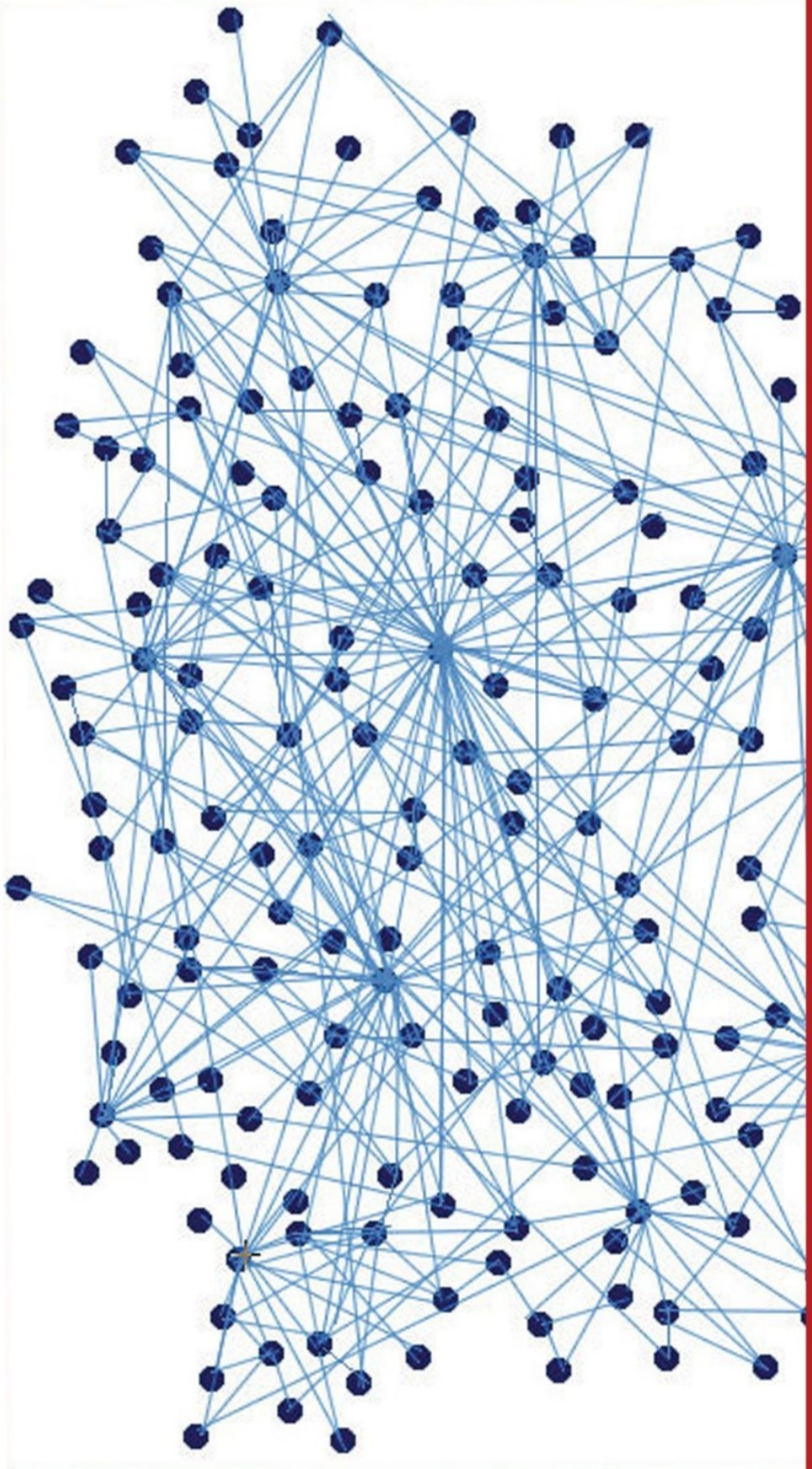
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 3
2. GLI ORGANI DELEGATI 5
BIBLIOGRAFIA 7

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il Consiglio di Amministrazione

Il legislatore ha previsto che le S.p.A. non quotate possano scegliere tra l'adozione di un consiglio di amministrazione ed un amministratore unico, le S.p.A. quotate invece devono adottare obbligatoriamente un C.D.A.

Il C.D.A. è retto da un presidente scelto tra i suoi membri nel caso in cui non sia eletto dall'assemblea ex art. 2380 bis quinto comma c.c.

Ai sensi dell'art. 2381 primo comma c.c., salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il C.D.A., ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Ai sensi dell'art. 2388 primo comma c.c. per la validità delle deliberazioni del C.D.A. è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richieda un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

La rappresentanza non è però ammessa.

Con la riforma del 2003 il legislatore ha disciplinato la materia della invalidità delle delibere del C.D.A. prevedendo che le deliberazioni adottate non conformemente alla legge o allo statuto possano essere impugnate solo:

- dal collegio sindacale;
- dagli amministratori assenti;
- dagli amministratori dissenzienti;

nel termine di novanta giorni dalla deliberazione. È ammessa la legittimazione all'impugnazione da parte dei soci nel caso in cui la delibera sia lesiva dei loro diritti.

Il legislatore richiama espressamente l'applicazione dell'art. 2377 e dell'art. 2378 c.c. in quanto compatibili. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

La disciplina del conflitto di interessi degli amministratori è regolata dall'art. 2391 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'amministratore ha l'obbligo di dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si stratta di amministratore unico invece deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.

La deliberazione del C.D.A. deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Se tali prescrizioni non vengono osservate o in caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni – qualora possano recare danno alla società – possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data.

Non è legittimato all'impugnazione chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma art. 2391 c.c.

Sono salvi i diritti acquistati in buona fede da terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.

L'amministratore risponde dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio dell'incarico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Gli organi delegati

Gli organi delegati possono prendere la forma del comitato esecutivo, il quale è un organo collegiale, oppure dagli amministratori delegati, nel qual caso si tratta di organi unipersonali.

La creazione degli organi delegati deve essere prevista dallo statuto o debbono essere consentite dall'assemblea ordinaria.

La designazione è fatta però dal C.D.A., il quale determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega.

È escluso che la delega abbia ad oggetto:

- La redazione del bilancio di esercizio;
- La facoltà di aumentare il capitale sociale;
- La facoltà di emettere obbligazioni convertibili per delega;
- Gli adempimenti posti a carico degli amministratori in caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale per perdite;
- La redazione del progetto di fusione o scissione.

Il comitato esecutivo come si è osservato è un organo collegiale.

Le sue decisioni sono adottate in riunioni alle quali devono partecipare ai sensi dell'art. 2405 c.c. i sindici. Le relative deliberazioni sono annotate in un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni, la cui tenuta è onere del medesimo organo.

Il legislatore lascia ampio spazio allo statuto nel regolare l'attività del comitato esecutivo.

Gli interpreti ritengono però che siano applicabili a tale organo, in quanto compatibili, le norme relative al C.D.A.

Gli amministratori delegati, come si è osservato, sono organi unipersonali.

Se ve ne sono più di uno può essere previsto statutariamente o nell'atto di nomina un potere di azione disgiunta o congiunta.

Agli amministratori delegati può essere affidata anche la rappresentanza della società.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Può essere inoltre prevista l'operatività di un comitato esecutivo e di uno o più amministratori delegati con competenze definite.

Si dà atto del fatto che la delega non spoglia il C.D.A. delle attribuzioni delegate, ma costituisce un sistema di competenze concorrenti con gli organi delegati (ex art. 2381 terzo comma c.c.).

Ai sensi dell'art. 2381 quinto comma c.c., gli organi delegati:

- curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell'impresa;
- riferiscono al C.D.A. ed al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e dalle sue controllate (con una periodicità fissata dallo statuto ed in ogni caso ogni sei mesi).

Ai sensi dell'art. 2381 sesto comma c.c. gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

Inoltre, ai sensi dell'art. 2381 terzo comma c.c. sono altresì tenuti a valutare in base a tali informazioni l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, se elaborati devono essere esaminati i piani strategici, industriali e finanziari della società e deve essere valutato il generale andamento della gestione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

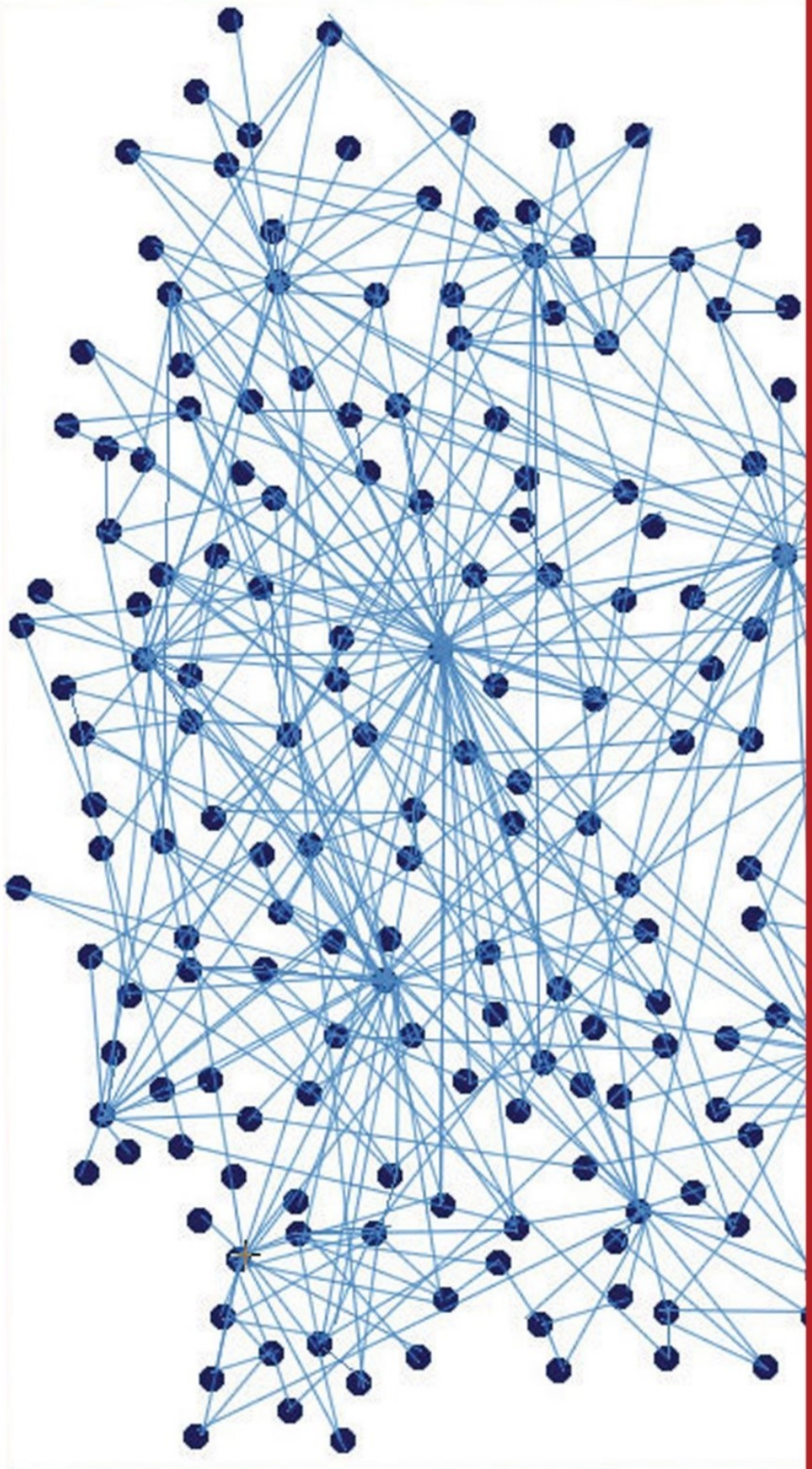
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ: PROFILI GENERALI 3
2. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO LA SOCIETÀ 5
3. LA DISCIPLINA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITÀ 6
BIBLIOGRAFIA 7

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La rappresentanza della società: profili generali

Gli amministratori sono i rappresentanti della società.

Gli amministratori ai quali è conferita la rappresentanza della società devono essere indicati nello statuto o nella deliberazione di nomina.

Se la rappresentanza è attribuita a più amministratori deve essere specificato se il potere di agire è conferito loro in maniera congiunta o disgiunta.

La rappresentanza è generale e non è circoscritta dall'oggetto sociale, è compresa la rappresentanza processuale della società.

Il potere di rappresentanza si esplica all'esterno della società, impegnando quest'ultima verso i terzi.

Il potere di gestione di esplica all'interno della società nella fase decisoria delle operazioni sociali.

Le fonti del diritto di matrice comunitaria hanno influito sulla disciplina della rappresentanza degli amministratori della S.p.A., individuando come oggetto di tutela l'affidamento dei terzi e la certezza e stabilità dei rapporti giuridici.

Il legislatore ha infatti previsto l'inopponibilità ai terzi di buona fede della mancanza di potere rappresentativo degli amministratori in conseguenza dell'invalidità dell'atto di nomina.

Il potere di rappresentanza può essere limitato convenzionalmente, ma la società resta vincolata verso i terzi anche se gli amministratori hanno violato i limiti posti dalla società ai loro poteri, in particolare ai sensi dell'art. 2384 secondo comma c.c., le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

La regola dell'art. 2384, secondo comma c.c., non si estende alle limitazioni legali (ad esempio la conclusione di un acquisto di cui all'art. 2343 bis c.c. in difetto della autorizzazione assembleare).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Vi è poi il caso in cui l'amministratore che conclude un affare per conto della società sia effettivamente dotato di rappresentanza, ma sia privo di potere gestorio poiché la delibera necessaria per poter concludere l'affare risulta affetta da invalidità.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La responsabilità degli amministratori verso la società

Gli amministratori sono responsabili del loro operato nei confronti della società.

Ai sensi dell'art. 2392 c.c. gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. La norma richiede pertanto che gli amministratori operino con diligenza professionale.

Pertanto, non incorreranno nella responsabilità verso la società nel caso in cui abbiano operato con la diligenza professionale richiesta ed il risultato economico della società sia negativo (perdita).

Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.

In ogni caso gli amministratori privi di delega sono solidalmente responsabili con gli amministratori delegati se essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento od eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose. È dovere degli amministratori agire in modo informato ex art. 2381 sesto comma c.c.

La responsabilità degli amministratori non è di carattere oggettivo, in effetti ai sensi dell'art. 2392 c.c. infatti la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per scritto al presidente del collegio sindacale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La disciplina dell'azione di responsabilità

La disciplina dell'azione di responsabilità è dettata dal codice civile all'art. 2393.

Innanzitutto, è promossa a seguito di delibera dell'assemblea ordinaria dei soci anche se la società è in liquidazione.

Può essere altresì deliberata in occasione della discussione del bilancio anche se non è indicata nell'ordine del giorno quando concerne fatti di competenza dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

L'azione di responsabilità inoltre può essere promossa a seguito di deliberazione del collegio sindacale, assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

Tale azione può essere esercitata entro i cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.

La deliberazione dell'azione importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro i quali è proposta nel caso in cui sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, nel qual caso l'assemblea provvede altresì alla sostituzione degli amministratori.

La società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere se sussistono due condizioni:

- La rinuncia e la transazione devono essere approvate con espressa deliberazione assembleare.
- Non deve esserci il voto contrario di una minoranza di soci che rappresentano almeno il quinto del capitale sociale, se la società fa ricorso al mercato del capitale di rischio il dato di riferimento è il ventesimo del capitale sociale oppure la misura prevista dallo statuto per l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità ex art. 2393 bis primo e secondo comma c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

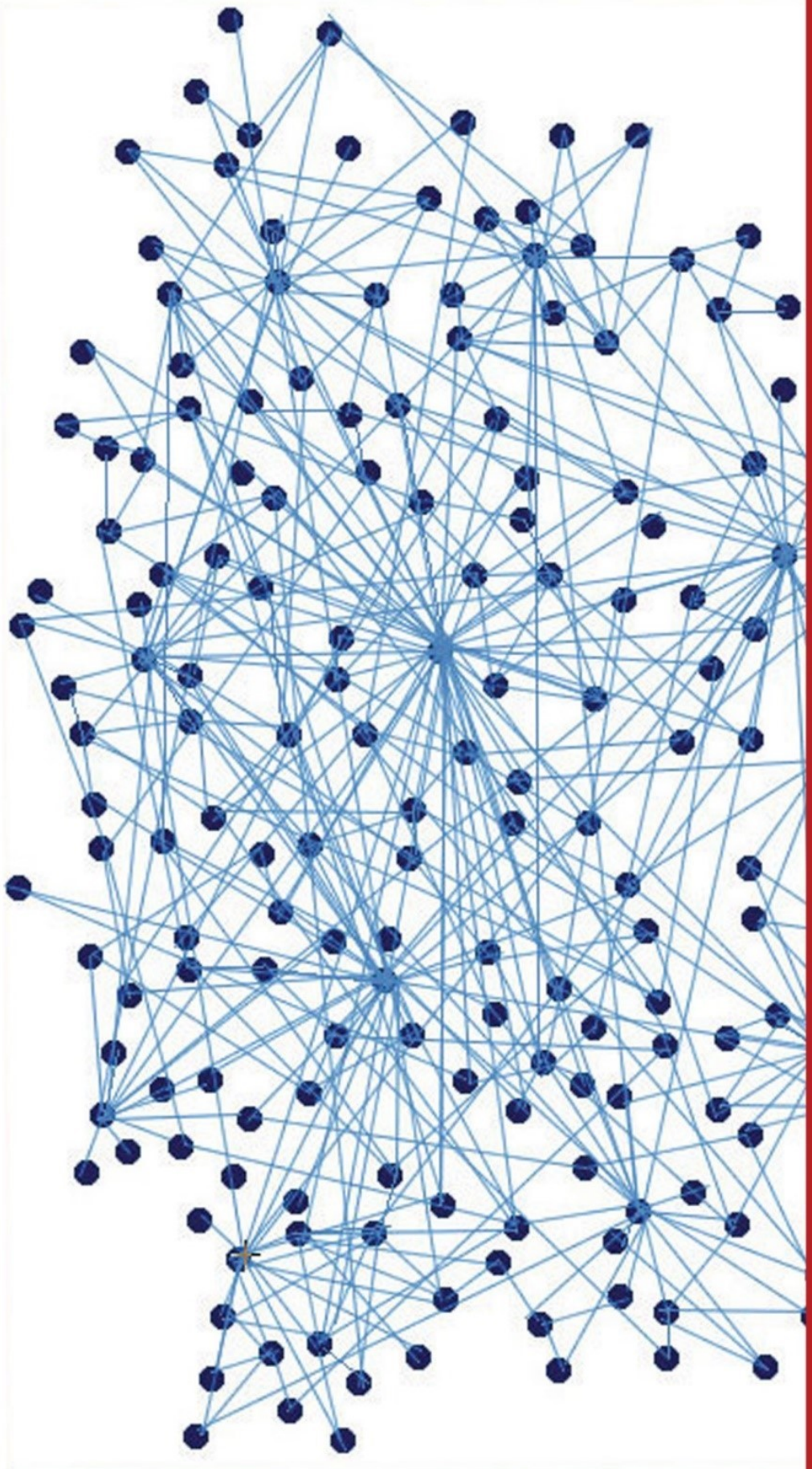
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I CREDITORI SOCIALI 3
2. LA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI VERSO I SOCI O VERSO I TERZI 5
3. LA RESPONSABILITÀ DI DIRETTORI GENERALI E DEGLI AMMINISTRATORI DI FATTO 6
BIBLIOGRAFIA 7

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali

Ai sensi dell'art. 2394 c.c. gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

L'azione può essere proposta dai creditori solo quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

I creditori sociali possono agire per far valere in giudizio la responsabilità degli amministratori solo ed esclusivamente ove ricorrano i presupposti indicati dall'art. 2394 c.c.. La legittimazione a tali creditori non spetta laddove la società sia soggetta a procedure concorsuali ex art. 2394 bis c.c.; in tale caso la legittimazione ad esperire le azioni di responsabilità spetta infatti al curatore fallimentare, al commissario liquidatore e al commissario straordinario.

La responsabilità degli amministratori ha ad oggetto l'inadempimento di obblighi specifici posti dalla legge a carico degli stessi.

Gli interpreti escludono che tale responsabilità abbia natura extracontrattuale, ed affermano che avrebbe natura contrattuale.

Tale inquadramento giuridico esonera pertanto chi agisce in giudizio per far valere tale responsabilità dalla prova della sussistenza di dolo o colpa in capo agli amministratori.

L'art. 2394 terzo comma c.c. enuncia il principio per il quale la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali.

Può essere impugnata dai creditori sociali la transazione esclusivamente con l'esperimento della dell'azione revocatoria qualora ne ricorrano i presupposti.

Gli interpreti si sono interrogati circa la natura di tale tipo di azione.

Alcuni interpreti ritenevano infatti che l'azione ex art. 2394 c.c. fosse una azione autonoma; altri invece ritenevano che l'azione di cui si discute non fosse altro che una forma di azione sociale di responsabilità esercitata dai creditori in via surrogatoria.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Autorevole dottrina sostiene la tesi dell'autonomia dell'azione di cui all'art. 2394 c.c. osservando come la legittimazione ad esperirla non sia subordinata all'inerzia della società, presupposto che è invece necessario per poter esperire l'azione surrogatoria ex art. 2900 c.c.

Accogliendo tale tesi, inoltre, si può affermare che i creditori sociali che agiscono nei confronti degli amministratori non devono citare altresì la società in giudizio e la sospensione della prescrizione dell'azione sociale non opera per l'azione dei creditori sociali fino a quando gli amministratori restano in carica.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La responsabilità degli amministratori verso i soci o verso i terzi

Ai sensi dell'art. 2395 primo comma c.c. l'esperimento delle azioni di cui agli articoli da 2393 a 2394 bis c.c. non pregiudicano il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori.

La nozione di danno diretto è quindi il presupposto in base al quale poter azionare tale strumento giuridico di tutela.

Un esempio di danno diretto subito dal socio o dal terzo è il caso in cui gli amministratori, con un falso bilancio, inducano il socio o un terzo a sottoscrivere un aumento di capitale a prezzo eccessivo.

Altro caso di danno diretto è causato dalla dissimulazione dolosa da parte degli amministratori dello stato di dissesto della società al fine di ottenere dalla banca un finanziamento.

Per quanto concerne il profilo probatorio deve essere provato dall'attore l'esistenza del nesso causale intercorrente tra la condotta illecita (dolosa o colposa) degli amministratori ed il danno subito. Nel caso si qualifichi tale azione di responsabilità come extracontrattuale (ex art.2043 c.c.) allora l'attore dovrà provare in giudizio anche il profilo soggettivo (dolo o colpa) degli amministratori.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La responsabilità di direttori generali e degli amministratori di fatto

I direttori generali sono figure stabilmente inserite nell'organigramma aziendale delle quali si avvalgono gli amministratori per gestire l'impresa.

Ai sensi dell'art. 2396 c.c. ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, si applicano le disposizioni che regolano la responsabilità civile degli amministratori (verso la società, i creditori sociali, verso i singoli soci ed i terzi).

Si può inoltre affermare che sotto il profilo della responsabilità penale sono equiparati agli amministratori.

Restano comunque salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

Altra figura che si distingue da quella di amministratore e di direttore generale è l'amministratore di fatto.

Tale soggetto difetta della qualifica di amministratore per la mancanza di nomina assembleare, ma si ingerisce di fatto ed in modo sistematico nella direzione dell'impresa sociale, ad esempio impartendo istruzioni agli amministratori e trattando con i terzi direttamente.

Gli interpreti si sono posti la questione della possibilità dell'applicazione della responsabilità civile prevista ex artt. 2392-2394 c.c. a questa particolare figura.

La dottrina prevalente, con riguardo alle S.p.A., ritiene sia applicabile agli amministratori di fatto operanti nel predetto modello societario tale regime di responsabilità seppure seguendo diverse linee interpretative.

Di tale avviso è anche la giurisprudenza più recente della Suprema Corte.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

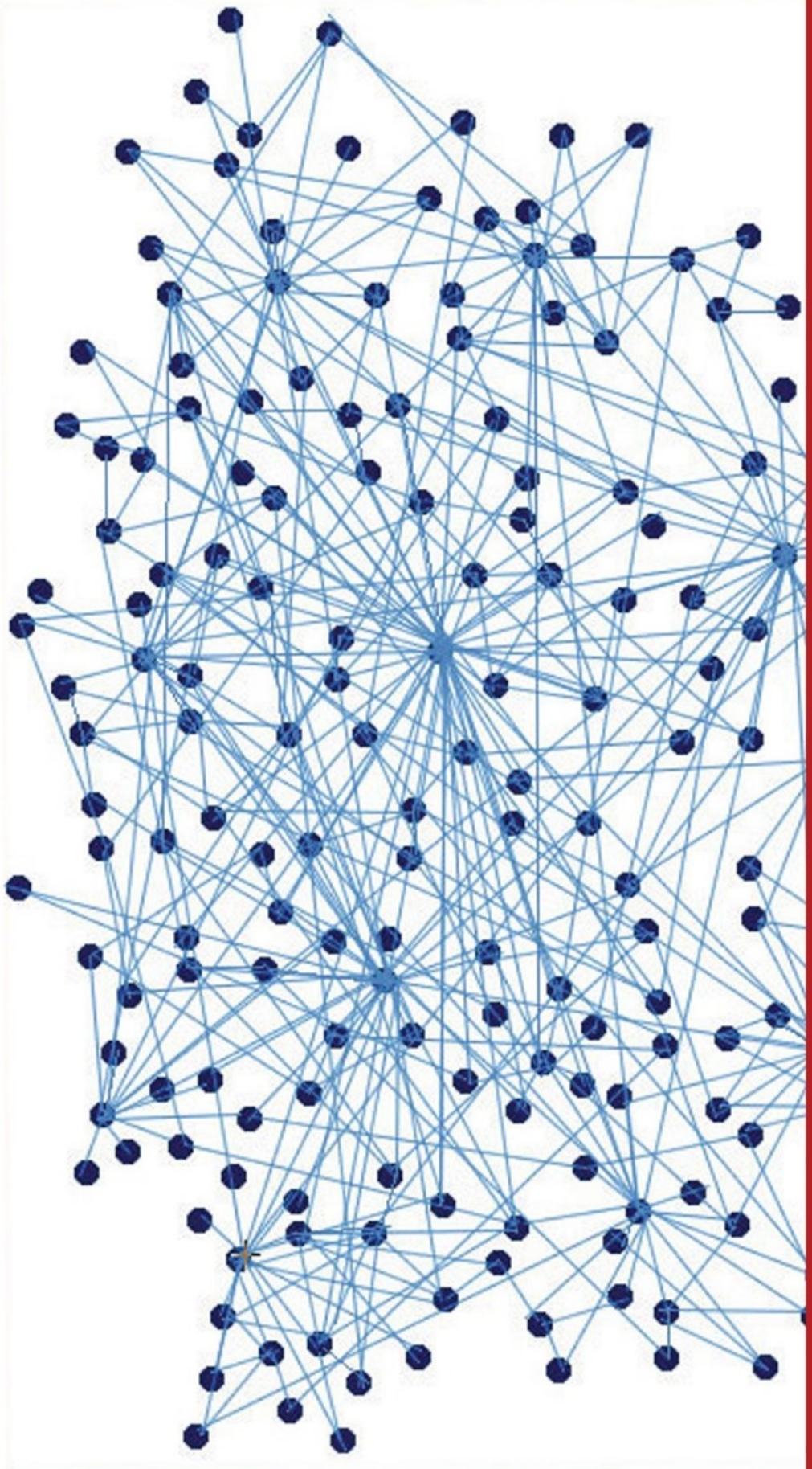
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CARATTERI TIPICI DEL SISTEMA DUALISTICO E CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 3
2. IL CONSIGLIO DI GESTIONE 6
3. IL SISTEMA MONISTICO 7
BIBLIOGRAFIA 9

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Caratteri tipici del sistema dualistico e consiglio di sorveglianza

Il sistema tradizionale di amministrazione e controllo è uno dei tre sistemi che la S.p.A. può adottare con il sistema dualistico ed il sistema monistico.

La S.p.A. può però scegliere in sede di costituzione o con modifica allo statuto l'adozione del sistema dualistico o di quello monistico. In difetto di espressa menzione il modello adottato sarà quello tradizionale.

Il sistema dualistico (artt. 2409 octies-2409 quinquiesdecies c.c.) è caratterizzato dalla presenza di un consiglio di gestione e di un consiglio di sorveglianza.

La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore esterno.

Il consiglio di gestione è l'organo corrispondente al consiglio di amministrazione del sistema tradizionale.

Il consiglio di sorveglianza invece è caratterizzato dalla attribuzione di funzioni che sono proprie del collegio sindacale nonché di alcune funzioni che sono proprie dell'assemblea dei soci: la nomina e la revoca dei consiglieri di gestione, l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea ordinaria ha una competenza ridotta rispetto a quella attribuitale dal sistema tradizionale. Ai sensi dell'art. 2364 bis primo comma c.c. infatti:

- Nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;
- Determina il compenso a questi spettante se non è stabilito nello statuto;
- Delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;
- Delibera sulla distribuzione degli utili;
- Nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione.

È fatta salve dall'art. 2364 bis secondo comma c.c. la possibilità di restringere la competenza dell'assemblea ordinaria attribuendo alcune funzioni agli altri organi societari.

Il consiglio di sorveglianza ai sensi dell'art. 2409 duodecies c.c. si compone di un numero di componenti anche non soci non inferiore a tre, salvo un maggio numero previsto dallo statuo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il sesto comma dell'art. 2409 duodecies c.c. prevede che lo statuto possa subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, fatta salve l'applicazione delle leggi speciali.

La nomina di uno dei consiglieri di sorveglianza può essere:

- Riservata dalla legge o dallo statuto allo Stato o ad enti pubblici purché abbiano partecipazioni nella società;
- Riservata dallo statuto ai possessori di strumenti finanziari partecipativi (art. 2351 quinto comma c.c.).

Inoltre, nelle società quotate almeno un componente deve essere eletto dalla minoranza con il sistema di voto di lista fissato secondo le modalità della CONSOB.

Ai sensi dell'art. 2409 duodecies terzo comma c.c. almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, ai sensi del predetto articolo, comma decimo, non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e se eletti decadono dall'ufficio:

- Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2383 c.c.;
- I componenti del consiglio di gestione;
- Coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettono l'indipendenza.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma ex art. 2364 bis c.c.

La cessazione per scadenza ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione statutaria.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sono revocabili dall'assemblea in qualsiasi momento con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quinto comma dell'art. 2393 c.c. Se la revoca avviene senza giusta causa è fatto salve il risarcimento dei danni.

Le competenze del consiglio di sorveglianza sono determinate dall'art. 2409 terdecies c.c., ai sensi del quale a tale organo spetta:

- La nomina e la revoca dei componenti del consiglio di gestione e la determinazione del relativo compenso, salvo determinazione assembleare;
- L'approvazione del bilancio di esercizio e se redatto del bilancio consolidato;
- Vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento;
- Promuovere l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;
- Presentare la denunzia al tribunale ex art. 2409 c.c.;
- Almeno una volta l'anno riferire all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni, sui fatti censurabili rilevanti;
- Se previsto dallo statuto deliberare in ordine alle operazioni strategiche ed ai piani industriali e finanziari della società predisposti dal consiglio di gestione.

I componenti del Consiglio di Sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

La diligenza con la quale devono operare i consiglieri di sorveglianza ha carattere professionale (adeguata alla natura dell'incarico).

Essi sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi se il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi derivanti dalla natura del loro incarico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il consiglio di gestione

Il consiglio di gestione è l'organo al quale sono attribuite le funzioni del consiglio di amministrazione del sistema tradizionale (art. 2409 novies c.c.). Il legislatore fa espresso richiamo alle norme dettate per il C.D.A. ex art. 2409 undecies c.c.

È un organo plurisoggettivo in quanto non può essere costituito da un numero inferiore a due consiglieri. Con l'atto costitutivo sono nominati i primi consiglieri e successivamente la loro nomina spetta al consiglio di sorveglianza, salvo la nomina sia attribuita statutariamente all'assemblea.

Ai sensi dell'art. 2409 decies c.c. l'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci ai sensi dell'art. 2393 e 2393 bis c.c.; legittimato è altresì il consiglio di sorveglianza entro i cinque anni dalla cessazione del consigliere in carica.

Nel caso sia deliberato l'esercizio dell'azione di responsabilità con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio di sorveglianza, i consiglieri di gestione contro i quali verrà proposta l'azione decadono dall'ufficio.

Il consiglio di sorveglianza può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigerla se sussistono contemporaneamente tali requisiti:

- Vi sia l'approvazione della maggioranza assoluta dei componenti di tale organo;
- Non si opponga una percentuale di soci di cui all'art. 2393 ultimo comma c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il sistema monistico

Il sistema monistico è caratterizzato dalla mancanza del collegio sindacale.

L'amministrazione ed il controllo sono funzioni svolte dal consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione, il quale si forme all'interno del C.D.A. ed ha le competenze proprie del collegio sindacale.

La revisione legale dei conti è poi affidata ad un terzo.

Ai sensi dell'art. 2409 noviesdecies c.c. si applicano al consiglio di amministrazione le norme relative agli amministratori del sistema tradizionale.

In conseguenza del fatto che all'interno del C.D.A. deve essere costituito il comitato per il controllo sulla gestione, almeno un terzo dei componenti del C.D.A. deve avere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci e se richiesto dallo statuto quelli previsti dai codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione dei mercati regolamentati (art. 2409 septiesdecies secondo comma c.c.).

Il comitato per il controllo sulla gestione è disciplinato dall'art. 2409 octiesdecies c.c.

Salvo diversa disposizione statutaria, la determinazione del numero e la nomina dei componenti di tale organo è attribuita al C.D.A., per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può essere inferiore a tre.

Almeno uno dei componenti del comitato deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 2409 octiesdecies quinto comma c.c., le funzioni attribuite a tale organo sono:

- L'elezione del suo presidente;
- La vigilanza sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla idoneità di tale struttura e di tale sistema a rappresentare correttamente i fatti di gestione;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Svolgere gli ulteriori compiti affidatigli dal C.D.A. con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

In caso di morte, rinuncia, revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione è il C.D.A. a provvedere alla sua sostituzione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

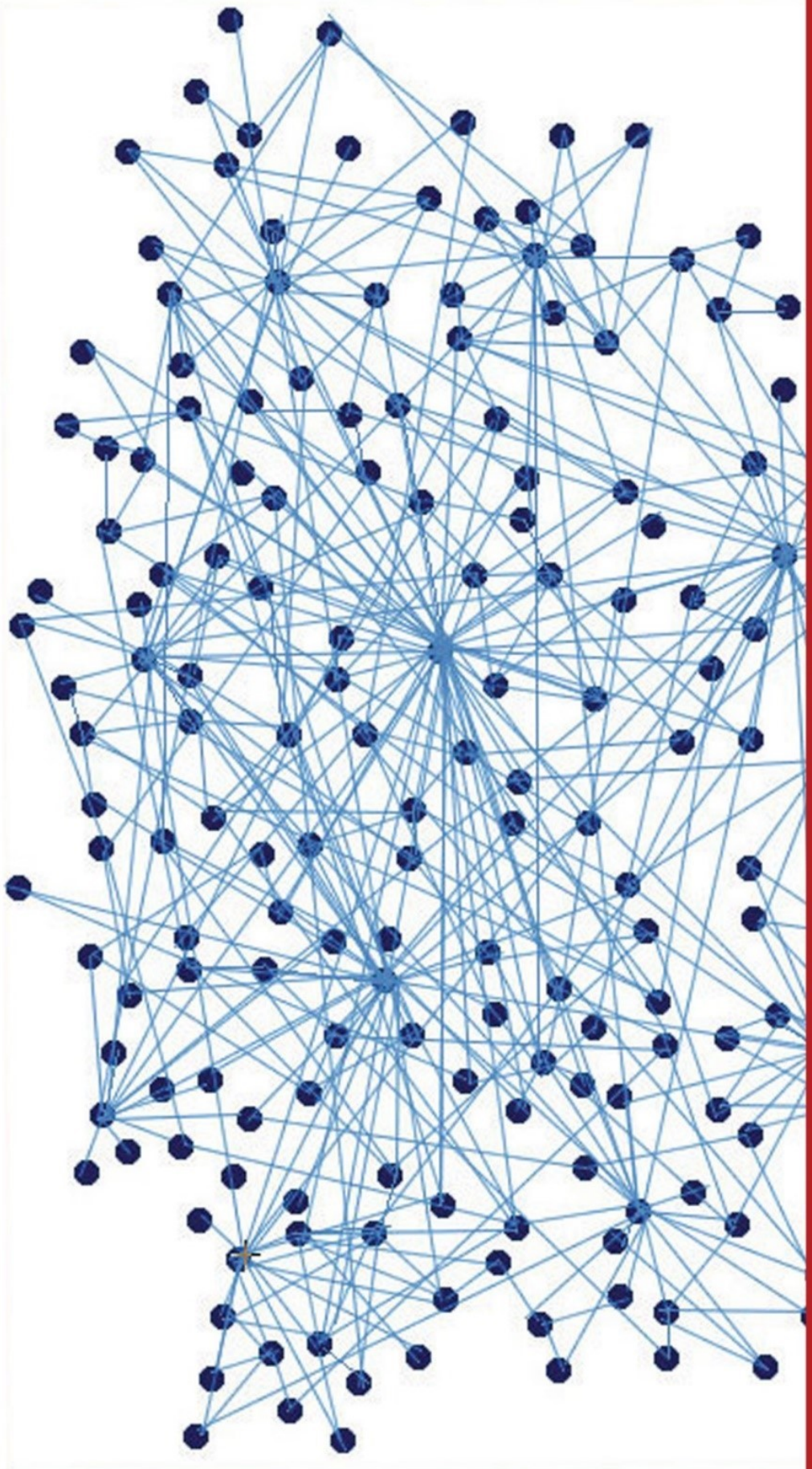
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. MODIFICAZIONI DELLO STATUTO: CARATTERI ESSENZIALI 3
2. IL DIRITTO DI RECESSO: RATIO E CAUSE 4
3. ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO 6
BIBLIOGRAFIA 8

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Modificazioni dello statuto: caratteri essenziali

La modificazione dello statuto della S.p.A. avviene ogni qual volta viene inserita, modificata o soppressa una clausola contenuta nell'atto costitutivo o nello statuto.

Gli interpreti distinguono nella teoria del diritto societario le modificazioni soggettive da quelle oggettive.

Le modificazioni soggettive nelle S.p.A. avvengono in conseguenza del trasferimento della titolarità dell'azione e non influiscono sul contenuto del contratto sociale.

La particolarità della S.p.A. consiste infatti nella possibilità di trasferire liberamente la titolarità della partecipazione senza dover apportare modifiche al contratto sociale.

Le modificazioni oggettive, invece, sono oggetto di specifica disciplina legislativa poiché determinano un cambiamento influente sul contratto sociale.

Ai sensi dell'art. 2365 c.c. la competenza a deliberare in merito alle modificazioni statutarie (oggettive) spetta all'assemblea straordinaria.

Si osserva però come sia possibile statutariamente attribuire all'organo amministrativo la competenza a deliberare su alcuni fatti che comportano la modifica oggettiva del contratto sociale; si ricorda a titolo esemplificativo la deliberazione relativa ad alcuni casi di fusione, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'aumento del capitale sociale a pagamento.

Ai sensi dell'art. 2436 c.c. è affidato al Notaio il controllo circa la legittimità della modifica statutaria deliberata dall'assemblea e provvede alla iscrizione della delibera presso il Registro delle Imprese entro trenta giorni dalla deliberazione.

Il Registro delle Imprese provvede invece a verificare la regolarità formale della documentazione depositata.

Ai sensi del terzo comma del citato articolo, se il Notaio non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge, deve darne comunicazione tempestiva agli amministratori.

Gli amministratori, entro i trenta giorni successivi possono convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti o ricorrere al Tribunale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il diritto di recesso: ratio e cause

Il diritto di recesso è attribuito ai soci nel caso in cui le modificazioni del contratto sociale siano così importanti da snaturare il contratto per il quale questi avevano acconsentito ad aderirvi.

Ai sensi dell'art. 2437 primo comma c.c. hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- La modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- La trasformazione della società;
- Il trasferimento della sede sociale all'estero;
- La revoca dello stato di liquidazione;
- L'eliminazione di una o più cause di recesso previste dalla legge (in quanto derogabili) o dallo statuto;
- La modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- Le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Le cause appena elencate sono clausole inderogabili di recesso.

Il legislatore indica due ulteriori cause di recesso che sono derogabili statutariamente, in quanto possono essere espressamente escluse dallo statuto; si tratta dell'attribuzione del diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

La proroga del termine (clausola derogabile statutariamente);

L'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari (clausola derogabile statutariamente).

Qualora la società sia costituita a tempo indeterminato e le relative azioni non sono quotate in un mercato regolamentato, il socio può sempre recedere con un preavviso di almeno centottanta giorni.

Lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore però ad un anno.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.

Il legislatore, come norma di chiusura, sanziona con la nullità ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma dell'art. 2436 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Esercizio del diritto di recesso

Il diritto di recesso deve essere esercitato dal socio a mezzo di spedizione di lettera raccomandata entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima.

Il termine è di trenta giorni dalla conoscenza del fatto se ciò che legittima il recesso non è costituito dalla deliberazione.

Si osserva però come la perdita della qualità di socio avvenga non avvenga con la spedizione della lettera raccomandata, ma esclusivamente a seguito del rimborso delle azioni.

I criteri per la determinazione del valore delle azioni sono indicati dall'art. 2437 ter c.c.

Il legislatore afferma il principio per il quale il socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.

Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Deve essere ovviamente considerata in tale valutazione la consistenza patrimoniale della società nonché delle sue prospettive reddituali e dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In tale caso il legislatore richiede che il valore di liquidazione così determinato sia conoscibile dai soci nei quindici giorni precedenti la data fissata per l'assemblea.

Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati, invece, è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Lo statuto può inoltre stabilire criteri differenti di determinazione del valore di liquidazione, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Lo statuto delle società con azioni quotate in mercati regolamentati può prevedere che il valore di liquidazione sia determinato come sopra descritto, fermo restando che in ogni caso il valore così determinato non possa essere inferiore al valore che sarebbe dovuto a fronte della media aritmetica dei prezzi di chiusura dei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero la ricezione dell'avviso di comunicazione sopra citato.

Ai sensi dell'art. 2437 quater, gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute.

Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste sulla base del rapporto di cambio.

Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del socio recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati regolamentati.

Se la società non è quotata ed i soci non acquistano le azioni del socio recedente, le azioni vengono a questi rimborsate mediante l'acquisto da parte della società con le riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2357 c.c.

In assenza di utili e riserve disponibili deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale (nel qual caso si applica l'art. 2445 secondo terzo e quarto comma c.c.) o lo scioglimento della società.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

Con riferimento alle sole pagine relative ai temi trattati.

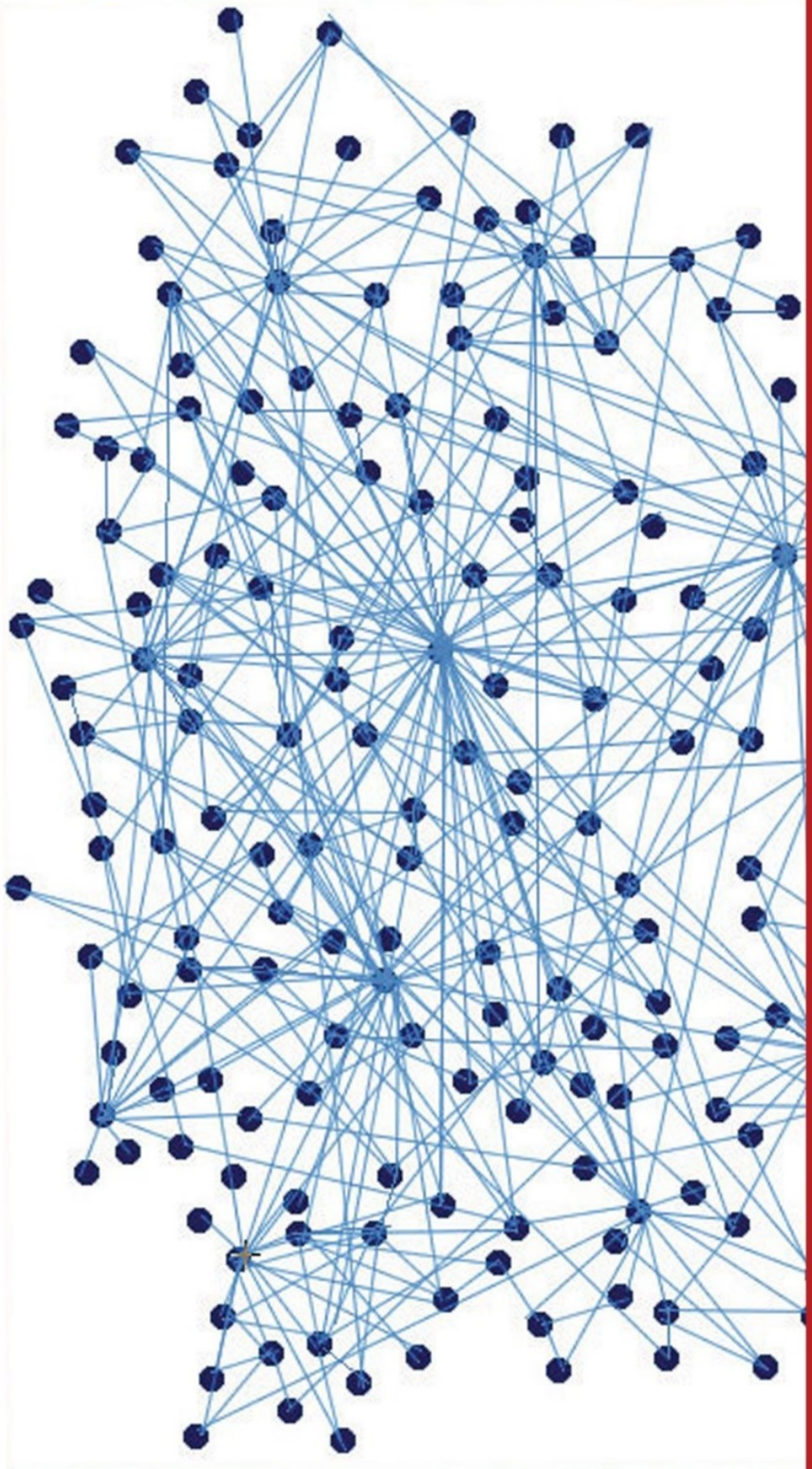
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. I SINDACI 3
2. LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI – CENNI 6
3. IL CONTROLLO GIUDIZIARIO SULLA GESTIONE 7
BIBLIOGRAFIA 9

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. I sindaci

Il collegio sindacale è l'organo di controllo interno delle S.p.A. nel sistema tradizionale.

La sua funzione è quella di vigilare sull'amministrazione della società.

La composizione di tale organo è differente a seconda che si prenda in esame una S.p.A. quotata o non quotata.

Ai sensi dell'art. 2397 c.c. il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi.

Possono essere soci o non soci.

Devono essere eletti inoltre due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente debbono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nelle società quotate l'atto costitutivo può determinare liberamente il numero dei sindaci (ex art. 148 T.U.F.), in ogni caso l'organo deve essere pluripersonale ed i sindaci effettivi devono essere almeno tre e due supplenti.

I primi sindaci sono nominati nell'atto costitutivo, successivamente sono nominati dall'assemblea ordinaria.

La legge o lo statuto possono poi prevedere che la nomina di uno o più sindaci sia riservata allo stato o agli enti pubblici che abbiano partecipazioni nella società.

È possibile riservare statutariamente la nomina di un sindaco ai possessori degli strumenti finanziari partecipativi ex art. 2351 quinto comma c.c.

Si osserva come per le società quotate sia previsto che un membro effettivo del collegio sindacale debba essere eletto da parte dei soci di minoranza con il sistema del voto di lista, secondo le regole fissate dalla CONSOB.

Le norme che disciplinano la scelta dei sindaci sono ispirate dalla volontà di garantire la competenza professionale e l'indipendenza dei sindaci, nonché al tentare di limitare il fenomeno del cumulo di incarichi.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'art. 2399 c.c., non possono essere eletti alla carica di sindaco e se eletti decadono da tale ufficio:

- chi si trova nella situazione di cui all'art. 2382 c.c. ovvero l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è stato condannato ad una pena che importi l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi;
- il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questi controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- chi è legato alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Lo statuto può prevedere ai sensi dell'art. 2399 ultimo comma c.c. ulteriori cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Ai sensi dell'art. 2400, comma secondo, i sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in il collegio è stato ricostituito.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e la relativa deliberazione deve essere approvata con decreto dal Tribunale.

La nomina e la cessazione dalla carica di sindaco debbono essere iscritte presso il Registro delle Imprese nel termine di trenta giorni a cura degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2403 c.c., il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'art. 2403 bis c.c., i sindaci possono procedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo; il collegio può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, anche con riferimento alle società controllate.

Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Il legislatore prevede che il collegio sindacale si riunisca almeno ogni novanta giorni.

È motivo di decadenza dall'ufficio la mancata partecipazione del sindaco a due riunioni nel medesimo esercizio sociale in difetto di giustificato motivo.

I sindaci debbono assistere alle adunanze del C.D.A., alle assemblee ed alle riunioni del comitato esecutivo.

Ai sensi dell'art. 2406 primo comma c.c., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

I sindaci debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

Sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.

All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli artt. 2393, 2393 bis, 2394, 2394 bis e 2395 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La revisione legale dei conti – cenni

La revisione legale dei conti, un tempo affidato al collegio sindacale, è oggi affidata a seguito della riforma del 2003 ad un revisore legale o ad una società di revisione (art. 2409 bis c.c.).

Lo statuto può prevedere che la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale, nel qual caso tutti i membri dovranno essere iscritti nell'albo dei revisori legali.

Tale clausola statutaria non può essere adottata:

- dalle società tenute a redigere il bilancio consolidato;
- dalle società qualificate come enti di interesse pubblico;
- dalle società che controllano o sono controllate o sono soggette a comune controllo con un ente di interesse pubblico.

Il revisore legale dei conti ha la funzione di verificare che nel corso dell'esercizio la tenuta della contabilità e la rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione siano corretti.

Verifica, inoltre, che il bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato siano redatti conformemente alle norme che li disciplinano; l'esito viene riportato in una apposita relazione.

Al fine di compiere alla sua funzione è necessario che abbia accesso alla documentazione aziendale.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti deve adempiere ai propri doveri con diligenza professionale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il controllo giudiziario sulla gestione

Ai sensi dell'art. 2409 primo comma c.c., qualora vi sia fondato sospetto che gli amministratori – in violazione dei loro doveri – abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, sono legittimati a farne denuncia al Tribunale, a mezzo di ricorso notificato anche alla società:

- i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale;
- i soci che rappresentano il ventesimo del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

  Lo statuto può prevedere una percentuale minore per la legittimazione attiva dei soci.

Si tratta pertanto di uno strumento di controllo dell'attività gestoria attribuito ai soci, indipendentemente dall'attività di controllo svolta dai sindaci.

Il Tribunale può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società e se sussistono le violazioni denunciate dai soci potrà essere disposti i provvedimenti provvisori e la convocazione dell'assemblea affinché deliberi opportunamente.

Nei casi più gravi può essere disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci; il Tribunale provvederà a nominare un amministratore giudiziario, indicandone la durata d'incarico ed i relativi poteri.

L'amministratore giudiziario deve rendere conto dell'attività svolta, convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre eventualmente la messa in liquidazione della società o la ammissione ad una procedura concorsuale.

Il Tribunale non potrà provvedere all'ispezione e dovrà invece sospendere il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori ed i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano per accertare se le violazioni denunciate dai soci sussistono e nel caso eliminarle, riferendo al Tribunale sugli accertamenti e le attività compiute.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2409 c.c. possono adire altresì il Tribunale il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione e per le società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio il pubblico ministero.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

Con riferimento alle sole pagine relative ai temi trattati.

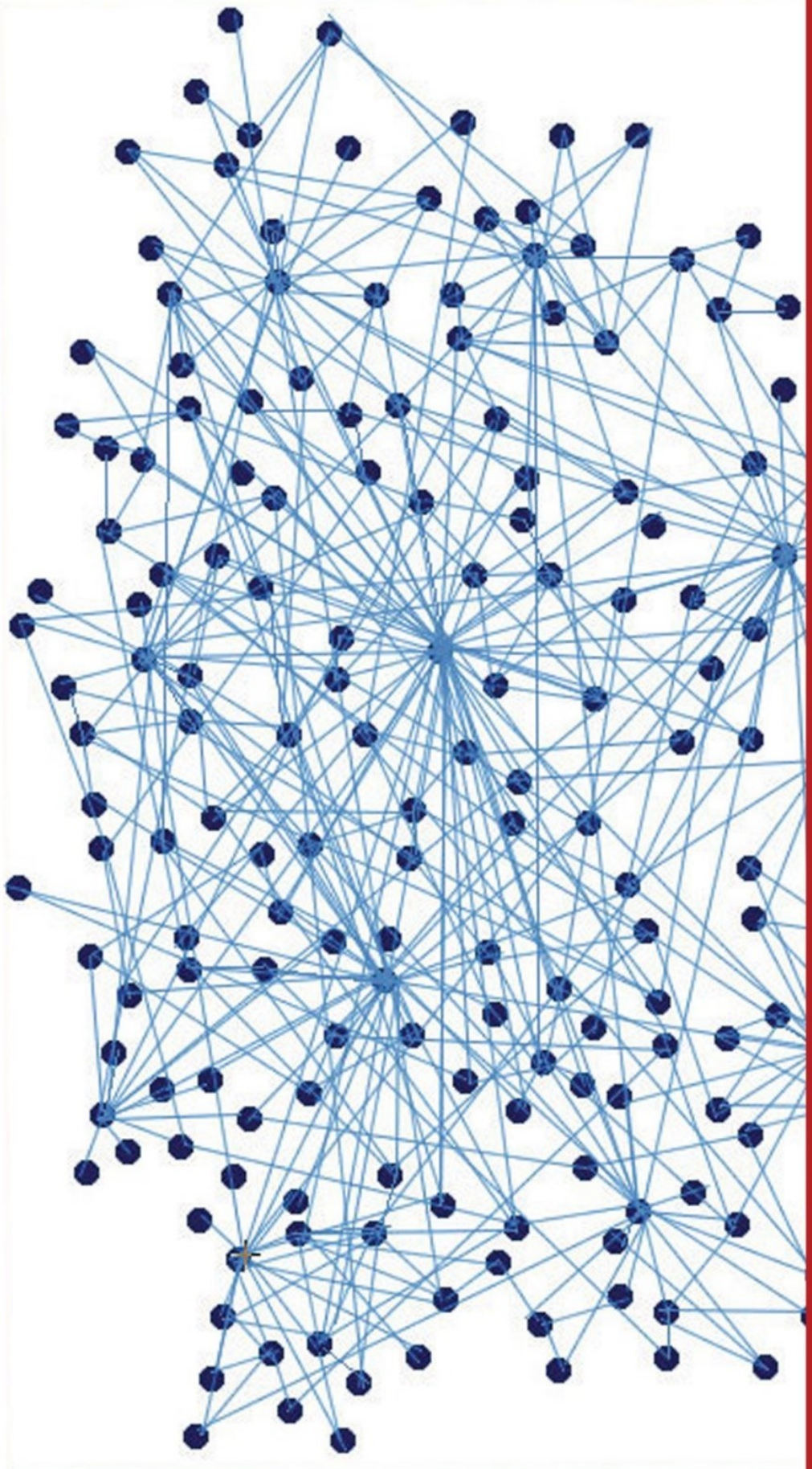
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LE MODIFICAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE E L'AUMENTO DI CAPITALE 3
2. IL DIRITTO DI OPZIONE 5
3. L'AUMENTO GRATUITO (NOMINALE) DEL CAPITALE SOCIALE 7
BIBLIOGRAFIA 8

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Le modificazioni del capitale sociale e l'aumento di capitale

Il legislatore disciplina agli articoli 2438-2447 c.c. le modificazioni del contratto sociale relative al capitale sociale.

Il capitale sociale può subire modificazioni in aumento o in diminuzione.

In questa sede ci si occuperà dell'aumento del capitale sociale.

Si possono distinguere due tipologie di aumento del capitale: reale o a pagamento, nominale o gratuito.

Nel caso di aumento del capitale sociale a pagamento vengono apportati nuovi conferimenti nella società.

Ai sensi dell'art. 2438 c.c. primo comma, l'aumento di capitale non può essere eseguito se le azioni emesse in precedenza non sono interamente liberate ovvero non sono stati versati i relativi conferimenti promessi.

In caso di violazione di tale norma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi.

Restano salvi in ogni caso gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione di tale norma.

È competente a deliberare tale aumento l'assemblea straordinaria dei soci.

Lo statuto può prevedere che tale competenza sia attribuita agli amministratori, ma in tale caso, ai sensi dell'art. 2443 c.c.:

- Deve essere predeterminato il valore nominale massimo che può raggiungere il capitale sociale;
- La delega agli amministratori per compiere la modifica in oggetto è conferita per un periodo massimo di cinque anni, salvo rinnovo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'art. 2439, secondo comma c.c., se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine nel quale le sottoscrizioni debbono essere raccolte, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima abbia espressamente previsto il caso di raccolta parziale.

Sottoscritte le nuove azioni, i soci debbono effettuare i conferimenti, che seguono le regole dettate per i conferimenti da effettuarsi nel momento della costituzione della società (ex art. 2440 c.c.).

I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono versare alla società almeno il venticinque per cento del valore nominale delle azioni sottoscritte allo stesso momento della sottoscrizione.

L'art. 2439 c.c. fa salve l'applicazione dell'art. 2342 comma quarto c.c.

Se previsto un soprapprezzo deve essere interamente versato all'atto della sottoscrizione.

L'art. 2346 c.c. dispone che il valore dei conferimenti non possa essere inferiore all'ammontare dell'aumento del capitale sociale deliberato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il diritto di opzione

Il diritto di opzione è il diritto dei soci di essere preferiti ai terzi e di avere precedenza su questi ultimi sulla sottoscrizione dell'aumento di capitale reale.

La sua funzione è di mantenere costante la proporzione con la quale ciascun socio partecipa alla società, nonché di mantenere inalterato il valore reale della partecipazione azionaria in presenza di riserve accumulate, che invece si ridurrebbe se le azioni fossero sottoscritte da terzi ad un prezzo inferiore al valore effettivo delle azioni precedentemente emesse.

Ai sensi dell'art. 2441 c.c., le azioni di nuova emissione debbono essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero delle azioni possedute e se vi sono obbligazioni convertibili il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio.

L'offerta di opzione deve essere depositata presso l'ufficio del Registro delle Imprese e contestualmente resa nota mediante un avviso pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità del documento e la certezza della data di pubblicazione; in mancanza mediante il deposito presso la sede della società.

Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a quindici giorni dalla pubblicazione dell'offerta.

Le azioni non optate non sono liberamente trasferibili dagli amministratori.

Il diritto d'opzione può essere oggetto di autonoma cessione ed acquista pertanto un proprio valore economico di scambio.

Nel caso in cui la S.p.A. non sia quotata, chi ha esercitato il diritto di opzione ha diritto di prelazione nella sottoscrizione delle azioni non optate se ne è stata fatta richiesta all'atto di esercizio del diritto di opzione.

Nel caso di società quotata, invece, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti sul mercato dagli amministratori per un determinato periodo di tempo ed il ricavato della vendita è attribuito a favore del patrimonio sociale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le azioni di nuova emissione saranno liberamente collocabili se gli azionisti non si avvarranno per l'intero del diritto di prelazione o i diritti offerti nel mercato regolamentato restano invenduti.

Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova emissione che devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Il diritto di opzione degli azionisti può essere escluso se sussiste un concreto interesse della società che deve essere protetto.

Il diritto di opzione degli azionisti è inoltre escluso per legge quando le azioni devono essere liberate mediante conferimenti in natura.

Il diritto di opzione può essere escluso o limitato con la delibera di aumento del capitale quando l'interesse della società lo esiga.

Nei casi in cui opera l'esclusione l'emissione delle nuove azioni deve avvenire con sovraprezzo al fine di ridimensionare il pregiudizio patrimoniale degli azionisti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. L'aumento gratuito (nominale) del capitale sociale

Come si è avuto modo di accennare in precedenza, l'aumento gratuito o nominale del capitale sociale non dà luogo all'apporto di nuovi conferimenti.

Ai sensi del primo comma dell'art. 2442 c.c., l'assemblea può aumentare il capitale imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.

Si osserva come non sia possibile però utilizzare per tale tipo di aumento di capitale la riserva legale, eccetto per la parte eccedente il venti percento della stessa.

Tale operazione ha come conseguenza il fatto di estendere sulle somme utilizzate per effettuare l'aumento di capitale gratuito il vincolo di indisponibilità che grava sul capitale sociale; pertanto, non sarà possibile disporre a favore dei soci di tali somme (che originariamente erano invece disponibili).

L'aumento nominale del capitale sociale si ottiene:

- Mediante l'aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione;
- Mediante l'emissione di nuove azioni che avranno le medesime caratteristiche di quelle già in circolazione e che dovranno essere attribuite gratuitamente agli azionisti in proporzione del portafoglio azionario, al fine di mantenere gli equilibri azionari preesistenti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

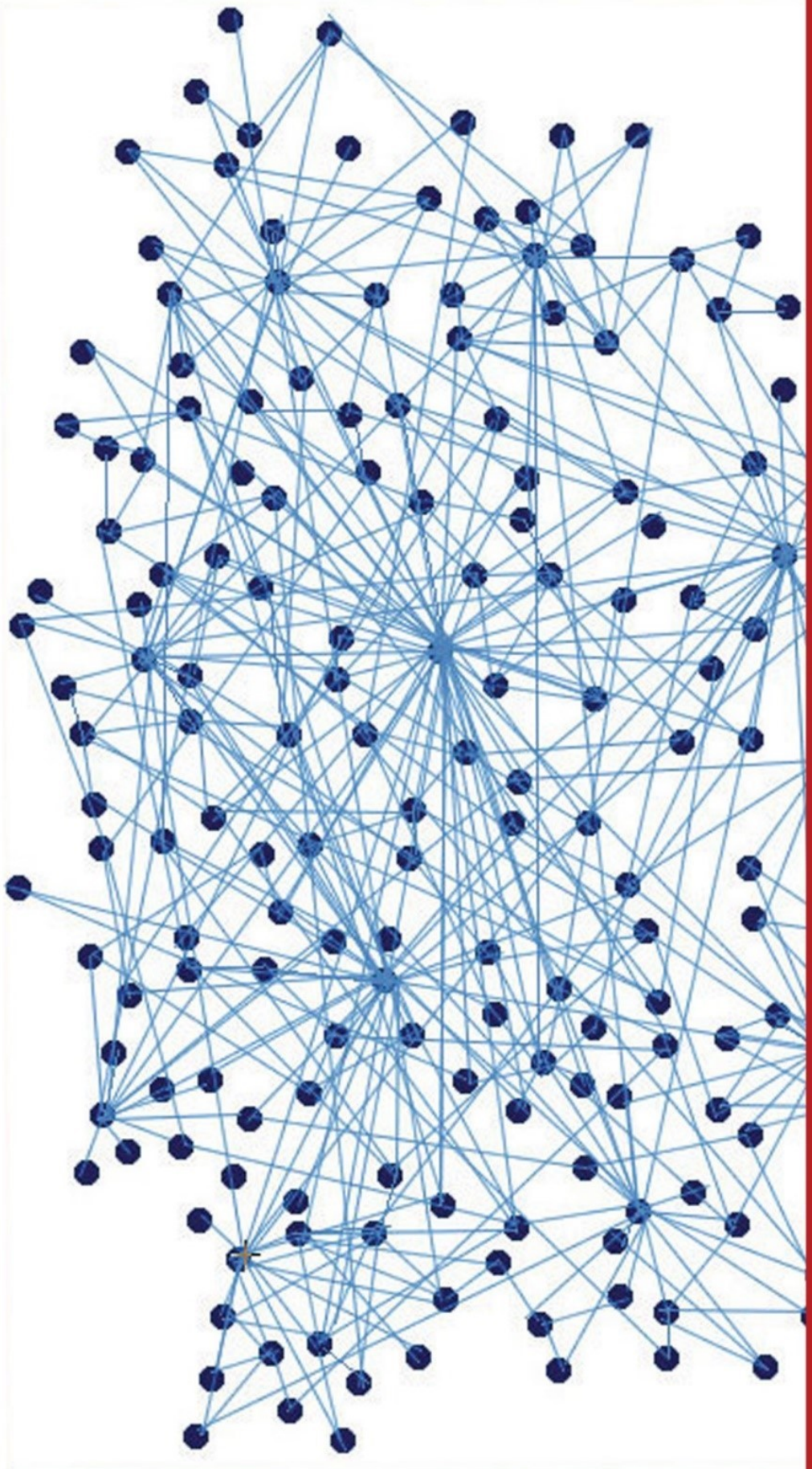
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA RIDUZIONE REALE DEL CAPITALE SOCIALE 3
2. LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE 5
3. UTILI, RISERVE E DIVIDENDI 7
BIBLIOGRAFIA 9

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La riduzione reale del capitale sociale

La riduzione del capitale sociale integra un caso di modifica del contratto sociale della S.p.A.

La riduzione del capitale sociale può essere reale o nominale.

Il caso di riduzione reale del capitale sociale è disciplinato dall'art. 2445 c.c.

Sono diverse le modalità con le quali la riduzione del capitale sociale può avvenire:

- Mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti;
- Mediante rimborso del capitale ai soci nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413 c.c.;
- Acquisto da parte della società di azioni proprie e successivo annullamento (ex art. 2357 bis c.c. n. 1). Se la S.p.A. è quotata deve tener conto delle regole fissate dalla CONSOB in merito.

La modalità di riduzione del capitale adottata deve comunque assicurare il principio di pari trattamento degli azionisti.

Nel caso particolare dell'acquisto di azioni proprie e di successivo annullamento, le azioni da annullare devono essere sorteggiate e deve ovviamente essere rimborsato ai relativi azionisti il valore nominale delle azioni stesse.

In considerazione del fatto che tale tipo di operazione può recare pregiudizio ai creditori sociali (nonché ai soci di minoranza) il legislatore ha disciplinato il procedimento di riduzione del capitale introducendo particolari cautele.

Ai sensi dell'art. 2413 c.c. infatti se la società ha emesso obbligazioni, la riduzione reale del capitale sociale non può aver luogo se non è rispettato il limite legale all'emissione.

Inoltre, il capitale sociale non può essere ridotto sotto la soglia del minimo legale di euro 50.000,00 ovvero il capitale minimo per la costituzione della S.p.A.

Il legislatore richiede inoltre che le ragioni e le modalità di riduzione siano indicate nell'avviso di convocazione dell'assemblea dei soci (art. 2445 secondo comma c.c.).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A tutela dei creditori sociali è attribuita loro legittimazione attiva a proporre opposizione contro la delibera di riduzione. L'opposizione deve essere proposta entro il termine di novanta giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese.

La proposizione dell'opposizione ha l'effetto di sospendere l'esecuzione della delibera sino all'esito del giudizio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La riduzione del capitale sociale per perdite

Il patrimonio reale della società è costituito dalle voci di bilancio componenti il patrimonio netto. Una delle voci che lo compongono è l'utile o la perdita d'esercizio.

In alcuni casi le perdite possono assumere un carattere talmente grave da incidere sul capitale sociale della società.

In tale caso l'operazione di riduzione del capitale sociale è un mero adeguamento del valore del capitale sociale stesso, in quanto il patrimonio netto contabilmente è già rappresentativo della grave perdita patrimoniale subita dalla società.

Il grado di gravità della perdita dipende dal fatto di essere minore o uguale ad un terzo del capitale sociale (primo caso) oppure superiore ad un terzo del capitale sociale (secondo caso, nel quale si verifica che la perdita ha ovviamente superato il valore delle riserve).

Nel primo caso, infatti, il legislatore prevede che la riduzione sia facoltativa e segue la disciplina generale delle modificazioni dell'atto costitutivo.

Un limite alla mancata riduzione del capitale sociale facoltativa è dato dal disposto dell'art. 2433 comma terzo c.c. per il quale se si verifica una perdita del capitale sociale non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Nel caso in cui la perdita sia superiore ad un terzo del capitale sociale, allora la riduzione del capitale sociale è obbligatoria.

In tale caso è necessario distinguere se la perdita abbia determinato la riduzione o meno del capitale sociale al di sotto dell'importo minimo legale (euro 50.000,00).

Se la perdita non ha determinato la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, trova applicazione l'art. 2446 c.c.

In tale caso gli amministratori hanno l'obbligo di convocare l'assemblea per l'adozione degli opportuni provvedimenti, previa presa visione della relazione nella quale è descritta la situazione patrimoniale della società.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita al di sotto di un terzo del capitale sociale, l'organo competente alla approvazione del bilancio ha l'obbligo di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In difetto gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al Tribunale che venga disposta la riduzione anzidetta.

Se la perdita invece riduce il capitale sociale al di sotto della soglia minima legale, ai sensi dell'art. 2447 c.c. deve essere convocata l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra almeno pari a detto minimo oppure la trasformazione della società; in caso contrario la società si scioglie (art. 2484, 1° comma, n. 4).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Utili, riserve e dividendi

A deliberare sulla distribuzione degli utili ai soci è l'assemblea (ordinaria) che approva il bilancio. Se il sistema di amministrazione e controllo adottato dalla società è il dualistico, allora è competente a deliberare l'assemblea previa approvazione del bilancio da parte del consiglio di sorveglianza.

Il legislatore però impone una destinazione specifica per una parte degli utili, diversa dalla distribuzione ai soci. È legittima, inoltre, la possibilità di prevedere statutariamente che parte degli utili conseguiti abbiano una destinazione diversa dalla distribuzione ai soci.

Un limite legale alla distribuzione degli utili è stato ampiamente discusso in precedenza e riguarda la perdita incidente sul capitale sociale conseguita negli esercizi precedenti.

L'art. 2430 c.c. disciplina la cosiddetta riserva legale, per la quale per ogni esercizio deve essere accantonato a tale riserva il 5% degli utili conseguiti, fino a quando la riserva abbia raggiunto l'importo pari al 20% del capitale sociale.

È fatto obbligo del legislatore il reintegro della riserva legale nel caso in cui diminuisca per qualsiasi ragione.

Lo statuto può istituire ulteriori riserve indisponibili, indicando la percentuale di utile da destinare alle stesse in ciascun esercizio.

Il carattere indisponibile delle riserve statutarie ha come conseguenza il fatto che l'assemblea ordinaria non possa deliberare la distribuzione degli utili ivi accantonati.

Ovviamente resta salva la possibilità della assemblea straordinaria di deliberare una modifica dello statuto con la quale si deroghi al carattere indisponibile di tale riserve e rendendo pertanto distribuibili gli utili accantonati ai soci.

Possono essere istituite dall'assemblea ordinaria che approva il bilancio le cosiddette riserve facoltative, le quali sono prive del carattere di indisponibilità caratterizzanti invece le riserve legali e statutarie.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'articolo 2433 secondo comma c.c. è chiaro nell'affermare che non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se gli utili non sono realmente conseguiti o non risultano dal bilancio regolarmente approvato, sono fittizi.

I dividendi erogati in violazione della predetta norma non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Ai sensi dell'art. 2627 c.c., gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve indisponibili, sono puniti con l'arresto fino ad un anno, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Il reato si estingue però se avviene la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

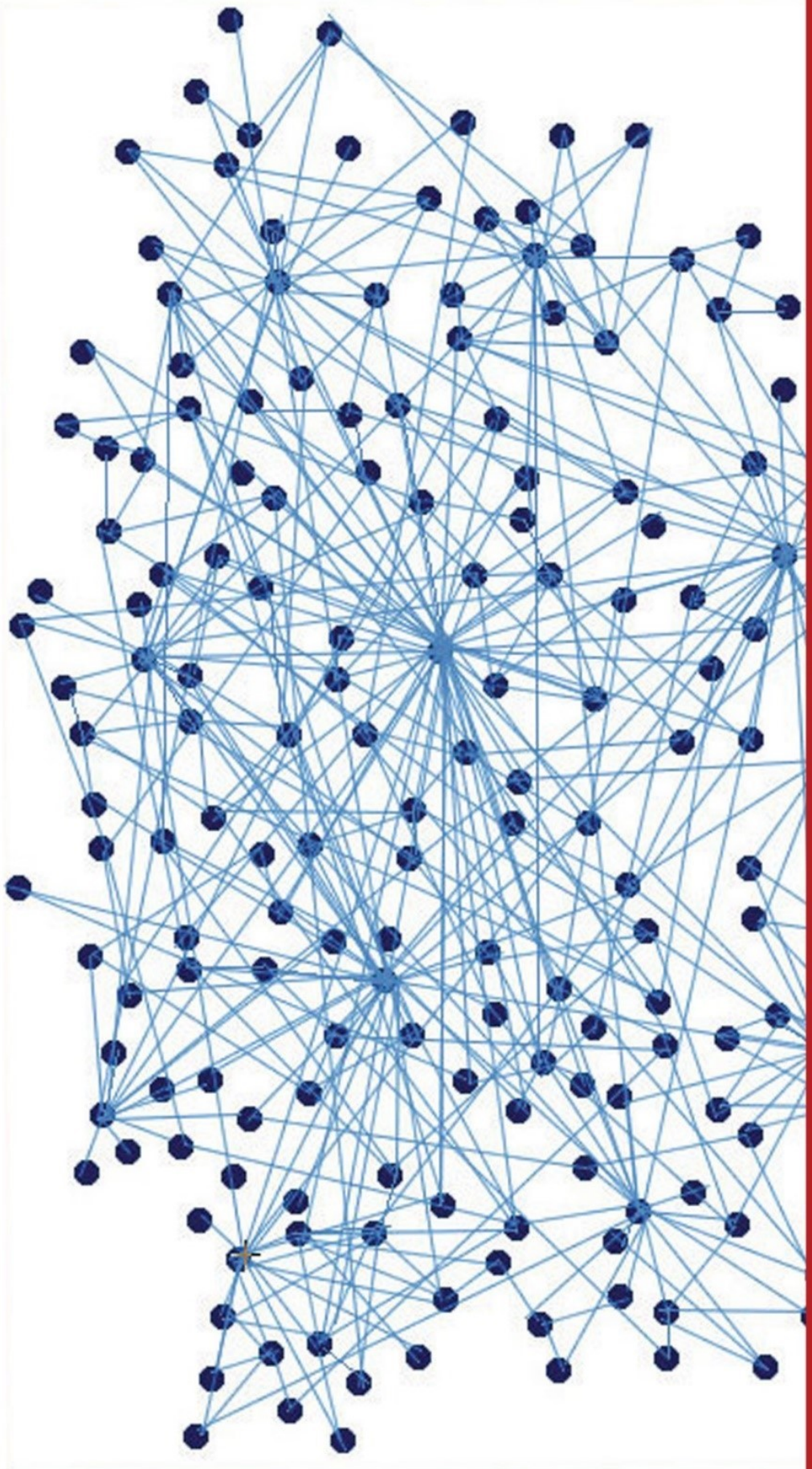
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LE OBBLIGAZIONI: NOZIONE, CARATTERI FONDAMENTALI E LIMITI DI EMISSIONE 3
2. IL PROCEDIMENTO DI EMISSIONE 6
3. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI 8
BIBLIOGRAFIA 10

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Le obbligazioni: nozione, caratteri fondamentali e limiti di emissione

Le obbligazioni sono titoli di credito di massa in quanto rappresentano una frazione di un finanziamento richiesto dalla società a terzi a titolo di mutuo, la cui disciplina è pertanto applicabile salvo quanto disposto altrimenti dal legislatore.

L'obbligazione si distingue dall'azione in quanto non attribuisce la qualità di socio.

Più sfumata risulta essere la differenza con gli strumenti finanziari partecipativi, ma questi ultimi costituiscono una categoria residuale nella quale convergono i titoli non qualificabili come azioni o obbligazioni.

Le obbligazioni attribuiscono il diritto al rimborso del capitale investito.

Ai sensi dell'art. 2411 c.c. tale diritto può essere in tutto o in parte subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori alla società. I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società. Tale disciplina è applicabile, inoltre, agli strumenti finanziari che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società.

Si possono annoverare diversi tipi di obbligazioni:

- Le obbligazioni a premio, le quali attribuiscono agli obbligazionisti il diritto di partecipare alla assegnazione mediante sorteggio o altra modalità di una utilità (in natura o in denaro);
- Le obbligazioni indicizzate, il cui tasso di remunerazione è collegato all'andamento del tasso di interesse o del valore di rimborso di un indice;
- Le obbligazioni in valuta estera;
- Le obbligazioni convertibili in azioni, le quali attribuiscono all'obbligazionista la facoltà di trasformare il credito vantato in partecipazione azionaria sia nella società finanziata, sia in una società a questa collegata;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Le obbligazioni con warrant o con diritto di opzione su azioni, le quali attribuiscono all'obbligazionista il diritto ulteriore di sottoscrivere o acquistare azioni di una società, pur mantenendo la titolarità delle obbligazioni;
- Le obbligazioni partecipative, nelle quali i tempi e l'entità degli interessi sono dipendenti dall'andamento economico della società (art. 2411 primo comma c.c.);
- Le obbligazioni subordinate, il cui rimborso avviene solo dopo il soddisfacimento integrale degli altri creditori, ma comunque prima degli azionisti.

Il codice civile detta una disciplina per le sole obbligazioni convertibili.

L'art. 2412 c.c. prescrive i limiti relativi all'emissione del prestito obbligazionario.

La società può emettere obbligazioni per una somma complessivamente non eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. A tale computo concorrono gli importi relativi alle garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società.

Tale limite può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali.

Non è soggetto al limite anzidetto - e non vi rientra nel calcolo del medesimo – l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

Il limite anzidetto e la deroga relativa alle obbligazioni emesse eccedenti tale limite perché destinate alla sottoscrizione di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale non trovano applicazione se le obbligazioni emesse sono destinate ad essere quotate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione o di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni (obbligazioni convertibili o con warrant).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La società può emettere legittimamente un prestito obbligazionario non osservando i limiti di cui all'art. 2412 c.c. se a ciò autorizzata dall'autorità governativa qualora ricorrano particolari ragioni che interessano l'economia nazionale.

Resta salva l'applicazione delle norme contenute nelle leggi speciali, in particolare per quanto riguarda l'emissione di obbligazioni ad opera delle Banche, materia disciplinata quasi esclusivamente dal Testo Unico Bancario.

Le vicende del prestito obbligazionario emesso dalla società sono influenti sulla eventuale delibera di riduzione del capitale sociale.

Infatti, ai sensi dell'art. 2413 c.c., la società che ha emesso il prestito obbligazionario non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'art. 2412 c.c risulterebbe violato. Sono esclusi da tale computo i presiti obbligazionari di cui all'art. 2413 terzo, quarto e quinto comma c.c.

Se la riduzione del capitale è obbligatoria o le riserve diminuiscono in conseguenza delle perdite, non possono distribuirsi utili fino a quando l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non raggiungano l'ammontare della metà del valore delle obbligazioni in circolazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il procedimento di emissione

Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione delle obbligazioni è deliberata dagli amministratori (art. 2410 primo comma c.c.).

In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio e deve essere depositata ed iscritta presso il Registro delle Imprese a norma dell'art. 2436 c.c.

Se ne ricorrono i presupposti, all'offerta sul mercato delle obbligazioni è applicabile la disciplina relativa alla offerta al pubblico di prodotti finanziari ex art. 94 ss. del Testo Unico Finanziario.

Le modalità di sottoscrizione sono fissate dal bando di emissione.

A seguito della sottoscrizione del titolo obbligazionario deve essere rilasciato il titolo (che però può essere anche dematerializzato), il quale può essere nominativo o al portatore, ma deve contenere quanto indicato dall'art. 2414 c.c.

Il prezzo delle obbligazioni, salvo per quelle convertibili, può essere inferiore al valore nominale.

Il procedimento di emissione delle obbligazioni convertibili in azioni è disciplinato dall'art. 2420 bis c.c., ai sensi del quale è competente a deliberare l'emissione di tale tipo di obbligazioni l'assemblea straordinaria.

Contestualmente a tale deliberazione deve essere deliberato l'aumento di capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione (si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'art. 2346 secondo, terzo, quarto e quinto comma c.c.).

La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale originariamente sottoscritto non è stato interamente versato.

Le obbligazioni convertibili devono essere offerte in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili anteriormente emesse ai sensi dell'art. 2441 primo comma c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La delibera di emissione del prestito obbligazionario convertibile deve contenere:

- Il rapporto di cambio tra obbligazione ed azione;
- Il periodo e le modalità di conversione.

Deve contestualmente deliberare l'aumento di capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni attribuite in conversione.

L'aumento di capitale deliberato sarà ad esecuzione differita e progressiva, poiché avverrà in conseguenza dell'esercizio del diritto di conversione.

Non si può fare a meno di osservare come durante la pendenza del periodo di conversione debbano essere contemperati i diversi interessi della società ad operare liberamente e degli obbligazionisti titolari del diritto di conversione a non vedere alterato il valore del diritto di conversione.

Come sopra ricordato, il legislatore ha pertanto previsto il diritto di opzione sulle obbligazioni convertibili di nuova emissione agli azionisti ed ai già titolari di obbligazioni convertibili (ex art. 2441 primo comma c.c.).

On presenza di un aumento gratuito del capitale sociale o di una riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è automaticamente modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione del capitale ai sensi dell'art. 2410 bis quinto comma c.c.

Si ricorda poi come la società non possa deliberare la riduzione reale del capitale sociale, la fusione con altra società, la scissione o la modificazione delle disposizioni dell'atto costitutivo sulla ripartizione degli utili sino a quando i termini fissati per la conversione non siano scaduti.

Il divieto può essere agevolmente superato grazie alla concessione da parte della società agli obbligazionisti di avvalersi della facoltà di conversione anticipata.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. L'organizzazione degli obbligazionisti

Il legislatore prevede che gli obbligazionisti abbiano un organo di rappresentanza: l'assemblea degli obbligazionisti (artt. 2415-2418 c.c.).

Tale organo non è previsto in caso di emissione del prestito obbligazionario da parte dello Stato o di enti pubblici.

Ai sensi dell'art. 2415 primo comma c.c. l'assemblea degli obbligazionisti delibera:

- Sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- Sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- Sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- Sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- Sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata dal C.D.A., dal consiglio di gestione o dal rappresentante degli obbligazionisti quando lo ritengono necessario o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentano il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.

Si applicano a tale assemblea le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale nel Registro delle Imprese.

Il rappresentante comune degli obbligazionisti è nominato dall'assemblea; se non è da questa nominato, ai sensi dell'art. 2417 comma secondo c.c. è nominato con decreto del Tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società.

Dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.

Ai sensi dell'art. 2418 c.c. il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Ha diritto di assistere

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

all'assemblea dei soci. Ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni anche nelle procedure concorsuali e nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.

L'organizzazione di gruppo non menoma il singolo obbligazionista del diritto di tutela del suo credito nei confronti della società.

Ai sensi dell'art. 2419 c.c. si osserva però che la legittimazione ad agire individualmente viene meno se ciò è incompatibile con le deliberazioni assembleari ex art. 2415 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

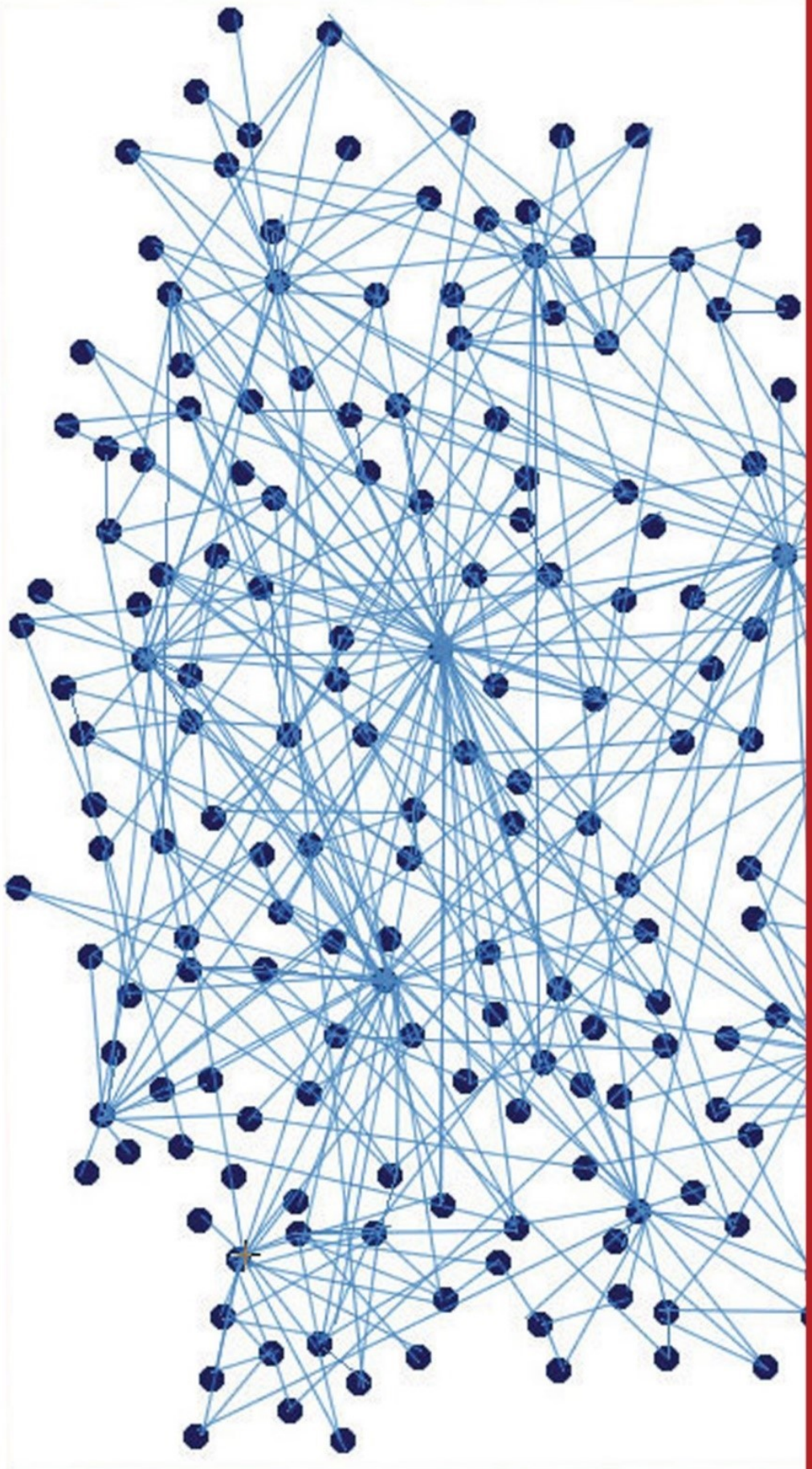
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL BILANCIO: NOZIONE E PRINCIPI FONDAMENTALI 3
2. LA STRUTTURA DEL BILANCIO 5
3. IL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL BILANCIO 7
BIBLIOGRAFIA 9

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il bilancio: nozione e principi fondamentali

L'imprenditore che per legge è obbligato alla tenuta delle scritture contabili deve redigere per ogni anno di esercizio di attività il bilancio.

Il bilancio è un documento di natura contabile ed informativa, sia per i soci sia per i terzi, che deve rappresentare in maniera chiara, veritiera e corretta la situazione patrimoniale e finanziaria della società, nonché il risultato economico dell'esercizio stesso (art. 2423 secondo comma c.c.).

Il bilancio di esercizio ha la precisa funzione giuridica di individuare il momento dal quale trova applicazione la normativa posta a salvaguardia dell'integrità del patrimonio sociale; inoltre è il presupposto per l'adozione di alcune delibere assembleari.

Il bilancio è redatto secondo dei criteri comuni, frutto del riassunto delle migliori prassi operative, che sono stati riassunti e raccolti dall'Organismo Italiano di Contabilità e sono stati denominati principi contabili nazionali.

Non hanno valore regolamentare e non hanno valore vincolante, forniscono però indicazioni per la corretta applicazione delle norme relative al bilancio.

Come sopra accennato, ai sensi dell'art. 2423 secondo comma c.c. il bilancio deve essere caratterizzato dalla chiarezza, che si esplica nelle norme relative alla struttura ed al contenuto del bilancio, dalla verità e dalla correttezza, che si esplicano nelle norme che fissano i criteri di valutazione dei cespiti patrimoniali.

Tali caratteri costituiscono le cosiddette clausole generali che permeano l'intera disciplina normativa della redazione del bilancio.

Altro criterio che deve essere tenuto in considerazione per la redazione del bilancio è la competenza rispetto all'esercizio dei ricavi e dei proventi finanziari, nonché degli oneri economici e finanziari, che non è sempre coincidente con il momento di incasso o di esborso di una somma di denaro.

Il bilancio è infatti di competenza, non di cassa.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Deve essere rispettato inoltre nella redazione del bilancio il principio della continuità per il quale devono essere adottati sempre i medesimi criteri redazionali, poiché la mutazione degli stessi renderebbe più difficile la comparazione dei bilanci nel tempo.

Solo ed esclusivamente in casi eccezionali è data la possibilità di mutare i criteri redazionali del bilancio, in tale caso però gli amministratori debbono motivare tale cambiamento nel documento denominato nota integrativa e spiegare in che modo influenzi la redazione del bilancio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La struttura del bilancio

Il bilancio è costituito da tre documenti, stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, al quale si è aggiunto un quarto documento con la riforma del 2015 ovvero il rendiconto finanziario.

Tali documenti sono accompagnati da alcune relazioni che non costituiscono parte integrante del bilancio: la relazione sulla gestione degli amministratori, la relazione del collegio sindacale e dal revisore legale dei conti.

Lo stato patrimoniale è la rappresentazione sintetica della composizione del patrimonio sociale. È una fotografia delle poste di carattere finanziario della società.

Evidenzia inoltre le voci del patrimonio netto della società.

Il contenuto dello stato patrimoniale è espressamente indicato all'articolo 2424 c.c., ai sensi del quale si struttura in due parti, una denominata attivo patrimoniale e l'altro passivo patrimoniale.

Nelle voci dell'attivo patrimoniale compaiono, contrassegnati con le lettere dell'alfabeto in carattere maiuscolo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (con separata indicazione della parte già richiamata);
B) Immobilizzazioni (suddivise in immateriali, materiali e finanziarie);
C) Attivo circolante (nel quale si annoverano le rimanenze ed i crediti);
D) Ratei e risconti.

Nelle voci del passivo patrimoniale compaiono, contrassegnati con le lettere dell'alfabeto in carattere maiuscolo:

A) Patrimonio netto: è composto da I) capitale II) riserva da sovrapprezzo delle azioni III) riserve di rivalutazione IV) riserva legale V) riserve statutarie VI) riserva per azioni proprie in portafoglio VII) altre riserve distintamente indicate VIII) utili (perdite) portati a nuovo IX) utile (perdita) dell'esercizio;
B) Fondi per rischi ed oneri;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

C) Trattamento di fine rapporto subordinato (TFRL);

D) Debiti: tra le sottovoci compaiono le obbligazioni e le obbligazioni convertibili;

E) Ratei e risconti.

Il conto economico è il riassunto delle operazioni di tipo economico, costi e ricavi, sostenuti dalla società nel corso dell'anno d'esercizio ed evidenzia il conseguimento di un utile o di una perdita finale.

Il conto economico è redatto secondo uno schema espositivo scalare indicato dall'art. 2425 c.c. nel quale si individuano alcune grandi voci:

A) Valore della produzione;

B) Costi della produzione;

C) Proventi ed oneri finanziari;

D) Rettifiche di valori di attività finanziarie;

E) Proventi ed oneri straordinari.

Tali voci raggruppano altre sottovoci.

La somma algebrica delle voci indicate con la lettera maiuscola individua contabilmente il risultato economico d'esercizio, che può essere un utile o una perdita.

Il rendiconto finanziario è il documento informativo contabile, reso obbligatorio con la riforma del 2015 (D. Lgs. n. 139 del 18 agosto 2015), con il quale sono rappresentati i flussi finanziari della società.

Ai sensi dell'art. 2425 ter c.c., dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

La nota integrativa (artt. 2427 – 2427 bis c.c.), il cui contenuto è discorsivo, permette a chi consulta il bilancio di avere maggiori informazioni relative alle voci sinteticamente indicate. Dalla nota integrativa devono inoltre risultare i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il procedimento di formazione del bilancio

Nel procedimento di formazione del bilancio sono coinvolti, nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo, tutti gli organi della società.

Ai sensi dell'articolo 2364 comma secondo c.c., l'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno – per l'approvazione del bilancio - entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Sono gli amministratori a redigere il progetto di bilancio.

Tale funzione non può essere delegata né al comitato esecutivo, né agli amministratori delegati.

Il progetto di bilancio con i relativi allegati e le relazioni sopra citate devono essere depositati in copia nella sede della società durante i quindici giorni antecedenti l'assemblea e fino alla approvazione del bilancio, affinché i soci possano prenderne visione.

L'assemblea ordinaria dei soci è competente a deliberare sulla approvazione del bilancio, pertanto può approvarlo o respingerlo.

Il bilancio approvato deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 2435 c.c.

Entro trenta giorni dalla approvazione una copia del bilancio, corredata dalle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 e dal verbale di approvazione deve essere a cura degli amministratori depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese o spedita al medesimo ufficio a mezzo di lettera raccomandata.

Ai sensi dell'art. 2434 bis c.c., le azioni previste dall'art. 2377 c.c. (annullabilità delle deliberazioni) e dall'art. 2379 c.c. (nullità delle deliberazioni) non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione dell'esercizio successivo, producendosi un effetto sanante.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su ci il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale. Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità tiene conto delle ragioni di questa.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

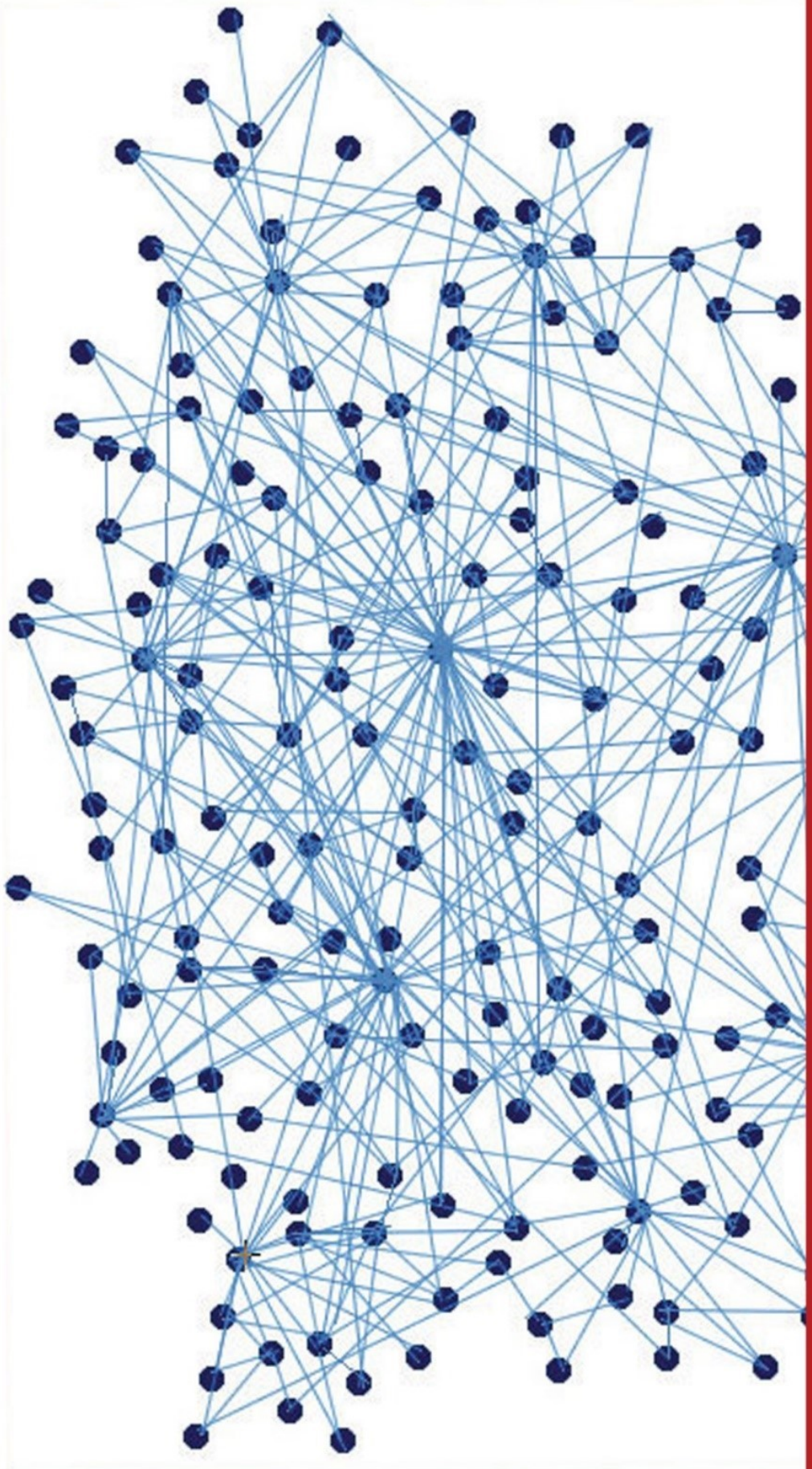
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LO SCIOGLIMENTO DELLA S.P.A. E LO STATO DI LIQUIDAZIONE 3

2. IL PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE E LA CANCELLAZIONE DELLA SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE 5

3. LA SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI 7

BIBLIOGRAFIA 8

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Lo scioglimento della S.p.A. e lo stato di liquidazione

Le cause di scioglimento della S.p.A., S.a.p.a. (società in accomandita per azioni) e s.r.l. sono indicate espressamente all'art. 2482 c.c. In particolare, la società si scioglie:

- Per il decorso del termine;
- Per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea appositamente convocata non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- Per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- Per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quando disposto dagli artt. 2447 e 2482 ter c.c.;
- Nelle ipotesi previste dagli articoli 2437 quater e 2437c.c.;
- Per deliberazione dell'assemblea;
- Per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Ai sensi dell'art. 2485 primo comma c.c., gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere agli adempimenti di cui all'art. 2484 terzo comma c.c. In caso di ritardo od omissione, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi.

Gli effetti dello scioglimento si determinano in conseguenza delle prime cinque ipotesi elencate dalla data di iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori accertano la causa ed in caso di deliberazione assembleare dalla data dell'iscrizione di questa nel medesimo Ufficio.

Al verificarsi di una delle cause di scioglimento della società non consegue l'immediata estinzione della società, la quale invece entra nella fase di liquidazione.

Ai sensi dell'art. 2487 bis secondo comma c.c. alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione di società in liquidazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Lo stato di liquidazione ha la funzione di permettere alla società di organizzarsi e provvedere al pagamento dei creditori sociali ed alla ripartizione dell'eventuale residuo attivo tra i soci.

Ai sensi dell'art. 2486 c.c. al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese della nomina dei liquidatori e della consegna a questi dei libri contabili, gli amministratori conservano il potere di gestire la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale. Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in tale fase.

Lo stato di liquidazione della società si ripercuote anche sui poteri dell'assemblea dei soci.

Alla questione "alcune delibere modificative dello statuto sono compatibili o meno con lo stato di liquidazione della società" gli interpreti non rispondono uniformemente.

La risposta a tale questione è affermativa, fino a quando non sia iniziata la distribuzione dell'attivo, nel caso modifica del contratto sociale per fusione della società.

Ai sensi dell'art. 2487 ter c.c. la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione previa eliminazione della causa di scioglimento.

La revoca dello stato di liquidazione avviene con deliberazione dell'assemblea straordinaria ed ha effetto solo trascorsi sessanta giorni dall'iscrizione presso il Registro delle Imprese della relativa deliberazione, slavo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso.

Qualora entro tale termine i creditori anteriori all'iscrizione abbiano proposto opposizione, è rimessa al Tribunale la competenza in merito alla decisione se debba procedersi o meno con la revoca.

Ai sensi dell'art. 2437 primo comma lettera d) c.c. ai soci che non abbiano concorso alla deliberazione della revoca dello stato di liquidazione è attribuito il diritto di recesso dalla società.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il procedimento di liquidazione e la cancellazione della società dal registro delle imprese

Ai sensi dell'art. 2487 primo comma c.c., contestualmente all'accertamento della causa di scioglimento debbono convocare l'assemblea straordinaria dei soci affinché deliberi:

- Il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- La nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- I criteri in base ai quali si devono svolgere la liquidazione; i poteri dei liquidatori e gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, compreso il suo esercizio provvisorio in funzione del migliore realizzo.

La convocazione dell'assemblea a tali fini non è necessaria se la causa di scioglimento verificata sia tra quelle di cui all'art. 2484, numeri 2) 4) 6) e vi abbia già provveduto l'assemblea oppure l'atto costitutivo o lo statuto non avessero già previsto in materia.

I liquidatori possono essere revocati dall'assemblea o quando sussiste una giusta causa dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del pubblico ministero.

Ai sensi dell'art. 2489 c.c. i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, salvo diversa disposizione statutaria ovvero adottata in sede di nomina.

I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

Ai sensi dell'art. 2491 c.c. se i fondi disponibili risultassero insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti. I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

prestazione da parte del socio di idonee garanzie. I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione dei doveri di cui all'art. 2491 c.c.

Ai sensi dell'art. 2492 c.c. compiuta la liquidazione i liquidatori debbono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo.

Il bilancio sottoscritto dai liquidatori, corredato dalle relazioni previste dalla legge, è depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

Ciascun socio è legittimato a proporre reclamo al Tribunale entro i novanta giorni successivi a tale deposito. La sentenza fa stato anche riguardo ai soci non intervenuti.

Se il termine di novanta giorni è decorso senza la proposizione di reclami, ai sensi dell'art. 2493 c.c. il bilancio di liquidazione finale si intende approvato.

I liquidatori sono liberati di fronte ai soci, salvo gli obblighi relativi alla distribuzione dell'attivo risultante da bilancio.

Inoltre, la quietanza rilasciata senza riserve all'atto del pagamento dell'ultima quota di riparto comporta approvazione del bilancio indipendentemente dalla decorrenza del termine.

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

L'art. 2495 secondo comma c.c. ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Si osserva poi come i creditori possano comunque chiedere il fallimento della società entro un anno dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La società in accomandita per azioni

La società in accomandita per azioni (s.a.p.a.) è disciplinata da codice civile agli articoli 2452-2461.

Si caratterizza per la necessaria compresenza di due tipi di soci: il socio accomandate ed il socio accomandatario. Il socio accomandatario è illimitatamente responsabile per le obbligazioni sociali; il socio accomandate risponde esclusivamente per la quota di capitale sottoscritta. La partecipazione sociale è rappresentata da azioni.

Il socio accomandatario è altresì di diritto amministratore della società ed in quanto tale è soggetto agli obblighi degli amministratori della S.p.A.

Ai sensi dell'art. 2454 c.c. alla s.a.p.a. sono applicabili le norme relative alla S.p.A. in quanto compatibili.

Ai sensi dell'art. 2455 c.c. l'atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari ed ai sensi dell'art. 2453 c.c. la denominazione della società è costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari, con l'indicazione di società in accomandita per azioni.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

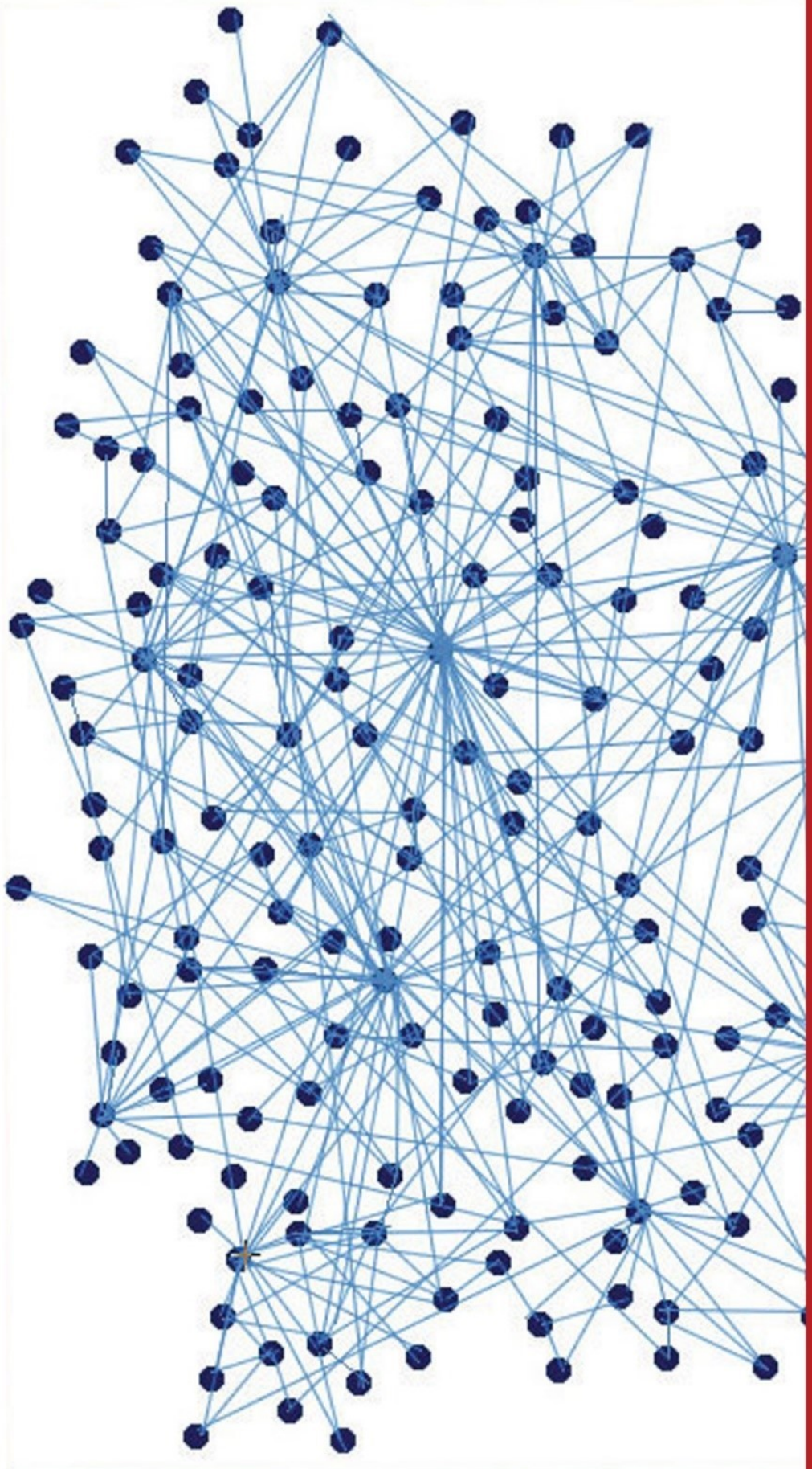
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA TRASFORMAZIONE: NOZIONE E CARATTERI ESSENZIALI 3
2. LA TRASFORMAZIONE OMOGENEA: IL PROCEDIMENTO 6
3. LA RESPONSABILITÀ DEI SOCI 8
BIBLIOGRAFIA 9

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La trasformazione: nozione e caratteri essenziali

La trasformazione è il risultato di un procedimento per il quale una società che ha adottato un certo modello-tipo organizzativo sceglie successivamente di adottare un altro modello tipico di organizzazione societaria.

Originariamente il codice civile del 1942 regolava esclusivamente la trasformazione di una s.n.c. nonché della s.a.s., ma il passaggio era consentito solo per le società lucrative.

La società cooperativa non poteva trasformarsi in una società lucrativa, dovendosi pertanto estinguere il contratto societario per contrarne uno nuovo.

La riforma del 2003 ha innovato la disciplina della trasformazione (artt. 2498 – 2500 novies c.c.), facendo cadere buona parte dei limiti previsti dal codice.

Attualmente la disciplina in vigore prevede due tipi di trasformazione: quella omogenea e quella eterogenea.

La trasformazione omogenea si ha quando la società passa da un tipo ad un altro di società lucrativa, il legislatore in tal caso non prevede sia estinta la società preesistente per costituirne una nuova, ma tratta la vicenda come una modifica del contratto sociale precedentemente concluso.

Ai sensi dell'art. 2498 c.c. con la trasformazione l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione, verificandosi la cosiddetta continuità dei rapporti giuridici.

La funzione della trasformazione consiste nella possibilità data ai soci di adeguare il modello organizzativo prescelto alle nuove esigenze riscontrate dalla attività imprenditoriale.

L'art. 2500 ter c.c. disciplina la trasformazione da società di persone a società di capitali, l'art. 2500 sexies c.c. il caso inverso.

La trasformazione di società con scopo mutualistico in società a scopo lucrativo comportano invece un mutamento della causa del contratto sociale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La legge speciale continua a vietare la trasformazione della società cooperativa a mutualità prevalente in società lucrativa.

A seguito della riforma del 2003 invece è oggi possibile trasformare le altre società cooperative in società lucrative o consorzi (ex artt. 2545 decies-2545 undecies).

Altri casi di trasformazione eterogenea, oltre a quelli appena citati, sono identificabili nella trasformazione di società di capitali in: cooperative, consorzi, società consortili, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute, fondazioni e viceversa (art. 2500 septies c.c.).

L'art. 2500 septies terzo comma c.c. richiede che la deliberazione della trasformazione eterogenea da società di capitali sia assunta con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che si assumono la responsabilità illimitata.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 2500 septies c.c. è richiamata l'applicazione dell'art. 2500 sexies c.c. in quanto compatibile.

L'art. 2500 octies c.c. disciplina invece la trasformazione eterogenea in società di capitali, ai sensi del quale la deliberazione di trasformazione deve essere assunta:

- nei consorzi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consorziati;
- nelle comunioni di aziende alla unanimità;
- nelle società consortili e nelle associazioni con la maggioranza richiesta dalla legge o dall'atto costitutivo per lo scioglimento anticipato.

La trasformazione di associazioni in società di capitali può essere esclusa dall'atto costitutivo o per determinate categorie di associazioni dalla legge; non è comunque ammessa perle associazioni che abbiano ricevuto contributi pubblici oppure liberalità e oblazioni del pubblico (art. 2500 octies, comma terzo c.c.).

Il capitale sociale della società risultante dalla trasformazione è diviso in parti uguali fra gli associati, salvo diverso accordo degli stessi.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2500 octies c.c., le trasformazioni di fondazioni in società di capitali è disposta dall'autorità governativa, su proposta dell'organo competente. Le azioni o quote sono assegnate secondo le disposizioni dell'atto di fondazione, o in mancanza dell'art. 31 c.c.

Ai sensi dell'articolo 2500 novies c.c., la trasformazione eterogenea ha effetto dopo sessanta giorni dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari previsti dal legislatore e salvo che vi sia il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Entro il predetto termine i creditori possono fare opposizione e sarà il Tribunale competente a decidere in merito all'opportunità della trasformazione.

Autorevole dottrina sostiene che le trasformazioni eterogenee indicate dal legislatore siano le uniche possibili nel nostro ordinamento giuridico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La trasformazione omogenea: il procedimento

Ai sensi dell'art. 2500 ter c.c. la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salvo diversamente disposto dal contratto sociale, in ogni caso però al socio che non ha concorso alla decisione spetta il diritto di recesso.

La disciplina attualmente vigente si differenza alquanto rispetto a ciò che aveva previsto originariamente dal legislatore, il quale richiedeva per il compimento di tale operazione straordinaria il consenso di tutti i soci.

Se la trasformazione riguarda una società di capitali è necessario che questa venga deliberata dall'assemblea straordinaria da adottare nelle S.p.A. non quotate con maggioranze rafforzate.

Se la società di capitali è quotata, ai sensi dell'art. 2500 sexies c.c. il legislatore prevede che vi sia il consenso dei soci che a seguito della trasformazione diventano illimitatamente responsabili dell'adempimento delle obbligazioni sociali.

La delibera di trasformazione, la cui finalità è quella di adattare l'organizzazione della società al nuovo modello giuridico adottato, deve rispondere ai requisiti di forma e di contenuto richiesti dal legislatore per il tipo di modello societario prescelto e rispettare gli adempimenti prescritti dalla legge per la regolare costituzione (art. 2500 c.c.).

Ai sensi del secondo e terzo comma dell'art. 2500 c.c. l'atto di trasformazione è soggetto, infatti, alla disciplina prevista per il tipo adottato ed alle forme di pubblicità relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione dell'ente che effettua la trasformazione.

La trasformazione ha effetto dall'ultimo degli adempimenti pubblicitari al cui adempimento si è obbligati.

Con la riforma del 2003 il legislatore ha introdotto nel codice civile la disciplina della trasformazione regressiva: da società di capitali a società di persone (art. 2500 sexies c.c.).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In tale caso, come già sopra è stato ricordato, il legislatore prevede che sia prestato il consenso a tale operazione da parte di tutti i soci che con la trasformazione assumeranno la responsabilità illimitata.

È opportuno osservare che a seguito della trasformazione da società di capitali a società di persone, i soci che assumeranno la responsabilità illimitata delle obbligazioni sociali, saranno illimitatamente responsabili anche per quelle sorte anteriormente alla trasformazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La responsabilità dei soci

La trasformazione è una operazione straordinaria che può incidere sulla responsabilità patrimoniale dei soci.

Nel caso disciplinato dall'art 2500 quinques c.c. infatti la trasformazione ha l'effetto di far venire meno la responsabilità patrimoniale personale illimitata dei soci.

Il legislatore però ha previsto che tale restrizione di responsabilità operi solo per il futuro, rimanendo pertanto i soci illimitatamente responsabili per i crediti sociali sorti anteriormente alla trasformazione, a meno che i creditori sociali non abbiano dato il loro consenso alla trasformazione.

Si presume inoltre che i creditori vi abbiano acconsentito se nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione loro inviata con modalità tali da consentire di provare l'avvenuto ricevimento, non abbiano espresso il loro diniego alla trasformazione.

In tale sede è opportuno osservare che, nel caso in cui a seguito della trasformazione permanga una responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali sorte anteriormente alla operazione straordinaria di cui si discute, i soci sono passibili di fallimento se l'insolvenza è dovuta totalmente o parzialmente ad obbligazioni sorte anteriormente alla trasformazione.

Nel caso, inverso, di trasformazione regressiva sopra citata, in conseguenza della quale la società di capitali si trasforma in società di persone (art. 2500 sexies c.c.), i soci assumono la responsabilità illimitata anche delle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

Con riferimento alle sole pagine relative ai temi trattati.

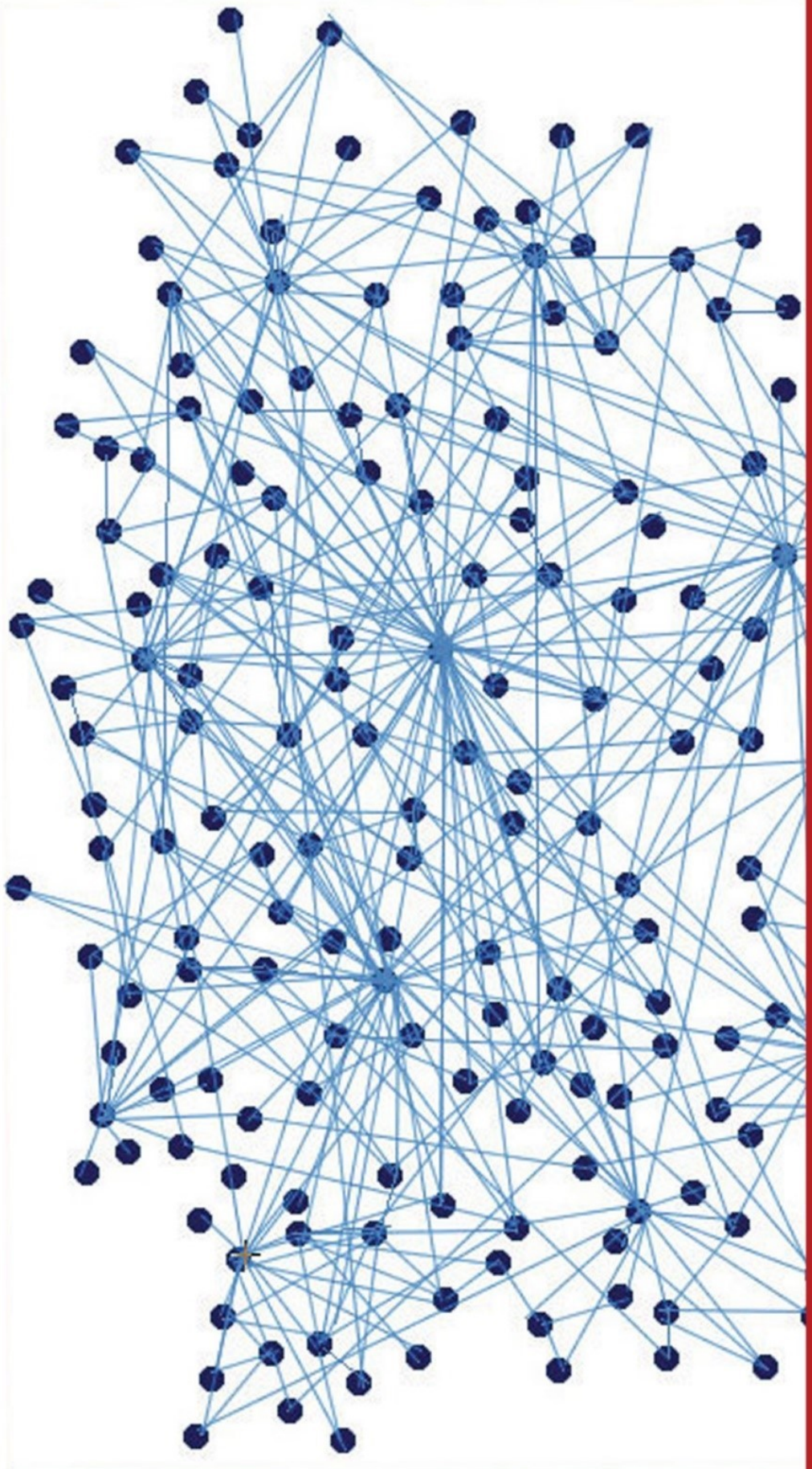
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA FUSIONE: NOZIONI E CARATTERI ESSENZIALI. IL PROGETTO DI FUSIONE 3
2. IL PROGETTO DI FUSIONE E CENNI ALLA DISCIPLINA DELL'INVALIDITÀ 6
3. LA SCISSIONE 8
BIBLIOGRAFIA 10

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La fusione: nozioni e caratteri essenziali. Il progetto di fusione

La fusione è generalmente definita come la unificazione di due o più società in una sola. Tale operazione straordinaria può avvenire:

- con la unione di due o più società in una unica e nuova società (fusione in senso stretto);
- con la cosiddetta incorporazione in una società preesistente di una o più società fuse (fusione per incorporazione).

La fusione ha la funzione di concentrare in una sola unità i patrimoni delle diverse aziende, pur continuando a svolgere le attività delle società fuse.

A seguito della fusione non sorge pertanto alcuna necessità di regolare i rapporti con i terzi e fra i soci, i quali continuano a svolgersi con la società che risulta dalla fusione.

Nell'ottica della continuità dell'attività aziendale delle società fuse, si può affermare che giuridicamente la fusione sia una modifica del contratto sociale che non implica l'estinzione dello stesso.

Si osserva poi come il legislatore abbia espressamente previsto come la partecipazione alla fusione non è consentita alla società che si trova in stato di liquidazione e abbia già iniziato la distribuzione dell'attivo (art. 2501 secondo comma c.c.), salvo quanto disposto dall'art. 2505 quater c.c. nel caso in cui alla fusione partecipino solo società con capitale non rappresentato da azioni.

Ai sensi dell'art. 2501 ter c.c., l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige un progetto di fusione che deve contenere:

- Tipo, denominazione o ragione sociale, sede delle società partecipanti alla fusione;
- Atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con le eventuali modificazioni derivanti dalla fusione;
- Il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l'eventuale conguaglio in denaro;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Le modalità di assegnazione delle azioni o delle quote della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- La data dalla quale le azioni o quote partecipano agli utili;
- La data a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante;
- Il trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- I vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione.

Si osserva in particolare che il rapporto di cambio è il rapporto in base al quale saranno assegnate ai soci delle società fuse le azioni o le quote della nuova società.

Ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione redige la situazione patrimoniale delle società stesse riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione è depositato nella sede della società ovvero pubblicato sul sito internet di questa.

Oltre alla situazione patrimoniale l'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi economicamente e giuridicamente il progetto di fusione ed in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote (ex art. 2501 quinquies c.c.).

Tale relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio e devono essere segnalate le eventuali difficoltà di valutazione.

Ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c. inoltre uno o più esperti per ciascuna società redigono una relazione avente ad oggetto la congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Secondo quanto previsto dall'art. 2501 septies c.c., nella sede delle società partecipanti alla fusione devono restare depositati in copia ovvero pubblicati sul sito internet delle stesse durante il termine di trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione (salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime) e finchè la fusione sia decisa:

- Il progetto di fusione con le relazioni ove redatte indicate negli articoli 2501 quinquies e 2501 sexies c.c.;
- I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;
- Le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'art. 2501 quater c.c.

I soci hanno diritto di prender visione di tali documenti e di ottenerne gratuitamente copia.

Il progetto di fusione è depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo dove hanno sede le società partecipanti alla fusione. In alternativa al deposito presso il Registro delle Imprese il progetto di fusione è pubblicato sul sito internet della società, con modalità atte a garantire la sicurezza del sito medesimo, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

Tra l'iscrizione o la pubblicazione nel sito internet del progetto e la data fissata per la deliberazione in ordine alla fusione devono intercorrere almeno trenta giorni, salvo rinuncia dei soci con consenso unanime.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il progetto di fusione e cenni alla disciplina dell'invalidità

Ai sensi dell'art. 2502 c.c. la fusione è decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto.

Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene:

- nelle società di persone con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno degli utili, slava la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione;
- nelle società di capitali secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto.

La decisione di fusione può apportare al progetto solo le modifiche che non incidono sul diritto dei soci o dei terzi.

L'articolo 2503 c.c. prevede espressamente che la fusione possa essere attuata una volta trascorsi sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2502 bis, a meno che:

- non vi sia il consenso dei creditori delle società che vi partecipano anteriori all'iscrizione o alla pubblicazione ex art. 2501 ter terzo comma c.c.;
- sia effettuato il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso o il deposito delle somme corrispondenti presso una banca;

tranne nel caso in cui la relazione degli esperti ex art. 2501 sexies c.c. sia redatta per tutte le società partecipanti alla fusione da un'unica società di revisione, la quale asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria delle predette società renda non necessarie garanzie a tutela dei summenzionati creditori.

Qualora non ricorra alcuna di tale eccezione, i creditori possono proporre opposizione entro il termine di sessanta giorni.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'atto di fusione deve risultare da atto pubblico e deve essere depositato per l'iscrizione a cura del notaio o dei soggetti cui compete l'attività gestoria delle società risultante dalla fusione entro trenta giorni nell'Ufficio del Registro delle Imprese dei luoghi dove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione e di quella che ne risulta (ex art .2504 c.c.).

Gli effetti della fusione sono disciplinati dall'art. 2504 c.c., il quale conferma come la società che risulti dalla fusione assume e prosegue i rapporti delle società fuse anteriori alla fusione.

Gli effetti si esplicano quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 c.c., ma nella fusione mediante incorporazione può essere stabilita una data successiva.

Ai sensi dell'art. 2504 ultimo comma c.c., la fusione attuata mediante costituzione di una nuova società di capitali o mediante incorporazione di una società di capitali non libera i soci a responsabilità illimitata per le obbligazioni delle rispettive società partecipanti alla fusione anteriori all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c., se non risulta che i creditori vi abbiano dato consenso.

L'art. 2504 quater c.c. prevede che una volta eseguite le iscrizioni dell'atto di fusione a norma del secondo comma dell'art. 2504 c.c., l'invalidità dell'atto di fusione non possa essere più pronunciata.

Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci ed ai terzi danneggiati dalla fusione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La scissione

Con la scissione una società assegna l'intero suo patrimonio (scissione totale) a più società, preesistenti o di nuova costituzione o parte del suo patrimonio (scissione parziale) anche ad una sola società e le relative azioni o quote ai suoi soci.

Si osserva come nel caso di scissione totale la società si estingua senza liquidazione della stessa poiché l'attività continua a mezzo della società beneficiaria della scissione.

Il progetto di scissione, elaborato dall'organo amministrativo delle società partecipanti la scissione, redige un progetto il cui contenuto ricalca quello del progetto di fusione per espresso richiamo legislativo, ma ai sensi dell'art. 2506 bis primo comma c.c. esso deve altresì indicare l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie e dell'eventuale conguaglio in denaro.

Dal progetto di scissione devono poi risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie.

Nel caso in cui il progetto preveda una attribuzione delle partecipazioni ai soci non proporzionale alla loro quota di partecipazione originaria, il progetto deve prevedere il diritto dei soci che non approvino la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla scissione redige la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa conformemente a quando indicato dagli artt. 2501-quater e 2501-quinquies.

La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre:

- illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote;
- indicare il valore effettivo del patrimonio netto assegnato alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.

La predetta relazione non è l'unica che deve essere redatta ai sensi dell'art. 2506 ter c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In tale sede però si ritiene sufficiente osservare come, ai sensi dell'art. 2506 ter comma quarto c.c., con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti dai commi precedenti del medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 2506 quater primo comma c.c. la scissione ha effetto come regola generale dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del Registro delle Imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.

Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari (simili a quelli della fusione) relativi alla società stessa.

Con riguardo al profilo delle responsabilità patrimoniali facenti capo alla società scissa, si osserva come degli elementi del passivo la cui destinazione non sia desumibile dal progetto:

- nell'ipotesi di assegnazione dell'intero patrimonio della società scissa alle società beneficiarie rispondano in solido le società beneficiarie;
- nell'ipotesi di assegnazione parziale del patrimonio della società scissa, risponderanno la società scissa e le società beneficiarie.

Si osserva però come ciascuna società sia solidalmente responsabile dei debiti della società scissa (non soddisfatti dalla società a cui fanno capo) nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

Con riferimento alle sole pagine relative ai temi trattati.

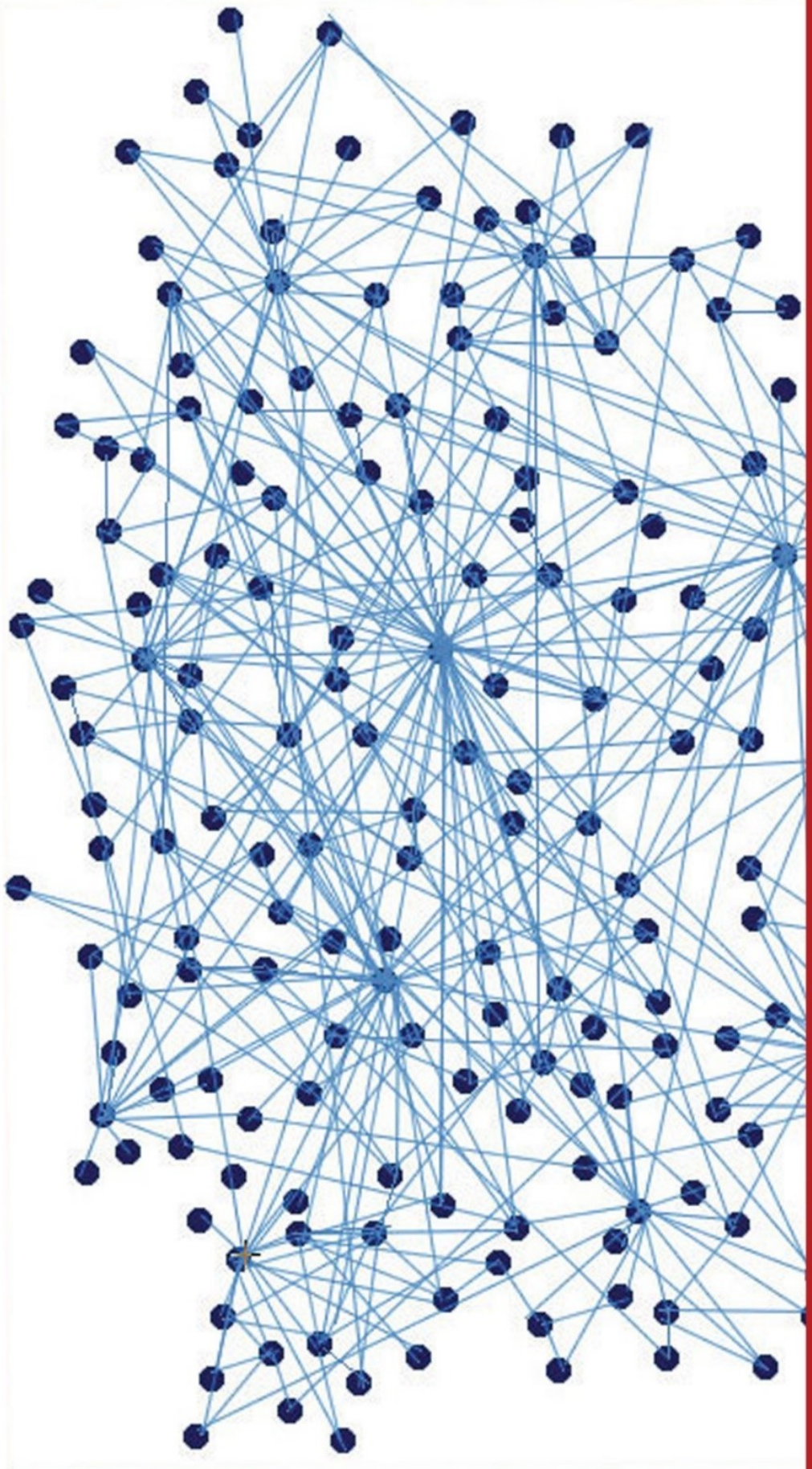
- "DIRITTO COMMERCIALE – VOL. 2 DIRITTO DELLE SOCIETA'" – G. F. CAMPOBASSO, edito UTET, Torino (ultima edizione aggiornata).
- "DIRITTO COMMERCIALE – a cura di Marco CIAN", edito G. Giappichelli Editore, Torino (ultima edizione aggiornata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. EVOLUZIONE STORICA DELLA S.R.L. 3

1.1 INQUADRAMENTO 3
1.2 L'INTRODUZIONE DELLA S.R.L. NEL CODICE CIVILE DEL 1942 4
1.3 L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA DAL 1942 AL 2003 6
1.4 LA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA NELLA RIFORMA DEL DIRITTO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI 7
1.5 IL MODELLO LEGALE DELLA S.R.L. ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA RIFORMATA 7

2. IL MODELLO VIGENTE DELLA S.R.L. E L'ATTO COSTITUTIVO 8

2.1 L'AUTONOMIA STATUTARIA NELLA CONFIGURAZIONE DEL MODELLO S.R.L. 8
2.2 CONSIDERAZIONI SULL'UTILIZZAZIONE DELLA S.R.L. DA PARTE DEGLI OPERATORI 8
2.3 L'ATTO COSTITUTIVO: NATURA ORGANIZZATIVA 9
2.4 INTERPRETAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO 9
2.5 LO STATUTO NELLA S.R.L. 10

3. FORMA E CONTENUTO DELL'ATTO COSTITUTIVO 12

3.1 LA FORMA DELL'ATTO COSTITUTIVO 12
3.2 GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO COSTITUTIVO 12
3.3 LA CIRCOLAZIONE DELLE QUOTE PRIMA DELL'ISCRIZIONE 13
3.4 IL CONTROLLO NOTARILE SULL'ATTO COSTITUTIVO 14

BIBLIOGRAFIA 16

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Evoluzione storica della s.r.l.

1.1 Inquadramento

Il tipo sociale a responsabilità limitata è stato oggetto, nel corso degli anni, a numerosi provvedimenti legislativi che hanno contribuito a plasmare la sua struttura e le regole di disciplina che lo informano.

Tutti questi interventi normativi sembrano, però, condividere talune finalità il cui raggiungimento pare, da sempre, essere un obiettivo del Legislatore nazionale.

In via di prima approssimazione, infatti, sembra utile osservare che le regole di governo delineate dalla novella riformatrice, datata 2003, per il tipo in esame, lungi dal generare una "profonda frattura" con la normativa di riferimento ante riforma, pare, in una qualche misura, un "ritorno al passato" giacché si situa, dal punto di vista delle aspirazioni, nel solco tracciato dalle prime bozze di codici di commercio anteriori alla codificazione del 1942 nonché dei progetti riformatori degli di metà del XX° secolo.

La legge di riforma, come osservato dalla dottrina, ha, quindi, dato deciso impulso al fenomeno, che era già in atto, di graduale allontanamento del tipo sociale a responsabilità limitata da quello azionario.

Larga parte della dottrina, sulla scia dell'intento mai troppo celato del Legislatore, seguita dalla giurisprudenza più sensibile, aveva, già prima dell'entrata in vigore della legge di riforma, auspicato il distacco concettuale tra i due modelli societari, valorizzando l'effetto benefico, sotto il profilo operativo, di tale cesura concettuale.

Anche lo sviluppo delle scienze comparatistiche ha dato il proprio contributo, come ben colto dalla dottrina di settore, all'incremento della portata del fenomeno a cui si è poc'anzi accennato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Per questo motivo sembra utile fare precedere all'esame dell'influenza esercitata sul modello s.r.l. dalla legge di riforma una breve disamina storico-comparatistica tesa ad evidenziare i profili di continuità e quelli di discontinuità nella disciplina normativa del tipo.

1.2 L'introduzione della s.r.l. nel Codice Civile del 1942

Il modello a responsabilità limitata, introdotto nel 1942, era, in buona sostanza, caratterizzato:

a) dalla volontà dei soci di adottare un regime di responsabilità limitata per le obbligazioni sociali;
b) dall'impossibilità he la partecipazione sociale fosse rappresentata da azioni ossia che la medesima potesse essere incorporata in un titolo di credito;
c) da un'organizzazione di stampo corporativo che, benché fosse informata alla distribuzione del potere decisionale e di quello gestorio tra assemblea dei soci e organo amministrativo, imponeva, ad ogni modo, ad entrambi gli organi l'agire collegiale.

L'idea di fondo che trasversalmente dominava questo segmento del sapere giustcommercialistico era quella di fornire un modello societario utile a mandare ad effetto esigenze imprenditoriali di modeste dimensioni ove forti erano i legami tra i componenti della base sociale e intensi i rapporti di fiducia correnti tra i medesimi.

A differenza dei modelli societari a base personalistica, tuttavia, il tipo societario a responsabilità limitata avrebbe risposto alle istanze di quanti, pur non volendo abdicare alla gestione personale e diretta dell'impresa, avessero voluto circoscrivere la propria responsabilità, per le obbligazioni sociali, al capitale investito nell'ente.

Tale modello, dunque, lungi dall'incrinare l'antico rapporto corrente tra gestione e responsabilità, consentiva a quanti volessero intraprendere attività di impresa, in forma societaria, di accedere al beneficio della responsabilità limitata controbilanciando detto vantaggio con l'asservimento alle regole di disciplina proprie del tipo prescelto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'archetipo societario in esame è passato, dunque, preso atto di quanto testé ricordato, da una fase di preliminare accostamento ai modelli personalistici (così era ipotizzato nei primi progetti di codici di commercio all'inizio del 1900[1]) ad un graduale avvicinamento al tipo azionario[2] .

Tale processo di sviluppo è culminato, nel 1942, con la codificazione dell'idea per cui la società a responsabilità limitata si sarebbe dovuta atteggiare come una società azionaria "alleggerita" di talune formalità e connotata da una maggiore snellezza strutturale e regolamentare.

Il fenomeno appena descritto portò parte della dottrina a discorrere di "piccola società per azioni senza azioni".

La svalutazione dell'autonomia strutturale e disciplinare del modello a responsabilità limitata rispetto a quello azionario ed il correlativo "appiattimento" regolamentare su quest'ultimo, si accentuò a tal punto, nel pensiero di taluni autori, da invocare una sostanziale omologia tra i due tipi societari.

Questi ultimi, unificati dalla comune base del rischio limitato al capitale investito, si sarebbero, poi, caratterizzati, sulla scorta delle dimensioni dell'attività di impresa e della propensione di ciascuno al mercato del capitale di rischio, grazie ad innesti di regimi disciplinari speciali.

---

[1] In merito pare opportuno, quantomeno, ricordare due esperimenti di inizio '900.
Il primo fu quello elaborato dalla "Commissione Ministeriale per la riforma della legislazione commerciale" presieduta dal Prof. Vivante, la quale, nel 1921, delineò i confini della c.d. società a garanzia limitata. Tale modello societario, che non poteva avere più di 25 soci, si strutturava intorno ad un sistema di bilanciamento tra la concessione della responsabilità limitata e talune garanzie in favore dei terzi ossia:

- il capitale sociale doveva avere un certo ammontare e doveva essere interamente versato al momento della costituzione della società;
- tale incombenza era garantita dalla responsabilità personale dei soci fondatori;
- era possibile, dietro conferimenti supplementari di capitale, emettere quote supplementari;
- il bilancio doveva essere reso pubblico.

Tale società, in estrema sintesi, si presentava come una forma associativa con tratti spiccatamente personalistici, connotata dalla responsabilità limitata e dotata di ampi margini di flessibilità. Il secondo progetto, invece, fu quello elaborato dalla "Commissione reale per la riforma dei codice – sottocommissione B" presieduta dal prof. D'Amelio, la quale, nel 1925, si propose di conservare la forma associativa a garanzia limitata, ma con lievi modifiche ispirate dalla novella legislativa che in Francia, in quel periodo, disciplinò detta fattispecie.

[2] Al riguardo sembra opportuno ricordare la soluzione interpretativa accolta dal "progetto De Gregorio" che, nel 1966, cercò di rinnovare, in ottica sistematica, il modello societario a responsabilità limitata per come codificato nel 1942.
Detto progetto di riforma, seppur in una peculiare logica di contingentamento della base associativa, anticipò, seguendo l'insegnamento impartito dal Prof. Vivante, molte delle linee di tendenza poi seguite da Legislatore riformista del 2003.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'evoluzione storica ha smentito, tuttavia, tale impostazione teorica venendo, gradualmente, a delineare l'esistenza di una netta linea di demarcazione tra i vari modelli di governo del fenomeno associativo in àmbito di impresa.

1.3 L'evoluzione della disciplina della società a responsabilità limitata dal 1942 al 2003

Il rilancio del tipo societario a responsabilità limitata ha visto concorrere l'opera di tutti i formanti di cui, ad opinione di acuta dottrina, si compone il nostro ordinamento giuridico.

Hanno "spinto" in tal senso le opinioni di quella parte della dottrina, seguita dalla giurisprudenza più sensibile al tema, che ha, da sempre, accentuato l'autonomia dei due modelli di organizzazione societaria dell'attività di impresa, valorizzando, tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto quello regolamentare, le peculiarità dello schema s.r.l.

Il contributo più significativo, però, è giunto dal Legislatore il quale ha provveduto a sottolineare, anche sotto il profilo applicativo, la distanza concettuale che corre tra i due modelli societari in esame.

Prima di esaminare la portata innovativa della riforma del 2003 pare opportuno, invero, dedicare qualche accenno al contributo apportato dalle scienze comparatistiche al tema in commento.

Il panorama societario che si è spiegato alla vista del Legislatore del 2003 era, sul punto, tanto variegato da consentire al medesimo di "edificare" un modello societario a responsabilità limitata attingendo dalle esperienze consolidatesi oltre i confini nazionali.

Senza soffermarsi troppo diffusamente su tale aspetto sembra sufficiente ricordare come molti sistemi giuridici, di derivazione romanistica o germanica, conoscano modalità di ibridazione tese a combinare, in via concettuale, la limitazione della responsabilità (per le obbligazioni sociali al capitale investito nell'esercizio dell'attività di impresa) con tratti fisionomici dei modelli associativi

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

a vocazione personalistica, disegnando, per questa via, assetti societari soluzioni concrete a peculiari istanze provenienti dal mondo della piccola e media imprenditoria.

1.4 La società a responsabilità limitata nella riforma del diritto delle società di capitali

L'articolato quadro normativo, tra sedimentazioni nazionali e spinte propulsive di matrice sovranazionale, è stato, come poc'anzi accennato, rimodulato in ossequio alla Legge 3 ottobre 2001, n. 366 con la quale il Parlamento ha delegato il Governo ad adottare, tra l'altro, ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle società di capitali e cooperative entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

1.5 Il modello legale della s.r.l. alla luce della disciplina riformata

Le direttive portanti di siffatta legge delega possono essere così sintetizzate:

- autonomo ed organico corpus normativo per la s.r.l.;
- incremento dei profili di autonomia, strutturale e disciplinare, tra il modello azionario e quello a responsabilità limitata;
- rilevanza centrale del socio all'interno del modello;
- valorizzazione dei legami contrattuali sorti tra i componenti dell'ente associativo;
- incremento della flessibilità del tipo in ossequio al principio di libertà delle forme organizzative.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il modello vigente della s.r.l. e l'atto costitutivo

2.1 L'autonomia statutaria nella configurazione del modello s.r.l.

La legge di riforma, attuando le direttive fissate dal Parlamento con la delega, assegna ampio margine operativo all'autonomia privata nell'edificazione del modello societario a responsabilità limitata che meglio risponda alle esigenze imprenditoriali dei soci.

Tale autonomia può, in concreto, declinarsi nei modi che seguono:

1) può far tendere lo schema associativo verso le regole che informano le società a vocazione personalistica;
2) può, al contrario, fare assumere all'ente associativo una connotazione più marcatamente capitalistica di quanto non avesse immaginato il Legislatore predisponendo le regole suppletive;
3) può, nei limiti fissati inderogabilmente dalla legge (art. 2483 c.c.), aprire le porte sociali al mercato del capitale di credito;
4) può ampliare i contorni di figure normative predefinite oppure regolare aspetti di disciplina che il Legislatore abbia omesso di considerare;
5) può dare attuazione ad uno tra i molteplici messi a disposizione dalla normativa di settore;
6) può semplificare un procedimento oppure introdurre specificazioni al medesimo.

2.2 Considerazioni sull'utilizzazione della s.r.l. da parte degli operatori

Quanto sin qui osservato in tema di concrete applicazioni dell'autonomia privata in àmbito societario non consente, però, ad opinione della migliore dottrina, di elevarla a valore assoluto e, come tale, di ritenere che la medesima non soffra limitazione alcuna.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La snellezza e la duttilità del modello in questione deve, di necessità, essere bilanciata con il riconoscimento della responsabilità limitata.

Per questa ragione all'autonomia di cui i soci sono portatori risultano sottratte le materie che costituiscono il presupposto per il riconoscimento di tale regime di responsabilità. Per rendere maggiormente chiara l'asserzione può essere utile precisare, a titolo esemplificativo, che risultano insensibili alle scelte autonomistiche dei soci la disciplina della costituzione e, in parte significativa, quella dei conferimenti, le regole di formazione del capitale sociale, quelle di finanziamento dell'ente, quelle di tenuta delle scritture contabili e le norme afferenti alla pubblicità delle decisioni.

2.3 L'atto costitutivo: natura organizzativa

Nelle società di capitali, di regola, si distingue tra atto costitutivo e statuto.

Con il primo i soci/il socio, a seconda che l'ente sia uni o plurisoggettivo, possono predisporre un sistema multiforme di regole che costituiscono il patrimonio genetico della società, fissando, in termini documentali, la volontà dei privati di esercitare, in forma sociale, l'attività di impresa.

Con il secondo, invece, si evoca il concetto di "insieme di pattuizioni volte a regolare l'organizzazione ed il funzionamento della società".

2.4 Interpretazione dell'atto costitutivo

In merito al suo contenuto la dottrina ha assunto opinioni differenziate.

Parte di essa, adottando un atteggiamento sostanzialista, ritiene che l'atto costitutivo debba indicare solo gli elementi essenziali tipici, rimandando ad altro documento per la fissazione delle regole di funzionamento ed amministrazione della società che, unitamente al primo, darebbe luogo ad un unico documento complesso.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Altra parte della medesima, invece, adottando una soluzione letterale, ritiene che tutti gli elementi decritti dall'art. 2463 c.c. debbano essere contenuti nell'atto costitutivo posto che la loro ricomprensione in un diverso documento renderebbe patente un difetto di forma di quest'ultimo.

2.5 Lo statuto nella s.r.l.

La lettera della norma in commento, se paragonata all'art. 2328 c.c. in materia di s.p.a., tradisce, preso atto di quanto sopra esposto, un particolare atteggiamento del Legislatore della riforma, il quale, per la s.r.l., pare, come precisato dal comma 2°, n. 7 della stessa disposizione, aver prediletto, per questo tipo sociale, l'unicità di contesto documentale tra le regole che ne informano la genesi e quelle che ne disciplinano la vita.

La differente formulazione letterale tra le due norme non sembra, ad opinione della dottrina più diffusa, supportare una diversa scelta normativa sul punto, potendosi giustificare sulla scorta di valutazioni attinenti al diverso grado di scindibilità tra gli aspetti personalistici e quelli organizzativi nei due modelli societari di riferimento (maggiore nei modelli azionari e minore in quelli a responsabilità limitata).

Per queste ragioni, quindi, lo schema unitario è da interpretarsi "suggerito" e non già "imposto" dal Legislatore di tal che i soci, mediante una apposita manifestazione di volontà, riescano a disarticolare le regole fondative dell'ente (atto costitutivo) da quelle relative al suo funzionamento interno (statuto).

Esercitata quest'ultima opzione teorica i due documenti, dovendo essere tra loro equiparati, necessiteranno, entrambi, della forma pubblica e saranno, di conseguenza, soggetti agli incombenti notarili previsti dalla legge.

Il tratto di disciplina maggiormente dubbio tra gli interpreti attiene all'applicazione, in via analogica, dell'art. 2328, ultimo comma, c.c. al caso in cui, disarticolato l'atto costitutivo, una norma contenuta nello statuto contrasti con il primo.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La dottrina maggioritaria, benché contro di essa si staglino le acute osservazioni di taluni importanti autori, opina nel senso favorevole all'operatività del fenomeno analogico atteso che una volta scelta una modalità di redazione analoga a quella tipizzata per le s.p.a. anche le regole interpretative ad essi applicabili dovrebbero conformarsi a tale opzione. Ogni altro aspetto relativo alla procedura di costituzione della s.r.l. è regolato attraverso un rinvio, effettuato dall'art. 2463, ultimo comma c.c., alle speculari norme in materia di s.p.a.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Forma e contenuto dell'atto costitutivo

3.1 La forma dell'atto costitutivo

L'art. 2463, comma 2°, c.c. impone, tanto che l'atto costitutivo abbia struttura contrattuale quanto che il medesimo abbia struttura unilaterale, la forma dell'atto pubblico ai fini della validità.

Fissando tale forma ad substantiam il Legislatore ha messo fuori gioco, per il modello societario in questione, la modalità costitutiva, invece ammessa per i modelli azionari, per pubblica sottoscrizione, la quale, peraltro, secondo autorevole opinione dottrinale, sarebbe stata, ad ogni modo, impercorribile per le s.r.l. sulla scorta del divieto fissato dall'art. 2468, comma1° c.c.

3.2 Gli elementi essenziali dell'atto costitutivo

Il Legislatore fissa, all'art. 2463 c.c., il contenuto minimo del medesimo che può essere reso nel modo che segue:

1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il Comune[3] ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'attività[4] che costituisce l'oggetto sociale;
4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro[5], sottoscritto e di quello versato;

[3] Ciò significa che la sede della società è costituita solo dal Comune non rilevando l'indirizzo all'interno del medesimo. Non si applicherà, quindi, l'art. 111 ter delle disp. att. c.c.
In caso di variazione:
- dell'indirizzo all'interno del medesimo Comune basterà che gli amministratori comunichino la modifica al registro delle imprese;
- del Comune sarà, invece, necessario l'espletamento della procedura tesa alla formale modifica dell'atto costitutivo.

Nel modello s.r.l., a differenza di quanto accade nel tipo s.p.a., il trasferimento della sede sociale non può essere delegato all'organo gestorio posto che le modificazioni afferenti l'atto costitutivo sono inderogabilmente affidate alla decisione collegiale dei soci.

[4] Detta formulazione (che si ritrova anche in materia di s.p.a.) sottende l'intento del Legislatore di prescrivere, in modo specifico, il programma imprenditoriale che i soci, mediante la forma associativa prescelta, si propongono di attuare.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito crediti e ai beni conferiti in natura;
6) la quota di partecipazione di ciascun socio;
7) le norme relative al funzionamento della società[6], indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza[7];
8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
9) l'importo globale, almeno approssimativo, della spesa per la costituzione poste a carico della società.

3.3 La circolazione delle quote prima dell'iscrizione

Il tema più spinoso sollecitato dal generico rinvio posto in essere dall'art. 2463, comma3°, c.c. attiene all'applicabilità della regola contenuta nell'ultimo comma dell'art. 2331 c.c. al modello s.r.l. posto che il divieto di emettere azioni prima della data di iscrizione nel Registro delle imprese mal si concilia con un modello societario in cui la partecipazione non può essere rappresentata da azioni.

Le soluzioni interpretative astrattamente adottabili possono essere:

- quella di ritenere che, prima dell'iscrizione, non sussistano partecipazioni sociali;
- quella di opinare, al contrario, che essendo il divieto connesso all'emissione e non alla circolazione delle azioni si potrebbe immaginare un'estensione della regola al tipo s.r.l. di

[5] L'elasticità del tipo societario in commento, in realtà, consente di rimanere entro il suo perimetro anche a fronte di conferimenti inferiori alla soglia ivi contemplata purché superiore ad 1 Euro e con il rispetto delle peculiari regole fissate dall'art. 2463, commi 4° e 5°, c.c. per come introdotti dal Decreto Legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito in Legge 9 agosto 2013 n. 99.

[6] Tale formulazione, atteso l'ampio margine concesso in materia all'autonomia privata, si presta ad accogliere molti elementi che posso arricchire il contenuto minimo dello statuto come, per esempio, l'indicazione della durata della società, le cause di scioglimento della medesima, l'emettibilità di titoli di debito, l'individuazione di diritti particolari per i soci, le modalità di assunzione delle decisioni e le materie rimesse alla competenza decisionale dei soci, l'enucleazione di ulteriori cause di recesso oltre a quelle legali, le regole afferenti la circolazione delle partecipazioni e l'adozione di modelli alternativi di amministrazione.

[7] La dottrina non dubita, benché la formulazione normativa sia piuttosto vaga, che, anche nel modello s.r.l., occorra indicare i modelli gestori scelti dai soci, le regole afferenti la nomina, le competenze, le modalità di funzionamento dell'organo di amministrazione e i soggetti a cui compete la rappresentanza dell'ente. Se non sono individuate le persone cui compete il potere gestorio la lacuna non potrà essere colmata in via interpretativa, dovendo i soci o l'assemblea provvedere alla nomina con atto successivo. Se, invece, non viene indicato il riparto del potere di rappresentanza esso deve ritenersi conferito a tutti i titolari del potere gestorio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

tal che sarebbe cedibile prima della iscrizione, nel rispetto delle regole fissate dagli art. 1406 e ss. c.c., la posizione contrattuale di socio;

- quella di ritenere, ancora, che la partecipazione sociale possa essere negoziata, prima dell'iscrizione, non già come bene immateriale presente, ma futuro, collegando, quindi, la sua efficacia, in coerenza con le regole fissate dal contratto sociale, al perfezionamento dell'iter di iscrizione presso il registro delle imprese competente.

3.4 Il controllo notarile sull'atto costitutivo

Il predetto rinvio normativo, attuato dall'art. 2463, comma 3° c.c., riguarda anche l'art. 2330 c.c. e si completa con il precetto dell'art. 138 bis della legge 16 febbraio 1913 n. 89 dal cui combinato disposto emergono tanto i confini operativi quanto le regole sanzionatorie sottese all'intervento notarile nel processo di costituzione dell'ente in commento.

In merito sembra sufficiente ricordare che, in passato, con il deposito presso il Registro delle imprese dell'atto costitutivo, si apriva la fase omologatoria del procedimento di costituzione della società.

Il Tribunale del luogo n cui aveva sede la società, secondo l'opinione nettamente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza, aveva il compito di effettuare un controllo di legittimità, anche sostanziale, teso ad accertare la conformità alla legge della costituenda società.

Per esigenze di semplificazione tale giudizio di omologazione è stato soppresso nel novembre del 2000, sopravvivendo, come facoltativo, per le sole modifiche successive dell'atto costitutivo.

Tale impianto normativo è stato confermato dalla legge di riforma.

Da ciò discende che il controllo di legalità in sede costitutiva è rimesso, in toto, al notaio rogante.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Anche in tale sede grava sul notaio, ad opinione della dottrina più diffusa, l'obbligo di verificare l'adempimento di tutte le condizioni previste dalla legge alla stregua di quanto accadeva in sede di omologazione giudiziaria.

La dottrina non ha raggiunto soluzioni univoche in ordine all'ampiezza di tale controllo.

L'opinione che sembra, ad oggi, prevalere tende a sovrapporre, quanto ad estensione, il controllo notarile a quello che era effettuato, vigente la normativa abrogata, dall'autorità giudiziaria in sede di omologa. L'area del controllo notarile si estenderà, in questa prospettiva, alla verifica della compatibilità ordinamentale dell'assetto organizzativo dell'ente per come disegnato dai soci.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

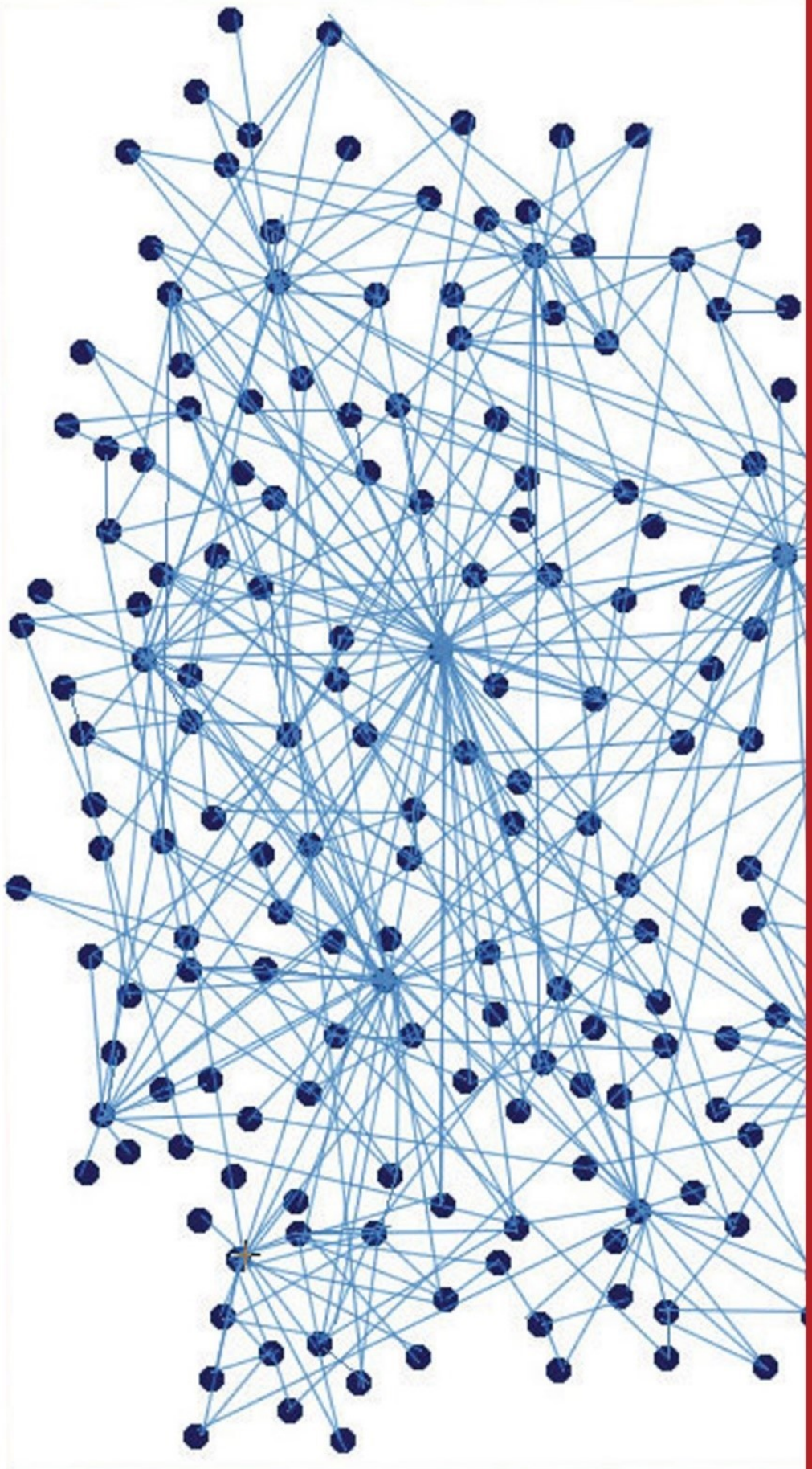
- G. M. Presti – M. Rescigno "Corso di diritto commerciale", Zanichelli, Bologna, 2015, Volume II, pag. 220-221.
- O. Cagnasso "La società a responsabilità limitata" in "Trattato di Diritto Commerciale", diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2007, Volume V, pagg. 4-36.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. NOZIONE E TIPI DI CONFERIMENTI 3

1.1 I PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ART. 2464 C.C. 3
1.2 L'OGGETTO DEI CONFERIMENTI 4
1.3 L'ART. 2464, 3° E 4° COMMA, C.C. 4

2. I CONFERIMENTI IN NATURA ED I CONFERIMENTI DI OPERA E SERVIZI. LA MANCATA ESECUZIONE DEI CONFERIMENTI 5

2.1 NOZIONE DI CONFERIMENTO IN NATURA 5
2.2 LA LIBERAZIONE INTEGRALE DEI CONFERIMENTI IN NATURA 5
2.3 LA RELAZIONE DI STIMA 6
2.4 L'ART. 2464, 5° E 6° COMMA, C.C. 7
2.5 L'INADEMPIMENTO DEL SOCIO 8
2.6 PROCEDIMENTO 8

3. IL FINANZIAMENTO DEI SOCI 10

3.1 L'ART. 2467 C.C.: CONSIDERAZIONI GENERALI 10
3.2 I PRESUPPOSTI PREVISTI DALLA NORMA. I SOGGETTI, LA TIPOLOGIA DEI FINANZIAMENTI E LE CIRCOSTANZE A CUI È SUBORDINATA 11
3.3 LA POSTERGAZIONE 12
3.4 L'OBBLIGO DI RESTITUZIONE DELLE SOMME RIMBORSATE 12

BIBLIOGRAFIA 14

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Nozione e tipi di conferimenti

1.1 I principi ispiratori dell'art. 2464 c.c.

Per conferimento si intende, tradizionalmente in dottrina, il contributo dei soci alla formazione del patrimonio della società in corrispettivo del quale gli stessi ricevono le quote di partecipazione alla medesima.

Nella società a responsabilità limitata il principio che governa la materia dei conferimenti è fissato dall'art. 2464 c.c. la cui lettera, nella ampiezza che la caratterizza, ricalca la formulazione utilizzata dal Legislatore comunitario nella II Direttiva CE all'art. 7.

Dalla lettera della legge, quindi, pare potersi desumere un'ampiezza maggiore rispetto alle regole che governano l'analogo fenomeno nel modello s.p.a. posto che, come meglio sarà precisato in seguito, nel tipo s.r.l. risultano conferibili anche prestazioni di opera e/o servizi.

Il Legislatore della riforma ha rimodellato la materia in commento seguendo delle linee direttive che paiono poter essere riassunte nel modo che segue:

- valorizzazione dell'autonomia del tipo sociale a responsabilità limitata mediante l'affrancazione dello stesso delle regole di disciplina, invocare per rinvio dalla normativa previgente, dei modelli azionari;
- concessione di ampi margini all'autonomia privata in tema di entità conferibili.

Il portato attuale dell'articolo in commento costituirebbe, ad opinione della dottrina migliore, il momento di sintesi tra due obiettivi che la legge delega aveva di mira ossia, da un lato, agevolare l'acquisizione alla società di ogni elemento utile allo svolgimento delle proprie attività e, dall'altro, tutelare la formazione e la conservazione del capitale sociale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.2 L'oggetto dei conferimenti

L'art. 2464, comma 2°, dichiara conferibile in detto modello societario "ogni elemento dell'attivo[1] suscettibile di valutazione economica[2] ".

1.3 L'art. 2464, 3° e 4° comma, c.c.

La disposizione normativa in esame, delineando uno dei c.d. conferimenti tipici, rende palese la regola generale che informa la materia in esame ossia che, in ogni ipotesi in cui lo statuto non legittimi il conferimento di entità differenti, il conferimento deve avere ad oggetto denaro.

Al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo almeno il 25% del conferimento e l'intero eventuale sovrapprezzo devono essere versati nelle mani dell'organo amministrativo nominato nel medesimo contesto documentale.

Con l'intento di rendere maggiormente appetibile lo sviluppo dell'attività economica per il tramite di questo strumento societario, anche in attuazione del principio costituzionale espresso nell'art. 41 della Carta fondamentale, è consentito di sostituire il predetto versamento in denaro con una polizza di assicurazione oppure una fidejussione bancaria che abbia le caratteristiche indicate con un decreto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che, però, allo stato, non risulta essere ancóra stato emanato. Tale carenza rende la facoltà sostitutiva, per adesso, inapplicabile;

---

[1] L'espressione ha dato luogo, in dottrina, ad opinioni differenti:

- tesi restrittiva: ha interpretato questa espressione come elementi dell'attivo riconosciuti tali con riguardo alle norme sul bilancio.
  Sarebbero conferibili in società, dunque, solo le entità iscrivibili, fra gli elementi dell'attivo, in bilancio. Gli altri beni, anche se rappresentano un'utilità dal punto di vista economico, non potrebbero, dunque, essere conferiti;
- tesi estensiva: l'espressione dovrebbe essere intesa in senso economico.
  Potrebbero, quindi, essere oggetto di conferimento tutte le entità che rappresentano un vantaggio, in senso economico, per la società, con l'esclusione, quindi, di ogni passività.
  Il riferimento a criteri di valutazione esclusivamente economici, ammettendo che ogni elemento che produca utilità economica per la società possa essere oggetto di un conferimento, finisce per ampliare il novero delle entità conferibili, le quali - essendo diverse dal denaro e non essendo facilmente valutabili - necessiteranno, con buona approssimazione, di una perizia di stima.

[2] La dottrina, con riguardo a tale requisito, si è domandata se occorra fare riferimento ad un criterio soggettivo (quello che per ciascuno di noi può essere suscettibile di valutazione economica) oppure ad un criterio oggettivo (quello che per chiunque sarebbe suscettibile di valutazione economica in quanto economicamente valutabile con parametri oggettivi). Tra gli interpreti è prevalsa la seconda tesi.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. I conferimenti in natura ed i conferimenti di opera e servizi. La mancata esecuzione dei conferimenti

2.1 Nozione di conferimento in natura

L'art. 2464, comma 5°, c.c. stabilisce, descrivendo un alto tipo di conferimento c.d. tipico, che l'atto costitutivo possa prevedere la possibilità di apportare in società utilità diverse dal denaro (altre tipologie di beni o crediti).

2.2 La liberazione integrale dei conferimenti in natura

La predetta previsione statutaria può trovare attuazione sol che il conferimento in natura si effettuato integralmente al momento della sua sottoscrizione.

La dottrina discute sul significato da attribuire a siffatta espressione:

- Parte di essa discorre di consenso idoneo al trasferimento.
- Per considerare liberato il conferimento in natura è sufficiente che sia stato prestato quel consenso idoneo a spostare la titolarità di quanto ne è oggetto dalla disponibilità del conferente a quella della società conferitaria. Questo significa che, ove l'oggetto del conferimento fosse un bene immobile, essendo vigente nel nostro ordinamento il principio consensualistico la proprietà sarebbe trasferita con l'accordo delle parti manifestato nelle forme previste dalla legge. In questa materia, dunque, la proprietà del bene oggetto del conferimento si trasferirebbe in forza dell'accordo tra conferente e società conferitaria cristallizzato nell'atto costitutivo.
- Secondo altra parte della dottrina occorrerebbe rifarsi al concetto di materiale disponibilità del bene.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- In quest'ottica non sarebbe sufficiente il consenso idoneo al trasferimento della proprietà, ma occorrerebbe qualcosa in più, ossia la concreta messa a disposizione del bene conferito (o del credito) alla società conferitaria. In altri termini, oltre al consenso idoneo al trasferimento della proprietà del bene (o del credito) oggetto del conferimento, occorrerebbe anche la materiale consegna.
- Altra parte ancóra della dottrina considera compatibile con il concetto di "integrale liberazione" la permanenza, in capo al conferente, di taluni obblighi, come testimoniato dal richiamo effettuato dal comma 5° dell'art. 2464 c.c. agli artt. 2254 e 2255 c.c. Ciò dimostra, in questa prospettiva, che nel sistema legale sarebbe ben possibile che permanga in capo al conferente qualche obbligo. L'integrale liberazione non dovrebbe, dunque, intendersi in modo che, a seguito dell'esecuzione del conferimento, sul soggetto che vi abbia provveduto non sopravvivano degli obblighi.

2.3 La relazione di stima

Le regole che informano tale tipologia di conferimento sono analoghe a quelle fissate dal Legislatore in materia di s.p.a. con una rilevante deviazione in tema di procedimento di stima.

Al riguardo occorre osservare che:

- l'esperto che deve predisporre la relazione giurata di stima è scelto dal conferente all'interno di un apposito albo professionale;
- non sono applicabili al modello s.r.l. i casi di esenzione della stima di recente introduzione nel tessuto regolamentare delle società azionarie (art. 2343 ter c.c.);
- nulla è previsto, poi, in merito al procedimento di revisione della stima ad opera dell'organo amministrativo per il caso in cui siano rilevata una discrasia valoriale superiore ad 1/5 del valore del bene conferito[3] . Al riguardo sembra persuasiva la tesi che, una volta accertata

[3] La dottrina è divisa tra quanti invocano l'applicazione analogica della normativa di riferimento predisposta per il modello s.p.a. e quanti, a ragione, tentano di risolvere la questione facendo applicazione del generale dovere di diligenza nella gestione corroborato da una responsabilità risarcitoria nei riguardi della società.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

la predetta discrasia ad opera dell'organo amministrativo, il socio conferente debba, onde evitare le conseguenze di cui all'art. 2466 c.c., correggere, mediante conferimento di denaro, l'asimmetria venutasi a creare in esito all'erronea valutazione del bene oggetto di conferimento.

2.4 L'art. 2464, 5° e 6° comma, c.c.

Le considerazioni svolte sopra con riferimento la comma quinto dell'articolo in commento devono essere ulteriormente precisate con riguardo ai conferimenti, anch'essi tipici, che abbiano ad oggetto la **prestazione d'opera e/o servizi.**

La possibilità di conferire siffatte entità[4], sintomo della vicinanza concettuale del modello, sotto questo aspetto, alle strutture associative a vocazione personalistica, è subordinata:

- ad un'apposita previsione statutaria;
- alla prestazione, ad opera del socio conferente, di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria idonee a garantire[5] gli impegni assunti in sede di conferimento. Dette garanzie possono essere, in ogni momento, sostituite dal versamento del controvalore in denaro, da valersi come cauzione, dell'opera o del servizio promesso;
- al procedimento di stima, secondo la migliore dottrina, di cui all'art. 2464 c.c. posto che esso rappresenta una species del genus ivi disciplinato.

[4] La dottrina è divisa tra quanti, preso atto del ruolo essenziale svolto dalle garanzie sopra ricordate, ritengono che oggetto del conferimento, in realtà siano proprio le medesime e quanti, al contrario, sottolineandone la strumentalità, propendono per assegnare ruolo centrale nella fattispecie all'esecuzione dell'opera o del servizio promesso.

[5] Dalla disciplina positiva non si comprende, con esattezza, quali effetti produca l'inadempimento sulla realizzazione delle garanzie in esame.
In particolare, non è chiaro se un inadempimento, anche parziale, legittimi l'escussione della garanzia per l'intero suo valore oppure la pretesa debba limitarsi alla differenza di valore sussistente tra la prestazione originariamente promessa e quella in concreto parzialmente realizzata.
Dal dato positivo, inoltre, non emergono, con nitidezza, quali regole debbano informare i rapporti tra società e socio nel corso dell'esecuzione della prestazione o del servizio promesso non risultando chiaro se a siffatta relazione debbano applicarsi le regole contrattuali di riferimento oppure il fenomeno si esaurisca nelle dinamiche endosocietarie.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.5 L'inadempimento del socio

In ordine alla **mancata esecuzione dei conferimenti** occorre osservare che i soci hanno l'obbligo di completare, nei tempi e nei modi che sono propri del tipo di "apporto" prescelto, il conferimento secondo le pattuizioni intervenute con la società.

2.6 Procedimento

L'organo amministrativo potrà richiedere, in ogni momento, quanto da ciascuno ancóra dovuto ai sensi dell'art. 2466 c.c. [6]

Nel caso in cui il socio non dia seguito alla sollecitazione proveniente dall'organo amministrativo quest'ultimo dovrà diffidarlo ad adempiere antro 30 giorni dalla richiesta.

Nell'ipotesi in cui l'intimato non adempia i titolari del potere gestorio potranno:

- agire nei suoi riguardi in via esecutiva;
- vendere, a suo rischio, la quota agli altri soci a "valore di libro";
- vendere, a suo rischio, la quota, ove ciò sia consentito dallo statuto, all'incanto.

In mancanza di acquirenti:

- il socio inadempiente verrà escluso;
- quanto da lui già corrisposto sarà trattenuto dalla società;
- si dovrà procedere alla correlativa riduzione del capitale sociale.

Queste regole si applicano anche nel caso in cui, per qualsiasi motivo, le garanzie prestate in sostituzione del conferimento in denaro o a rafforzamento dell'adempimento dei conferimenti di opera e/o servizi siano divenute inefficaci.

Da ultimo occorre ricordare che il procedimento di stima previsto per i conferimenti in natura e di crediti si applica, anche nel modello s.r.l., ai c.d. acquisiti pericolosi.

[6] La dottrina si domanda se tale procedimento possa trovare applicazione, in analogia a quanto accade nei modelli azionari, anche nel caso di mancata attuazione dei conferimenti in natura (per esempio in esito ad evizione, vizi o invalidità/inefficacia dell'atto di conferimento).
La soluzione che ha raccolto maggiori consensi è positiva atteso che pare configurarsi in capo al socio un dovere, in tali casi, di liberare in denaro la partecipazione rimasta priva di copertura.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel tipo societario in esame si assiste, però, ad una semplificazione della disciplina di riferimento atteso che:

- l'autorizzazione dei soci può essere assunta anche prescindendo dal procedimento assembleare;
- l'atto costitutivo potrebbe disattivare l'obbligo di approvazione dell'operazione "pericolosa" da parte dei soci;
- non è richiamato il comma 3° dell'art. 2343 bis c.c. (anche se l'omissione pare potersi bilanciare con il potere riconosciuto ai soci dall'art. 2476, comma 2°, c.c.).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Il finanziamento dei soci

3.1 L'art. 2467 c.c.: considerazioni generali

La società, nel corso della propria vita, avrà, di regola, necessità di ottenere altre risorse finanziarie rispetto a quelle raccolte in fase costitutiva.

A tale esigenza possono sopperire i soci.

Questi ultimi, salvo che abbiano assunto tale obbligo in sede parasociale, non saranno tenuti ad ulteriori conferimenti oltre a quelli effettuati al tempo della costituzione dell'ente societario, ma potranno, ove lo vogliano, contribuire al rafforzamento finanziario della struttura associativa di cui fanno parte.

La partecipazione del socio a tale irrobustimento dell'impianto finanziario della società può avvenire:

- mediante apporto di risorse capitalizzate in esito ad una procedura di aumento del capitale sociale a pagamento;
- per il tramite di finanziamenti che, attesa la loro natura, porranno i soci finanziatori nella posizione di creditori della società.

L'intervento del Legislatore, sicuramente apprezzabile sotto il profilo della gestione astratta delle situazioni soggettive di conflitto che posso generarsi, in situazioni di crisi, tra creditori "differenti", pare difettoso sotto taluni aspetti che possono essere riassunti nel modo che segue:

- obbliga l'interprete a sviluppare conoscenze aziendalistiche e finanziarie che non sono a lui proprie;
- lascia irrisolti molti aspetti delicati di disciplina. Il più grave, sul quale pare opportuno brevemente soffermarsi, è quello attinente alla portata della "postergazione" atteso che il dato positivo non consente di comprendere se detto fenomeno venga in considerazione solo nel caso di liquidazione o fallimento della società oppure possa verificarsi (e, in questo caso, con quali modalità) anche durante la vita della medesima. La dottrina più autorevole

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

sul punto ipotizza che gli amministratori siano responsabili in tutte le ipotesi in cui il rimborso ai soci metta a repentaglio il soddisfacimento delle ragioni creditorie dei terzi, potendo la società (o il curatore in caso di fallimento della medesima) agire nei riguardi dei soci rimborsati in ossequio alle regole restitutorie dell'indebito.

Il Legislatore, inoltre, in àmbito fallimentare, ha disposto una significativa deroga all'impianto normativo infra descritto la cui portata può essere apprezzata prendendo in considerazione l'art. 182 quater, comma 3°, del. R.D. 16 marzo 1942 n.267.

3.2 I presupposti previsti dalla norma. I soggetti, la tipologia dei finanziamenti e le circostanze a cui è subordinata

Il reperimento delle risorse finanziare presso i componenti della compagine sociale presenta indubbi vantaggi tanto sotto il profilo delle condizioni del finanziamento quanto sotto quello dalla facilità dell'ottenimento.

Il sistema in esame, però, potrebbe celare notevoli insidie per i soggetti terzi che entrino in contatto con la società soprattutto nei casi in cui, manente una situazione di difficoltà di un ente societario sottocapitalizzato, l'obbligo restitutorio si combini con il regime di responsabilità limitata per le obbligazioni sociali che connota il tipo societario in esame.

In tale circostanza, infatti, una parte del rischio connesso all'esercizio dell'attività di impresa verrebbe spostato sulla testa dei terzi creditori rispetto ai quali i soci finanziatori, anch'essi creditori della società, hanno un indubbio vantaggio che si articola tanto sotto il profilo dell'accesso alle informazioni dell'ente quanto sotto quello della possibilità di incidere direttamente sui tempi e sulle modalità di rimborso.

Le asimmetrie che potrebbero venirsi a determinare in materia hanno spinto il Legislatore a formulare la regola scolpita nell'art. 2467[7].

[7] Tale norma, a giudizio della migliore dottrina, rappresenterebbe una **regola transtipica** posto che, come può essere desunto dalla normativa afferente alla direzione e coordinamento di società (art. 2497 *quinquies* c.c.) e da quella fallimentare, essa potrebbe bilanciare interessi tra ceto creditorio sociale e ceto creditorio composto da soggetti estranei alla società a prescindere dal tipo di società in cui i medesimi vengono a determinarsi.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La formulazione letterale della norma consente:

- di circoscrivere i suoi effetti ai finanziamenti effettuati dai soci nei riguardi della società;
- di ascrivere alla classe dei finanziamenti "critici" non solo le classiche ipotesi di mutuo, ma anche tutti i casi di c.d. finanziamento indiretto (p.e. dilazioni di pagamento oppure concessioni di garanzie a terzi finanziatori);
- di circoscrivere, sotto il profilo temporale, quali operazioni di finanziamento ricadano sotto la sua egida ossia quelli che siano erogati in un memento in cui, anche in considerazione dell'attività svolta dalla società:
- risulti un eccessivo squilibrio tra l'indebitamento e l'ammontare del patrimonio netto;
- l'ente verta in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

3.3 La postergazione

La disposizione in esame, allo scopo precipuo di tutelare i terzi creditori della società, pospone le esigenze di rimborso dei soci finanziatori a quelle dei terzi creditori tutte le volte in cui ci si trovi di fronte a finanziamenti c.d. "critici".

3.4 L'obbligo di restituzione delle somme rimborsate

In presenza dei presupposti di cui all'art. 2467, comma 2°, c.c. e qualora non risultasse possibile soddisfare, con precedenza, i creditori sociali, l'organo amministrativo dovrà rifiutare ai soci il rimborso dei finanziamenti erogati pena l'assoggettamento ad azione di responsabilità.

Le regole recuperatorie che la società dovrà rispettare sono quelle fissate, ad opinione della dottrina maggioritaria, dall'art. 2033 c.c. posto che tale rimborso si atteggia come un indebito oggettivo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Siffatto rimborso, poi, potrebbe generare responsabilità dell'organo amministrativo tanto nei riguardi della società quanto in quelli dei creditori, i quali, peraltro, potranno agire, avverso la restituzione in commento, con la revocatoria ordinaria o con l'azione surrogatoria nel caso in cui la società non agisse ex 2033 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

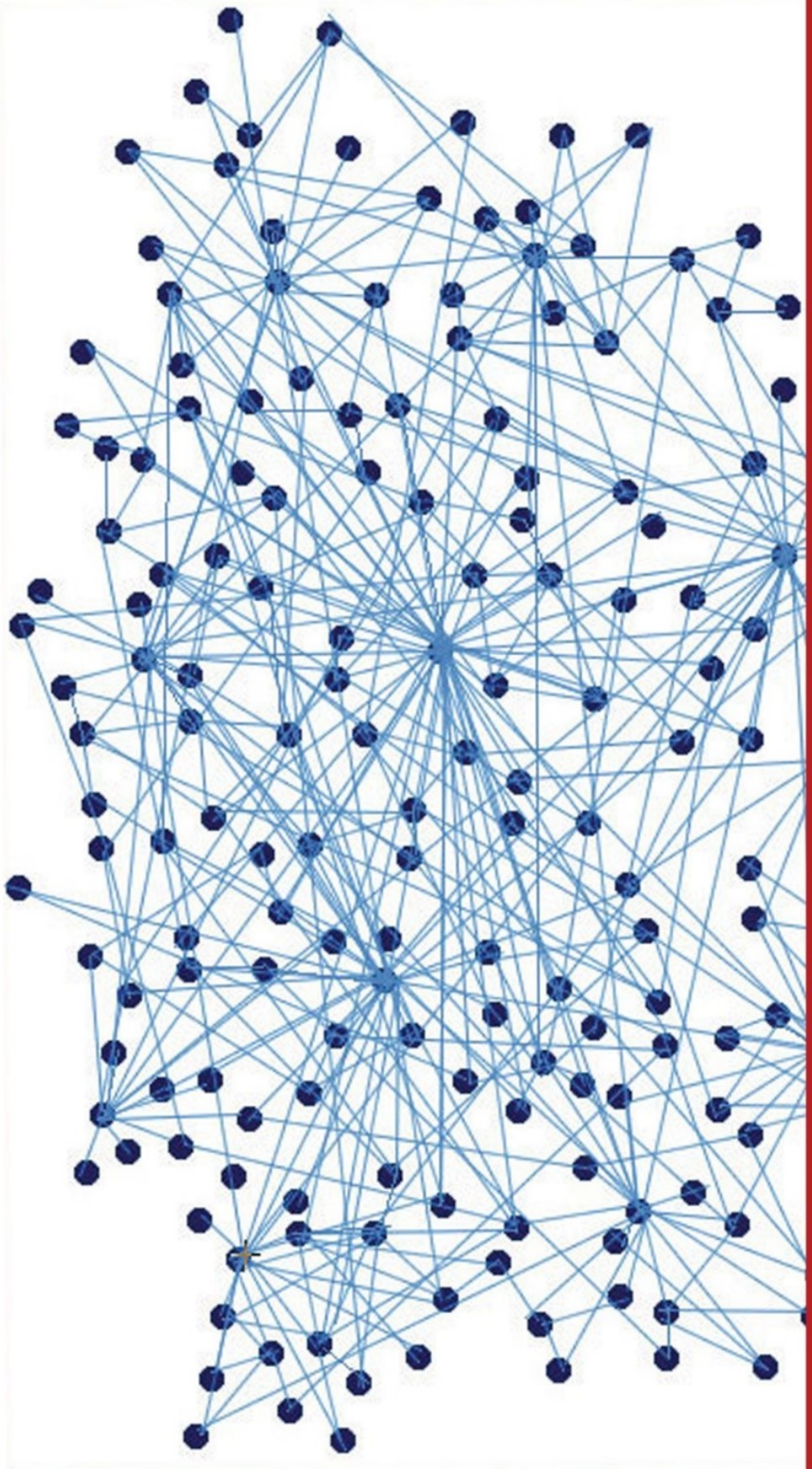
- G. M. Presti – M. Rescigno "Corso di diritto commerciale", Zanichelli, Bologna, 2015, Volume II, pagg. 222-227.
- O. Cagnasso "La società a responsabilità limitata" in "Trattato di Diritto Commerciale", diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2007, Volume V, pagg. 73-122.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA PARTECIPAZIONE SOCIALE: NOZIONE, NATURA E CARATTERISTICHE 3

1.1 NOZIONE 3
1.2 NATURA E CARATTERISTICHE 3
1.3 I DIRITTI SOCIALI 5
1.4 L'ASSEGNAZIONE DI QUOTE NON PROPORZIONALE 6

2. I DIRITTI PARTICOLARI EX ART. 2468, COMMA 3°, C.C. 7

2.1 NATURA DEI PARTICOLARI DIRITTI 7
2.2 ÀMBITO DEI DIRITTI PARTICOLARI 9
2.3 LA MODIFICABILITÀ DEI DIRITTI PARTICOLARI 12
2.4 TRASFERIBILITÀ DEI PARTICOLARI DIRITTI 13

3. COMUNIONE E DIVISIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 17

3.1 IL PROBLEMA DELLA DIVISIBILITÀ DELLA QUOTA 17
3.2 COMPROPRIETÀ DELLA PARTECIPAZIONE 17
3.3 LA PARTECIPAZIONE SOCIALE È UN BENE IMMOBILE IMMATERIALE? 18

BIBLIOGRAFIA 19

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La partecipazione sociale: nozione, natura e caratteristiche

1.1 Nozione

Con la legge di riforma il concetto, tradizionalmente prevalente, di "quota" viene sostituito con quello di "partecipazione", la quale costituisce indice riassuntivo della posizione e del peso del socio nei riguardi degli altri soci nonché della società.

1.2 Natura e caratteristiche

La comprensione di tali aspetti può essere agevolata da una comparazione tra la partecipazione tipica dei modelli azionari e quella del tipo societario a responsabilità limitata

A titolo di premessa sembra d'uopo ricordare che:

- nei modelli azionari si assiste ad una divisione del capitale sociale nominale giusta criterio astratto-matematico: le partecipazioni dei soci sono rappresentate da azioni omogenee e standardizzate che prescindono dalle persone dei soci e dal loro numero;
- nel modello a responsabilità limitata viene, al contrario, impiegato un criterio personale di divisione del capitale sociale nominale: «le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni» (art. 24681 c.c.).

Il capitale della s.r.l. è, pertanto, diviso avuto riguardo al numero dei soci:

- il numero iniziale delle quote corrisponde al numero dei soci che partecipano alla costituzione della società e ciascun socio diventa titolare di un'unica quota di partecipazione;
- la quota di s.r.l., inoltre, non è un bene mobile materiale. Questa, però, ha un proprio valore patrimoniale oggettivo di estensione pari alla frazione del patrimonio sociale che rappresenta.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Ciò spiega la ragione per la quale essa sia trattata, sotto più profili, dalla legge come oggetto unitario di diritti (artt. 2466, 2468 e 2471 c.c.).

Una tabella pare essere in grado di ben rappresentare i punti differenziali di maggior interesse tra le due tipologie di partecipazioni societarie.

AZIONI DI S.P.A.	**QUOTE DI S.R.L.**
1) Le azioni hanno necessariamente uguale valore (art. 2346[2] c.c.);	1) Le **quote** possono essere di **diverso ammontare** (lo sono se diverso è l'ammontare del capitale detenuto da ciascun socio: es. se il capitale di 10 è detenuto da Tizio per 5 da Caio per 3 e da Sempronio per 2, le quote sociali sono tre, ciascuna di diverso ammontare). Nella s.r.l. l'atto costitutivo *non* può prevedere la divisione del capitale sociale in parti uguali ed indivisibili;
2) Nella s.p.a. il socio ha più partecipazioni sociali, le quali che restano tendenzialmente autonome e distinte tra loro;	2) Nella S.r.l. il **socio è titolare di una sola quota** (p.e. il socio che sottoscrive capitale per 10 non avrà 10 quote da 1, ma un'unica quota da 10). L'acquisto di altre quote, oltre quella originaria, non rende il socio titolare di più quote distinte, ma determina solo un *incremento quantitativo* dell'originaria ed unica partecipazione (p.e. se il socio titolare di una quota di 10 acquista

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

	un'ulteriore quota di 5, diviene titolare di un'unica quota di 15);
3) Le azioni sono, normalmente, incorporate in un titolo di credito.	3) Le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito «*né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari*» (art. 2468[1] c.c.). L'eventuale *certificato di quota*, rilasciato dalla società, costituisce semplice documento probatorio della qualità di socio e della misura della partecipazione sociale. Esso non è, quindi, uno strumento per la circolazione della stessa.

1.3 I diritti sociali

Ogni partecipazione sociale attribuisce al suo titolare un complesso unitario di diritti e poteri all'interno del quale si possono enucleare:

- diritti e poteri di natura amministrativa;

diritti e poteri di natura patrimoniale;

diritti e poteri a contenuto complesso ossia per certi versi amministrativo e per tali altri patrimoniale.

La regola suppletiva fissata dal codice, all'art. 2468, comma 2°, è quella della proporzionalità tra i diritti sociali esercitabili è la partecipazione da ciascuno posseduta.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.4 L'assegnazione di quote non proporzionale

Nella s.r.l., al pari di quanto accade nei modelli a vocazione personalistica ex art. 2263 c.c. e nei modelli azionari ex art. 2346, comma4° c.c., sono ammessi i c.d. conferimenti non proporzionali: l'art. 24682, seconda parte, c.c. stabilisce, infatti, che «se l'atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento».

L'atto costitutivo può prevedere, in altri termini, che conferimenti non siano proporzionali alle partecipazioni.

Nel qual caso, pur restando fermo il principio secondo cui «il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale» (art. 24641 c.c.), viene alterata la regola sopra espressa.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. I diritti particolari ex art. 2468, comma 3°, c.c.

2.1 Natura dei particolari diritti

Tale previsione normativa rafforza l'anima personalistica del modello s.r.l. e personalizza la partecipazione veicolando, all'interno dello statuto, l'intuitus personae che avvince i soci.

Si potrebbe, istintivamente, essere indotti a credere che l'interesse tutelato dalla norma sia quello del singolo socio a cui il particolare diritto è riconosciuto, atteso che la concessione di particolari diritti, in materia di amministrazione o di partecipazione agli utili, pare fungere da stimolo alla partecipazione del socio alla società. Se così fosse, per modificare tale diritto, occorrerebbe il consenso del suo titolare (in maniera non dissimile da quanto sopra indicato, nella vigenza della disciplina anteriforma, per la modificabilità dei diritti spettanti ai soci uti singuli).

La norma, invece, non stabilisce che la modifica debba passare attraverso il consenso del solo socio attributario, ma attraverso il consenso di tutti i soci.

Ciò si spiega alla luce della considerazione che l'interesse tutelato dall'art. 24683 c.c. non è quello del solo attributario, ma quello di tutti i soci, in quanto l'attribuzione di particolari diritti, a contenuto amministrativo o patrimoniale, se da un lato incentiva la partecipazione di un socio (l'attributario) dall'altro, risponde all'interesse della società (la quale avrà interesse a contare sul buon nome commerciale dell'attributario o sulle sue specifiche capacità imprenditoriali).

L'art. 2468, comma 3°, c.c. tutela l'interesse di tutti i soci a che sia mantenuto costante nel tempo, fino ad una diversa manifestazione della loro volontà, l'assetto originario che è stato dato alla società: ogni socio può, in sostanza, temere che la modifica o l'eliminazione dei particolari diritti di cui è titolare l'attributario, conduca quest'ultimo ad uscire dalla società o, comunque, possa cagionarle un danno che, riverberandosi sull'investimento da ciascun socio effettuato in società, ne renderebbe meno vantaggiosa la permanenza. Per questo motivo si ritiene che l'interesse tutelato dalla norma sia quello di tutti i soci, i quali devono, salva diversa previsione statutaria, poter mantenere inalterato l'assetto societario originariamente adottato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'art. 24682, prima parte, c.c. stabilisce la regola generale della proporzionalità tra partecipazione sociale e diritti sociali, in ossequio al principio di parità di trattamento, per il quale deve essere assicurato il medesimo trattamento ai soci che si trovino identiche condizioni («salvo quanto disposto dal terzo comma del presente articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta»).

Ciò non significa che la parità di trattamento debba essere intesa in senso assoluto ossia che non possa essere mai derogata.

Una deroga alla parità di trattamento ricorre quando si vuole attribuire un particolare diritto a singoli soci: l'art. 24683 c.c. stabilisce che «resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili».

Secondo la dottrina maggioritaria è necessario che l'attribuzione dei particolari diritti venga effettuata in favore di «soci» e non di terzi[1].

I particolari diritti non possono essere connessi alla quota, ma devono essere attribuiti «a singoli soci».

In altri termini la facoltà di attribuire particolari diritti a singoli soci non autorizza la creazione di «categorie di quote» aventi diritti diversi. I diritti sociali "particolari" non fanno parte del contenuto della partecipazione, ma ineriscono alla persona del socio.

Preso atto di tale caratteristica occorre porsi il problema della sorte di tali particolari diritti nel caso in cui il soggetto attributario cessi di essere socio.

Da quanto testé osservato discende che tali diritti non possono:

- essere attribuiti a chi non sia ancora socio;
- permanere in capo a chi non è più socio.

[1] Ciò parrebbe scontato, essendo una vicenda interna alla società. In realtà, per il modello S.r.l. risultante dalla riforma del 2003, lo è meno di quel che potrebbe apparire, in quanto per tale modello il legislatore sembra avere ipotizzato, all'art. 2479 c.c., che vi possano essere particolari diritti attribuibili *ai terzi*.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.2 Àmbito dei diritti particolari

L'art. 24683 c.c. discorre, sinteticamente, di «particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili».

A titolo di premessa occorre precisare che il socio della s.r.l. si è titolare di:

1. diritti che gli spettano in quanto tale: il socio, in quanto tale, è titolare di diritti a contenuto essenzialmente informativo e di controllo come, p.e. quello di impugnare le delibere assembleari, il diritto di consultare i libri sociali, il diritto ad ottenere informazioni sull'andamento delle operazioni sociali: tutti i soci li possono esercitare in egual misura, non essendo parametrati all'entità della quota. In tal contesto, quindi, non sono ravvisabili particolari diritti;
2. i diritti che gli spettano in quanto titolare di una quota di partecipazione al capitale sociale: i diritti particolari di cui all'art. 24683 c.c., oltre a riguardare l'amministrazione della società e/o la distribuzione degli utili, devono, in ultima analisi, essere inerenti a materie, questioni o competenze per le quali, assumendo rilevanza la quota di partecipazione al capitale sociale, possa essere alterato il principio di proporzionalità nella quota di partecipazione[2].

Ciò posto, con riferimento al contenuto dei particolari diritti, può essere utile distinguere:

Contenuto tipico

- ✓ <u>diritti riguardanti l'amministrazione della società</u>: in tale novero possono essere ricondotti:
- il diritto di nominare uno, più, o tutti gli amministratori. Il fatto che il particolare diritto possa consistere anche nel diritto di nominare l'intero organo amministrativo si evince dal combinato disposto degli artt. 2479 n. 2 (per il quale la nomina degli amministratori è riservata alla competenza dei soci solo «se prevista nell'atto costitutivo») e 2475 c.c. (per il

[2] A titolo esemplificativo nella partecipazione agli utili, nel caso in cui non siano riconosciuti diritti particolari a nessun socio, il principio è che i soci concorrano al loro riparto in proporzione alla quota di cui sono titolari. L'art. 2468[3] c.c. può incidere, alterando il principio di proporzionalità, su tale diritto.
Per il caso, invece, in cui si abbia riguardo a diritti che spettano ai soci in quanto tali, non facendosi riferimento al principio di proporzionalità nell'esercizio dei medesimi, non può essere il riconoscimento di un particolare diritto che, ai sensi dell'art. 2468[3] c.c., alteri quella proporzionalità.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

quale l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci, nominati con decisione dei soci, solo «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo»);

- il diritto di determinare la rosa di nomi entro cui l'assemblea dovrà effettuare la scelta degli amministratori;
- il diritto di scegliere un amministratore all'interno di una rosa di nomi scelta da altri;
- il diritto di rivestire la carica di amministratore, potendosi prevedere che il singolo socio sia amministratore unico o, nel caso di pluralità di membri, consigliere (eventualmente presidente dell'organo dotato di specifiche deleghe);
- il diritto di veto su determinate decisioni riguardanti l'amministrazione della società (p.e. per le operazioni immobiliari, per l'assunzione di obbligazioni oltre un certo importo, ecc.);
- il diritto di compiere specifici atti gestionali (come l'alienazione di beni immobili o di rami d'azienda), data la responsabilità di cui all'art. 24767 c.c.;

✓ il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori:

- tesi negativa: l'art. 24792 n. 3 c.c. riserva ai soci la nomina dell'organo di controllo;
- tesi favorevole: si possono estendere, a livello ermeneutico, i confini dell'art. 24683 c.c., includendovi anche il diritto di nomina di uno o più sindaci o revisori;

✓ <u>diritti riguardanti gli utili</u>: in tale novero possono essere ricondotti:

- il diritto a percepire una percentuale di utili in misura diversa da quella che spetterebbe in proporzionalmente alla quota;
- il diritto agli utili in misura fissa, purché conseguiti, e nei limiti del divieto del patto leonino ex art. 2265 c.c.;
- il diritto alla mera priorità nella distribuzione degli utili;
- il diritto a ricevere gli utili per effetto della mera approvazione del bilancio come accade nelle società di persone (art. 2262 c.c.);
- il diritto alla distribuzione degli utili inerenti all'andamento di uno specifico ramo d'azienda in sintonia con quanto accade, nei modelli azionario, in materia di azioni correlate di cui all'art. 23502 c.c.;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il diritto - in sede di riparto dell'attivo conseguente alla liquidazione della società - ad una quota di liquidazione superiore a quella spettante in base alla partecipazione sociale oppure all'attribuzione di un bene in natura (e non alla liquidazione in denaro, come per gli altri soci non attributari).

Contenuto atipico

Il tema evoca uno dei problemi teorici di maggior interesse in materia ossia quello della tassatività dei diritti particolari attribuibili ai soci.

In altri termini, è necessario chiedersi se la previsione dell'art. 24683 c.c. - il quale sembra limitare, al solo riconoscimento di diritti particolari inerenti l'amministrazione o la distribuzione degli utili, la possibilità di intervento dell'autonomia privata - debba essere interpretato restrittivamente, in quanto recante un'eccezione al principio di parità di trattamento tra soci, oppure se queste due ipotesi riconosciute dal Legislatore siano mere esemplificazione, rispondenti ad una regola di frequenza statistica, del più ampio spettro operativo riconosciuto, in quest'ambito, all'autonomia privata.

È discusso, infatti, se possano essere attribuiti particolari diritti al di fuori delle ipotesi previste dalla legge:

Parte della dottrina, muovendo eccezionalità dalla deroga al principio della proporzionalità di cui all'art. 2468 c.c., opina nel senso della tassatività delle ipotesi normative.

Altra parte, forse maggioritaria della medesima, al contrario, ritiene che le indicazioni di cui all'art. 24683 c.c. siano meramente esemplificative e non tassative.

I particolari diritti che l'atto costitutivo di s.r.l. può attribuire a singoli soci possono, quindi, avere ad oggetto materie non strettamente riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, ai quali espressamente si riferisce alla norma, bensì ulteriori diritti diversi.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In quest'ottica occorre riconoscere all'autonomia negoziale, al pari di quanto dispone l'art. 2348 c.c. in materia di s.p.a., la facoltà di «liberamente determinare il contenuto» dei particolari diritti, «nei limiti imposti dalla legge» ossia:

- il divieto del patto leonino (art. 2265 c.c.), per cui non si possono attribuire particolari diritti tali da escludere del tutto il socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite;
- rispetto delle competenze che «in ogni caso» sono riservate ai soci ai sensi dell'art. 24792 c.c. (ad eccezione della nomina degli amministratori prevista dal numero 2);
- rispetto della regola secondo cui «il voto vale in misura proporzionale alla… partecipazione» (art. 24794 c.c.);
- il principio di integrità del capitale sociale (art. 24641 c.c.).

Non sarebbe, quindi, possibile attribuire:

- il diritto esclusivo all'azione di responsabilità (art. 24763 c.c.);
- il diritto esclusivo di impugnativa delle delibere assembleari (art. 2479 ter c.c.);
- più in generale tutti i diritti inderogabilmente spettanti a tutti i soci.

2.3 La modificabilità dei diritti particolari

L'esegesi del dato normativo (art. 2468, comma 4 °, c.c.) supporta le seguenti osservazioni:

1. l'inciso «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo»:

a) consente di derogare alla previsione normativa, prevedendo che le modifiche siano assunte:

✓ a maggioranza e, pertanto, anche senza il consenso del titolare del particolare diritto. Tale deroga al regime legale delle modifiche dei particolari diritti può essere:

- prevista già al momento della costituzione della società;
- introdotta successivamente: in tal caso, però, la delibera che deroga alla previsione normativa, prevedendo che le modifiche siano assunte a maggioranza, deve essere approvata all'unanimità.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- ✓ con un sistema misto strutturato intorno al consenso unanime degli attributari e a della maggioranza dei soci non attributari.

b) non consente, posto che il modello in esame è pur sempre di stampo capitalistico, che la decisione inerente alla modifica dei particolari diritti possa essere rimessa:

- alla minoranza dei soci;
- a soggetti terzi;

2. la decisione che abbia ad oggetto la modifica dei particolari diritti deve essere assunta giusta metodo collegiale con la particolarità che il quorum deliberativo sarà, salvo una diversa disposizione, quello dell'unanimità;
3. l'inciso «salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473» implica che qualora (e solo in tal caso) l'atto costitutivo preveda la possibilità di modificare i particolari diritti a maggioranza, spetterà ai soci dissenzienti, benché non titolari del particolare diritto, il diritto di recesso.

2.4 Trasferibilità dei particolari diritti

La fattispecie può essere riguardata sotto un duplice angolo visuale:

- trasmissione senza trasferimento della quota: tale circostanza è ipotizzabile, esclusivamente, in favore di altri soci. Anche in tal caso è necessario il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo. Il problema che si pone è quello della forma in cui debba essere prestato tale consenso. Ci si chiede, in altri termini, se esso debba essere espresso necessariamente in forma assembleare, come sembra preferibile, ovvero se possa essere manifestato anche in forma negoziale;
- trasmissione con trasferimento della quota sociale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In quest'ambito occorre ancora distinguere:

1. l'ipotesi del **trasferimento dell'intera quota** → nel silenzio del Legislatore sul punto la dottrina ha assunto posizioni diversificate:

- parte della medesima ha ritenuto che le partecipazioni sociali cui sono attribuiti particolari diritti siano assolutamente intrasferibili;
- altra parte, invece, ha opinato che tali partecipazioni sociali siano liberamente trasferibili posto che l'attribuzione ad un singolo socio di particolari diritti non comporta alcun limite al trasferimento della sua quota, la quale rimane liberamente cedibile (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo).

Ciò chiarito, nel caso in cui il singolo socio alieni per intero la sua partecipazione e nulla sia previsto nel contratto sociale, ci si chiede che sorte abbiano i particolari diritti. In dottrina sul punto si sono sviluppate diverse opinioni:

a) parte di essa, adducendo una motivazione che in realtà non pare del tutto chiara, ritiene che i particolari diritti circolino insieme alle quote e, quindi, che si trasferiscano al cessionario;
b) altra parte della medesima si dimostra, invece, incline a non ammettere che particolari diritti diversi da quelli patrimoniali, circolino con la partecipazione, ritenendo che i medesimi si estinguano;
c) l'opinione prevalente, tuttavia, è nel senso che in caso di trasferimento totale della quota tutte le tipologie di diritti particolari non si trasferiscono al cessionario, ma si estinguono.

- L'ipotesi del trasferimento parziale della quota → in tal caso si ritiene che l'atto costitutivo possa liberamente determinare la sorte dei particolari diritti e, quindi, stabilire che tali diritti siano:
- mantenuti in capo all'alienante;
- trasmessi in capo all'acquirente;
- mantenuti in capo all'alienante, ma in misura ridotta;
- ripartiti tra alienante ed acquirente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel silenzio dell'atto costitutivo, preso atto che siffatti diritti sono attribuiti al singolo socio prescindendo dall'entità della sua partecipazione, si ritiene che (in caso di alienazione parziale della partecipazione) essi rimangono attribuiti per intero al socio alienante (posto che quest'ultimo rimane comunque socio).

Se la regola è, in caso di trasferimento dell'intera quota sociale, quella per cui i diritti sociali si estinguono, è discusso se sia possibile prevedere, nell'atto costitutivo, la trasmissione del particolare diritto all'acquirente della quota sociale.

In merito si fronteggiano due ricostruzioni teoriche:

- parte della dottrina opina che tale clausola comporterebbe una oggettivizzazione del particolare diritto nella quota ossia la creazione di una categoria di quote la cui circolazione implica l'automatico trasferimento del privilegio;
- altra parte della medesima, pur convenendo sull'asserzione che la regola, nel caso in esame, sia quella dell'estinzione del particolare diritto, ritiene possibile che l'atto costitutivo disponga nel senso di ammettere la trasferibilità dei particolari diritti agli aventi causa del socio, a discrezione di quest'ultimo o di altro socio, prescindendo o no, dall'entità della quota trasferita.

Qualora il trasferimento totale o parziale della partecipazione del socio, cui sono stati attribuiti i particolari diritti, comporti l'estinzione totale o parziale dei diritti medesimi oppure la variazione della loro misura, è necessario modificare l'atto costitutivo, in quanto deve essere eliminata la relativa clausola o deve essere variata la loro misura o, infine, deve essere modificato il nome del socio che ne è, in tutto o in parte, titolare.

A tal fine:

- sarebbe necessaria, secondo i principi generali, una formale deliberazione da parte dell'assemblea, modificativa dell'atto costitutivo;
- secondo un'interpretazione più moderna della dottrina sarebbe da ritenere legittima la clausola che attribuisca agli amministratori la facoltà di depositare presso il registro delle imprese, ai sensi dell'art. 2436, ult. comma, c.c. il testo aggiornato dello statuto, riportante le

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

modificazioni derivanti dal trasferimento della partecipazione, senza che sia all'uopo necessaria una deliberazione assembleare che prenda atto dell'intervenuta modificazione del testo dell'atto costitutivo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Comunione e divisibilità della partecipazione

3.1 Il problema della divisibilità della quota

Occorre, sul punto, muovere dalla considerazione che il Legislatore della riforma, a differenza di quanto preveduto sotto la vigenza della normativa anteriforma, nulla ha statuito al riguardo.

La dottrina, tuttavia, non ravvisa nel silenzio normativo un indice utile a ricostruire un divieto, posto che tale lacuna consente il pieno esplicarsi dell'autonomia dei privati.

La riforma, in altri termini, pare avere preservato la divisibilità come tratto naturale della partecipazione come potrebbe, indirettamente, ricavarsi dal riconoscimento, in materia, del principio di libera trasferibilità delle medesime.

Tale opinione, benché maggioritaria in dottrina, non è pacifica atteso che contro la medesima si stagliano le critiche di taluni autori che, valorizzando il dato personalistico e la rinnovata formulazione legislativa, ritengono la partecipazione indivisibile salvo pattuizione statutaria contraria.

3.2 Comproprietà della partecipazione

L'art. 24685 c.c. statuisce che «nel caso di comproprietà di una partecipazione i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune rappresentato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106»

Tale disciplina si riconnette al principio di unicità della partecipazione con ciò evocando il dato per cui la partecipazione di s.r.l. è unitaria e, sotto il profilo della titolarità, esprime in maniera univoca la posizione del socio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tale principio informa di sé anche il diritto di voto posto che la lettera della legge, per come riformata nel 2003, prende in considerazione quale base di computo per la misurazione di tale diritto sociale la partecipazione in quanto tale, escludendo che possano darsi fenomeni di voto disgiunto o frazionato.

3.3 La partecipazione sociale è un bene immobile immateriale?

La legge non specifica se la partecipazione di s.r.l. vada considerata come un bene immateriale, un credito, oppure una posizione contrattuale.

La dottrina, soprattutto in passato, ha molto dibattuto sul punto posto che la penuria di regole afferenti la circolazione delle partecipazioni rinfocolava, a cadenze cicliche, l'interesse verso questo aspetto di disciplina.

La dottrina più moderna, in esito alla riforma del 2003, precisa, tuttavia, che il rinnovato quadro normativo condurrà ad un affievolimento di tale dibattito atteso che il medesimo si è fatto carico di regolamentare i più discussi aspetti di disciplina sino ad allora oggetto di incertezze tra gli interpreti, conducendo ad un'interpretazione che sempre più pare andare nel verso del riconoscimento della natura di bene mobile immateriale alla partecipazione sociale nel modello s.r.l.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

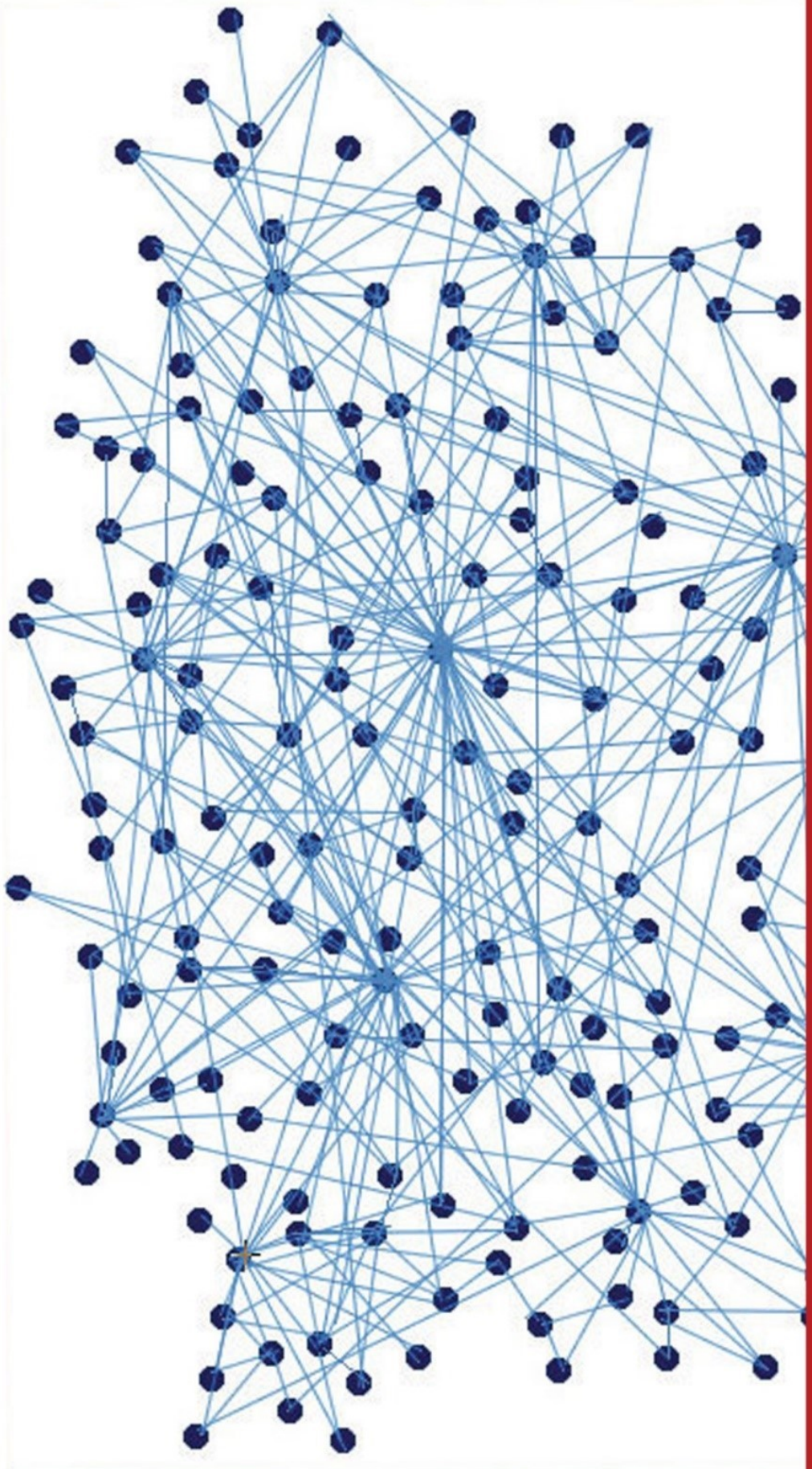
- G. M. Presti – M. Rescigno "Corso di diritto commerciale", Zanichelli, Bologna, 2015, Volume II, pagg. 227-228.
- O. Cagnasso "La società a responsabilità limitata" in "Trattato di Diritto Commerciale", diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2007, Volume V, pagg. 123-133.
- Daccò, "I diritti particolari del socio nelle s.r.l.", in "Il nuovo diritto delle società" Liber amicorum G. F. Campobasso (diretto da P. Abbadessa e G. B. Portale), vol. 3, Torino, 2007, pag. 393 e ss.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. L'ART. 2469 C.C. 3

2. LE SINGOLE CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA TRASFERIBILITÀ E DI INTRASFERIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE 6

BIBLIOGRAFIA 12

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. L'ART. 2469 C.C.

L'evoluzione della disciplina: il contesto *ante* riforma e l'intervento del Legislatore nel 2003.

Il primo comma della norma in commento, ponendosi in linea di continuità con l'ordinamento previgente alla riforma delle società di capitali, fissa il principio, coerente con la natura capitalistica del modello societario in esame, per cui le partecipazioni soni liberamente trasferibili, tanto per atto tra vivi quanto mortis causa, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il portato della legge di riforma può essere apprezzato, sotto il profilo lessicale, nell'introduzione nel testo normativo dell'avverbio "liberamente" e nella sostituzione del termine "quota" con "partecipazione".

Il mutamento da ultimo evidenziato si pone quale conseguenza del carattere marcatamente personalistico del modello societario in questione, mentre l'inserimento dell'avverbio di cui sopra, invero ridondante, pare voler enfatizzare il tratto capitalistico dell'investimento in tali società.

Il principio di libera trasferibilità della partecipazione.

La soluzione offerta del Legislatore della riforma, come osservato dalla dottrina, mette in luce la duplice anima dell'autonomia privata in materia di circolazione delle partecipazioni:

- quella impersonata dal titolare della quota nel decidere circa tempi, modi e destinatari del trasferimento delle stesse;
- quella facente capo alla collettività dei soci nel porre se e come fissare limiti alla circolazione delle medesime

Le clausole di natura convenzionale contenute nell'atto costitutivo.

La clausola di salvezza che si rinviene nella parte finale del comma 1° della disposizione in esame si presta a configurare, come puntualmente osservato dalla dottrina, il modello societario a responsabilità limitata come una struttura potenzialmente multiforme plasmabile, a seconda delle esigenze di cui siano portatori i soci, dall'autonomia privata.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quest'ultima, infatti, ove veicolata dall'atto costitutivo, consente di modellare il tipo sociale secondo le più svariate esigenze tenendo, comunque, fermo tale assetto di interessi in fase circolatoria atteso che la le scelte ivi effettuate soci mantengono la loro attualità anche in ipotesi di trasferimento della partecipazione, risultando vincolanti per i nuovi soci che, acquistandole, condividono la configurazione data all'ente dai soci fondatori.

Le clausole di natura convenzionale contenute nei patti parasociali.

L'ampio margine concesso all'autonomia privata dal modello societario in esame fa si che i componenti della base sociale possano decidere di non affidare all'atto costitutivo le loro scelte afferenti al regime circolatorio delle partecipazioni, ma ricondurre le medesime alla dimensione parasociale.

A differenti esigenze attuate mediante l'impiego di strumenti diversi consegue, naturalmente, una forma di protezione coerente alle scelte poste in essere.

Per il caso in cui, infatti, si preferisca la dimensione contrattuale a quella sociale per la configurazione degli aspetti in questione le regole di disciplina e gli strumenti di reazione avverso potenziali violazioni dei predetti accordi seguiranno la via contrattuale in luogo di quella apprestata dal diritto societario.

Il divieto dei patti successori e le clausole limitative della trasferibilità o di intrasferibilità della partecipazione sociale.

L'accordo contenuto in un contratto, categoria alla quale appartiene l'atto costituivo della società, con il quale si sia disposto della partecipazione come oggetto della futura successione ed in favore di determinati soggetti crea delle interferenze convenzionali, in favore di tali soggetti, con i meccanismi approntati dall'ordinamento per gli acquisti *mortis causa*.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Al riguardo pare opportuno, tuttavia, distinguere:

a) l'ipotesi in cui l'accrescimento, in capo ai soci superstiti, avvenga a titolo gratuito: integra un patto successorio atteso che, per questa via, la partecipazione sociale non seguirebbe, in caso di evento infausto, le regole devolutive tipiche della successione del socio defunto, ma andrebbe a beneficio di soggetti già ben determinati nell'accordo sociale ossia i soci superstiti;

b) l'ipotesi in cui l'accrescimento, in capo ai soci superstiti, avvenga dietro corrispettivo: la giurisprudenza, in un caso come quello in esame, ammette che laddove sia previsto il pagamento di un corrispettivo a favore degli eredi del socio defunto la clausola non integri un patto successorio vietato atteso che la stessa non sarebbe idonea a creare il vincolo giuridico con il quale si vuole trasferire un bene dell'eredità futura (in questo caso la partecipazione sociale, in favore di soggetti terzi determinati), ma si stabilirebbe soltanto un limite alla libertà testamentaria che si stempera, giustificandosi, nelle peculiari esigenze societarie.

Nel patrimonio del socio defunto gli eredi di quest'ultimo, in sostanza, non troveranno più la partecipazione sociale, ma il suo controvalore in denaro.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. LE SINGOLE CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA TRASFERIBILITÀ E DI INTRASFERIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE

Le clausole di mero gradimento

La clausola di gradimento può atteggiarsi a **gradimento *mero*** ossia prevedere che il soggetto deputato ad esprimerlo oppure a negarlo non debba motivare la propria scelta.

Quest'ultima, infatti, ben potrebbe essere arbitraria.

In tal caso l'art. 2469[2] c.c. concede al soggetto che intenda disinvestire il diritto di recesso.

Tale limite alla circolazione delle partecipazioni è espressamente disciplinato dall'art. 2469[2] c.c., per il quale "*qualora l'atto costitutivo subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti il socio* (può) *esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473*".

La previsione dell'eventuale obbligo di motivazione del rifiuto

Non sembra sufficiente ad escludere la sussistenza del gradimento mero, ad opinione della dottrina migliore, la previsione di un obbligo di motivazione afferente all'eventuale rifiuto del placet da parte del soggetto o dell'organo deputato ad esprimerlo giacché la motivazione non costituisce un limite all'esercizio del potere discrezionale, ma un vincolo di natura procedimentale che consente, a ritroso, di verificare l'*iter* seguito nell'esercizio di tale potere.

Il c.d. gradimento motivato, quindi, rientra nel perimetro operativo tracciato dal comma 2° dell'art. 2469 c.c. posto che all'alienante non risulta garantita la possibilità di disinvestire.

Le clausole di gradimento non mero.

La clausola di gradimento può atteggiarsi, inoltre, a **gradimento *non mero*** ossia *sottoposto a limiti o condizioni*.

In tal caso il soggetto deputato ad esprimerlo o a negarlo deve rispettare, nell'espletamento dell'incarico, la regola di giudizio, predeterminata ed obiettiva, fissata nello statuto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le valutazioni attinenti alla sussistenza dei requisiti richiesti dallo statuto potranno essere espletate solo nella fase di acquisto della qualità di socio e sono circoscritte al semplice accertamento della loro ricorrenza sulla scorta del tracciato statutario.

Tale fattispecie non è espressamente disciplinata dal Legislatore, ma rientra nella previsione dell'art. 2469[1] c.c. («*salvo contraria disposizione dell'atto costitutivo*») e, pertanto, non da luogo a recesso.

A queste clausole vengono accomunate quella di gradimento c.d. alla francese ossia quelle per cui alla negazione del *placet* è contestuale l'individuazione ad opera di chi ha formulato il giudizio negativo di un soggetto gradito che acquisti la partecipazione alle medesime condizioni.

Le clausole di prelazione.

Rientrano in tale classe le clausole che impongono al socio che intenda alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione sociale di preferire, a parità di condizioni, gli altri soci ai terzi.

Essa, quindi, costituisce una limitazione alla libertà contrattuale del socio cedente in ordine alla scelta dell'altro contraente (cioè il soggetto cessionario) e non in relazione alle condizioni del negozio di cessione (prezzo, modalità di pagamento, etc.).

Nel caso in cui la clausola non sia inserita nello statuto ciascun socio potrà determinare:

- il contenuto del negozio di cessione;
- il soggetto con il quale contrattare, in omaggio al principio della libertà contrattuale.

Nell'ipotesi opposta, invece, residuerà in capo ciascun socio solo il diritto a determinare il contenuto del contratto di cessione, dal momento che si è obbligato a preferire, a parità di condizioni, gli altri soci in caso di cessione delle partecipazioni di cui è titolare.

La carenza di un referente normativo complica la ricostruzione della sua natura giuridica posto che, da un lato, il Legislatore ha riconosciuto che vi possano essere clausole limitative della circolazione delle partecipazioni e, quindi, anche che le parti possano introdurre nello statuto una clausola di prelazione, mentre, dall'altro lato, non ha attribuito a ciascun socio un diritto di prelazione legale.

Per questa ragione il diritto di prelazione, in àmbito societario, deve essere tenuto distinto dalle ipotesi di prelazione legale, essendo, concettualmente, può vicina alla prelazione volontaria, ancorché, rispetto ad essa, la prelazione societaria riceva un regime di pubblicità (iscrizione nel registro delle imprese dello statuto), che ne rende peculiare la disciplina (soprattutto sotto l'aspetto della sua opponibilità ai terzi).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il principio generale è che la prelazione operi a **parità di condizioni** ossia che la libertà del cedente venga limitata in ordine alla scelta del contraente, ma non nella determinazione del contenuto del negozio di cessione.

Ciò deriva dal fatto che, in àmbito societario, similmente a quanto accade per la prelazione volontaria, non si ravvisa un interesse di carattere pubblicistico idoneo ad alterare questo principio.

Corollario della "parità di condizioni" è che la prelazione, in linea generale, potrà trovare applicazione solo nel caso in cui la prestazione sia fungibile.

Se, invece, la prestazione a cui è tenuto il cessionario fosse infungibile, il prelazionario non potrebbe, a parità di condizioni, prenderne il posto.

Ciò chiarito, da come è strutturata la clausola, comunemente si ritiene che la prelazione societaria risponda all'interesse dei soci di:

1. evitare l'ingresso in società di soggetti non graditi: questo interesse è tutelato predisponendo una clausola di prelazione relativa o, tuttalpiù, una clausola di gradimento;
2. conservare inalterato il proprio peso all'interno della società: questo interesse è tutelato predisponendo una clausola di prelazione assoluta, in quanto a ciascun socio sarebbe consentito, proporzionalmente alla quota di cui è titolare, di acquistare la quota del cedente in modo da mantenere inalterato il peso percentuale ad egli riconosciuto, prima della cessione, in società.

Una parte della dottrina, tuttavia, riconosce nella clausola di prelazione l'esistenza, accanto all'interesse dei soci, di un interesse della società, ravvisabile nell'omogeneità della compagine, la quale renderebbe maggiore l'efficienza funzionale dell'ente.

Se a questo si aggiunge il ragionamento talvolta svolto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale osserva come l'introduzione statutaria di detta clausola serva ad emancipare la stessa dalla semplice dimensione privata, attribuendole carattere sociale, apparirà chiaro come vengano in gioco, in questa materia, anche interessi diversi da quelli dei soci.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La *denuntiatio*.

In merito alla sua natura giuridica, in maniera analoga a quanto accade per il patto di prelazione civilistico, occorre ricordare che:

- parte della dottrina qualifica la *denuntiatio* come una vera e propria proposta contrattuale (un medesimo atto giuridico non può produrre un effetto antitetico a seconda della reazione che pone in essere il soggetto destinatario);
- altra parte della dottrina, invece, la qualifica come una mera dichiarazione di intenti avente una doppia valenza in quanto:
    - per il caso in cui venga rifiutata dal prelazionario libera l'offerente;
    - per il caso in cui venga accettata dal prelazionario non vincola l'offerente atteggiandosi a "sondaggio" sulla volontà del prelazionario inidoneo a produrre obblighi.

In ordine, invece, al suo contenuto occorre ricordare che la medesima deve contenere tutti gli elementi necessari ad informare, in modo completo, i soci con riferimento al contenuto del contratto di cessione.

L'unico dubbio si ravvisa in ordine alla necessità, *in assenza di un'apposita previsione statutaria*, che la *denuntiatio* debba contenere le generalità del terzo offerente (cioè il cessionario scelto dal cedente)[1].

La *denuntiatio* cumulativa

È possibile, inoltre, che la *denuntiatio* riguardi più partecipazioni sociali (c.d. *denuntiatio* cumulativa).

[1] La dottrina ha assunto sul punto posizioni non univoche:

- parte di essa ha ritenuto che tale indicazione fosse necessaria in quanto la clausola di prelazione assolve, da un lato, all'interesse dei soci all'acquisto della quota e, dall'altro lato, all'interesse della società all'omogeneità della compagine sociale.
  Preso atto della duplicità di scopi a cui la clausola di prelazione tenta di dare soddisfazione, si comprende la necessità che i soci vengano edotti in ordine alle generalità del soggetto che ha contrattato con il cedente. E ciò non tanto nel caso in cui i soci intendano esercitare il diritto di prelazione di cui sono titolari quanto, piuttosto, nel caso in cui non intendano dare esercitarlo, aprendo ad un terzo le porte della società; sarà, dunque, determinante conoscere le generalità del terzo acquirente, per comprendere in anticipo chi entrerà a far parte della società;
- altra parte della medesima, invece, ha osservato che nella *denuntiatio* non risulta necessaria l'indicazione delle generalità del terzo offerente in quanto l'interesse tutelato dalla clausola di prelazione sarebbe soltanto quello dei singoli soci all'acquisto.

Rispetto a questa esigenza sarebbe del tutto irrilevante la preventiva conoscenza delle generalità del terzo offerente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questa ipotesi il diritto ad essere preferito potrà essere esercitato dal titolare anche in ragione frazionaria quando la *proposta* risulti *scindibile* ossia quando il proponente ebbe intenzione di comunicare, benché in un unico contesto, volontà dispositive tra loro concettualmente dissociabili.

La prelazione a prezzo amministrato.

Tale concetto evoca una peculiare declinazione della clausola di prelazione impropria ossia quella che **prescinda** dal requisito **della parità di condizioni**, producendo un *vulnus* rispetto allo stesso.

Nel caso in cui tale clausola sia inserita nello statuto l'autonomia dei soci sarà incisa, sia sotto l'aspetto della determinazione del contenuto del negozio di cessione, sia sotto l'aspetto della scelta del soggetto con il quale contrattare.

Nel caso di specie, poi, è il meccanismo di calcolo del corrispettivo ad essere strutturato in modo tale da deprezzare statutariamente la partecipazione sino al punto di rendere sconveniente per il socio l'esercizio del suo potere dispositivo con riferimento alla quota di cui è titolare.

La dottrina, tenuto conto di quanto sin qui osservato, ritiene che ai soci, nell'ipotesi in commento, debba esser concesso il diritto di recesso.

Il riscatto (in caso di trasferimento della quota *inter vivos* o *mortis causa*).

Connotazione particolare rispetto alle clausole limitative della circolazione sino ad ora esaminate pare aver quella di riscatto ossia quella in forza della quale, al verificarsi di un dato evento (anche la morte), la partecipazione di un socio venga trasferita ad altro soggetto oppure ad una categoria di soggetti.

Come è stato osservato in dottrina tale clausola, invero, si pone quale motore propulsore del trasferimento e non come clausola limitativa del medesimo atteso che, a fronte dell'intento conservativo del socio titolare, la partecipazione viene fatta circolare sulla scorta della verificazione di un dato evento previsto nello statuto.

Clausola di consolidazione (o di accrescimento).

Ad opinione della migliore dottrina risulta lecita la clausola di consolidazione, per la quale, in caso di morte del socio, la sua quota si accresce ai soci superstiti in proporzione.

È discusso, in tale caso, se la clausola legittimi il recesso di per sé ossia anche da parte del socio quando era ancora in vita oppure se legittimi il recesso, dopo la morte del socio, solo da parte degli eredi.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A differenza che nel caso di *intrasmissibilità mortis causa* in caso di accrescimento la liquidazione della quota agli eredi (secondo la disciplina del recesso) è effettuata *dai soci superstiti* e non dalla società.

Clausola di opzione dei soci superstiti (in caso di trasferimento della quota *inter vivos* o *mortis causa*).

Ad opinione della dottrina migliore risulta, inoltre, ammissibile una clausola che attribuisca ai soci superstiti il diritto potestativo di acquistare, entro un dato periodo e ad un valore da determinarsi giusta parametri prestabiliti, da un socio o dai suoi eredi del defunto socio la partecipazione[2].

Nella s.r.l., a differenza che nella s.p.a., il diritto di opzione non può essere attribuito alla società, ma solo ai soci superstiti o a categorie di essi, preso atto del divieto di acquisto di quote proprie *ex* art. 2474 c.c.

[2] Tale clausola, benché non sia disciplinata, si ritiene lecita declinazione dell'autonomia privata anche in àmbito diverso da quello successorio. Detta clausola, valida ed efficace, non determina il diritto di recesso.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

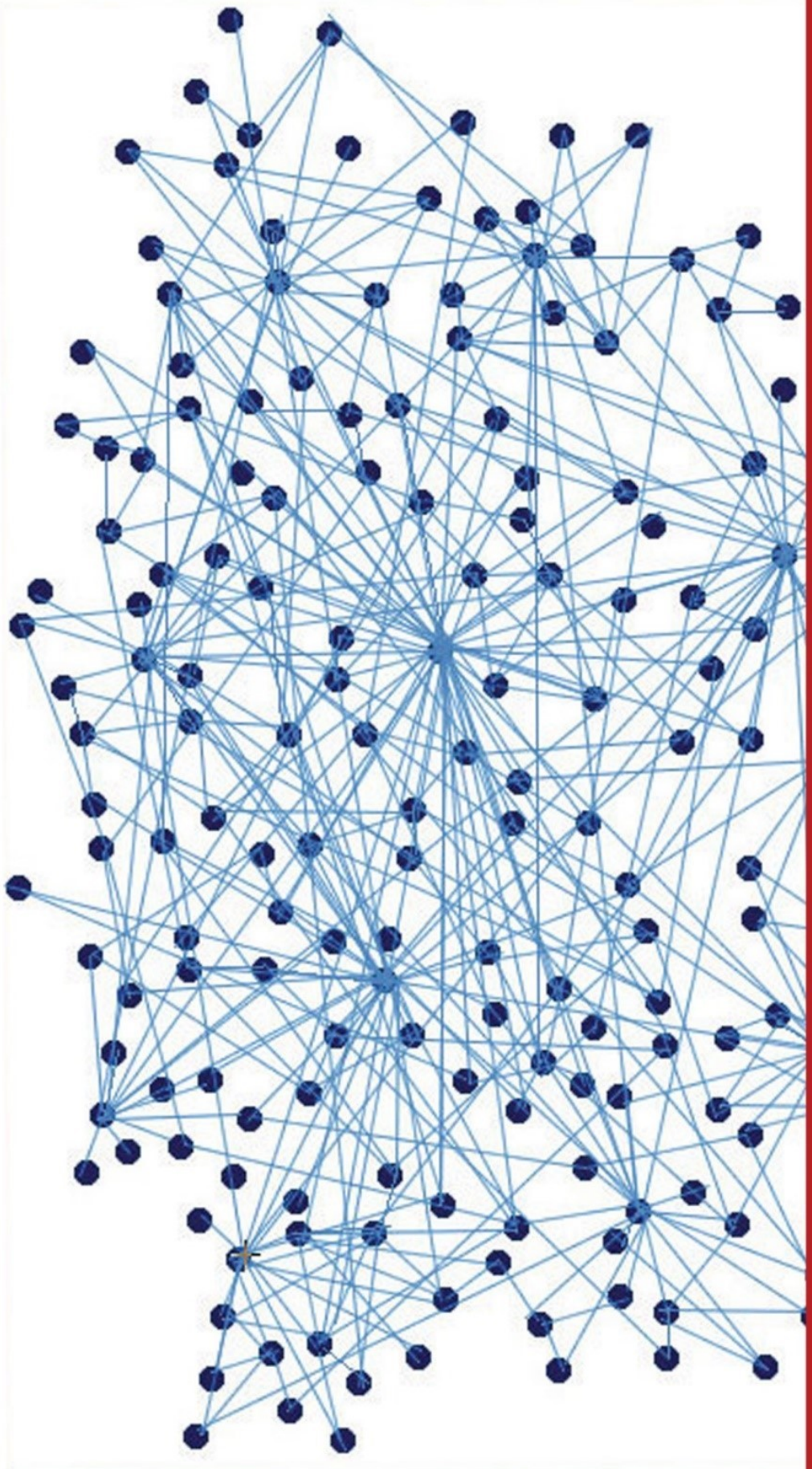
- G.M. Presti – M. Rescigno "Corso di diritto commerciale", Zanichelli, Bologna, 2015, Volume II, pagg. 227-231;
- O. Cagnasso "La società a responsabilità limitata" in "Trattato di Diritto Commerciale", diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2007, Volume V, pagg. 123-148;
- E. Fregonara "Commento sub art. 2469, comma 1°, c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 313-333.
- F. Riganti "Commento sub art. 2469, comma 2°, c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 334-363.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI: MODALITÀ 3

1.1 La situazione anteriore alla riforma e la disciplina riformata 3
1.2 I requisiti della norma 4
1.3 La scrittura privata autenticata dal notaio 5
1.4 Il documento informatico sottoscritto dalle parti con firma digitale semplice 5

2. LA CESSIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI: L'EFFICACIA DEL CONTRATTO E L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE 6

2.1 L'atto di trasferimento prima dell'iscrizione nel Registro delle imprese 6
2.2 Il deposito presso il Registro delle Imprese 6
2.3 Il ruolo degli amministratori 7

3. ABROGAZIONE DEL LIBRO SOCI E PROFILI DI RESPONSABILITÀ DELL'ALIENANTE DELLA QUOTA 8

3.1 Abrogazione del libro soci 8
3.2 La responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti 9

BIBLIOGRAFIA 10

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La cessione delle partecipazioni sociali: modalità

1.1 La situazione anteriore alla riforma e la disciplina riformata

Il polo dell'efficacia e quello della pubblicità hanno, da sempre, rappresentato i due aspetti fondamentali intorno ai quali si è sviluppata la disciplina relativa al trasferimento delle partecipazioni sociali nel modello associativo a responsabilità limitata.

Il fenomeno traslativo avente ad aggetto siffatte partecipazioni sociali era già stato considerato nei progetti di codici di commercio elaborati negli anni '20 del secolo scorso.

Al riguardo pare opportuno sinteticamente ricordare:

- Il progetto Vivante (1921) caratterizzato, per ciò che concerne il trasferimento delle quote di quella che veniva definita società a garanzia limitata:
  - ✓ dalla necessaria forma dell'atto pubblico per la cessione delle sue quote;
  - ✓ dall'iscrizione dell'atto traslativo nel libro dei soci;
  - ✓ dall'iscrizione dell'atto traslativo nel Registro di commercio sulla scorta della considerazione che il mutamento di titolarità avrebbe determinato anche un mutamento delle regole statutarie.
- Il progetto D'Amelio (1925) che ripercorreva la strada tracciata dal progetto Vivante;
- Il progetto Asquini (1940) il quale si connotava per:
  - ✓ la necessità di iscrizione dell'atto traslativo nel libro soci;
  - ✓ la necessità, onde attuare la pubblicità di carattere dichiarativo tipica delle modifiche statutarie, di iscrizione dell'atto traslativo nel Registro di commercio;
  - ✓ la forma dell'atto pubblico al solo scopo di accedere al sistema pubblicitario testé indicato.

Quest'ultimo progetto fu, poi, trasfuso nel progetto ministeriale avente ad oggetto il libro del lavoro.

Il dato positivo di risulta dell'iter codificatorio seguito in Italia, ossia l'art. 2479 c.c., non conteneva, invero, alcun riferimento alla forma dell'atto di cessione e al regime pubblicitario a cui il medesimo dovesse essere sottoposto.

Tale situazione normativa fece interrogare la dottrina che, sul punto, non raggiunge opinioni univoche.

Parte della medesima trovava giustificazione all'atteggiamento normativo nella sostanziale irrilevanza, per i terzi, della composizione della base sociale.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Altra parte della dottrina sottolineava come tale atteggiamento fosse da ricollegare alla volontà normativa di emancipare il tipo societario in esame dai modelli a vocazione personalistica, superando il dato per cui il mutamento dei componenti della compagine sociale avesse una diretta incidenza nella dimensione statutaria.

La situazione mutò, invero, con la promulgazione della Legge 12 agosto 1993 n. 310 la quale intervenne sul disposto dell'art. 2479 c.c.

Con la medesima si prevedeva, ferma restando l'ancoraggio del regime di efficacia dell'atto di cessione all'iscrizione del medesimo nel libro soci, che tale adempimento dovesse essere espletato entro 30 giorni dal deposito presso il Registro delle imprese dell'atto traslativo redatto nella forma della scrittura privata autenticata.

L'autenticazione di quest'ultima, pur rappresentando una fase di un procedimento complesso teso ad ottenere la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali, non integrava un requisito di validità della fattispecie traslativa, ma una condizione per poter procedere alla successiva iscrizione nel Registro delle Imprese.

La dottrina si domandava, senza addivenire a soluzioni univoche, se quest'ultima fosse utile ad assolvere ad una ulteriore funzione ossia quella di dirimere il conflitto tra più acquirenti della medesima quota.

Una parte della medesima elevava l'espletamento di tale formalità a criterio dirimente per il predetto conflitto, mentre altra opinione sapienziale escludeva che alla medesima, in assenza di precisi indici normativi, potesse essere assegnata tale funzione, dovendosi, piuttosto, concedere prevalenza alla regola del prior in tempore potior in iure corroborato dal requisito della data certa.

1.2 I requisiti della norma

La formulazione dell'art. 2470 c.c., per come risultante dalla legge di riforma delle società di capitali e successive modificazioni, conferma la dimensione procedimentale del fenomeno.

Si ribadisce, infatti, la necessità:

- che l'atto traslativo rivesta la forma della scrittura privata autenticata;
- che il medesimo, infine, venga iscritto presso il Registro delle imprese.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.3 La scrittura privata autenticata dal notaio

La forma autentica, per tutte le sottoscrizioni, è, quindi, richiesta ad regularitatem, al fine di consentire l'iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese ossia per fare in modo che l'atto traslativo produca, in pieno, tutti propri effetti tanto nei riguardi della società quanto nei confronti dei terzi.

1.4 Il documento informatico sottoscritto dalle parti con firma digitale semplice

Il sistema normativo appena descritto è stato "scosso" dalla Legge 6 agosto 2008 n. 133 con la quale, con l'art. 33.1 bis, è stata ampliata la competenza al deposito presso il Registro delle imprese degli atti di cessione "sottoscritti con firma digitale".

Tale novella ha suscitato molte incertezze interpretative afferenti alla persistenza del necessario ausilio notarile nell'espletamento delle formalità di autenticazione.

La dottrina, infatti, si è divisa tra:

- quanti ritengono ancora necessaria la formalità notarile;
- quanti ritengono che, in omaggio a ragioni di semplificazione, sussista una piena equiparazione tra l'atto autenticato dal notaio e quello digitalmente firmato;
- quanti, ancora, osservano che la formalità digitale sarebbe sufficiente alle finalità del deposito, ma non a quelle dell'iscrizione presso il Registro delle imprese.

Il Legislatore, però, pare avere espresso la propria idea al riguardo mediante la promulgazione della Legge 183/2011 a norma della quale occorrerebbe ritenere, in modo stridente rispetto al dettato costituzionale, che le regole fissate con la novella del 2008 integrino un regime circolatorio alternativo rispetto a quello codicistico, caratterizzato dall'assenza dell'ausilio notarile.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La cessione delle partecipazioni sociali: l'efficacia del contratto e l'iscrizione nel registro delle imprese

2.1 L'atto di trasferimento prima dell'iscrizione nel Registro delle imprese

La materia in esame si conforma al principio generale del c.d. consenso traslativo il quale, per come scolpito nell'art. 1376 c.c., fissa il momento del trasferimento della proprietà nell'incontro dei consensi legittimamente manifestati.

Tale principio trova applicazione, unitamente a quello della libertà di forma, anche in materia societaria di tal che, tra le parti, la cessione deve intendersi valida ed efficacia sol che le parti si accordino in tal senso.

La forma richiesta dall'art. 2470 c.c., lungi dall'incidere sulla validità e sull'efficacia dell'atto di trasferimento tra le parti, dischiude al medesimo le porte dei registri pubblici, consentendo l'espletamento delle formalità pubblicitarie ivi connesse allo scopo di legittimare l'acquirente all'esercizio dei diritti sociali.

2.2 Il deposito presso il Registro delle Imprese

Il regime di efficacia del trasferimento, in esito alla novella legislativa del 2003, è, oggi, ancorato al "deposito" dell'atto traslativo presso il Registro delle imprese.

Il profondo mutamento delle regole di efficacia del trasferimento in esame lascia, però, impregiudicata la questione afferente al momento in cui il soggetto acquirente acquisti la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali nei possa esercitare i diritti compendiati nella partecipazione nei riguardi della società.

La dottrina non ha raggiunto soluzioni interpretative univoche al riguardo:

- parte della dottrina, attuando un'interpretazione "ortopedica" del dato normativo ancora tale risultato alla concreta iscrizione dell'atto di trasferimento nel Registro delle imprese atteso che sarebbe necessario il rispetto di simmetria tra le risultanze pubblicitarie e le regole di legittimazione;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- altra parte, invece, valorizzando il dato positivo, tende a distinguere il regime di efficacia verso la società (connesso al deposito, non surrogabile da altra qualsivoglia, forma di conoscenza, dell'atto traslativo presso il Registro delle imprese) da quello verso i terzi (ancorata, invece, all'espletamento delle formalità di iscrizione in detto Registro).

2.3 Il ruolo degli amministratori

Il tessuto normativo di riferimento non aiuta a sciogliere il nodo esegetico afferente alla posizione e i doveri che si appuntano in capo all'organo amministrativo con riferimento al procedimento che culmina con il trasferimento della partecipazione sociale.

Il mutamento delle regole sopra brevemente ricordato fa sì che in capo al medesimo sia sorto, in aggiunta a quello di verificare il rispetto delle regole statutarie che presiedono alla cessione, un dovere di ispezione periodica del Registro delle imprese volto a rendere palese quali siano i soggetti legittimati all'esercizio dei diritti sociali nelle sedi di riferimento.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Abrogazione del libro soci e profili di responsabilità dell'alienante della quota

3.1 Abrogazione del libro soci

In un'ottica di forte deflazione dei costi endosocietari con i Decreto-legge 20 novembre 2008 convertito, con modificazioni, in Legge 29 gennaio 2009 n. 2 è stato soppresso il libro soci dal novero dei libri obbligatori ai sensi dell'art. 2478 c.c.

La dottrina si è domandata, preso atto delle difficoltà pratiche che possono annodarsi a tale soppressione, se fosse legittima una clausola con la quale si ripristinasse convenzionalmente il libro soci.

L'opinione sapienziale è compatta nel ritenere che non si possa anticipare ad un momento antecedente al deposito presso il Registro delle imprese l'opponibilità del trasferimento delle partecipazioni nei riguardi della società.

Molto più dibattuta, invero, è la questione se tale effetto possa essere ancorato all'espletamento di formalità ulteriori di tal che risulti posticipato rispetto alla previsione normativa.

Parte della dottrina, ritenendo le regole di legittimazione imperative ed indisponibili per le parti, ha negato che l'introduzione convenzionale del libro soci potesse assolvere a finalità di legittimazione verso la società.

Altra parte della dottrina, invece, non ritenendo decisive le considerazioni svolte dall'opinione antagonista, ammette, correttamente, che la previsione di un libro soci facoltativo possa assolvere alla predetta finalità non contrastando la medesima con alcun principio generale o interesse superiore.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.2 La responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti

Per il caso in cui circolino partecipazioni non interamente liberate la regola che il Legislatore a pone è, in consonanza alla disciplina delle s.p.a. (art. 2356 c.c.), quella della responsabilità solidale, per un periodo massimo di tre anni che principia dalla data di iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, tra acquirente e alienante per i versamenti ancora dovuti (art. 2472 c.c.).

La regola della solidarietà testé evocata è, tuttavia, corretta dalla sussidiarietà, e dà, quindi, luogo ad un'ipotesi di solidarietà c.d. diseguale.

In altri termini il creditore (società), prima di poter richiedere la prestazione dovuta al venditore (ex socio), dovrà averla infruttuosamente richiesta all'acquirente (nuovo socio) che, in esito al negozio con il quale è stata trasferita la partecipazione, assume la veste di obbligato principale per il versamento dei centesi ancora dovuti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

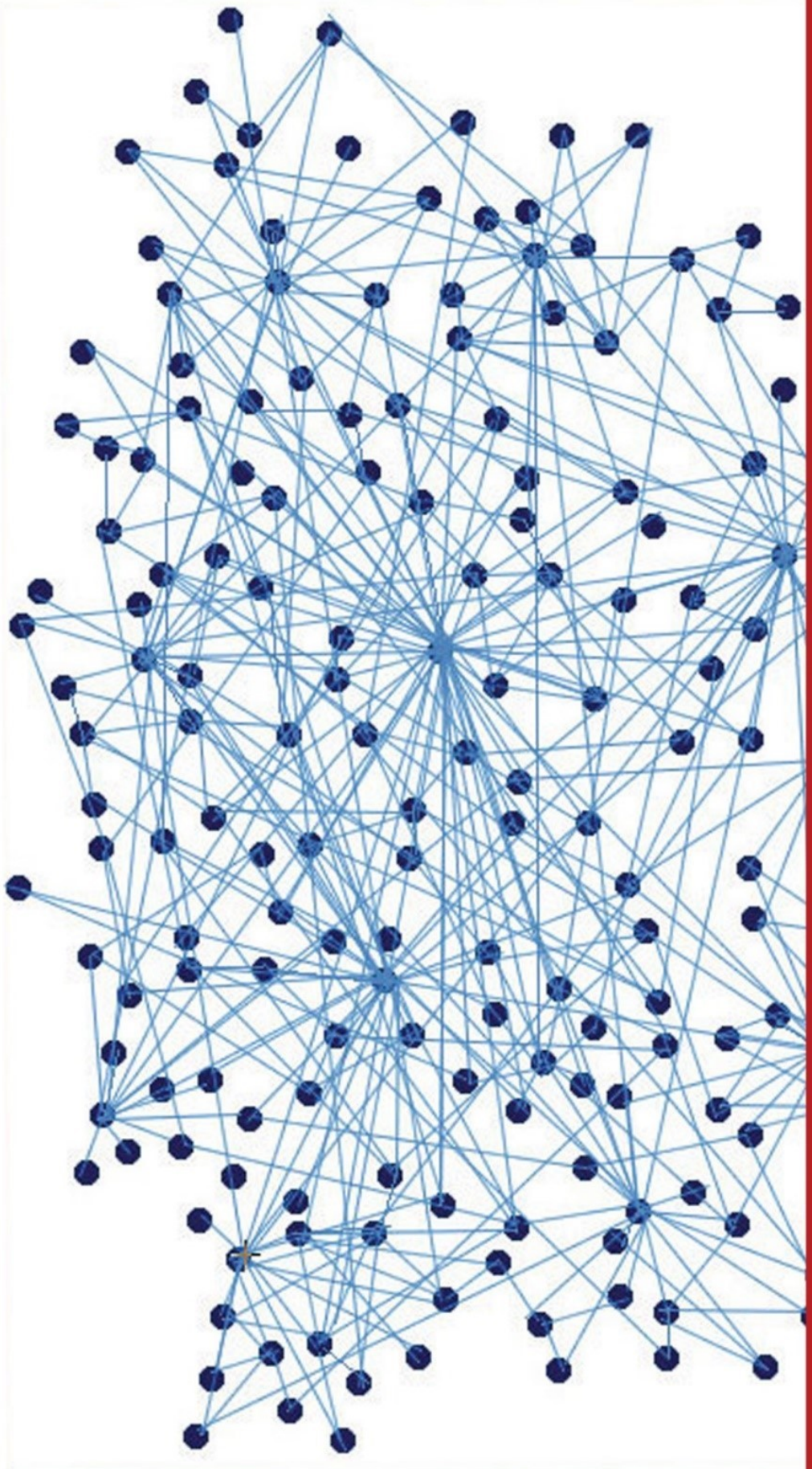
- G. M. Presti – M. Rescigno "Corso di diritto commerciale", Zanichelli, Bologna, 2015, Volume II, pagg. 229-230.
- O. Cagnasso "La società a responsabilità limitata" in "Trattato di Diritto Commerciale", diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2007, Volume V, pagg. 143-149.
- P. Revigliono "Commento sub art. 2470 c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 364-372.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CONFLITTO TRA PIÙ ACQUIRENTI DELLA MEDESIMA QUOTA 3

1.1 CONFLITTO TRA PIÙ ACQUIRENTI DELLA MEDESIMA QUOTA PRIMA DELLA RIFORMA 3
1.2 LA DISCIPLINA DELL'ART. 2470, COMMA TERZO, C.C. 3
1.3 LA NOZIONE DI BUONA FEDE 4

2. PARTICOLARI VICENDE AVENTI AD OGGETTO LA PARTECIPAZIONE SOCIALE 6

2.1 PEGNO, USUFRUTTO, SEQUESTRO DELLA QUOTA 6
2.2 OPERAZIONI SULLE PROPRIE QUOTE 7

3. L'ESPROPRIAZIONE DELLA QUOTA 10

3.1 LA QUESTIONE DELLA ESPROPRIAZIONE DI UNA FRAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 11

BIBLIOGRAFIA 13

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Conflitto tra più acquirenti della medesima quota

1.1 Conflitto tra più acquirenti della medesima quota prima della riforma

Nel sistema previgente alla legge di riforma del 2003 non esistevano puntuali referenti normativi in materia.

La dottrina aveva, quindi, assunto atteggiamenti non univoci in ordine a tale aspetto di disciplina dando luogo a due contrapposti orientamenti:

- parte maggioritaria della medesima risolveva la questione facendo applicazione piana del principio prior in tempore potior in iure;
- a tale opinione si contrapponeva quella di quanti, ascrivendo la quota alla classe dei beni immateriali iscritti in pubblici registri, tendevano a risolvere il problema facendo leva sulla regola dell'anteriorità della iscrizione dell'atto traslativo presso il Registro delle imprese.

1.2 La disciplina dell'art. 2470, comma terzo, c.c.

L'art. 2470, comma 3°, c.c., con un'innovazione rispetto al sistema normativo previgente, ha introdotto una regola tesa a risolvere i conflitti potenzialmente insorgenti tra più acquirenti della medesima "quota".

La norma, pur avendo il pregio di farsi carico di risolvere un annoso problema teorico, sorto con riferimento al sistema normativo previgente, introduce, a sua volta, una serie di dubbi interpretativi di non secondario momento.

In prima istanza occorre prendere atto che le regole di protocollazione degli atti depositati (progressiva secondo l'ordine di deposito) non sono propriamente estensibili anche all'espletamento delle formalità di iscrizione dei medesimi posto che non esiste un dato positivo che imponga per queste ultime regole analoghe a quelle che presiedono il deposito.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In seconda istanza occorre ricordare che l'assenza di una norma che imponga la continuità delle iscrizioni rende molto complicato ripercorre, a ritroso, il percorso circolatorio della partecipazione.

Sulla scorta della lettera di tale norma, tuttavia, ove la quota venga alienata, con successivi contratti, a soggetti differenti sarà preferita quella che, benché abbia un titolo che reca una data posteriore, abbia, in buona fede, curato per prima l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Il legislatore, dunque, pare avere selezionato quale criterio utile a dirimere il potenziale conflitto in esame quello della priorità dell'iscrizione.

Tale soluzione, nel fare eco a talune considerazioni svolte dalla dottrina anteriormente alla legge di riforma del sistema delle società di capitali, pare adombrare una modalità di soluzione del conflitto che riecheggia quella selezionata da Legislatore in tema di conflitti afferenti alla circolazione di beni immobili o mobili registrati.

1.3 La nozione di buona fede

La suggestione di cui sopra si struttura intorno all'impiego legislativo del parametro della buona fede che deve sorreggere l'espletamento delle formalità pubblicitarie sopra descritte.

Detto concetto può essere spiegato con la completa l'ignoranza dell'acquirente successivo in merito alla precedente alienazione che avesse avuto ad oggetto la partecipazione dal medesimo, poi, acquistata.

Il requisito in oggetto, ad opinione della dottrina, pare da riferire solo al tempo dell'acquisto del diritto di tal che la mala fede sopravvenuta a tale momento, nelle more della iscrizione, sarebbe da ritenere del tutto irrilevante per le finalità in esame.

Il riferimento a siffatto ulteriore parametro ha destato tra gli interpreti umori discordanti atteso che mediante la sua previsione si è determinato un pericoloso intreccio tra dati formali (iscrizione) e circostanze fattuali (buona fede) di non semplice accertamento.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A ciò si aggiunga, poi, che considerare l'ipotesi in questione annoverabile tra quelle di acquisto a non domino avrebbe significative ricadute in termini di disciplina.

Quella che balza più rapidamente agli occhi, come ben rilevato dalla dottrina, è quella che, facendo del caso in commento un'ipotesi di acquisto a non domino, non sarebbe più necessario verificare la continuità delle iscrizioni presso il Registro delle imprese o qualsivoglia altro indice formale afferente all'alienante onde tutelare l'acquirente.

Per queste ragioni la dottrina ha sostenuto impostazioni teoriche differenti:

1. parte di essa, facendo leva sull'introduzione del requisito della buona fede dell'iscrivente, ha evocato le regole di disciplina degli acquisti a non domino di beni mobili, sostenendo che la regola descritta nella norma in commento, altro non sia che una peculiare declinazione di quella, più generale, di cui all'art. 1153 c.c.;
2. altra parte, invece, ritenendo privo di supporto positivo il predetto ragionamento, in consonanza a talune opinioni già consolidatesi prima della riforma del 2003 e con lo spirito della novella, ha ricondotto l'ipotesi in esame ai principi che governano l'acquisto a non domino di beni immobili e mobili registrati;
3. altra parte ancòra, sottolineando le gravi difficoltà ermeneutiche a cui l'adesione all'una o all'altra tesi testé esposte condurrebbe, ha preferito valorizzare le peculiarità dell'ipotesi de qua argomentandone l'autonomia concettuale rispetto al tema degli acquisti a non domino.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Particolari vicende aventi ad oggetto la partecipazione sociale

2.1 Pegno, usufrutto, sequestro della quota

Il referente normativo di siffatti vincoli è dato dall'art. 2471 bis c.c.

A norma di tale articolo la partecipazione sociale può essere oggetto di pegno, usufrutto e sequestro tanto conservativo quanto giudiziario attesa la connotazione prettamente conservativa di entrambe le tipologie evocate.

Il Legislatore ha edificato l'impianto normativo di riferimento mediante la tecnica del rinvio.

Più precisamente la norma nella quale si trova il nucleo di regole atte a disciplinare i casi in esame è l'art. 2352 c.c. dettato in materia di s.p.a.

Quest'ultimo dato positivo rappresenta, dunque, la principale fonte regolamentare delle fattispecie in commento fermo, ad ogni modo, quanto disposto dall'art. 2471, comma 3°, c.c[1].

Da ciò consegue che, salva diversa previsione statutaria, in caso di pegno e di usufrutto il diritto di voto, come quasi ogni altro diritto amministrativo, spetta all'usufruttuario e al creditore pignoratizio, mentre nel caso di sequestro tale prerogativa, unitamente alla gestione conservativa, spetta al custode.

Per il caso in cui circolino partecipazioni non interamente liberate la regola che il Legislatore a pone è, in consonanza alla disciplina delle s.p.a., quella della responsabilità solidale, per un periodo massimo di tre anni che principia dalla data di iscrizione del trasferimento nel Registro delle imprese, tra acquirente e alienante per i versamenti ancora dovuti (art. 2472 c.c.).

[1] Il Legislatore, con tale norma, fissa una disciplina che deroga ai principi generali di riferimento senza, però, precisare il significato della medesima.
È, in sostanza, dubbio quale sia la portata della medesima. Per il caso in cui la partecipazione sia assolutamente intrasferibile a fronte di una generale opinione negativa nel pensiero degli autori che commentavano il dettato normativo anteriforma si stagliano le considerazioni della dottrina più moderna che risulta incline, valorizzando lo spirito della riforma del 2003, a sussumere tale fattispecie entro la classe delineata dall'articolo in commento.
Analoga considerazione viene fatta, in dottrina, per il caso in cui l'inespropriabilità della quota consegua ad una clausola di prelazione atteso che l'interesse che essa mira a proteggere è quello dell'intera compagine sociale.
Per l'ipotesi in cui, infine, la restrizione in esame provenga dalla legge la tesi prevalente in dottrina è quella per la quale occorra sussumere tale fattispecie entro la classe delineata dall'articolo in commento in omaggio alla preminenza che, in materia, è da riconoscere alla legge.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La regola della solidarietà testé evocata è, tuttavia, corretta dalla sussidiarietà, dando luogo ad un'ipotesi di solidarietà c.d. diseguale.

In altri termini il creditore (società), prima di poter richiedere la prestazione dovuta al venditore (ex socio), dovrà infruttuosamente richiederla all'acquirente (nuovo socio) che, in esito al negozio con il quale è stata trasferita la partecipazione, assume la veste di obbligato principale per il versamento dei centesi ancòra dovuti.

2.2 Operazioni sulle proprie quote

Il tema trova quale proprio referente normativo l'art. 2474 c.c.

In materia di s.r.l., a differenza di quanto accade in tema di s.p.a., sussiste un generale ed assoluto divieto di acquisto ed accettazione in garanzia delle proprie partecipazioni da parte della società medesima.

Tale divieto risponde ad una ratio che risulta, quanto ai contenuti, molto discussa in dottrina.

Sul punto l'opinione sapienziale ha dato origine a svariati orientamenti interpretativi che posso essere riassunti nel modo che segue:

- parte di essa, cercando supporto nelle considerazioni afferenti il tema in materia di s.p.a., ritiene che il divieto si giustifichi nell'ottica di protezione dell'integrità del capitale sociale a tutela delle minoranze sociali e dei creditori;
- altra parte della dottrina, invece, muovendo dalle risultanze della Relazione di accompagnamento alla legge di riforma del 2003, ritiene che il divieto si spieghi alla luce di una valutazione normativa di antieconomicità sottesa all'operazione in esame;
- altra parte della dottrina, argomentando dalla mancata incorporazione della quota di s.r.l. in un titolo, ritiene che il divieto in commento serva ad evitare gli effetti della confusione di cui all'art. 1253 c.c.;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- altra parte ancòra della dottrina opina che il basamento teorico del divieto in esame sia da rinvenire nelle peculiarità del tipo societario in commento e, precisamente, nel ruolo centrale assunto dai soci nel medesimo.

La norma in esame precisa quali siano le conseguenze del superamento di tale divieto.

Per ciò che concerne il profilo endosocietario è opinione diffusa in dottrina che la delibera che prenda posizione in tal senso sia nulla per illiceità dell'oggetto.

In ordine, invece, all'attività attuativa che ne consegue l'opinione dottrinale si articola tra quanti invocano la nullità, per illiceità, con sopravvivenza del rapporto sociale e l'obbligo del procedere alle reciproche restituzioni e quanti, al contrario, ritengono applicabile l'altro polo dell'invalidità ossia l'annullabilità.

Il divieto in commento, ad opinione della dottrina migliore deve trovare anche applicazione:

- nelle operazioni di leveraged buy out sulla scorta del portato normativo dell'art. 7 della legge 366/2001;
- nelle ipotesi di sottoscrizione reciproca di quote, di acquisto di quote di società controllate e di assunzione di partecipazioni in altre imprese che alterino profondamente l'oggetto sociale. La dottrina giunge, per via estensiva oppure analogica, a tale risultato contestando la carenza normativa sul punto che si tradurrebbe in un vulnus di tutela, per i creditori e le minoranze sociali, privo di logica spiegazione.

La dottrina si è chiesa se ed entro quali limiti l'autonomia privata possa limitare oppure escludere il divieto in esame raggiungendo i seguenti risultati teorici:

- parte di essa ha precisato che vi sarebbe un caso eccezionale in cui l'acquisto di proprie quote risulta consentito: si tratta della riduzione reale del capitale attuata mediante riscatto ed annullamento di quote proprie. Una simile operazione sarebbe consentita in quanto l'acquisto delle quote è finalizzato all'annullamento delle stesse e, pertanto, non sussiste la ratio del divieto in esame;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- altra parte, invece ritiene che il divieto non soffra eccezioni, in quanto la disposizione prevede che «in nessun caso» è consentito l'acquisto di azioni proprie. Di conseguenza, nella s.r.l. tra le modalità di attuazione della riduzione reale del capitale non dovrebbe ritenersi compreso il riscatto ed annullamento di quote proprie.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. L'espropriazione della quota

L'operazione in esame è, oggi, disciplinata dall'art. 2471 c.c.

Il dato positivo, incontrovertibilmente, statuisce che la partecipazione sociale del modello in esame può essere oggetto di espropriazione.

Quest'ultima riguarderà, tenuto conto della complessa composizione della quota, tanto le situazioni attive quanto quelle passive afferenti alla partecipazione.

Ciò posto occorre precisare che il pignoramento si esegue, nel rispetto delle regole di rito, mediante notifica al debitore e alla società di un atto complesso e la sua successiva iscrizione nel Registro delle imprese allo scopo di fare pervenire, coattivamente, al creditore quanto è a lui dovuto.

Il tessuto normativo di riferimento, benché possa sembrare, ad un approccio epidermico, soddisfacente, non ha contribuito in maniera significativa a dissipare i dubbi afferenti la qualificazione della procedura ivi descritta.

Nel sistema normativo previgente, in assenza di indici positivi in ordine alle concrete modalità con cui condurre l'esecuzione, si tendeva ad applicare la procedura del pignoramento presso terzi.

Il dato positivo odierno, nella sua non felice formulazione, potrebbe condurre a ritenere, evocando l'obbligo di notificazione alla società, che le regole di riferimento siano ancòra quelle del pignoramento presso terzi.

La dottrina, però, ha osservato che tale obbligo informativo potrebbe giustificarsi in maniera differente non essendo, di necessità, una declinazione del pignoramento sopra indicato.

La nuova formulazione legislativa, sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale più moderno, pare avere avallato una modalità esecutiva che in nulla assomiglia al pignoramento presso terzi, articolandosi, in via autonoma, attorno al fulcro della notificazione al debitore e alla pubblicità nel Registro delle imprese onde renderla opponibile ai terzi.

Tale modalità esecutiva prende avvio con il pignoramento.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Quest'ultimo si articolerà in due fasi:

1. notificazione, su istanza di parte, al socio debitore e alla società la quale funge da momento perfezionativo del pignoramento nei rapporti interni tra le parti;
2. iscrizione nel registro delle imprese con il quale lo stesso è portato a conoscenza dei terzi.

Da quando la procedura è iscritta nel Registro delle imprese gli atti di alienazione della quota che ne è oggetto possono essere dichiarati inefficaci ad opera del creditore procedente o di altri creditori che abbiano aderito alla procedura.

Da ultimo, nella sua fase finale, la procedura ritorna nell'alveo del pignoramento presso il debitore.

Il creditore procedente deve, nei termini fissati dal codice di rito, depositare, munito di titolo esecutivo, l'istanza di assegnazione o di vendita.

Sentite le parti il giudice statuisce, con ordinanza, sulla richiesta fissando le modalità del trasferimento. Tale provvedimento giudiziario deve essere notificato alla società a cura del creditore procedente. Non sono, invece, soggetti a siffatta regola pubblicitaria né l'aggiudicazione della partecipazione in sede di esecuzione forzata né l'assegnazione al creditore atteso che i medesimi producono effetti traslativi immediati (dovendosi ritenere all'uopo applicabile l'art. 2919 c.c.). Da ciò discende che questi ultimi dovranno sottostare alle regole pubblicitarie di cui all'art. 2470, comma 2°, c.c. le quali, peraltro, segneranno il momento a partire dal quale l'effetto traslativo risulterà opponibile alla società.

3.1 La questione della espropriazione di una frazione della partecipazione

La dottrina è divisa in merito alla possibilità di circoscrivere l'effetto espropriativo ad una parte soltanto della quota.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A tal riguardo si fronteggiano in dottrina contrapposte opinioni che possono essere riassunte nel modo che segue:

- una parte di essa, muovendo dalla unitarietà e dalla inscindibilità della quota di s.r.l., esclude tale possibilità;
- altra parte (maggioritaria), invece, argomentando dalla normativa di settore in materia di recesso, ritiene ammissibile tale operazione posto che la quota di s.r.l., lungi dall'essere un coacervo di posizioni soggettive inscindibilmente collegate le une con le altre, risulta divisibile;
- altra parte ancòra della dottrina, evocando una soluzione di compromesso, ritiene che si possa addivenire all'espropriazione parziale della quota solo ove la medesima abbia un valore di molto superiore al credito per il quale si procede posto che dovrebbero trovare qui applicazione i principi che regolano la vendita nella procedura esecutiva.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

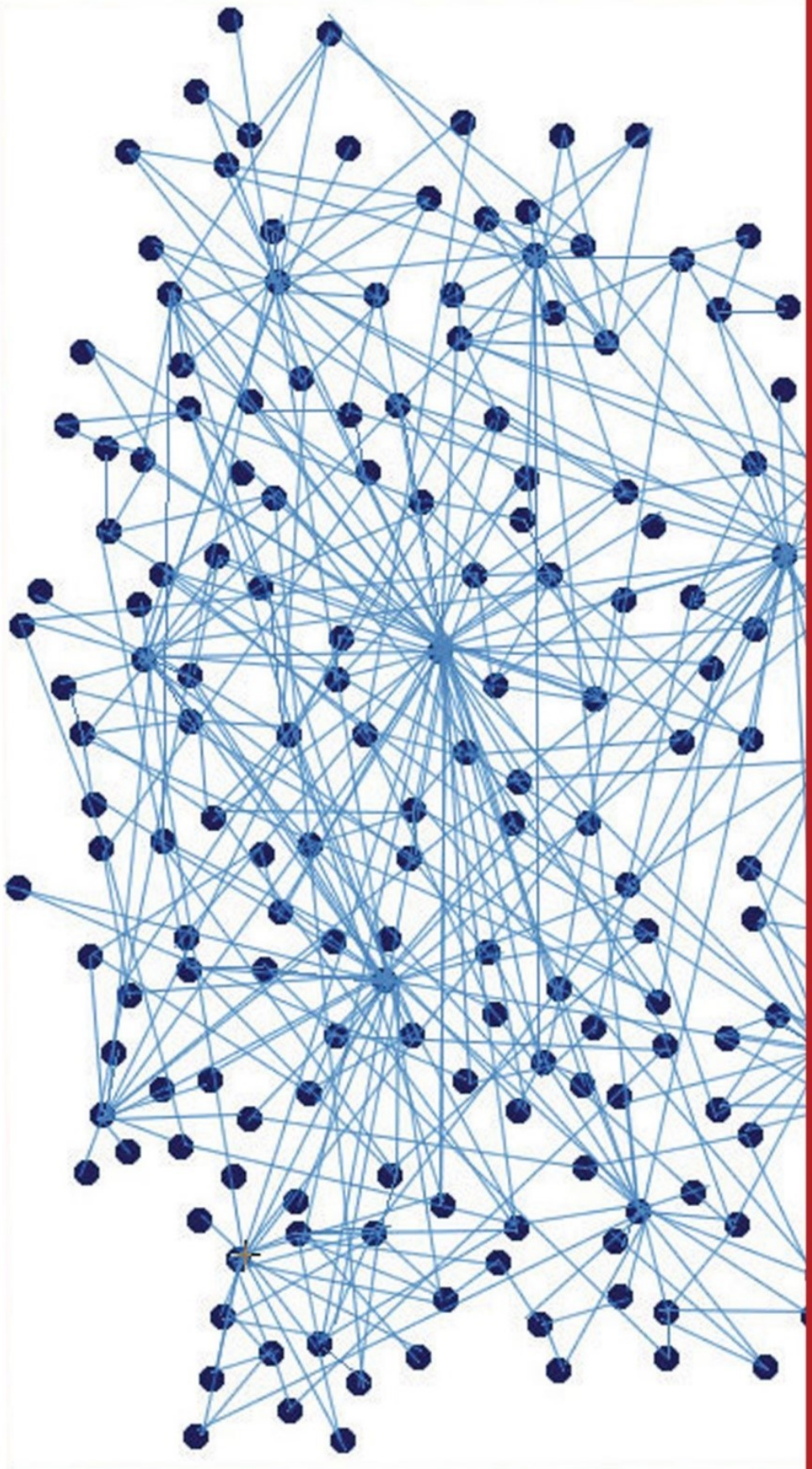
- G. M. Presti – M. Rescigno "Corso di diritto commerciale", Zanichelli, Bologna, 2015, Volume II, pagg. 231-232.
- O. Cagnasso "La società a responsabilità limitata" in "Trattato di Diritto Commerciale", diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2007, Volume V, pagg. 149-154.
- M. Quaranta "Commento sub artt. 2471- 2472 c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 380-393.
- Bollettinari "Commento sub art. 2474 c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 414-422.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA CADUCAZIONE DEL RECESSO 3

1.1 IL RECESSO COME FATTISPECIE A FORMAZIONE PROGRESSIVA CHE SI COMPLETA SOLO CON IL RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE 3
1.2 DEFINIZIONE DI CADUCAZIONE DEL RECESSO 3
1.3 LA REVOCAZIONE DELLA DELIBERA CHE HA LEGITTIMANTE IL RECESSO 4
1.4 LO SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ 5

2. LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO RECEDUTO: MODALITÀ OPERATIVE 6

2.1 DISCIPLINA PRECEDENTE ALLA RIFORMA 6
2.2 IL CREDITO CHE SORGE IN SEGUITO ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO È DI VALUTA, ESIGIBILE E DI FACILE E PRONTA LIQUIDAZIONE 6
2.3 L'ACQUISTO DELLA PARTECIPAZIONE DEL SOCIO RECEDENTE DA PARTE DEGLI ALTRI SOCI 7
2.4 IL CRITERIO PROPORZIONALE 7
2.5 L'INDIVIDUAZIONE DA PARTE DEI SOCI DI UN SOGGETTO CHE ACQUISTI LA PARTECIPAZIONE SOCIALE DEL SOCIO RECEDENTE 8

3. LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO RECEDUTO: MODALITÀ OPERATIVE IN DIFETTO DI ACQUISTO DELLA QUOTA 9

3.1 IL RIMBORSO EFFETTUATO MEDIANTE RISERVE DISPONIBILI 9
3.2 IL RIMBORSO EFFETTUATO MEDIANTE LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE E L'APPLICAZIONE DELL'ART. 2482 C.C. 9
3.3 LA MESSA IN LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ 10

BIBLIOGRAFIA 11

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La caducazione del recesso

1.1 Il recesso come fattispecie a formazione progressiva che si completa solo con il rimborso della partecipazione sociale

In esito alla legge di riforma il procedimento di liquidazione della quota del socio recedente[1] pare essere stato modellato sulla scorta di quello previsto in materia di s.p.a.

Esso si sviluppa, per tappe, lungo un iter che ricalca quello tipico dei modelli azionari, salvo talune deviazioni necessitate dal differente impianto normativo di riferimento.

Il comma 4° dell'art. 2473 c.c. traccia le linee di questo nuovo procedimento che si articola in cinque fasi tra loro logicamente e cronologicamente susseguenti ed ordinate, come meglio si chiarirà in seguito, in ossequio al principio per cui il capitale sociale deve essere preservato, per quanto più possibile, nell'espletamento della procedura di liquidazione.

1.2 Definizione di caducazione del recesso

Con tale espressione si intende, in dottrina, evocare l'instabilità effettuale della dichiarazione unilaterale e recettizia che sostanzia il recesso.

Il suo profilo effettuale, infatti, lungi dal ricalcare i confini operativi civilistici degli atti di tale natura, può essere rimesso in discussione dalla volontà dell'ente[2] il quale, in ultima analisi, è il

[1] Il credito che il socio matura in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso ha natura pecuniaria ed integra per la società, come meglio *infra* precisato, un debito di valuta. Esso si presenta come un credito esigibile e di facile e pronta liquidazione. Per tale, ragione si anticipa, detto credito sarà idoneo a produrre interessi di diritto sin dal momento in cui sorgerà senza bisogno della procedura di messa in mora nei riguardi della società.

[2] La dottrina, da quanto sin qui osservato in materia di efficacia della dichiarazione di recesso ed in assenza di un dato positivo di supporto, non ha raggiunto opinioni unanimi in merito alla possibilità per il socio recedente di revocare la propria dichiarazione.
Parte della dottrina, valorizzando la simmetria con lo *ius poenitendi* riconosciuto alla società, ha ritenuto che analoga possibilità debba essere riconosciuta al socio recedente il quale, sino a quando non sia stata iniziata la concreta liquidazione della sua partecipazione oppure non siano scaduti i termini per la medesima, dovrebbe vedersi riconosciuta la possibilità di togliere efficacia alla propria dichiarazione di *exit*.
Altra parte della dottrina, seguita sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, nega tale possibilità una volta che la dichiarazione di recesso sia divenuta conoscibile per la società posto che la prima integra un atto unilaterale recettizio e, come tale, non può essere più revocato quando abbia radicato nel destinatario un legittimo affidamento sulla propria portata effettuale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

soggetto dalla cui volontà dipende, come meglio sarà chiarito in seguito, il concreto radicarsi della procedura sottesa all'esercizio del diritto di exit.

Tale prerogativa si connota come una "agevolazione" per i soci di maggioranza, i quali possono, onde preservare il valore sotteso all'esercizio in comune di un'attività imprenditoriale, porre nel nulla gli effetti di una dichiarazione di recesso valida ed efficace.

Sono costoro a dover valutare, effettuata un'analisi dei costi e dei benefici, se convenga continuare l'attività di impresa, evitando il nocumento patrimoniale connesso alla liquidazione della partecipazione del socio recedente, oppure se, mettendo in liquidazione la società, sia più opportuno cessare l'attività di impresa liquidando, a questo punto, tutti i soci e non solo più il recedente.

Il Legislatore nulla ha detto in merito al termine entro cui la società possa esercitare siffatta opzione.

Tale silenzio ha alimentato, in dottrina, varie costruzioni interpretative.

Parte della medesima opina nel senso che siffatta scelta possa essere effettuata in ogni momento purché non sia, in concreto, iniziata la liquidazione della quota.

Altra parte della stessa, invece, ritiene che ciò sarebbe possibile solo fino alla scadenza del termine, pari a 180 gg, per liquidare i soci receduti.

1.3 La revocazione della delibera che ha legittimante il recesso

L'ente associativo, di fronte al rischio di sciogliersi, può decidere paralizzare gli effetti della dichiarazione di recesso ripristinando, attraverso la revoca della decisione che ha dato scaturigine al recesso, lo status quo ante.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.4 Lo scioglimento della società

La società, inoltre, può decidere, a fronte della ricezione della dichiarazione di recesso posta in essere da un socio, di sciogliersi anticipatamente quando:

- ritenga strategica la decisione assunta;
- la stessa sia ritenuta fondamentale per la prosecuzione della vita associativa;
- non ci siano le condizioni per effettuare, ai sensi dell'art. 2473 c.c., il rimborso al recedente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La liquidazione della quota del socio receduto: modalità operative

2.1 Disciplina precedente alla riforma

Sotto l'egida di tale formante legislativo erano stabiliti, onde preservare al massimo grado l'integrità del capitale sociale, criteri di liquidazione penalizzanti per il socio receduto posto che la valutazione della partecipazione, ai fini del rimborso, era riferita alle risultanze dell'ultimo bilancio approvato.

Da ciò discendeva che, nella quasi totalità dei casi, il valore di liquidazione non corrispondesse al valore effettivo della partecipazione del scio receduto.

2.2 Il credito che sorge in seguito all'esercizio del diritto di recesso è di valuta, esigibile e di facile e pronta liquidazione

La riforma del 2003 ha profondamente innovato il quadro normativo di riferimento ancorando la valutazione della quota da rimborsare al socio recedente al suo "valore di mercato" da stabilire alla luce delle risultanze del patrimonio netto e delle prospettive reddituali della società per come risultanti dall'applicazione delle più moderne tecniche aziendalistiche di computo.

Il credito che il socio matura, quindi, in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso ha natura pecuniaria ed integra per la società un debito di valuta.

Esso si presenta come un credito esigibile e di facile e pronta liquidazione.

Per tale ragione detto credito sarà idoneo a produrre interessi di diritto sin dal momento in cui sorgerà senza bisogno della procedura di messa in mora della società.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.3 L'acquisto della partecipazione del socio recedente da parte degli altri soci

Il procedimento di liquidazione in commento, il quale deve essere completato inderogabilmente entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso alla società, "può[3]" avvenire, ai sensi dell'art. 2473, comma 4° c.c., anche mediante acquisto da parte degli altri soci.

La formulazione della norma ha condotto parte della dottrina a ritenere che, tutte le volte in cui anche uno solo dei soci non intenda acquistare quanto di sua spettanza, sia necessario procedere con le modalità di liquidazione alternative fissate dal Legislatore.

L'opinione preferibile, però, è nel senso che l'autonomia privata possa incidere al riguardo mediante apposita modulazione dello statuto.

Per il caso in cui lo statuto nulla dica in merito pare preferibile ritenere che, in conformità alla ratio sottesa alla procedura di liquidazione, l'acquisto possa avvenire anche in deroga al principio di stretta proporzionalità finanche qualificando come "terzo" l'unico socio intenzionato ad acquistare l'intera quota del socio receduto, la quale, dunque, sarà a lui assegnata prima di attivare le modalità di rimborso alternative

2.4 Il criterio proporzionale

La lettera della legge aiuta, in questo caso, a determinare il criterio giusta, il quale i soci possano provvedere a rilevare la partecipazione del socio receduto.

Ai medesimi, infatti, compete acquistare la medesima solo in proporzione alle partecipazioni di cui sono titolari in ossequio al principio di parità di trattamento che domina trasversalmente il diritto societario.

[3] La formulazione legislativa porta la dottrina a dubitare, con riferimento a tale fase della procedura di liquidazione, della necessità, al contrario di quanto accade nei modelli azionari, di rispettare inderogabilmente i passaggi della procedura liquidatoria individuati dal Legislatore.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.5 L'individuazione da parte dei soci di un soggetto che acquisti la partecipazione sociale del socio recedente

Sullo stesso piano ed in alternativa all'acquisto da parte dei soci si pone la possibilità per questi ultimi di individuare di un terzo a cui offrire la quota del socio recedente[4].

In tal modo la norma assomma finalità composite che addizionano scopi propri delle clausole di gradimento e delle clausole di prelazione.

Il mancato gradimento da parte di anche uno solo dei soci, atteggiandosi come un diritto di veto, impedisce, salvo opzione statutaria difforme, l'acquisto da parte del terzo.

Da ultimo occorre osservare che la posizione del socio potrebbe essere in concreto frustrata da tale scelta dei soci in quanto le aspettative liquidatorie del medesimo potrebbero non avere riscontro se il terzo individuato dai soci risultasse insolvente.

[4] La raccolta dei consensi non deve ricalcare, di necessità, le formalità assembleari.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La liquidazione della quota del socio receduto: modalità operative in difetto di acquisto della quota

3.1 Il rimborso effettuato mediante riserve disponibili

Nel caso in cui il rimborso non sia eseguito mediante cessione di quota agli altri soci o ad un terzo da loro individuato il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili»

La lettera della norma deve essere interpretata, ad opinione della migliore dottrina, nel senso che allo scopo siano utilizzabili tutte le risorse patrimoniali disponibili e non solo le riserve che abbiano tale connotazione.

Occorre notare che, da un lato, non è possibile (a differenza che nella s.p.a.) l'acquisto della quota da parte della società, stante il divieto ex art. 2474 c.c. e, dall'altro lato, il capitale sociale resta invariato. Pertanto, l'utilizzazione delle riserve disponibili ai fini del rimborso comporta l'accrescimento della quota del recedente agli altri soci, senza necessità di un atto di cessione, in proporzione delle rispettive partecipazioni.

La dottrina non ha assunto posizioni univoche con riferimento alla necessità, nel caso in esame, di espletare le formalità pubblicitarie di cui all'art. 2470 c.c. atteso che parte di essa ne sottolinea l'opportunità, mentre altra parte, verificata l'inesistenza di un fenomeno strettamente traslativo, nega che ciò sia necessario;

3.2 Il rimborso effettuato mediante la riduzione del capitale sociale e l'applicazione dell'art. 2482 c.c.

In mancanza di riserve disponibili "il rimborso è effettuato corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482".

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sotto l'aspetto procedimentale l'organo amministrativo dovrà convocare tempestivamente l'assemblea dei soci (non sembra, seguendo l'insegnamento della dottrina migliore, una competenza delegabile all'organo amministrativo o suscettibile di espletamento extra-assembleare) onde decidere al riguardo e sarà concesso ai creditori uno spatium deliberandi, di 90 giorni, per opporsi a tale decisione.

Tale potere di opposizione del ceto creditorio si giustifica sol che si ponga mente al fatto che il "drenaggio" di risorse patrimoniali dalla società, che consegue all'espletamento della procedura di liquidazione della partecipazione del socio receduto, potrebbe volgere a nocumento del suo interesse alterando le garanzie patrimoniali sulle quali i suoi componenti fecero affidamento nell'interagire con la società.

Ove tale opposizione venga accolta la società andrà in scioglimento.

3.3 La messa in liquidazione della società

Qualora, poi, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio deceduto, in alcuno dei modi sopra descritti, la società viene posta in liquidazione.

Il tenore letterale della norma in commento sembra evocare, a differenza di quanto accade nel modello s.p.a., un ordine gerarchico tra la riduzione del capitale sociale e lo scioglimento anticipato della società.

Tali strumenti, infatti, non paiono avvinti da un nesso di alternatività, ma di subordinazione.

L'interpretazione maggioritaria in dottrina, però, estende le considerazioni svolte con riferimento la modello s.p.a. al tipo s.r.l., valutando i due strumenti vicendevolmente e reciprocamente sostituibili.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

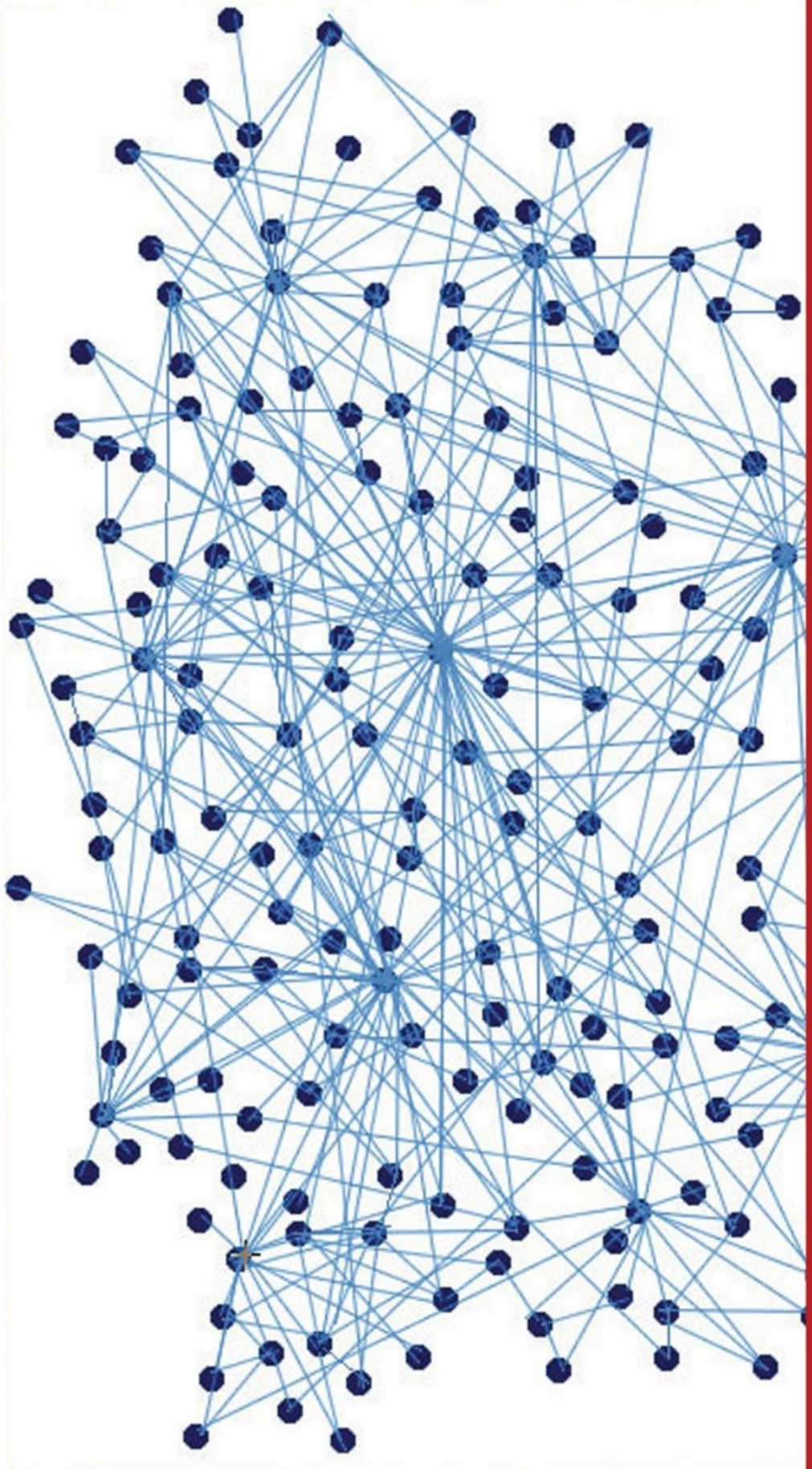
- G. M. Presti – M. Rescigno "Corso di diritto commerciale", Zanichelli, Bologna, 2015, Volume II, pagg. 232-234.
- O. Cagnasso "La società a responsabilità limitata" in "Trattato di Diritto Commerciale", diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2007, Volume V, pagg. 155-165.
- G. Buffone "Commento sub art. 2473 c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 394-406.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. S.R.L.: L'ESCLUSIONE DEL SOCIO 3

1.1 LA RATIO DELLA DISCIPLINA RIFORMATA 3
1.2 I PRESUPPOSTI DELL'ESCLUSIONE 4
1.3 SINGOLE IPOTESI DI ESCLUSIONE 5

2. L'ESCLUSIONE DEL SOCIO: IL PROCEDIMENTO 6

2.1 LA COMPETENZA A DELIBERARE L'ESCLUSIONE 6
2.2 LA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE DI ESCLUSIONE 6
2.3 LA CONOSCIBILITÀ DELLA DELIBERATA ESCLUSIONE DEL SOCIO 7

3. LA TUTELA DEL SOCIO ESCLUSO E LA LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA 8

3.1 LA CONTESTAZIONE DELLA LEGITTIMITÀ DELL'ESCLUSIONE DA PARTE DEL SOCIO ESCLUSO 8
3.2 LA LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 8
3.3 IL PROBLEMA DELLA DEROGABILITÀ DEI CRITERI LEGALI 9

BIBLIOGRAFIA 10

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. S.r.l.: l'esclusione del socio

1.1 La ratio della disciplina riformata

L'art. 2473 bis c.c., ponendosi accanto all'ipotesi di esclusione legale prevista dall'art. 2466 c.c. per il c.d. socio moroso, disciplina l'esclusione convenzionale del socio.

Il tema è stato oggetto, in esito alla riforma delle società di capitali datata 2003, di profonde revisioni che possono essere ben comprese sol che si mettano in relazione i due sistemi normativi.

A tal fine sembra opportuno rilevare che:

- prima della riforma: si ritenevano illegittime le clausole di esclusione nelle società di capitali in quanto si cercavano di circoscrivere le ipotesi di riduzione del capitale sociale ai soli casi contemplati dalla legge;
- dopo la riforma: l'avversione del Legislatore per l'esclusione dei soci è venuta meno per le s.r.l., preso atto del carattere personalistico trasversalmente assunto da tale modello.

L'istituto dell'esclusione del socio, tipico delle società di persone, è stato, infatti, esteso anche alla s.r.l., in considerazione di una più marcata caratterizzazione personalistica della stessa.

L'elasticità del tipo sociale in esame e l'ampia autonomia concessa ai privati in materia legittimano la previsione scolpita nell'art. 2473 bis c.c. a norma del quale «L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio».

Per questa via, dunque, il Legislatore della riforma ha dischiuso le porte ad una "fantasia statutaria" in materia che non aveva precedenti nel sistema positivo e che non si presta, oggi, a specifiche limitazioni.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.2 I presupposti dell'esclusione

Il quadro normativo di riferimento, nella sua versione novellata, consente, in materia, di raggiungere le conclusioni che seguono:

- l'esclusione (salva l'ipotesi prevista all'art. 2466 c.c.) non è prevista dalla legge, ma è subordinata ad una previsione statutaria;
- si è passati, con la legge di riforma, da un sistema "chiuso" di esclusione, ove la medesima era relegata alle sole ipotesi di morosità del socio, ad un sistema "aperto" nel quale le ipotesi convenzionali di esclusione possono, sulla scorta delle esigenze manifestate dai soci nella modulazione dello statuto, atteggiarsi in vario modo ed assumere forme differenziate;
- l'atto costitutivo non può limitarsi a prevedere la generica possibilità di escludere il socio per giusta causa, dovendo, al contrario, indicare specifiche ipotesi di esclusione sorrette dalla medesima;
- tali specifiche declinazioni dell'autonomia privata incontrano, inoltre, un "limite interno" al loro operare ossia quello di dover essere, di necessità, confortate da una "giusta causa".

Sui tratti fisionomici e sulla portata di quest'ultima la dottrina non risulta omogeneamente orientata.

Al riguardo occorre osservare quanto segue:

- parte di essa (preferibile), valorizzando la capacità previsionale dei soci, ritiene che "giusta causa" sia quella che i soci hanno statuito, in omaggio ad un criterio soggettivistico e discrezionale, che fosse. Da ciò discende che una fattispecie che venga qualificata come giusta causa di esclusione in una società potrebbe essere del tutto irrilevante in un'altra[1];

[1] A titolo esemplificativo il sopraggiunto limite di età potrà integrare un'ipotesi di esclusione in una società dove è importante l'apporto lavorativo del socio ed essere, invece, del tutto irrilevante quando il conferimento ha un carattere meramente finanziario.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- altra parte di essa, invece, mossa dall'esigenza di garantire sicurezza e tenuta al sistema, opina nel senso della necessaria sussistenza, in ossequio ad un criterio interpretativo marcatamente oggettivo, di un dato obiettivo che risulti, in concreto, idoneo ad alterare gli obiettivi perseguiti dai soci per il tramite della struttura associativa.

1.3 Singole ipotesi di esclusione

Al riguardo sembra necessario distinguere l'ipotesi normativa di esclusione da quelle eventualmente coniate per il tramite dello statuto.

In merito alla prima, a norma dell'art. 2466 c.c. nel caso in cui il socio sia moroso, siano mancate offerte da parte dei soci con riferimento alla sua partecipazione e l'incanto sia andato deserto, l'organo amministrativo dovrà procedere all'esclusione del socio. Dal momento della sua comunicazione a quest'ultimo essa diverrà efficace. Il socio potrà fare opposizione adducendo alternativamente o cumulativamente il difetto di comunicazione delle diffide ad adempiere e/o il rispetto dell'impegno assunto. L'esclusione del socio non comporta, inoltre, l'impossibilità per chi ne sia destinatario di impugnare le delibere.

In merito, invece, alla seconda ipotesi non può che prospettarsi, atteso quanto sopra esplicitato con riferimento alla portata dell'autonomia privata in materia, una esemplificazione delle possibili declinazioni della volontà dei soci.

A titolo esemplificativo, dunque, sarà possibile prevedere l'esclusione del socio che:

- subisca condanne penali di una certa gravità;
- fallisca;
- sia dichiarato interdetto o inabilitato;
- avendo promesso l'esecuzione di un'opera e/o di un servizio non sia più in grado di adempierle;
- abbia conferito in godimento un bene poi perito.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. L'esclusione del socio: il procedimento

2.1 La competenza a deliberare l'esclusione

L'esegesi della norma in esame non aiuta a dissolvere un forte dubbio che si è palesato in dottrina ossia quello afferente alla competenza a decidere l'esclusione del socio in assenza di una precisa indicazione statutaria sul punto.

Uno sguardo d'insieme sul sistema societario italiano consente di verificare che:

- nelle società di persone tale competenza è rimessa dei soci i quali deliberano per teste (art. 2287 c.c.);
- nelle società cooperative la competenza è rimessa agli amministratori (art. 2533 c.c.).

Le opinioni che si contendono il campo, in materia di s.r.l., invece, sono, in assenza di supporti positivi, quelle che seguono:

- parte della dottrina, ritenendo che tale operazione altro non sia che una declinazione del potere gestorio, è propensa ad ascrive la competenza in esame all'organo amministrativo;
- altra parte della dottrina, maggioritaria e preferibile, invece, valorizzando la portata decisionale dell'operazione, propende per assegnare tale competenza ai soci, i quali potranno provvedervi ai sensi degli artt. 2479 e 2479 bis c.c.

Resta, tuttavia, fermo il principio per cui, in assenza di supporti positivi, l'autonomia privata non è in grado di predisporre una clausola di esclusione nella quale la decisione spetti all'autorità giudiziaria posto che, salvo i casi previsti dalla legge, non pare che a quest'ultima possa competere un potere così penetrante nei riguardi della compagine sociale.

2.2 La motivazione della decisione di esclusione

Il dato positivo, benché fornisca indicazioni circa i requisiti che debbono supportare l'esclusione, nulla precisa in ordine alle regole da seguire, in concreto, per addivenirvi.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'opinione corrente in dottrina affida il compito suppletivo all'autonomia privata.

Quest'ultima, si osserva, dovrà esplicarsi in modo da fornire all'escluso le garanzie tipiche dei modelli societari che conoscono tale istituto.

In particolare, assume rilevanza l'obbligo di motivazione della decisione di esclusione atteso che dal corretto espletamento di tale onere discende la possibilità per il socio escluso di valutare l'opportunità di procedere all'impugnativa del provvedimento teso ad estrometterlo dalla compagine sociale.

2.3 La conoscibilità della deliberata esclusione del socio

Le tutela di cui è destinatario il socio escluso nei riguardi di coloro che ne hanno determinato l'esclusione passa, inoltre, per il corretto espletamento dell'onere di comunicazione al medesimo del provvedimento di esclusione allo scopo di consentite allo stesso di prendere atto del suo contenuto e parametrare, di conseguenza, la propria strategia difensiva.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La tutela del socio escluso e la liquidazione della quota

3.1 La contestazione della legittimità dell'esclusione da parte del socio escluso

L'esclusione del socio può prestarsi ad abusi e rappresentare uno strumento di prevaricazione delle maggioranze sulle minoranze societarie.

Gli strumenti di tutela di cui l'escluso dispone si differenziano a seconda che l'esclusione abbia operato automaticamente oppure sia scaturita da una decisione dell'organo competente ad assumerla.

Nel primo caso l'escluso potrà stimolare, mediante l'esperimento di un'azione di accertamento negativo, la verifica dell'insussistenza dei presupposti per l'operare dell'esclusione.

Nella seconda ipotesi, invece, troveranno applicazione le comuni regole poste dall'ordinamento societario, all'art. 2479 ter c.c., per impugnare le decisioni dei soci, non essendo, a tal fine, necessario che la facoltà di impugnativa sia contemplata, per le finalità in esame, nello statuto.

3.2 La liquidazione della partecipazione

L'art. 2473 bis c.c. dispone, in materia, che «si applicano le disposizioni del precedente articolo».

Al pari di quanto accade in tema di recesso:

- la quota deve essere rimborsata entro 180 giorni dall'esclusione;
- il rimborso avviene in base al "valore di mercato" alla data in cui si è verificata l'esclusione;
- il rimborso può avvenire anche mediante acquisto dagli altri soci o da un terzo concordemente individuato dai soci.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

A differenza, invece, di quanto previsto per il recesso è «esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale».

Da ciò, tuttavia, discende un dubbio in merito all'ipotesi in cui la società non disponga di risorse patrimoniali utili allo scopo liquidativo.

La dottrina oscilla tra quanti ritengono che, ove non sia possibile il rimborso della quota con le modalità previste dalla legge, si passi direttamente allo scioglimento della società e quanti, invece, individuano nella carenza di risorse utili a tal fine un limite negativo alla procedura di esclusione, la quale, dunque, in tale caso, non sarà percorribile.

3.3 Il problema della derogabilità dei criteri legali

La dottrina e la giurisprudenza non concordano sulla derogabilità dei criteri di determinazione del valore della quota, mentre non si dubita della inderogabilità del congegno liquidatorio atteso che esso risponde ad esigenze extra sociali.

La dottrina è, in parte, propensa a ritenere modellabile tale aspetto posto che la logica che presiede al procedimento di esclusione è speculare a quella sottesa alla procedura di recesso e, quindi, l'escluso potrebbe essere da sanzionare e non da tutelare.

La giurisprudenza di merito, invece, in ossequio al principio di parità di trattamento, esclude la legittimità di una clausola che imponga un valore di liquidazione "di libro" con l'esclusione dal riparto delle plusvalenze acquisite dalla società nel corso della sua vita.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

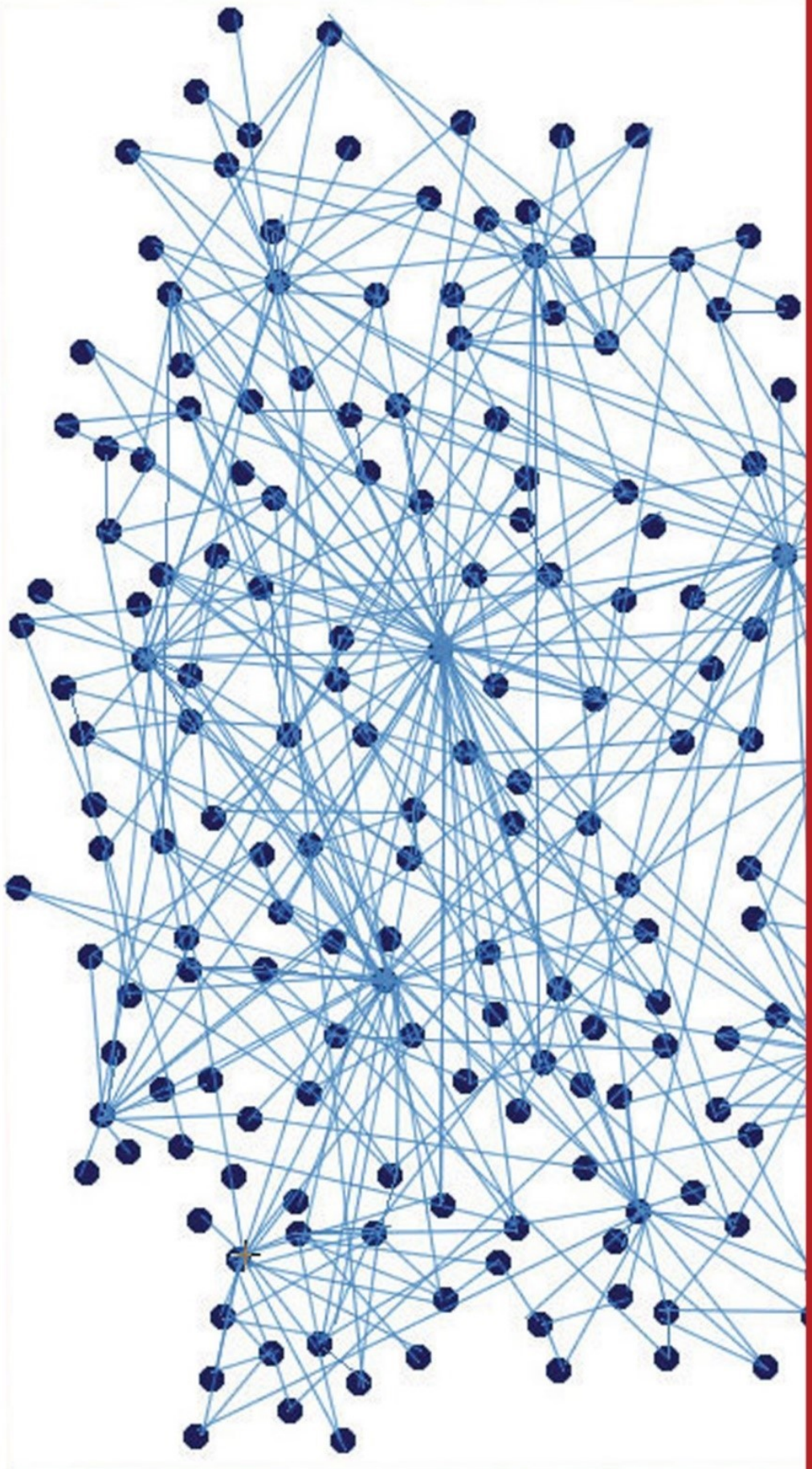
- G. M. Presti – M. Rescigno "Corso di diritto commerciale", Zanichelli, Bologna, 2015, Volume II, pag. 235.
- O. Cagnasso "La società a responsabilità limitata" in "Trattato di Diritto Commerciale", diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2007, Volume V, pagg. 170-173.
- G. Buffone "Commento sub artt. 2471- 2472 c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 409-413.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LE DECISIONI DEI SOCI. IL SISTEMA E LE MODALITÀ DI AMMINISTRAZIONE NELLA S.R.L. 3

1.1 LE COMPETENZE DEI SOCI 3
1.2 LE MODALITÀ DI ASSUNZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI 4
1.3 LE DECISIONI ASSEMBLEARI 5
1.4 CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'INVALIDITÀ DELLE DECISIONI DEI SOCI 5
1.5 LE DIVERSE IPOTESI DI INVALIDITÀ 6
1.6 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 7
1.7 NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI 8
1.8 IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITÀ: L'AMMINISTRAZIONE DISGIUNTIVA E CONGIUNTIVA 10

2. LA RAPPRESENTANZA ED IL CONFLITTO DI INTERESSI 12

2.1 NOZIONE DI RAPPRESENTANZA 12
2.2 LIMITAZIONI AL POTERE DI RAPPRESENTANZA 12
2.3 L'ART. 2475 TER, COMMA 1°, C.C. 13
2.4 L'ART. 2475 TER, COMMA 2°, C.C. 14
2.5 IL COORDINAMENTO TRA L'ART. 2475 BIS C.C. E L'ART. 2475 TER C.C. 16

3. PROFILI DI RESPONSABILITÀ DI AMMINISTRATORI E SOCI; CENNI AL SISTEMA DI CONTROLLO 17

3.1 I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ 17
3.2 ÀMBITO E DISCIPLINA DEI DIRITTI DI CONTROLLO: L'ART. 2476, COMMA 2°, C.C. 18
3.3 SIGNIFICATO E ÀMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ART. 2476, 7° COMMA, C.C. 18
3.4 OBBLIGATORIETÀ DEL SINDACO 19
3.5 IL REVISORE 20
3.6 COMPITI DEL SINDACO 21

BIBLIOGRAFIA 22

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Le decisioni dei soci. Il sistema e le modalità di amministrazione nella s.r.l.

1.1 Le competenze dei soci

L'art. 2479, comma 1°, c.c. statuisce che «i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione».

L'autonomia statutaria può, quindi, variamente ripartite tra i soci e gli amministratori le competenze gestorie, con ciò confermando, in ossequio ai principi dettati dalla legge delega, la centralità del socio nel modello in questione.

Sebbene l'atto costitutivo possa suddividere, con la massima libertà, le competenze tra soci ed amministratori esso dovrà, necessariamente, riservare a questi ultimi la redazione del progetto di bilancio, di progetti di fusione e di scissione, ai sensi dell'art. 24754 c.c.

L'art. 2479, comma 2°, c.c. statuisce, inoltre, che «in ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
2. la nomina, se prevista nell'atto costitutivo (l'atto costitutivo può, infatti, attribuire ai singoli soci il potere di nomina degli amministratori o il potere di amministrazione ex artt. 24751 e 24683 c.c.), degli amministratori;
3. la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
4. le modificazioni dell'atto costitutivo (a differenza che nella s.p.a. - art. 2365 c.c. - nella s.r.l. non è possibile la delega agli amministratori per la modifica dell'atto costitutivo, salvo le ipotesi eccezionali contemplate dalla legge);

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci».

1.2 Le modalità di assunzione delle decisioni dei soci

L'art. 2479, comma 5° c.c. prevede che «ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale (inderogabilmente) in misura proporzionale alla sua partecipazione»

La riforma del 2003 ha notevolmente inciso sulla disciplina delle decisioni dei soci.

Al fine di riconoscere rilevanza centrale alla persona del socio, lo statuto può prevedere che le decisioni dei soci siano prese, ai sensi dell'art. 2479, comma 3°, c.c., con il metodo non collegiale, al pari di quanto accade nelle società di persone.

A differenza di quanto può avvenire nelle società a vocazione personalistica:

- secondo una tesi, nelle s.r.l., qualunque sia il metodo adottato, non si può procedere senza informare o consultare ogni socio. Sarebbe dunque viziata, in quanto adottata in assenza totale di informazione, una decisione assunta senza il coinvolgimento anche di un solo socio;
- secondo un'altra tesi, in caso di consenso espresso per iscritto non è necessaria la informazione di tutti i soci.

Nella s.r.l. si distinguono, in definitiva, decisioni non collegiali (o extra-assembleari) e decisioni collegiali (o assembleari).

Il metodo legale è, tendenzialmente, ancòra quello as¬sembleare, che garantisce la ponderazione delle decisioni attraverso il confronto e lo scambio di informazione tra i soci, e ciò per tre ordini di ragioni:

- per utilizzare il metodo non collegiale è necessario che vi sia un'espressa previsione dell'atto costitutivo;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- si deve rispettare la riserva del metodo assembleare per le decisioni previste dai n. 4 e 5 dell'art. 24792 c.c.;
- la decisione collegiale può essere sempre sollecitata da ciascun amministratore e dai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

1.3 Le decisioni assembleari

Nel silenzio dell'atto costitutivo le decisioni sociali devono essere assunte in ossequio al metodo assembleare.

Tale modalità di assunzione, inoltre, è sottratta alla contraria scelta autonomistica dei soci nei casi indicati dall'art. 2479 comma 4°, c.c.

L'assemblea dei soci, nel caso in esame, si svolgerà nei tempi e con i modi fissati dall'art. 2479 bis c.c. per come interpolato dall'autonomia privata che, sul punto, si vede riconosciuto ampio margine di manovra

1.4 Considerazioni generali sull'invalidità delle decisioni dei soci

L'ordinamento reagisce alla patologia delle deliberazioni assembleari con un complesso organico di norme che derogano, in diversi punti, alle ordinarie regole di diritto comune sull'invalidità negoziale.

La legge delega prevedeva, al riguardo, che in materia dovessero essere contemperata l'esigenza di tutela dei soci e con quella alla funzionalità e alla certezza dell'attività sociale.

Il Legislatore, dunque, innovando rispetto al passato, ha prediletto le esigenze di speditezza e stabilità delle decisioni sociali, limitando la tutela reale (rimozione degli effetti prodotti) e spostando il baricentro degli strumenti di reazione sul piano obbligatorio (risarcimento del danno).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il sistema è stato criticato da gran parte della dottrina posto che la propensione, sopra ricordata, verso la tutela della stabilità delle decisioni sociali non è parsa proporzionata rispetto alle istanze di protezione rinvenienti dalla compagine sociale

1.5 Le diverse ipotesi di invalidità

L'art. 2479 ter c.c. disciplina **l'invalidità** delle decisioni dei soci.

La dottrina, benché il dato letterale non evochi espressamente tale riparto, ritiene che, in analogia a quanto accade per i modelli azionari, possano, al riguardo, distinguersi:

- **annullabilità delle decisioni** → è disciplinata dai commi 1° e 2° dell'art. 2479 ter c.c., per i quali «le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci...» e «qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società»;
- **nullità delle decisioni** → è disciplinata dal 3° comma, primo periodo, dell'art. 2479 ter c.c., per il quale «le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del 1° comma»;
- **nullità imprescrittibile delle decisioni** → è disciplinata dal 3° comma, secondo periodo, dell'art. 2479 ter c.c., per il quale «possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite».

Stabilisce infine l'art. 2479 ter, ult. comma, c.c. che «si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377, 1°, 5°, 7°, 8° e 9° comma, 2378, 2379 bis, 2379 ter e 2434 bis».

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.6 Il consiglio di amministrazione

L'art. 24753 c.c. statuisce che «quando l'amministrazione è affidata a più persone (anche solo due), queste costituiscono il consiglio di amministrazione».

L'art. 24754 c.c. disciplina, poi, il metodo referendario stabilendo che «qualora sia costituito un consiglio di amministrazione, l'atto costitutivo può prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso della stessa».

Quello in esame è il sistema di base dell'amministrazione pluripersonale, nel senso che, se nell'atto costitutivo l'amministrazione è affidata a più persone, queste compongono tale Consiglio.

In altri termini, dunque, in mancanza di una formale previsione dell'organo amministrativo contenuta nell'atto costitutivo tutti i soci devono essere considerati amministratori e dovrà ritenersi automaticamente costituito un consiglio di amministrazione: le ipotesi di amministrazione (pluripersonale) congiuntiva o disgiuntiva devono, quindi, essere frutto di una scelta specifica.

I dati positivi riportati sono i soli a disciplinare, a differenza di quanto accade per i modelli azionari, il fenomeno in commento.

Si propone, pertanto, il problema di comprendere il significato del mancato rinvio alla disciplina della s.p.a.

Le soluzioni, astrattamente ipotizzabili, per tale problema potrebbero essere:

- è applicabile, in via analogica, la disciplina delle s.p.a.;
- non è applicabile, in via analogica, la disciplina delle s.p.a., ma è consentito all'autonomia privata di introdurre, nell'atto costitutivo, tali regole;
- è vietato all'autonomia privata di introdurre, nell'atto costitutivo, la disciplina delle s.p.a.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le materie non disciplinate in sede di s.r.l. riguardano:

- la figura del Presidente del C.d.A.: si ritiene possibile che lo statuto utilizzi la disciplina della s.p.a. per modellare i poteri del Presidente del C.d.A. nella s.r.l.;
- le formalità di convocazione del C.d.A.: si ritiene possibile che lo statuto utilizzi la disciplina della s.p.a. per modellare le formalità della sua convocazione: anche in assenza di un espresso rinvio normativo, al C.d.A. della s.r.l. si ritiene applicabile, per analogia, l'art. 23881-2-3 c.c., rispettivamente, in ordine a:

✓ possibilità che lo statuto preveda la partecipazione con mezzi di telecomunicazione;

✓ quorum costitutivi e deliberativi della riunione del consiglio;

✓ impossibilità di partecipare per corrispondenza.

- la delega ad amministratori delegati o al comitato esecutivo: anche in assenza di un espresso rinvio normativo, al C.d.A. della s.r.l. si ritiene applicabile, per analogia, l'art. 23812 c.c. in ordine alla possibilità di delegare le funzioni ad amministratori delegati o ad un comitato esecutivo. La previsione di amministratori delegati e del comitato esecutivo nel solo modello della s.p.a. si spiega con le diverse dimensioni che normalmente queste hanno rispetto alle s.r.l., ma è lecito prevedere anche nello statuto della S.r.l. la possibilità di ricorrere all'amministratore delegato o al comitato esecutivo;
- l'impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione: anche in assenza di un espresso rinvio normativo, al C.d.A. della s.r.l. si ritiene applicabile, per analogia, l'art. 23884 c.c., sull'impugnazione delle delibere del consiglio di amministrazione.

1.7 Nomina e revoca degli amministratori

Se l'atto costitutivo non dispone diversamente la s.r.l. è amministrata da uno o più soci[1] nominati con decisioni degli stessi.

[1] Secondo l'opinione dottrinale più accreditata anche **persone giuridiche**.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La «diversa disposizione dell'atto costitutivo» ex art. 24751 c.c. può consistere:

- nella possibilità di attribuire all'amministrazione anche a terzi estranei;
- nell'attribuzione a singoli soci di un particolare diritto di amministrazione ex art. 24683 c.c.

Non sembra possibile, invece, affidare ad un terzo estraneo la nomina degli amministratori, in quanto l'art. 24792 n. 3 c.c. stabilisce che la loro nomina, se prevista dall'atto costitutivo, è in ogni caso riservata alla competenza dei soci.

Ai sensi dell'art. 24752 c.c. «all'atto di nomina degli amministratori si applicano il quarto e quinto comma dell'articolo 2383»

Poiché non è previsto un limite di durata alla carica (a differenza che nella s.p.a.: art. 23832 c.c.), gli amministratori di S.r.l. possono essere nominati anche a tempo indeterminato.

È, poi, discusso in dottrina se sia applicabile, per analogia, l'art. 2382 c.c. sulle cause di ineleggibilità e decadenza previste nella s.p.a.

Parte di essa ritiene che alla s.r.l. non si applichi l'art. 2382 c.c. e, pertanto, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o il condannato ad una pena con interdizione dai pubblici uffici possono essere nominati amministratori.

Altra parte della medesima ritiene, invece, che alla s.r.l. si applichi l'art. 2382 c.c., in quanto:

- l'inapplicabilità delle cause di ineleggibilità e decadenza alla s.r.l., a livello sistematico, non è conforme all'ordinamento, in quanto tali cause sono previste anche negli altri tipi di società:

✓ nella s.a.p.a., per il fatto che l'art. 2454 c.c. che rinvia alle norme della s.p.a.;

✓ nelle società di persone agli artt. 2286 e 2288 c.c.

- l'amministrazione non potrebbe essere esercitata direttamente dall'interdetto o dal fallito o dal condannato, ma eventualmente da un rappresentante.

In ogni caso è opportuno colmare la lacuna a livello di statuto riproducendo i divieti previsti dall'art. 2382 c.c.

All'atto costitutivo è demandata, inoltre, la disciplina dei compensi spettanti agli amministratori: il rapporto di amministrazione si presume oneroso.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

All'atto costitutivo, infine, è demandata l'introduzione di eventuali divieti per gli amministratori: nel silenzio dell'atto costitutivo, è controverso se sia applicabile l'art. 2390 c.c. o l'art. 2301 c.c. in ordine al divieto di concorrenza.

La cessazione dell'incarico è connessa alla morte o alla rinunzia dell'incaricato oppure alla sua revoca da parte dei soggetti che lo abbiano nominato.

Modi e termini della revoca dipendono dalla fonte della nomina.

1.8 Il superamento del principio di collegialità: l'amministrazione disgiuntiva e congiuntiva

Nella s.r.l. il Legislatore ha concesso all'autonomia privata di superare il limite della collegialità in àmbito gestorio dando la possibilità ai soci di prevedere modelli di amministrazione:

- congiuntiva → l'art. 24753, seconda parte, c.c. rinvia all'art. 2258 c.c., che, in materia di società di persone, stabilisce che:

✓ se l'amministrazione è congiuntiva, è necessaria l'unanimità dei soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali (comma 1);

✓ se l'amministrazione è congiuntiva a maggioranza (per l'amministrazione in genere o per determinati atti), questa si determina a norma dell'art. 22573 c.c. ossia «secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili» (comma 2);

✓ nei casi previsti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società (comma 3).

Il problema del rinvio attuato dall'art. 24753, seconda parte, c.c. all'art. 2258 c.c. consiste nel fatto che si richiama una norma che funziona perfettamente in sede propria, ma crea degli inconvenienti nel modello s.r.l. a causa del riferimento al calcolo della maggioranza secondo il criterio della partecipazione di ciascun socio nella distribuzione degli utili.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- disgiuntiva → l'art. 24753, seconda parte, c.c. rinvia all'art. 2257 c.c., che, in materia di società di persone, stabilisce che:

✓ salvo diversa pattuizione, l'amministrazione è disgiunta (comma 1);

✓ se l'amministrazione è disgiuntiva «ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta» (comma 2);

✓ la maggioranza dei soci (non degli amministratori: potrebbero esserci soci che non sono amministratori) determinata sulla base della partecipazione di ciascuno negli utili, decide sull'opposizione (comma 3).

Il problema del rinvio attuato dell'art. 24753, seconda parte, c.c. all'art. 2257 c.c. consiste nell'adattare tale sistema al modello societario in commento.

Occorre, pertanto, chiedersi se la decisione sull'opposizione preventiva in caso di amministrazione disgiuntiva debba spettare alla maggioranza degli (altri) soci o alla maggioranza degli (altri) amministratori in carica e, di conseguenza, come debba essere calcolata tale maggioranza.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La rappresentanza ed il conflitto di interessi

2.1 Nozione di rappresentanza

Per "rappresentanza" si intende la facoltà concessa ai soci di assumere, verso i terzi, diritti ed obblighi in nome e per conto della società in modo per essa vincolante.

Per il modello s.r.l. vige una disciplina che ricalca quella dettata per la s.p.a. (art. 2384 c.c.).

L'art. 2475 bis c.c. dispone che «gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (l'unico caso in cui la limitazione dei poteri è opponibile al terzo è, quindi, quello in cui si provi che il terzo ha intenzionalmente agito a danno della società, con la c.d. exceptio doli)».

È stato abbandonato, con la legge di riforma del 2003, il riferimento all'oggetto sociale che caratterizzava la disciplina anteriforma, con la conseguenza che il compimento di atti eccedenti l'oggetto sociale è irrilevante rispetto ai terzi, essendo, oggi, la rappresentanza di tipo generale.

2.2 Limitazioni al potere di rappresentanza

Le questioni interpretative di maggior interesse sorte con riferimento a questo tema riguardano:

- La portata delle limitazioni ai poteri degli amministratori.

Ci è chiesti, in latri termini, se esse si riferiscano, come pare letteralmente, al potere di amministrazione o piuttosto alle sole limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 1° della norma in esame.

Questo problema assume rilevanza nel caso in cui ci sia dissociazione tra potere di amministrazione e potere di rappresentanza.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Secondo la tesi preferibile, le limitazioni si riferiscono alle sole limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 1°, in quanto se il terzo dovesse, di volta in volta, verificare il corretto esercizio del potere di amministrazione, la società sarebbe di fatto paralizzata sul mercato e, pertanto, destinata a fallire.

- L'àmbito delle limitazioni legali.

Ci si domanda se l'art. 2475 bis c.c., quando parla delle limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina (le quali, in ultima analisi, derivano dalla volontà dei soci), faccia riferimento solo alle limitazioni pattizie oppure anche a quelle legali (ossia quelle che trovano la propria fonte nella legge).

Le limitazioni legali sono opponibili, ad opinione della dottrina maggioritaria, benché non unanime, al terzo contraente atteso che le stesse non risultano ricomprese nella disciplina della norma.

2.3 L'art. 2475 ter, comma 1°, c.c.

Notevoli differenze rispetto ai modelli azionari sono previste nella disciplina del conflitto di interessi nel tipo sociale s.r.l.

A norma dell'art. 2475 ter, comma 1°, c.c. «I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo».

Tale conflitto di interessi prende il nome di c.d. conflitto di interessi dell'amministratore rappresentante.

Il presupposto operativo dell'ipotesi contemplata al comma 1° della norma in esame è che l'atto sia posto in essere dall'amministratore rappresentante che sia in conflitto di interessi con la società.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'ipotesi in questione si può verificare in caso di:

- amministratore unico;
- Presidente del C.d.A.;
- amministratore congiunto o disgiunto munito di rappresentanza.

In questo caso la disciplina è analoga a quella prevista per il diritto comune dall'art. 1394 c.c.: è richiesto che il conflitto sia conosciuto o riconoscibile dal terzo. Di conseguenza, le ipotesi di conflitto di interessi sono facilmente riconoscibili dal notaio: si pensi al caso in cui il presidente del C.d.A. acquista come legale rappresentante della Alfa s.r.l. un immobile di cui è proprietario come persona fisica.

L'atto concluso dal rappresentante in conflitto di interesse è annullabile.

Il conflitto, tuttavia, può essere rimosso facendo intervenire una volontà che non è viziata:

- in caso di amministratore unico, il conflitto di interessi è rimosso quando la decisione è stata regolarmente assunta dai soci;
- allo stesso modo, in caso di presidente del C.d.A., il conflitto di interessi è rimosso quando la decisione è stata regolarmente assunta dall'intero Consiglio;
- così pure nei casi di amministrazione congiunta o disgiunta, il conflitto di interessi è rimosso quando la decisione è stata regolarmente assunta dagli altri amministratori.

L'importante è che la decisione sia sempre assunta da soggetti altri rispetto al soggetto che porterà tale volontà all'esterno (ovviamente anche l'amministratore rappresentante può votare nell'assunzione della decisione in quanto amministratore, ma se il suo voto è determinante vizia ugualmente la volontà).

2.4 L'art. 2475 ter, comma 2°, c.c.

A norma dell'art. 2475 ter, comma 2°, c.c. «Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti previsti dall'articolo 2477. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione».

Tale conflitto di interessi prende il nome di c.d. conflitto di interessi dell'amministratore non rappresentante.

Il presupposto operativo dell'ipotesi contemplata al comma 2° della norma in esame è che l'atto sia posto in essere dall'amministratore che concorre alla formazione della decisione, ma che non porta all'esterno la volontà della società, perché non è fornito del potere di rappresentanza.

Detto comma si applica non solo in caso di C.d.A., come testualmente previsto, ma in tutti i casi di amministrazione pluripersonale ed il conflitto ivi decritto colpisca colui che si presenti a stipulare dal notaio non come legale rappresentante; si applica il comma 2 persino nel caso in cui il socio, ex art. 24683 c.c., abbia il particolare diritto di decidere una determinata operazione.

Il medesimo, dunque, si occupa dell'ipotesi in cui il conflitto di interessi non colpisce il legale rappresentante, ma colpisce un altro componente del C.d.A., che ha espresso un voto determinante per l'assunzione della decisione.

Perché la decisione sia annullabile ai sensi dell'art. 24752 ter c.c. occorrono 3 condizioni:

- che il voto dell'amministratore sia stato determinante;
- che la delibera cagioni alla società un danno patrimoniale. Occorre che la decisione abbia effettivamente cagionato un danno alla società e non è sufficiente un danno astratto e potenziale: ciò rende molto più difficile la effettiva annullabilità della decisione, anche perché la realizzazione del danno deve avvenire nei 90 giorni;
- che la delibera sia impugnata entro 90 giorni.

In mancanza di questi presupposti la delibera è definitivamente valida ed efficace.

Legittimati all'impugnazione sono gli amministratori (assenti, dissenzienti e anche coloro che hanno votato favorevolmente purché non fossero a conoscenza della situazione di conflitto dell'altro amministratore, non essendoci un obbligo a carico degli amministratori di informare gli

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

altri di un loro conflitto di interessi, a differenza di ciò che è previsto per la s.p.a.) e, ove presente l'organo, di controllo.

2.5 Il coordinamento tra l'art. 2475 bis c.c. e l'art. 2475 ter c.c.

In conclusione, a quanto detto sopra pare possibile osservare che:

- tutte le volte in cui il conflitto colpisca l'amministratore rappresentante (quello che compare davanti al notaio per stipulare l'atto) la fattispecie è regolata nell'art. 24751 ter c.c. e il notaio deve verificare che tale conflitto sia stato superato mediante la manifestazione di volontà di un soggetto diverso da quello che compare in atto;
- tutte le volte in cui, invece, il conflitto colpisca uno degli amministratori che concorre alla decisione (ma che poi non si presenti dal notaio a stipulare l'atto come legale rappresentante della società) la fattispecie è regolata dall'art. 24752 ter c.c. e, tendenzialmente, il problema dell'annullabilità rimane un problema interno. In ogni caso, infatti, l'atto resta valido se il terzo che contrae con la società è in buona fede.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Profili di responsabilità di amministratori e soci; cenni al sistema di controllo

3.1 I presupposti della responsabilità degli amministratori e l'azione di responsabilità

In merito alla responsabilità degli amministratori occorre distinguere tra:

a) **responsabilità verso la società**: essa è disciplinata dall'art. 24761-5 c.c.

E così, tra l'altro, è previsto che «gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società» (comma 1) e che «l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio»; infine «l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società», sia pure con un quorum rafforzato (comma 5).

b) **responsabilità verso singoli soci terzi**: essa è disciplinata dall'art. 24766 c.c., per il quale sussiste «il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori»;

c) **responsabilità verso i creditori sociali**: nella s.r.l., a differenza che nella s.p.a., non è disciplinata la terza azione di responsabilità ossia quella dei creditori sociali.

La dottrina, avallata dalla giurisprudenza di merito ammette, comunque, l'azione di responsabilità dei creditori sociali argomentando, alternativamente, dalla natura surrogatoria dell'azione medesima oppure dalla natura aquiliana della lesione oppure dall'applicabilità dell'art. 2394 c.c. alla s.r.l.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.2 Àmbito e disciplina dei diritti di controllo: l'art. 2476, comma 2°, c.c.

Una prima forma di controllo interno è quella prevista dall'art. 24762 c.c. a norma del quale «i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione».

L'atto costitutivo può, con riferimento a tali diritti, regolare il loro esercizio, allo scopo di bilanciarne la portata con la contrapposta esigenza di speditezza dell'attività sociale, ma non può sopprimerli.

I soci, inoltre, dovranno esercitare i controlli nel rispetto del principio di correttezza e buona fede e senza divulgare a terzi le informazioni ricevute, esponendosi, in caso contrario, a responsabilità.

3.3 Significato e àmbito di applicazione dell'art. 2476, 7° comma, c.c.

Dispone l'art. 2476, comma 7°, c.c. che «sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente (devono essere esclusi i comportamenti colposi o omissivi) deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

L'impiego dell'avverbio intenzionalmente ha scatenato, in dottrina, un dibattito molto acceso e, per certi aspetti, non ancora sopito.

Le opinioni che si fronteggiano sono, in sintesi, quelle:

- che considerano l'utilizzo di tale avverbio pleonastico atteso che nessuna attività autorizzatoria o decisionale potrebbe mai dirsi "non intenzionale";
- che riferiscono la portata dell'avverbio alle conseguenze di tali attività;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- che attribuiscono un valore processuale a tale avverbio idoneo a rovesciare l'onere della prova in merito alla sussistenza dell'elemento psicologico in commento;
- che considerano tale espressione come una declinazione del principio teso ad arginare l'abuso di maggioranza.

3.4 Obbligatorietà del sindaco

È necessario osservare al riguardo che fino all'entrata in vigore della legge di stabilità per l'anno 2012, l'art. 2477 c.c. prevedeva la disciplina del collegio sindacale, in linea non soltanto con la disciplina dei modelli azionari, ma, soprattutto, con la tradizione giuridica del nostro ordinamento che riconosceva nella pluripersonalità e nella collegialità caratteri essenziali dell'organo di controllo delle società di capitali.

Con l'entrata in vigore della Legge n. 183/2011 il collegio sindacale è stato sostituito con il sindaco unico; sebbene la disciplina sia rimasta pressoché immutata (la lettera della norma è la stessa, salvo ad essere state sostituite le parole «collegio sindacale» con la parola «sindaco»), diversi sono i dubbi che ha generato la novella:

- Nomina del sindaco nella s.r.l.:
- Normalmente è facoltativa.

L'art. 24771 c.c. stabilisce, infatti, che «l'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo»;

- In alcuni casi è obbligatoria.
- L'art. 24773-4 c.c. stabilisce, infatti, che «La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435 bis.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati».

Ai sensi dell'art. 24775 c.c., «nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni».

Infine, l'art. 24776 c.c. prevede che «l'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al terzo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato».

- La sorte del collegio ancora in carica: nel silenzio della norma, le soluzioni possono essere le più disparate: si potrebbe ritenere, fatta salva l'ipotesi di dimissioni del collegio, che il collegio sia automaticamente decaduto; che i membri del collegio permangano in carica fino alla prima assemblea di approvazione del bilancio di esercizio, che l'assemblea possa liberamente revocare i sindaci in carica, costituendo il verificarsi delle condizioni di legge una giusta causa; che i membri del collegio rimangano in carica fino alla naturale scadenza del mandato, ecc.

3.5 Il revisore

Le questioni che hanno rivestito maggior interesse in dottrina in merito a siffatta figura sono quelle di seguito compendiate.

Parte della dottrina osserva, al riguardo, che nei casi in cui la nomina dell'organo di controllo non si obbligatoria per legge, l'aver nominato solo il revisore legale dei conti, atteso che la relativa funzione deve reputarsi connaturata, nel modello societario in esame, all'organo di controllo, dovrebbe intendersi come significativa della volontà dei soci di limitare il controllo ai soli profili contabili.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Altra parte, invece, non esclude che anche in questa ipotesi l'autonomia privata non possa modellare le competenze e i poteri del medesimo includendovi la vigilanza sulla gestione.

Altra parte ancora, poi, vede nell'art. 2477, comma1°, c.c. il regime di controllo interno tipico, ma non esclude che l'autonomia privata, nei limiti posti dal sistema, possa delinearne di atipici.

La possibilità di nominare alternativamente l'organo di controllo o il revisore legale dei conti pare, sulla scorta del dato normativo, praticabile anche nell'ipotesi in cui sussista l'obbligo legale di dotare l'ente di un organo di controllo.

3.6 Compiti del sindaco

All'organo di controllo, a prescindere dalla sua struttura, è demandato di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione con particolare riguardo all'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e al suo funzionamento.

I componenti dell'organo di controllo devono, quindi, verificare, preventivamente e successivamente, che le operazioni effettuate dalla società siano conformi all'interesse sociale e siano effettuate nel rispetto del principio di correttezza e ragionevolezza.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

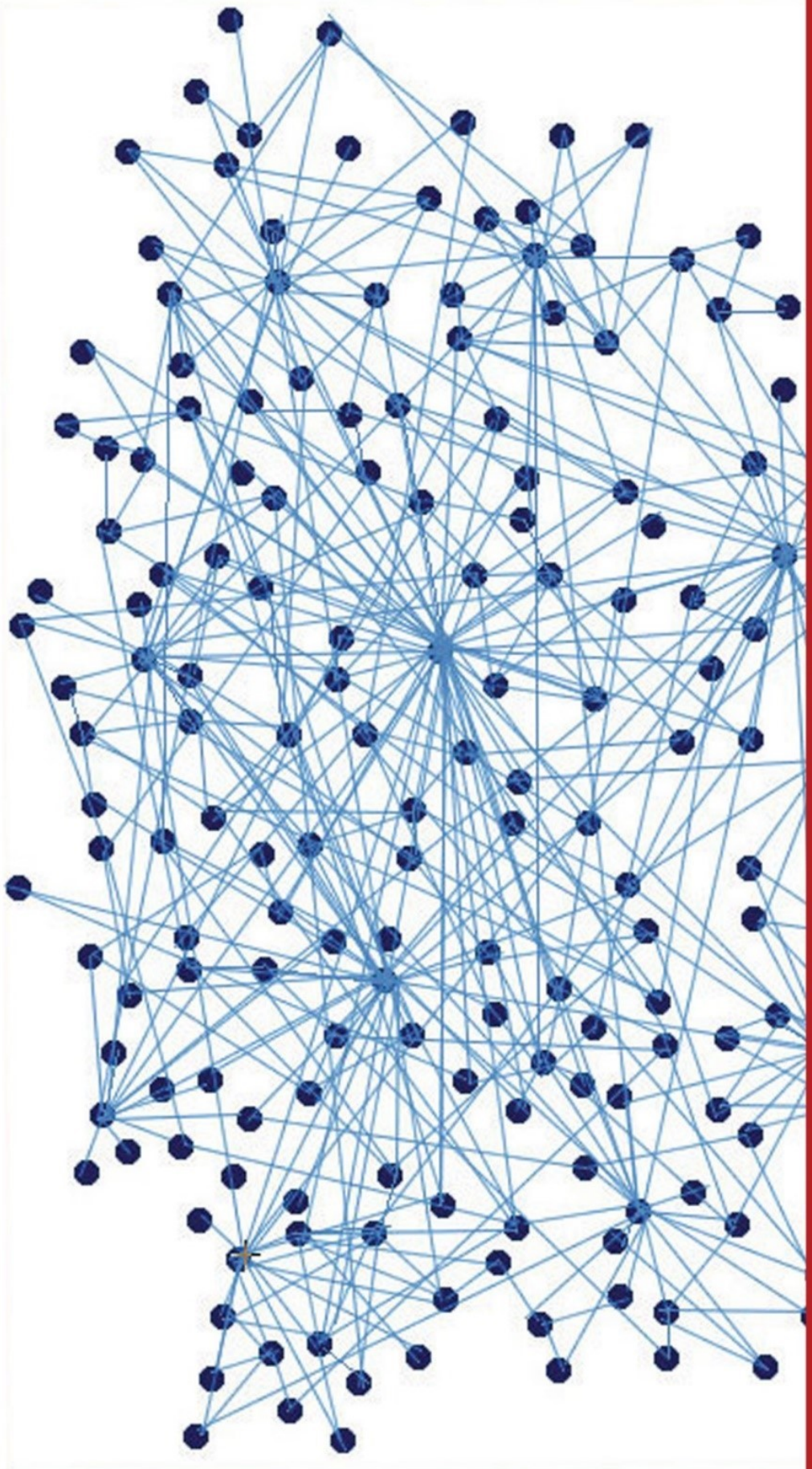
- G. M. Presti – M. Rescigno "Corso di diritto commerciale", Zanichelli, Bologna, 2015, Volume II, pagg. 238-253.
- O. Cagnasso "La società a responsabilità limitata" in "Trattato di Diritto Commerciale", diretto da G. Cottino, Cedam, Padova, 2007, Volume V, pagg. 175-313.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA 3

1.1 LA MODIFICAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO NEL SISTEMA DEL CODICE DEL 1942 3
1.2 I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA DEL 2003 (D.LGS. N. 6 DEL 17 GENNAIO 2003) 3
1.3 LE MODIFICHE SOGGETTE ALL'ART. 2480 C.C. 3
1.4 PARTICOLARE CASO APPLICATIVO: LA MODIFICA DEI PARTICOLARI DIRITTI DEI SOCI 4

2. LA COMPETENZA ED IL PROCEDIMENTO IN MATERIA DI MODIFICHE DELL'ATTO COSTITUTIVO 8

2.1 LA COMPETENZA ED IL METODO ASSEMBLEARE 8
2.2 IL PROCEDIMENTO 9
2.3 I QUORUM 9

3. PROFILI PUBBLICITARI 11

3.1 VALIDITÀ ED EFFICACIA DELLA DELIBERA IN CONSEGUENZA DELL'ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE 11
3.2 IL CONTROLLO NOTARILE 11
3.3 L'OMOLOGA GIUDIZIALE E LA RESIDUA POSSIBILITÀ DI UTILIZZAZIONE 13

BIBLIOGRAFIA 14

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. L'evoluzione della disciplina

1.1 La modificazione dell'atto costitutivo nel sistema del codice del 1942

Nel sistema codicistico originario la disciplina delle modificazioni dell'atto costitutivo era costruita (art. 2494 c.c.) per il tramite della tecnica del rinvio alla normativa fissata dal Legislatore per la s.p.a.

Sotto il vigore di quella normativa, dunque, non si ponevano questioni interpretative peculiari, posto che il tema era trattato esattamente alle stregue di quanto accadeva nei modelli azionari.

1.2 I principi ispiratori della riforma del 2003 (D.lgs. n. 6 del 17 gennaio 2003)

In esito alla novella del 2003 la situazione è, del tutto, variata posto che si è mandato ad effetto uno dei principi ispiratori della legge di riforma nella modulazione di questo aspetto regolamentare ossia si è cercato di emancipazione, concettualmente e disciplinarmente, il modello s.r.l. da quello per azioni.

1.3 Le modifiche soggette all'art. 2480 c.c.

La formalità in esame riguarda soltanto le modifiche oggettive dello statuto o le modifiche oggettive della parte statutaria dell'atto costitutivo in quanto esso soltanto, in sede di modifica, è soggetto al procedimento disciplinato dall'art. 2436 c.c. per come richiamato in materia dall'art. 2480 c.c.

I mutamenti soggettivi non sono, al contrario, soggetti a tale procedimento e, non a caso, non possono essere annoverate nella parte c.d. statutaria dell'atto costitutivo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Dette informazioni, infatti, non contribuiscono, per loro natura, a formare l'insieme delle regole che governano la società, ma si limitano ad assolvere una funzione informativa.

Dalle modifiche sin ora menzionate devono essere tenute distinte le c.d. modifiche di fatto o deroghe all'atto costitutivo.

La differenza è da rimarcare, oggi più che mai, in quanto la normativa di settore si dimostra aperta ad una applicazione estensiva di frammenti della disciplina in esame a tali variazioni, ma, a stretto rigore, le formalità cristallizzate nella norma in esame risultano applicabili solo alle vere e proprie modifiche dell'atto costitutivo.

1.4 Particolare caso applicativo: la modifica dei particolari diritti dei soci

L'art. 2468, comma 4°, c.c. dispone che «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci».

L'inciso «salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo» consente di derogare alla previsione normativa, prevedendo che le modifiche siano assunte:

- ✓ a maggioranza e, pertanto, anche senza il consenso del titolare del particolare diritto. Tale deroga al regime legale delle modifiche dei particolari diritti può essere:
- prevista già al momento della costituzione della società;
- introdotta successivamente: in tal caso, però, la delibera che deroga alla previsione normativa, prevedendo che le modifiche siano assunte a maggioranza, deve essere approvata all'unanimità.
- ✓ con un sistema misto che preveda il consenso unanime degli attributari e quello maggioritario dei soci non attributari.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'inciso di cui sopra non consente, invece, che la decisione inerente alla modifica dei particolari diritti possa essere rimessa alla minoranza dei soci oppure a soggetti terzi, in quanto la s.r.l. è pur sempre un tipo societario capitalistico.

A quest'ultimo, dunque, è connaturato che la decisione (sulla quale l'autonomia privata può incidere facendo degradare la regola di assunzione da "unanimistica" a "maggioritaria") non possa essere rimessa alla minoranza o, addirittura, a terzi.

La dottrina si domanda se per prendere tale decisione (a prescindere dalla regola, unanimistica o maggioritaria, di assunzione) sia necessario il metodo assembleare oppure possa risultare sufficiente quello extra assembleare (consenso espresso per iscritto o consultazione scritta)?

Secondo la tesi preferibile è necessario il metodo assembleare (anche se il quorum deliberativo sarà quello dell'unanimità dei consensi, salvo una diversa disposizione).

L'espressione «salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'articolo 2473» implica che qualora (e solo in tal caso) l'atto costitutivo preveda la possibilità di modificare i particolari diritti a maggioranza, spetterà ai soci dissenzienti il diritto di recesso, ciò anche riguardo ai soci che non sono titolari del particolare diritto.

Differenza tra la decisione ex: l'art. 24684 c.c. deve essere raffrontato con l'art. 24792 n. 5 c.c., il quale attribuisce alla competenza dei soci l'assunzione di decisioni, da prendersi con il metodo assembleare (art. 24793 c.c.), che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci. La norma, in questo caso, non prevede l'unanimità dei consensi, limitandosi a rimettere tale decisione alla competenza dei soci.

Dal raffronto tra l'art. 24684 c.c. e l'art. 24792 n. 5 c.c. emergono le seguenti differenze:

1. con riguardo all'**oggetto**:

- la decisione ex art. 24684 c.c. incide direttamente, in senso modificativo, sui particolari diritti in materia di amministrazione o di distribuzione degli utili (tale modifica assurge ad oggetto della decisione presa dai soci);

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- la decisione ex art. art. 24792 n. 5 c.c. incide indirettamente sui particolari diritti, in quanto si rientra in tale norma nel caso in cui l'oggetto della deliberazione sia il compimento di una data operazione, la quale, pur non avendo ad oggetto i particolari diritti, li riguarda in via mediata, cioè comporta «una rilevante modificazione dei diritti dei soci».

2. con riguardo alle **conseguenze**:

- l'art. 24684 c.c. disciplina ogni modifica, ancorché minima, che abbia ad oggetto i diritti particolari;
- l'art. 24792 n. 5 c.c. disciplina le operazioni che comportino una «rilevante modificazione» di quei diritti.

La differenza sopra illustrata spiega la diversità normativa tra le due ipotesi: nel caso dell'art. 24684 c.c. occorre l'unanimità dei consensi, mentre nel caso dell'art. 24792 n. 5 c.c. la decisione può essere adottata a maggioranza.

L' art. 24684 c.c. richiede l'unanimità solo per le modifiche dei particolari diritti ossia per le modifiche dirette dei particolari diritti.

È, tuttavia, pacifico che siano compresi altresì:

1) L'**introduzione** dei particolari diritti: posto che l'art. 24684 c.c. disciplina solo la modifica dei particolari diritti, presupponendone già la previsione, ci si chiede se per la loro introduzione occorra l'unanimità oppure sia sufficiente la maggioranza:

I. tesi minoritaria: introducibilità a maggioranza: siccome il tenore letterale della norma richiede l'unanimità solo per il caso di modificazione di tali diritti, la loro introduzione dovrebbe seguire le regole tipiche dei modelli societari capitalistici;

II. tesi maggioritaria: introducibilità all'unanimità, per le seguenti ragioni:

- in maniera del tutto analoga a quanto accadrebbe in tema di modifica, si altera l'assetto originario della società per come predisposto dai soci. I soci, infatti, hanno diritto a conservare l'assetto societario pattuito tra loro. Essendo questo l'interesse tutelato dall'art. 24684 c.c. si comprende come una sua revisione, sia essa determinata dalla modifica di

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

particolari diritti già esistenti oppure dalla loro introduzione in una società che non ne prevedesse, debba necessariamente passare per la regola unanimistica;

- i particolari diritti costituiscono una deroga alla parità di trattamento dei soci, per cui è necessario che tale deroga sia accettata da tutti i soci.

III. tesi intermedia: occorre distinguere:

- nell'ipotesi in cui l'attribuzione di un particolare diritto, per un verso, avvantaggi l'attributario e, per altro, danneggi la posizione degli altri soci (ad es., il diritto che riguardi l'amministrazione o il riparto degli utili), è necessario il consenso unanime;
- nell'ipotesi in cui l'attribuzione di un particolare diritto, pur avvantaggiando l'attributario, non danneggi gli altri soci (ad esempio: diritto di recedere dalla società in condizione che, prima dell'introduzione, non erano previste), è sufficiente la maggioranza.

2) La **eliminazione** dei particolari diritti. È il caso di precisare che, per la eliminazione del particolare diritto, non è sufficiente il consenso del socio titolare di quel particolare diritto (che sembrerebbe essere l'unico socio pregiudicato dall'eliminazione del diritto), ma è necessario il consenso di tutti i soci (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo).

3) La **trasmissione** dei particolari diritti, inter vivos o mortis causa, senza trasferimento (o con trasferimenti in favore di altri) della quota sociale.

Naturalmente la fattispecie della trasmissione dei soli particolari diritti (senza trasferimento della quota sociale) è ipotizzabile esclusivamente in favore di altri soci. Anche in tal caso, è necessario il consenso di tutti i soci, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Il problema che si pone è quello della forma in cui debba essere prestato tale consenso ossia se esso debba essere espresso necessariamente in forma assembleare, come sembra preferibile, ovvero se possa essere manifestato anche in forma negoziale;

4) **Le modifiche indirette** dei particolari diritti.

Il consenso di tutti i soci (salva diversa disposizione dello statuto) è necessario anche per quelle delibere che, pur non avendo ad oggetto direttamente i particolari diritti, indirettamente ne comportano una modifica.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La competenza ed il procedimento in materia di modifiche dell'atto costitutivo

2.1 La competenza ed il metodo assembleare

La competenza a decidere sulle modifiche dell'atto costitutivo spetta, ai sensi dell'art. 2479 bis c.c., all'assemblea dei soci.

Tale attribuzione è:

- inderogabile;
- non delegabile, a differenza di quanto accade nei modelli azionari, salvo i casi eccezionalmente previsti dalla legge (in peculiari frammenti di disciplina in tema di aumento e riduzione del capitale sociale e di fusione o scissione nei casi fissati dagli artt. 2505 e 2505 bis c.c.);

da attuarsi, necessariamente, mediante una decisione collegiale (non sono ammesse modalità alternative di decisone sul punto).

Il metodo assembleare, è bene precisare, si caratterizza per la preventiva informazione di tutti i soci e la contestuale manifestazione di volontà da parte dei medesimi per l'assunzione della decisione.

Quest'ultima, anche nel contesto societario in commento, può, quindi, definirsi in termini di atto collegiale imputabile direttamente alla società e che diventa autonomo rispetto alla volontà di coloro che hanno emesso le dichiarazioni in ossequio al principio maggioritario che connota i modelli societari capitalistici.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.2 Il procedimento

L'assunzione della decisione passa per una **molteplicità di fasi**:

- la convocazione dell'assemblea;
- la relazione del Presidente dell'assemblea il quale illustra la proposta di modifica allo scopo di stimolare il dibattito assembleare sulla medesima;
- in esito ad opportuna discussione si passa alla votazione della stessa;
- il Presidente dell'assemblea, poi, proclamerà il risultato delle votazioni;
- la medesima, successivamente, verrà, necessariamente, verbalizzata dal notaio ai sensi dell'art. 2480 c.c.;
- e, da ultimo, sarà soggetta alle formalità pubblicitarie fissate dalla legge ai sensi dell'art. 2436 c.c. per come richiamato dall'art. 2480 c.c.

2.3 I quorum

Le decisioni di modifica dell'atto costitutivo devono essere adottate:

- necessariamente in forma di delibera assembleare;
- con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

L'art. 2480 c.c., nel rinviare all'art. 2479 bis c.c., pone un quorum deliberativo e consente di ricavare anche un quorum costitutivo.

Il gioco dei rinvii pare possa ingenerare un dubbio con riferimento all'art. 2479, ultimo comma, c.c. il quale, però, deve essere confutato osservando che:

- l'art. 2479, ultimo comma, c.c. si riferisce alle decisioni non assembleari;
- l'art. 2479 bis, comma 3°, c.c. si riferisce a quelle assembleari con la previsione di un quorum rafforzato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La regola sopra esposta soffre **due eccezioni**:

- la richiesta normativa di quorum diversi per particolari materie;
- la possibilità che i medesimi vengano ritoccati, tanto verso l'alto quanto verso il basso, dall'autonomia privata.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Profili pubblicitari

3.1 Validità ed efficacia della delibera in conseguenza dell'iscrizione presso il Registro delle imprese

Dopo aver tratteggiato il procedimento in cui si articola l'espressione della volontà modificativa dell'atto costitutivo pare opportuno soffermarsi sul regime di efficacia ed esecutività di tali variazioni.

Nelle società di capitali, a differenza di quanto accade in quelle a vocazione personalistica, gli effetti delle deliberazioni risultano differiti e subordinati, salvo espresse eccezioni, all'espletamento della formalità iscrizionale presso il Registro delle imprese.

Prima dell'espletamento della medesima, tuttavia, la decisione, per ciò che concerne il modello s.r.l., assume una rilevanza interna.

Tale rilievo finisce per attenuare, come ritenuto dalla dottrina, le conseguenze pratiche scaturenti dalla qualificazione, in termini dichiarativi o costitutivi, del regime pubblicitario a cui devono essere sottoposti gli atti societari.

Parte autorevole della dottrina, poi, tende a riportare in quest'àmbito, benché il quadro normativo di riferimento sia differente, le considerazioni svolte sul tema per i modelli azionari posto che sussistono per entrambi i medesimi problemi di tutela dell'incolpevole affidamento che si radichi in capo ai terzi.

3.2 Il controllo notarile

La verbalizzazione era, originariamente, soggetta ad omologazione da parte del Tribunale ai fini dell'espletamento della formalità iscrizionale.

Successivamente (nell'anno 2000) l'omologazione è stata soppressa ed il relativo compito di controllo è stato affidato al notaio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'art. 138 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 dispone, infatti, che « Il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese delle deliberazioni di società di capitali, dallo stesso notaio verbalizzate, quando risultano manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge, viola l'articolo 28, primo comma, numero 1°, ed è punito con la sospensione di cui all'articolo 138, comma 2, e con la sanzione pecuniaria da 516 euro a 15.493 euro.

Con la stessa sanzione è punito il notaio che chiede l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo di società di capitali, da lui ricevuto, quando risultino manifestamente inesistenti le condizioni richieste dalla legge».

Ciò premesso, il notaio che verbalizzi i lavori assembleari tesi alla modifica dell'atto costitutivo effettua un controllo finalizzato all'iscrizione ex art. 1382 bis l. not. il quale consiste nella verifica della esistenza delle condizioni previste dalla legge.

Detto controllo coincide, esattamente, con quello che prima era il controllo omologatrio del Tribunale.

Valgono, pertanto, le stesse considerazioni a cui dottrina e giurisprudenza erano giunte relativamente all'omologazione giudiziale:

- si tratta di un **controllo di legalità e non di merito**;
- si tratta di un **controllo di legalità** non solo formale, ma **anche sostanziale**;
- secondo la dottrina prevalente, **il notaio deve rilevare non solo le cause di nullità, ma anche quelle di annullamento**;
- si tratta di un controllo **successivo** ossia deve essere espletato solo dopo «che vi sia stata la verbalizzazione».

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.3 L'omologa giudiziale e la residua possibilità di utilizzazione

Per il caso in cui il notaio, dopo aver verbalizzato l'adunanza, non ritenga adempiute le condizioni di legge per l'iscrivibilità della decisione e, quindi, non proceda a curarne l'iscrizione presso il Registro delle imprese comunica tale sua determinazione all'organo amministrativo il quale avrà 30 giorni per valutare se opporsi a tale negazione.

A tal riguardo possono profilarsi le seguenti ipotesi:

- inutile decorso del termine sopra ricordato: delibera inefficace;
- convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori per adottare "opportuni provvedimenti" giusta i quali si può giungere alla rinnovazione della decisione che non ha superato il vaglio notarile senza adire le vie giudiziarie;
- opposizione giudiziale al rifiuto di procedere alle formalità iscrizionali da parte del notaio per il tramite dell'esperimento di un'azione tesa ad incardinare un procedimento di volontaria giurisdizione presso il Tribunale delle imprese competente il quale, secondo l'opinione dominante in dottrina, sarebbe l'autorità giudiziaria da interpellare anche nell'ipotesi in cui si voglia instaurare un procedimento non contenzioso come quello in esame.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

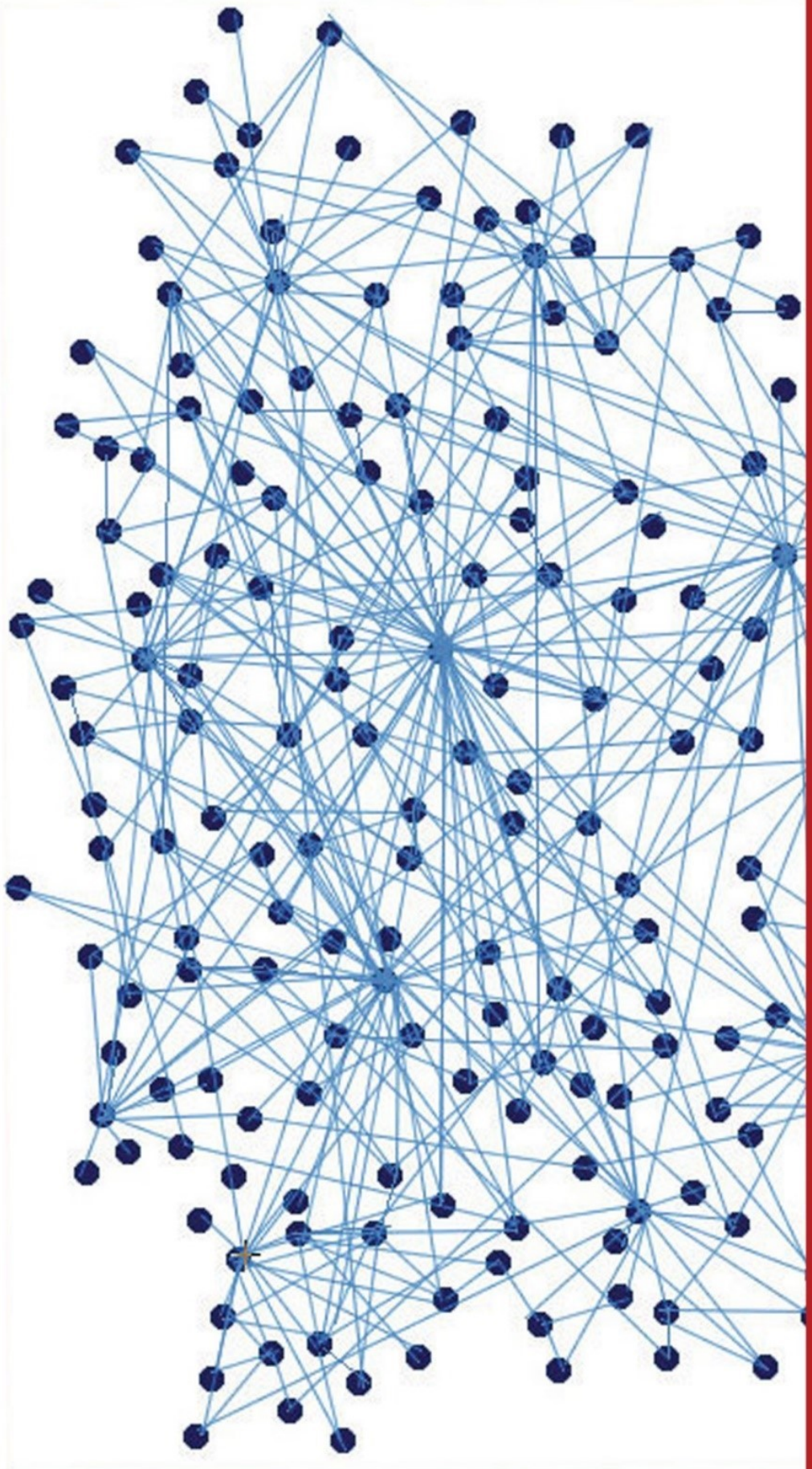
- G. M. Presti – M. Rescigno "Corso di diritto commerciale", Zanichelli, Bologna, 2015, Volume II, pag. 253.
- P. M. Smirne "Commento sub art. 2480 c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 706-737.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. L'AUMENTO REALE DI CAPITALE SOCIALE (O A PAGAMENTO) 3

1.1 I PRESUPPOSTI 3
1.2 LE MODALITÀ ED I TERMINI DELL'AUMENTO 4
1.3 L'AUMENTO SCINDIBILE INSCINDIBILE E L'AUMENTO CON EFFICACIA PROGRESSIVA 11

2. I CONFERIMENTI RELATIVI ALL'AUMENTO DI CAPITALE REALE 12

2.1 LA DISCIPLINA APPLICABILE 12
2.2 IL CONFERIMENTO IN DENARO 12
2.3 IL CONFERIMENTO DI BENI O CREDITI 12
2.4 IL CONFERIMENTO MEDIANTE COMPENSAZIONE CON UN CREDITO VERSO LA SOCIETÀ 13
2.5 È POSSIBILE EFFETTUARE UN CONFERIMENTO ATIPICO 14

3. L'AUMENTO GRATUITO DI CAPITALE SOCIALE NELLE S.R.L. 15

3.1 LA DISCIPLINA APPLICABILE 15
3.2 I PROFILI OPERATIVI DELL'AUMENTO 15
3.3 IL DIVIETO DI MODIFICAZIONE DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE NELL'AUMENTO NOMINALE 16
3.4 LA DEROGA DELLA RIPARTIZIONE NON PROPORZIONALE DI PARTECIPAZIONI 16
3.5 OPERATIVITÀ DELLA PREDETTA DEROGA IN RELAZIONE ALLE QUOTE CHE ATTRIBUISCONO "DIRITTI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI" 17

BIBLIOGRAFIA 18

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. L'aumento reale di capitale sociale (o a pagamento)

1.1 I presupposti

Per poter procedere ad aumentare il capitale a pagamento è necessario:

1) Innanzitutto, rispettare la condizione dettata dall'art. 24812 c.c. in base al quale «la decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fin quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti».

Al riguardo occorre osservare che, da un lato, per «attuazione» dell'aumento deve intendersi la sua sottoscrizione con efficacia immediata e, dall'altro lato, che per «conferimenti precedentemente dovuti» occorre intendersi il capitale sottoscritto e non quello deliberato.

È il caso di precisare che non è richiamato dalle norme di governo del modello s.r.l. l'art. 24382 c.c. per cui può discutersi se esso sia applicabile, per analogia, a tale tipo societario.

La dottrina ha assunto al riguardo posizioni divergenti posto che parte di essa ha propugnato un'interpretazione analogica della disciplina in commento invocando l'identità di ratio, mentre altra parte, al contrario, ha preferito attestarsi su una posizione negativa di tal che la violazione del divieto, proprio per il mancato rinvio dell'art. 24382 c.c., conduca alla declaratoria di invalidità e di inefficacia dell'operazione decisa.

2) Che la società non verta, ad opinione della giurisprudenza, benché non si ravvisi alcun dato positivo di supporto, nelle condizioni di cui agli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.

Al fine di accertare la presenza della condizione in oggetto, la giurisprudenza ritiene necessaria la sussistenza di una situazione patrimoniale aggiornata della società, che verrà allegata al verbale notarile. Anche in questo caso si può considerare aggiornata una situazione patrimoniale riferita ad un data non anteriore a centoventi giorni a quella dell'assemblea che delibera l'aumento.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.2 Le modalità ed i termini dell'aumento

La disciplina procedimentale dell'aumento del capitale a pagamento nel modello s.r.l., a differenza di quanto accade nel modello s.p.a., è molto scarna atteso che, ai sensi dell'art. 24812 bis c.c., si statuisce solamente che «la decisione di aumento di capitale prevede le modalità ed i termini entro i quali può essere esercitato il diritto di sottoscrizione. Tali termini non possono essere inferiori a trenta giorni dal momento in cui viene comunicato ai soci che l'aumento di capitale può essere sottoscritto».

La lettera della legge concede, quindi, ampi spazi all'autonomina privata la quale, tuttavia, deve conformarsi ai generali canoni di correttezza e buona fede contrattuale di guisa che lo strumento societario non venga piegato ad esigenze immeritevoli di tutela giacché rivolte alla prevaricazione della maggioranza sulle minoranze.

È bene notare, inoltre, che, a differenza che nella s.p.a., nel tipo s.r.l. l'offerta di sottoscrizione non è pubblicata nel registro delle imprese, ma è «comunicata» ai soci.

Quest'ultima formalità può essere espletata, ad opinione della dottrina, mediante invio di avviso al domicilio del socio (quale risultante dal Registro delle imprese) [1] oppure direttamente ai soci in assemblea, qualora alla stessa partecipino tutti i soci della società.

Non pare ammissibile, invece, sostituire la comunicazione ai soci con altre forme pubblicità quali l'iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese o la trascrizione della stessa nel libro della decisione dei soci facoltativamente mantenuto.

Sembra poi da precisare che nel modello s.r.l., a differenza di quanto accade nei modelli azionari, è espressamente stabilito che il termine per la sottoscrizione debba essere previsto dalla decisione[2].

---

[1] Pertanto, si può ritenere estensibile la previsione dell'art. 2479[1] *bis* c.c. che impone la convocazione dell'assemblea di s.r.l., mancando una diversa disciplina nell'atto costitutivo, mediante raccomandata spedita al domicilio di ciascun socio, essendo l'*eadem ratio* rappresentata dal numero limitato e facilmente identificabile dei destinatari dell'informazione, né essendovi esigenze di informazione dei terzi, considerato che la S.r.l. non fa appello al pubblico risparmio.

[2] Pertanto, si può ritenere estensibile la previsione dell'art. 24791 bis c.c. che impone la convocazione dell'assemblea di s.r.l., mancando una diversa disciplina nell'atto costitutivo, mediante raccomandata spedita al domicilio di ciascun socio, essendo l'eadem ratio rappresentata dal numero limitato e facilmente identificabile dei destinatari dell'informazione, né essendovi esigenze di informazione dei terzi, considerato che la S.r.l. non fa appello al pubblico risparmio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La sottoscrizione dell'aumento di capitale, al pari che nella s.p.a., può essere contestuale o successiva alla decisione:

1) se la sottoscrizione è «**contestuale**», l'aumento del capitale ha efficacia istantanea e produce un'immediata modifica dell'atto costitutivo che può essere, fin da subito, iscritta nel Registro delle imprese;
2) se la sottoscrizione è «**non contestuale**» in un primo momento l'aumento del capitale è solo deliberato ed in un secondo momento verrà sottoscritto, per cui si avrà una modifica dell'atto costitutivo solo se e quando, l'aumento sarà sottoscritto.

La sottoscrizione non contestuale è l'unica modalità prevista dal codice civile.

Quanto agli adempimenti pubblicitari nel Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 24816 bis c.c. «nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito».

Non è riprodotto l'art. 24442 c.c. (che in tema di s.p.a. dispone che «fino a che l'iscrizione nel registro delle imprese non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società»), ma non si dubita che tale norma si applichi anche alla s.r.l.

Quanto alle altre questioni in tema di sottoscrizione non contestuale (distinzione tra termine per la sottoscrizione e termine per l'esercizio del diritto di sottoscrizione, modifica della clausola dello statuto relativa al capitale, effetti delle sottoscrizioni, proroga del termine per la sottoscrizione, revoca dell'aumento di capitale ancora pendente), valgono le considerazioni svolte per la s.p.a.

Il diritto di sottoscrizione è il diritto dei soci attuali di sottoscrivere, in proporzione delle partecipazioni possedute, l'aumento di capitale sociale a pagamento. Stabilisce infatti l'art. 24811 bis c.c. che «in caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute».

Il Legislatore (nella s.r.l.) ha utilizzato il termine «diritto di sottoscrizione» invece di quello di «diritto di opzione», è opinione condivisibile, tuttavia, che il diritto di sottoscrizione equivalga al diritto di opzione della s.p.a.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si è posta, tuttavia, la questione se, ai fini della cessione a terzi del diritto di sottoscrizione, sia necessaria la previsione statutaria di cui all'art. 24811 bis c.c. (sia necessario cioè che lo statuto preveda che l'aumento di capitale possa essere offerto a terzi), ovvero sia necessaria la previsione nella delibera di cui all'art. 24812 bis c.c. (sia necessario cioè che la delibera consenta la collocazione dell'inoptato presso terzi):

- parte della dottrina ha ritenuto necessaria la previsione statutaria di cui al 1° comma, muovendo dal presupposto che, in mancanza, la S.r.l. avrebbe una struttura chiusa, per cui non sarebbe ammesso l'ingresso in società di terzi estranei;
- altra parte della dottrina ha ritenuto necessaria la previsione nella delibera di cui al 2° comma, muovendo dal presupposto che, in mancanza, l'inoptato non potrebbe essere offerto ad un terzo, con la conseguenza che a maggior ragione dovrebbe ritenersi non consentito che a tale risultato si pervenga attraverso la cessione del diritto di sottoscrizione;
- secondo altra dottrina e la giurisprudenza, il diritto di sottoscrizione può essere ceduto a prescindere dal fatto che lo statuto consenta l'aumento di capitale con offerta ai terzi, o che la delibera consenta la collocazione dell'inoptato presso terzi. Infatti, in assenza di limiti alla circolazione, anche se lo statuto non consentisse l'offerta dell'aumento a terzi o la delibera non consentisse la collocazione dell'inoptato presso terzi, il socio potrebbe ottenere il medesimo risultato sottoscrivendo l'aumento e cedendo successivamente la nuova quota sociale al terzo.

L'esclusione del diritto di sottoscrizione è disciplinata dall'art. 24811 bis c.c., in base al quale «*l'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473*».

A differenza che nella s.p.a., nel tipo s.r.l. l'esclusione del diritto alla sottoscrizione preferenziale è possibile solo se è prevista dall'atto costitutivo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In ciò si manifesta la maggiore considerazione che il Legislatore attribuisce, nelle s.r.l., alla posizione individuale del singolo socio.

Qualora l'atto costitutivo nulla preveda è necessario effettuare un «doppio passaggio»:

- inserire nello statuto la previsione astratta della possibilità di aumentare il capitale con offerta delle quote di nuove emissioni a terzi;
- deliberare il concreto aumento di capitale con esclusione dell'opzione.

È discusso però se l'inserimento nello statuto della possibilità di escludere l'opzione debba essere introdotto con il consenso di tutti i soci oppure possa essere deliberato a maggioranza:

- tesi minoritaria dell'unanimità: l'inserimento nello statuto della possibilità di escludere l'opzione deve essere deliberata con il consenso di tutti i soci, sul presupposto che, in mancanza, la s.r.l. avrebbe una struttura chiusa, per cui non sarebbe ammesso l'ingresso in società di terzi estranei;
- tesi maggioritaria della maggioranza: la delibera può essere assunta a maggioranza in quanto il principio generale che governa le società di capitali è quello maggioritario e quando il Legislatore ha voluto l'unanimità l'ha richiesta espressamente (art. 24684 c.c.). Né si può ritenere che, se lo statuto non consente l'offerta dell'aumento a terzi, la società debba considerarsi a struttura chiusa, perché, in assenza di limiti alla circolazione, il socio può, comunque, sottoscrivere l'aumento e successivamente cedere la nuova quota sociale al terzo. Il socio di minoranza, inoltre, è sempre tutelato dal diritto di recesso.

Secondo la prassi notarile è possibile adottare la delibera in esame, anche in assenza di una espressa previsione statutaria, purché la delibera sia adottata con il voto favorevole di tutti i soci partecipanti alla società.

Nella s.r.l., a differenza che nella s.p.a., l'unica ipotesi di esclusione dell'opzione disciplinata dal Legislatore è l'esclusione per ingresso in società di terzi.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Non è disciplinata, invece, la esclusione del diritto di sottoscrizione per conferimento in natura da parte dei soci; sono possibili tre soluzioni:

1) si potrebbe ritenere che nella s.r.l. non sia possibile escludere il diritto di sottoscrizione per conferimento in natura da parte dei soci (e che l'unica via per raggiungere un simile risultato sia la rinuncia all'opzione da parte dei soci). Una simile conclusione sembra, in verità, eccessivamente limitativa;
2) si potrebbe ritenere, altresì, che trovi applicazione analogica la disciplina dell'art. 2441 c.c. in tema di s.p.a., per la quale il diritto di opzione è escluso ex lege ed occorre osservare le formalità ivi previste. È stato, tuttavia, osservato che non è necessario applicare la normativa della s.p.a., potendosi, invece, applicare analogicamente quella della s.r.l.;
3) secondo la dottrina prevalente, infatti, a tale ipotesi è applicabile per analogia l'art. 24811 bis c.c., con la conseguenza che è l'atto costitutivo a dover prevedere l'esclusione e la disciplina del diritto di sottoscrizione in caso di conferimenti in natura. Qualora una simile clausola sia inserita nello statuto successivamente, l'inserimento può avvenire a maggioranza, ma è opportuno attribuire statutariamente ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c. [3]

Nella s.r.l., a differenza che nella s.p.a., quando è escluso o limitato il diritto di sottoscrizione non è necessaria l'osservanza di alcuna formalità (relazione degli amministratori, deposito presso la sede sociale, ecc.) né vi è alcun obbligo di motivazione all'interno del verbale assembleare. Permane, invece, la necessità della relazione di stima in caso di conferimento in natura.

Con riferimento al sovrapprezzo, l'art. 24812 bis c.c. stabilisce che «la decisione di aumento di capitale prevede l'eventuale soprapprezzo».

[3] La previsione del recesso è opportuna, anche perché (in mancanza) si potrebbe ritenere che l'introduzione *successiva* nello statuto di una simile clausola debba essere deliberata con il consenso di *tutti* i soci.
Più in generale la disciplina del 1° comma (previsione dello statuto e recesso) deve ritenersi applicabile nella s.r.l. ad ogni ipotesi di esclusione o limitazione del diritto di sottoscrizione.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nella la s.r.l. il sovrapprezzo è:

- per parte minoritaria della dottrina obbligatorio nel caso in cui il diritto di sottoscrizione sia escluso o limitato: l'espressione «eventuale» deve essere intesa nel senso che il sovrapprezzo è obbligatorio solo nell'eventualità che il valore del patrimonio netto sia superiore al capitale nominale;
- per la dottrina prevalente, invece, proprio in considerazione dell'utilizzo dell'espressione «eventuale», nella s.r.l. (a differenza che nella s.p.a.) il sovrapprezzo non è obbligatorio.

In altri termini, quando è escluso o limitato il diritto di sottoscrizione, la fissazione del sovrapprezzo è sempre eventuale, anche se il valore reale delle quote è superiore a quello nominale, in quanto il socio di minoranza è tutelato dal recesso.

Ai sensi dell'art. 24814 bis c.c. all'atto di sottoscrizione deve essere versato «l'intero soprapprezzo». Quanto alle altre questioni in tema di sovrapprezzo (delega agli amministratori per la determinazione del sovrapprezzo, sovrapprezzo nel caso di aumento offerto in sottoscrizione ai soci, sovrapprezzo in natura), si rinvia alle considerazioni svolte nella S.p.A.

L'art. 24812 bis c.c. stabilisce che «la decisione può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci (in proporzione della rispettiva partecipazione sociale) o da terzi».

Preliminarmente occorre precisare che, anche se il 2° comma stabilisce che è «la decisione» che può prevedere la possibilità di offrire l'inoptato a terzi, non vi è dubbio che ciò possa essere contenuto anche nello statuto (ed anzi una simile previsione è frequentemente contenuta negli statuti della s.r.l.).

Ciò premesso, la disciplina della parte di aumento di capitale inoptata da uno o più soci (c.d. inoptato) nella s.r.l. pone una serie di questioni di notevole interesse atteso che:

1) Mentre nella s.p.a. la sorte dell'inoptato è disciplinata ex lege nella s.r.l. è «la decisione (che) può consentire che la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi».

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel silenzio della delibera (e dello statuto) l'inoptato non può essere più sottoscritto né dagli altri soci né da terzi. ÙIn altri termini: nel silenzio della delibera (e dello statuto) l'inoptato non sussiste. In ciò si manifesta la maggiore considerazione che il Legislatore attribuisce, nelle società a responsabilità limitata, alla posizione individuale del singolo socio.

2) Mentre nella s.p.a. l'inoptato deve essere offerto in prelazione ai soci, e solo quando costoro non lo sottoscrivano potrà essere offerto in sottoscrizione a terzi, nella s.r.l. è previsto solo che la decisione può offrire l'inoptato «agli altri soci o a terzi».

In altri termini anche quando è previsto l'inoptato, nel silenzio della delibera (e dello statuto), non sussiste la prelazione dei soci o dei terzi; concludendo perché sussista la prelazione sull'inoptato è necessario che la delibera di aumento di capitale (o lo statuto) la preveda espressamente in modo distinto e specifico rispetto alla sola previsione dell'inoptato.

3) È controverso se, ai fini della offerta dell'inoptato a terzi, ex 2° comma, sia necessaria la previsione statutaria astratta di cui al 1° comma (sia necessario cioè che lo statuto preveda che l'aumento di capitale possa essere offerto a terzi):

- parte della dottrina ha ritenuto necessaria una simile previsione, muovendo dal presupposto che, in mancanza, la s.r.l. avrebbe una struttura chiusa, per cui non sarebbe ammesso l'ingresso in società di terzi estranei;
- secondo la dottrina prevalente l'inoptato può essere offerto a terzi a prescindere dal fatto che lo statuto consenta l'aumento di capitale con offerta ai terzi. Infatti, mentre il 1° comma stabilisce che è «l'atto costitutivo» che può prevedere la possibilità di offrire l'aumento a terzi, il 2° comma stabilisce che è «la decisione» che può prevedere la possibilità di offrite l'inoptato a terzi. A sostegno della teoria prevalente può osservarsi poi che, in assenza di limiti alla circolazione, anche se lo statuto non consentisse l'offerta dell'aumento a terzi, il socio potrebbe comunque sottoscrivere l'aumento e poi cedere la nuova quota sociale al terzo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.3 L'aumento scindibile inscindibile e l'aumento con efficacia progressiva

Il comma 3° dell'art. 2481 bis c.c. stabilisce che l'aumento è inscindibile, salva diversa indicazione.

Da ciò consegue che, se entro i termini fissati dalla legge, l'aumento non è stato interamente sottoscritto l'operazione non produce alcun effetto e la società dovrà restituire quanto, eventualmente, già ottenuto a titolo di conferimento.

L'autonomia privata può, tuttavia, alterare detta regola prevedendo la scindibilità dell'aumento del capitale sociale ossia una diversa articolazione dell'operazione sulla cui portata effettuale la dottrina si è molto affaticata non raggiungendo risultati univoci.

Gli orientamenti che si contendono il campo possono essere così riassunti:

- parte della dottrina ritiene che le sottoscrizioni via via raccolte abbiano efficacia immediata con conseguente attribuzione ai soci dei correlativi diritti sociali salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo;
- altra parte della dottrina ritiene, invece, che le sottoscrizioni via via raccolte, benché sotto il profilo astratto abbiano efficacia immediata, con conseguente attribuzione ai soci dei correlativi diritti sociali, sul piano concreto assumono rilevanza corporativa solo con lo spirare del termine finale fissato per l'esecuzione dell'operazione divisata;
- altra parte della dottrina, da ultimo, ritiene, a ragione, che la previsione della scindibilità consenta solo di determinare l'aumento nella misura delle sottoscrizioni raccolte senza comportare, in assenza di una apposita previsione dell'atto costitutivo (c.d. scindibilità ulteriore o efficacia progressiva dell'aumento), anche l'immediata efficacia delle singole sottoscrizioni.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. I conferimenti relativi all'aumento di capitale reale

2.1 La disciplina applicabile

L'aumento oneroso di capitale è espressamente disciplinato dagli artt. 24812 e 2481 bis c.c.

2.2 Il conferimento in denaro

Per il caso in cui il conferimento sia in denaro, l'art. 24814 bis c.c. prevede che «*salvo quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma e dal sesto comma dell'articolo 2464, i sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta*»;

2.3 Il conferimento di beni o crediti

Per il caso in cui il conferimento sia in natura l'art. 24814 bis c.c. statuisce che «per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2464», per cui le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

Non è richiamato, espressamente, l'art. 2465 c.c., ma non vi è dubbio che esso si applichi anche in sede di aumento di capitale, con conseguente necessità della relazione di stima per i conferimenti in natura.

Quest'ultima, poi, dovrà essere allegata al verbale di aumento (e non al successivo negozio di conferimento in natura).

Al pari che nella s.p.a. si ritiene, poi, applicabile l'art. 24643 c.c., ai sensi del quale «se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in denaro».

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Pertanto, affinché possa essere deliberato un aumento con conferimento in natura, è necessaria un'espressa previsione dell'atto costitutivo.

Qualora lo statuto non preveda la fattispecie sarà, quindi, necessario modificare previamente l'atto costitutivo ove si voglia deliberare un aumento di capitale da liberarsi mediante conferimento in natura.

In alternativa, secondo una autorevole opinione, sarebbe possibile adottare la delibera senza preventivamente modificare l'atto costitutivo, purché la delibera sia adottata all'unanimità.

2.4 Il conferimento mediante compensazione con un credito verso la società

Fra le modalità di liberazione dall'obbligo di conferimento vi è, altresì, la compensazione con un credito verso la società.

Tale situazione si concerta nella riqualificazione contabile di un debito in capitale sociale.

In merito a tale operazione occorre precisare che:

- la dottrina, dopo un primo arresto sfavorevole, non ha più dubbi nell'ammetterla nella forma convenzionale ossia allorquando l'effetto della reciproca elisione si radichi in un contratto intercorrente tra socio e società (la volontà della medesima dovrà formarsi in seno all'assemblea dei soci, salvo delega all'organo amministrativo);
- in dottrina, invece, si incontrano molte più resistenze in ordine all'operatività della compensazione legale in materia. Per ciò che interessa l'opinione oggi decisamente prevalente in dottrina ed in giurisprudenza è nel senso di ritenere tale operazione ammissibile posto che non sussiste alcun divieto espresso sul punto e tale modalità di estinzione dell'obbligo di sottoscrizione non urta contro principi generali che informano il sistema dei conferimenti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.5 È possibile effettuare un conferimento atipico

L'ampliamento delle entità conferibili e la necessità di costruire la disciplina ad essi applicabile ha condotto parte della dottrina, dopo il 2003, a rielaborare, in maniera sistematica, tali aspetti di disciplina cercando di ricondurre ad unità le varie tipologie di conferimento non codificate grazie ad un meccanismo di sussunzione entro le classi, che hanno assunto, in questa prospettiva, carattere "generale", dei conferimenti in natura e di opera e servizi.

Il combinato disposto degli artt. 2464 e 2468, comma 2°, c.c. segna, poi, i confini di un altro strumento giuridico giusta il quale potrebbero dischiudersi le porte a conferimenti c.d. atipici ossia di entità che non trovano una disciplina nella normazione positiva, ma che ciononostante posso essere utili all'espletamento dell'attività di impresa.

Per queste ragioni non pare revocabile in dubbio che anche in seno all'operazione in commento possano trovare cittadinanza conferimenti c.d. atipici purché vengano rispettate le guarentigie, formali e sostanziali, che assistono l'operazione di dotazione della società in fase costitutiva.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. L'aumento gratuito di capitale sociale nelle s.r.l.

3.1 La disciplina applicabile

L'aumento gratuito di capitale è disciplinato, nella s.r.l., dall'art. 2481 ter c.c. il quale:

- al 1° comma stabilisce che: «la società[4] può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili»;
- al 2° comma aggiunge che «in questo caso la quota di partecipazione (intesa come percentuale di partecipazione al capitale) di ciascun socio resta immutata».

3.2 I profili operativi dell'aumento

Sotto l'aspetto operativo l'operazione in commento si connota per:

- una diversa allocazione contabile di risorse di cui la società è già titolare con il contestuale assoggettamento delle medesime al più stingente vincolo di indisponibilità che caratterizza il capitale sociale rispetto alle altre voci di cui si compone il netto patrimoniale;
- l'impiego, a tal fine, di riserve e fondi "in quanto disponibili";
- la necessità, almeno ad opinione della giurisprudenza, della predisposizione di una situazione patrimoniale aggiornata, ad una data non antecedente a 120 gg, dalla quale emergano le poste all'uopo utilizzabili allorquando non possa a tal fine essere impiegato il bilancio perché approvato altri sei mesi prima della decisione di cui si discorre;
- la sua inidoneità, di regola, ad alterare i rapporti di forza correnti tra i soci posto che la medesima si sostanzia in un incremento, proporzionale, della partecipazione di cui ciascuno è titolare.

[4] La competenza è attribuita genericamente alla società, e non all'assemblea, il che costituisce un indizio a favore della tesi che anche l'aumento gratuito sarebbe delegabile all'organo amministrativo. Parte della dottrina, infatti, dal tenore letterale dell'art. 2481[2] c.c. ritiene che la norma si riferisca al solo aumento a pagamento e sarebbe, pertanto, esclusa la possibilità di delegare l'aumento gratuito; si argomenta inoltre dalle norme contenute nella legge delega che attribuiscono inderogabilmente ai soci le decisioni riguardanti le sfere soggettive degli stessi («*una rilevante modificazione dei diritti dei soci*», secondo la lettera dell'art. 2479 c.c.).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.3 Il divieto di modificazione delle quote di partecipazione nell'aumento nominale

Il comma 2° dell'art. 2481 ter c.c. mette in luce l'ultima delle caratteristiche sopra esposte e si giustifica sulla scorta della considerazione per cui l'aumento gratuito del capitale sociale, non comportando nuovi esborsi per i soci, va a vantaggio, in ragione alle singole partecipazioni, di tutti i soci.

Tale operazione, in altri termini, non può dare luogo a mutamenti nella composizione della compagine sociale e non può, di regola, alterare la partecipazione al capitale dei singoli soci.

3.4 La deroga della ripartizione non proporzionale di partecipazioni

La regola poc'anzi descritta pare, tuttavia, superabile nel caso in cui vi sia il consenso unanime dei soci posto che la stessa presidia un interesse esclusivamente privatistico che si appunta in capo ai medesimi.

L'alterazione della regola dell'incremento proporzionale alle partecipazioni da ciascun socio detenute può legittimare:

- l'assegnazione di tutte le partecipazioni risultanti dall'aumento a taluni soci;
- l'assegnazione di tutte le partecipazioni risultanti dall'aumento ad un solo socio.

Non essendovi, però, alcun conferimento l'ipotesi in commento non pare sovrapponibile a quella contemplata dall'art. 2468, comma 2°, c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.5 Operatività della predetta deroga in relazione alle quote che attribuiscono "diritti particolari riguardanti la distribuzione degli utili"

Il caso in esame conduce a considerare il delicato intreccio che potrebbe venire a crearsi tra la fattispecie regolata dall'art. 2468, comma 3° c.c. e quella afferente all'immutabilità della quota in sede di aumento gratuito del capitale sociale.

Al riguardo occorre, preliminarmente, osservare che non si ravvisano problemi nel caso in cui la decisione venga assunta all'unanimità posto che la stessa è in grado si spostare l'asse valutativo dall'àmbito societario a quello contrattuale.

In caso, invece, di deliberazione a maggioranza pare, invece, debba essere rispettato il disposto dell'art. 2481 ter c.c. benché corretto, in concreto, dall'art. 2479, comma 2°, n, 5 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

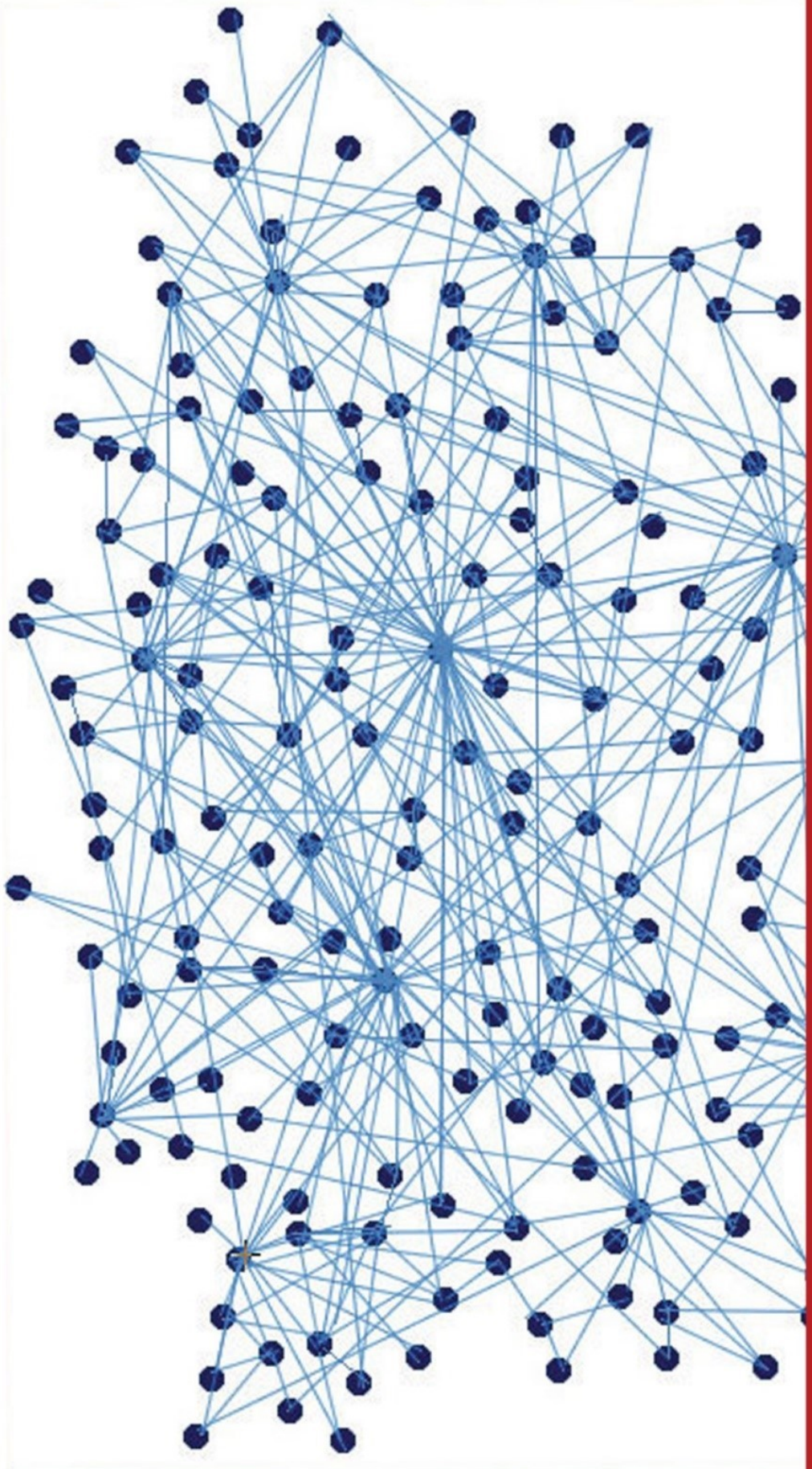
- S. A. Cerrato e R. Secondo "Commento sub artt. 2481 – 2481 ter c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 738-822.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE PER PERDITE: PROFILI GENERALI 3

1.1 I PRESUPPOSTI 3
1.2 LA RATIO DELLA DISCIPLINA 3
1.3 IL CONCETTO DI PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE ED IL RIFLESSO SULLA DISCIPLINA DEL PATRIMONIO NETTO 4
1.4 IL CONCETTO DI PERDITA DEL CAPITALE SOCIALE ED IN PARTICOLARE IL RIFLESSO SULLE RISERVE 4

2. IL PROCEDIMENTO 6

2.1 L'ATTIVAZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI: TEMPESTIVITÀ E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE AI SOCI 6
2.2 LA RELAZIONE SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E LE OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO 6
2.3 LA CONVOCAZIONE ASSEMBLEARE 7
2.4 LA DELIBERAZIONE E GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI 8
2.5 LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN SEDE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO SUCCESSIVO A QUELLO A CUI VENNE ACCERTATA LA PERDITA INFERIORE AL TERZO 9
2.6 LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE OBBLIGATORIA "DELEGATA" (ULTIMO COMMA DELL'ART. 2482 BIS C.C.) 9

3. LA RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE AL DI SOTTO DEL MINIMO LEGALE 10

3.1 IL RAPPORTO TRA L'ART. 2482 TER C.C. E L'ART. 2463, QUARTO COMMA, C.C. 10
3.2 IL PROCEDIMENTO DI RIDUZIONE E RICAPITALIZZAZIONE 10
3.3 LA TRASFORMAZIONE QUALE PROVVEDIMENTO ALTERNATIVO ALLA RIDUZIONE E RICAPITALIZZAZIONE 12

BIBLIOGRAFIA 13

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La riduzione del capitale sociale per perdite: profili generali

1.1 I presupposti

L'operazione di riduzione nominale del capitale sociale si sostanzia in un'operazione contabile tesa a raggiungere la coincidenza tra il valore nominale del capitale sociale e l'effettiva consistenza del patrimonio sociale così per come ridotto in seguito alle perdite registrate.

I presupposti necessari affinché possa trovare applicazione questa peculiare modifica statutaria sono:

- la perdita deve essere di ammontare superiore ad un terzo del capitale sociale → resta, quindi, confermata la scelta del Legislatore di considerare, tendenzialmente, irrilevanti le perdite inferiori al terzo del capitale sociale anche nel caso in cui le stesse portino il capitale sociale al disotto del minimo legale;
- l'ammontare della perdita non deve, comunque, essere tale da condurre il capitale sociale sotto la soglia minima prevista dalla legge per il modello societario in esame → tale presupposto continua ad assistere la disciplina in commento benché il tema della rilevanza del capitale sociale nel modello societario a responsabilità limitata sia stato oggetto di profonde innovazioni apportate con la Legge 9 agosto 2013 n. 99.

1.2 La ratio della disciplina

Funzione del complesso normativo di riferimento è quella di tutelare:

- i terzi: che hanno interesse a che il capitale nominale trovi precisa corrispondenza nei reali valori dell'attivo patrimoniale;
- i soci: il quali hanno interesse ad adeguare il capitale sociale alle perdite affinché in futuro non possa addivenirsi alla distribuzione degli utili;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il generale interesse ad evitare l'accumulo di perdite all'interno degli enti associativi.

1.3 Il concetto di perdita del capitale sociale ed il riflesso sulla disciplina del patrimonio netto

Quando si evoca detto concetto, ben distinto da quello di "passività", si intende fare riferimento al deficit riscontrabile tra gli elementi attivi e quelli passivi di cui si compone il patrimonio netto.

Il patrimonio netto è così composto: capitale sociale + riserve + utili accantonati e quelli di esercizio – perdite portate a nuovo da precedenti esercizi o accumulate nell'esercizio sociale in corso.

Le regole che presidiano tale operazione rispondono ad un generale principio di ordine pubblico per cui sono sottratte all'autonomia privata.

Per il caso in cui i soci non rispettino tali regole la giurisprudenza ha invocato la nullità della delibera (impossibilità o illiceità dell'oggetto), ma la dottrina tende a ricondurre tale ipotesi nell'alveo dell'art. 2377 c.c. (deliberazione non presa in conformità alla legge) evocando, quindi, la sola annullabilità della stessa.

1.4 Il concetto di perdita del capitale sociale ed in particolare il riflesso sulle riserve

Così delineato il concetto di perdita occorre, inoltre, precisare che, ad opinione della dottrina oggi maggioritaria e della giurisprudenza di legittimità, l'autonomia privata si vede, in quest'àmbito, concesso pochissimo margine di manovra posto che la progressione con la quale la perdita erode gli elementi del patrimonio netto è sottratta alla disponibilità dei soci.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tale considerazione risente del diverso grado di vincolatività che assiste i vari elementi dell'attivo i quali risultano organizzati gerarchicamente partendo fa quelli in cui il vincolo ha intensità minore per giungere a quelli in cui il medesimo ha massima estensione.

Le perdite sembrano destinate ad incidere sul patrimonio netto nel modo che segue:

- riserve volontarie o facoltative disponibili;
- riserve statutarie (libere e vincolate);
- fondi di rivalutazione, la parte della riserva da sovrapprezzo che segue le sorti della riserva legale e la riserva legale;
- capitale sociale.

L'autonomia privata potrà solo incidere, individuando un ordine di precedenza, sull'aggredibilità di elementi che abbiano lo stesso grado di vincolatività.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il procedimento

2.1 L'attivazione degli organi sociali: tempestività e completezza dell'informazione ai soci

Nel contesto della riduzione per perdite superiori ad un terzo si assiste ad una sovrapposizione tra le regole di governo dei modelli azionari e quelle che informano la disciplina del modello a responsabilità limitata.

Gli amministratori devono[1], senza indugio, convocare l'assemblea onde consentire alla medesima di adottare opportuni provvedimenti per fare fronte alla situazione in cui verte la società.

L'organo gestorio deve, inoltre, predisporre una situazione patrimoniale accompagnata da una relazione sulla stessa corredata dalla relazione dell'organo di controllo che dovranno, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo, rimanere depositi presso la sede sociale negli otto giorni che precedono l'adunanza affinché i soci possano visionarle e chiederne copia.

In questa fase l'obbligo a carico dell'organo gestorio manda ad effetto una esigenza informativa che si esprime nella predisposizione dei documenti sopra ricordati.

2.2 La relazione sulla situazione patrimoniale e le osservazioni del collegio

Tali documenti presentano un innegabile nesso funzionale.

La situazione patrimoniale e la relazione sulla medesima assolvono ad una funzione prettamente informativa, mentre le osservazioni dell'organo di controllo si pongono quale ulteriore vaglio e verifica delle medesime prima della loro illustrazione ai soci riuniti in assemblea.

[1] La mancata convocazione integra gli estremi dell'illecito di cui all'art. 2361 c.c.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il dato positivo evoca solo una relazione sulla situazione patrimoniale di tal che parte della dottrina (minoritaria) ha sostenuto che, nel caso in esame, non fosse necessaria la predisposizione di una apposita situazione patrimoniale, redatta nel rispetto dei criteri che informano la predisposizione del bilancio, bastando allo scopo un prospetto illustrativo idoneo a quantificare le perdite onde consentire all'assemblea di prendere gli opportuni provvedimenti.

La dottrina maggioritaria, invece, ricava dalla lettera della legge una considerazione esattamente opposta atteso che la sua formulazione pare presupporre la redazione di una situazione patrimoniale regolata dagli stessi criteri di governo del bilancio.

La situazione patrimoniale in commento svolge una funzione certificativa della perdita e informativa per i soci per cui deve essere "aggiornata" ossia, secondo l'opinione maggioritaria, non antecedente di 120 gg alla data per cui è fissata l'adunanza.

2.3 La convocazione assembleare

Il tema di maggiore interesse riguarda, posto che sussiste l'obbligo di convocazione senza indugio per l'organo gestorio, la concerta formulazione dell'ordine del giorno.

Preso atto della funzione informativa che è sottesa a tale elemento pare potersi ipotizzare che la stessa sia realizzata allorquando ai soci vengano prospettate tutte le possibilità per porre rimedio alla situazione loro esposta dagli amministratori.

Gli opportuni provvedimenti potrebbero, altresì, essere assunti, ad opinione della dottrina maggioritaria, anche da un'assemblea totalitaria atteso che l'interesse protetto dalle regole sin ora esaminate è quello alla corretta informazione dei soci i quali ben potrebbero non opporsi alla discussione svolta in seno all'assemblea in composizione totalitaria dichiarando di essere edotti rispetto alle materie al vaglio.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.4 La deliberazione e gli opportuni provvedimenti

L'assemblea dei soci, convocata senza indugio dall'organo amministrativo, deve adottare gli opportuni provvedimenti.

Questi ultimi possono essere suddivisi utilizzando le seguenti classi:

- **inerzia** → dalla norma traspare che il Legislatore consente, innanzitutto, ai soci di prendere solo atto, mediante il corredo documentale sopra ricordato, della situazione in cui verte la società senza che ai medesimi sia fatto obbligo, in questo frangente, di intervenire per porvi rimedio consentendo loro di rimandare la decisione all'esercizio successivo;
- "**manovre" sul patrimonio** → sono quelle operazioni che mediante un informale ricostituzione della dotazione patrimoniale dell'ente producono l'effetto di assorbire la perdita, disinnescando il c.d. circuito di allarme che presidia il capitale sociale;
- "**manovre" sul capitale** → la società, benché non sia al momento obbligata, potrà decidere di ridurre il capitale sociale corrispondentemente alla perdita accertata. Sino all'ammontare di quest'ultima, osserva la dottrina, si applicheranno le norme sulla riduzione nominale del capitale sociale, mentre ove si profili una riduzione del capitale sociale che ecceda la consistenza della perdita accertata si applicherà, con riferimento all'eccedenza, la disciplina della riduzione reale del capitale sociale;
- "**manovre" sull'organizzazione** → sono quelle che mirano all'assorbimento delle perdite per il tramite di una riorganizzazione dell'ente. Tra le medesime possono essere annoverate la trasformazione, la fusione, la scissione e, come extrema ratio, lo scioglimento anticipato della società con contestuale nomina dei liquidatori.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.5 La riduzione del capitale sociale in sede di approvazione del bilancio d'esercizio successivo a quello a cui venne accertata la perdita inferiore al terzo

Nel modello s.r.l., al pari di quanto previsto nella s.p.a., «*se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti nominati ai sensi dell'articolo 2477 devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio*».

Il Tribunale (a differenza dell'art. 24462 c.c. non è prescritto l'intervento del Pubblico Ministero), «*anche su istanza di qualsiasi interessato, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel Registro delle imprese a cura degli amministratori*».

2.6 La riduzione del capitale sociale obbligatoria "delegata" (ultimo comma dell'art. 2482 bis c.c.)

In dottrina è ancora discussa la delegabilità dell'operazione in commento all'organo amministrativo posto che il dato positivo statuisce che «*si applica, in quanto compatibile, l'ultimo comma dell'articolo 2446*».

La norma richiamata consente la devoluzione al consiglio di amministrazione delle competenze dell'assemblea in ordine alla riduzione del capitale per perdite.

Considerato il dato letterale della norma richiamata, che prevede la deliberazione del consiglio di amministrazione, si deve ritenere che la competenza spetti collegialmente al consiglio anche nel caso di amministrazione disgiuntiva.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. La riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

3.1 Il rapporto tra l'art. 2482 ter c.c. e l'art. 2463, quarto comma, c.c.

Ai fini di delineare i confini operativi dell'art. 2482 ter c.c. occorre verificare quale sia il presupposto sostanziale per la sua applicazione ossia quale possa dirsi oggi il capitale minimo previsto dalla legge per il modello societario a responsabilità limitata.

Al riguardo la dottrina non ha espresso opinioni unanimi:

- parte minoritaria della medesima continua a ritenere che il limite sia quello fissato dall'art. 2463, comma 2°, n. 4 c.c.;
- altra parte, maggioritaria, della stessa sostiene, al contrario, che tale limite, in un'ottica sistematica ed adeguatrice delle sviste legislative, vada oggi ricercato nel comma 4° dell'art. 2463 c.c.

Da ciò consegue che nel caso in cui il capitale sociale di una s.r.l., a causa di perdite, veda ridursi in un margine compreso tra 10.000 Euro ed 1 Euro, non potrà invocarsi la disciplina di cui all'art. 2482 ter c.c., ma potrà trovare applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, quella fissata dall'art. 2482 bis c.c.

3.2 Il procedimento di riduzione e ricapitalizzazione

La riduzione del capitale per perdite al disotto del minimo legale nella s.r.l. è disciplinata dall'art. 2482 ter c.c., il quale al 1° comma stabilisce che «*se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo*».

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Il procedimento che conduce all'assunzione della decisione si riduzione e alla contestuale ricapitalizzazione segue, ad opinione della dottrina maggioritaria, l'impronta data dall'art. 2482 bis c.c.

L'oggetto della deliberazione riguarderà l'integrale riduzione della perdita e il contestale aumento del capitale sociale volto sino al minimo legale che, dovendo essere offerto in sottoscrizione preferenziale anche ai soci assenti, non dovrà essere, di necessità, sottoscritto integralmente in sede assembleare.

La disciplina delle s.r.l., in larga misura sovrapponibile, sul punto, con quella della s.p.a. sembra aver preso partito in merito alla possibilità di escludere, in fase di ricapitalizzazione, il diritto alla sottoscrizione preferenziale dei soci.

L'art. 24811 bis c.c. stabilisce, infatti, che «*l'atto costitutivo può prevedere, salvo per il caso di cui all'articolo 2482 ter, che l'aumento di capitale possa essere attuato anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi*».

Per i modelli azionari:

- è opinione consolidata che (nella sola ipotesi di azzeramento del capitale) non sia possibile escludere il diritto di opzione dei soci;
- è notevolmente controverso se tale diritto di opzione possa essere, a maggioranza, solo limitato.

In tema di s.r.l., l'inciso «salvo il caso di cui all'art. 2482 ter» chiarisce che il diritto di sottoscrizione non può essere escluso, né limitato.

A ciò occorre aggiungere che mentre nella s.p.a. il problema è discusso solo nell'ipotesi di azzeramento del capitale, per la s.r.l. il riferimento è all'intera disciplina dell'art. 2482 ter c.c., per cui il diritto di sottoscrizione non può essere escluso, né limitato, non solo in caso di azzeramento del capitale sociale, ma anche nel caso «normale» di riduzione al disotto del minimo legale.

Stabilisce l'art. 2482 quater c.c. che «in tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci».

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La disposizione in esame intende ribadire il principio di parità di trattamento e non comporta alcuna novità rispetto alle considerazioni svolte per modelli azionari.

In particolare:

a) resta ferma la possibilità di attribuire a singoli soci il particolare diritto ad una diversa incidenza delle perdite sulla propria partecipazione sociale (art. 24683 c.c.);

b) resta ferma la possibilità, con il consenso di tutti i soci, di deliberare una riduzione non proporzionale del capitale per perdite.

3.3 La trasformazione quale provvedimento alternativo alla riduzione e ricapitalizzazione

L'art. 24822 ter c.c., stabilisce, prendendo partito su un punto discusso in materia di s.p.a., che «è fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società».

Nella s.p.a. è discusso se, in caso di trasformazione, sia comunque necessaria la previa riduzione del capitale.

Per la s.r.l. il fatto che la possibilità di deliberare la trasformazione della società sia contenuta in un comma separato, lascia chiaramente intendere che la previa riduzione non è necessaria;

La dottrina osserva, al riguardo, che l'art. 2482 ter c.c. prevede, nel caso di perdita di oltre un terzo del capitale che riduca lo stesso al disotto del minimo legale, al comma 1°, che l'assemblea possa deliberare la riduzione del capitale ed il contestuale aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo. Al comma 2° e, quindi, in un comma separato fa salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

Nel caso di trasformazione della società in modello associativo più semplice è pertanto possibile trasformare la società senza procedere alla previa riduzione del capitale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

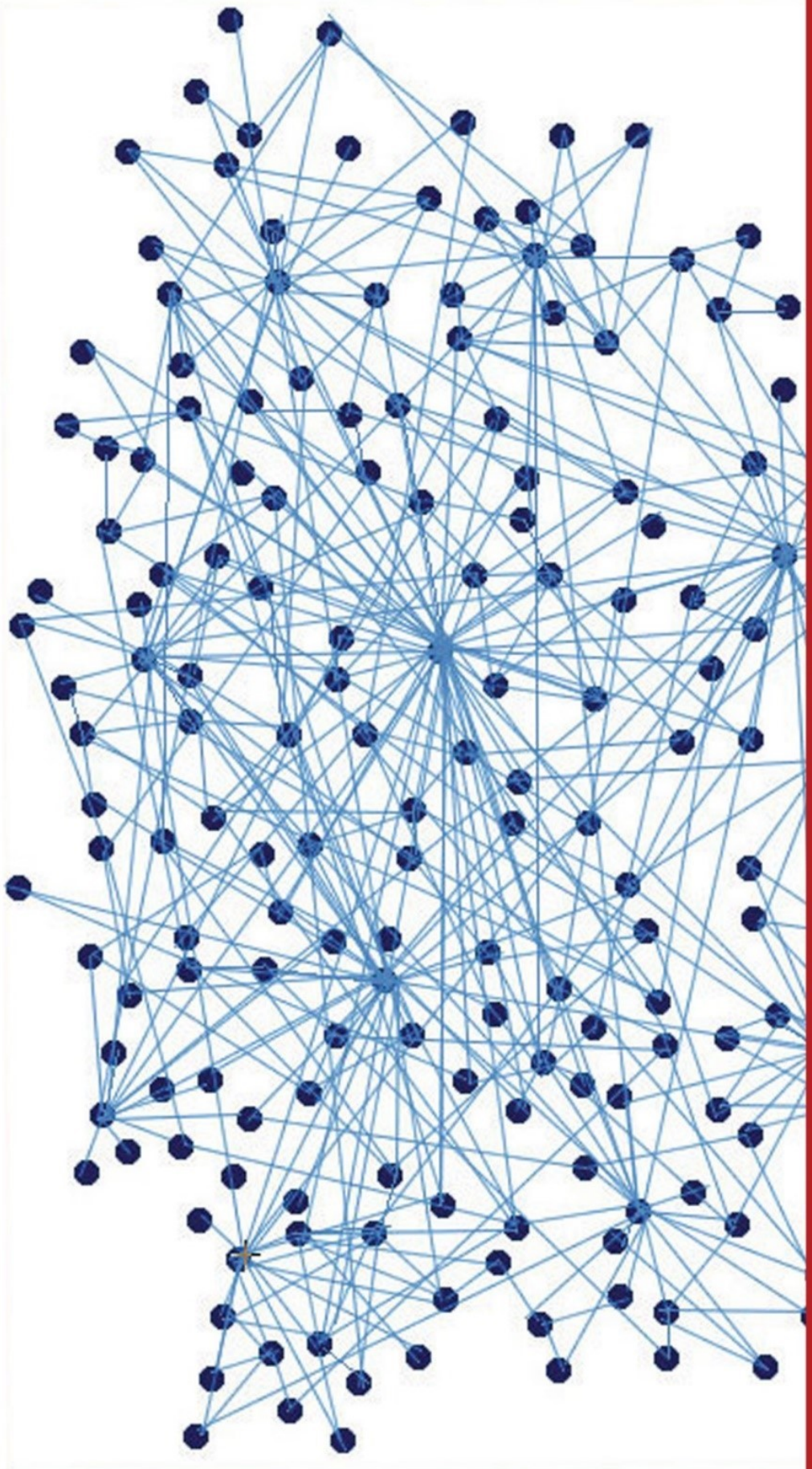
- G. A. M. Trimarchi "Commento sub art. 2482 bis c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 872-890.
- G. Miceli "Commento sub art. 2482 ter c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 893-90.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI DEBITO 3

1.1 LA CIRCOLAZIONE DEI TITOLI DI DEBITO SUCCESSIVAMENTE ALLA SOTTOSCRIZIONE 3
1.2 IL CASO PARTICOLARE DEL TRASFERIMENTO DEI TITOLI AI SOCI 3
1.3 IL TRASFERIMENTO DEI TITOLI AD INVESTITORI NON PROFESSIONALI 4

2. LE TECNICHE DI TUTELA DELL'INVESTITORE PROFESSIONALE 6

2.1 L'ART. 2483, COMMA 2° C.C. 6
2.2 IL DIVIETO DI CESSIONE 6
2.3 LA DEROGABILITÀ DELLA GARANZIA LEGALE 7

3. PROFILI DI RESPONSABILITÀ 8

3.1 CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ EMITTENTE 8
3.2 CARATTERISTICHE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'INVESTITORE PROFESSIONALE 8
3.3 CONSEGUENZE RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI DI DEBITO DA PARTE DEI SOCI 9
3.4 CONSEGUENZE RELATIVE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLI DI DEBITO DA PARTE DI INVESTITORI NON PROFESSIONALI 10

BIBLIOGRAFIA 11

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. La circolazione dei titoli di debito

1.1 La circolazione dei titoli di debito successivamente alla sottoscrizione

In caso di successiva circolazione dei titoli di debito il soggetto che li trasferisca risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società emittente.

Quanto riferito riguarda, è bene precisarlo, la circolazione successiva alla prima sottoscrizione in merito alla quale non pare sussistere alcuna specifica limitazione atteso che, fermo restando il predetto regime di responsabilità in capo al cedente, il silenzio normativo sul punto pare significare che i titoli di debito, dopo la prima sottoscrizione ad opera di investitori professionali, possano circolare senza particolari problemi.

La dottrina si interroga, come sarà chiarito in seguito, sulla sorte di titoli di debito sottoscritti, sul mercato primario (per la prima volta dopo l'emissione), da soggetti che non possano essere qualificati come investitori professionali.

Sul mercato secondario i titoli di debito possono essere ceduti, quindi, ad altri investitori professionali, ai soci oppure ad investitori non professionali.

Nel caso in cui vengano ceduti ai primi non si pongono particolari problemi in quanto i profili di rischio sottesi all'investimento non mutano, sostituendosi ad un gruppo creditorio "qualificato" altro gruppo con analogo grado di competenze ed esperienza.

Il secondo e il terzo caso meritano una specifica trattazione.

1.2 Il caso particolare del trasferimento dei titoli ai soci

Nell'ipotesi di trasferimento dei titoli di debito ai soci della società emittente, in linea di principio, non ci dovrebbero essere particolari esigenze di tutela da assecondare.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Questo soggetto, facendo parte dell'ente che ha deciso l'emissione dei predetti titoli, può dirsi informato sui rischi che assume divenendo creditore della società.

Il medesimo, infatti, anche nel caso in cui non rivesta il ruolo di amministratore nella società, è dotato di penetranti poteri di ispezione ed informazione che gli consentono di valutare la convenienza dell'operazione.

I soci, quindi, nel caso in cui acquistino tali titoli saranno esclusi dalla copertura della garanzia della solvenza atteso che l'investitore professionale che li venda loro cesserà di rispondere.

La circostanza per cui i soci acquistino titoli di debito apre un peculiare scenario in merito alla portata dell'art. 2467 c.c.

La dottrina tende ad estendere gli effetti scaturenti da quest'ultima disposizione, sussistendone i presupposti applicativi, anche ai finanziamenti mediati dall'emissione di titoli di debito onde evitare fenomeni di aggiramento della predetta norma imperativa.

Al riguardo, però, si ci interroga sul momento in cui occorra accertare la sussistenza dei presupposti operativi dell'art. 2467 c.c. non essendo chiaro se occorra riferire la valutazione al momento della sottoscrizione dei titoli di debito da parte degli investitori professionali oppure se rilevi l'acquisto dei medesimi attuato dai soci.

L'opinione migliore in dottrina è quella che àncora la valutazione all'acquisto effettuato dai soci atteso che solo in questo momento si potrebbero palesare, in presenza degli altri presupposti normativi, le istanze di tutela del ceto creditorio che l'art. 2467 c.c. mira a perseguire.

1.3 Il trasferimento dei titoli ad investitori non professionali

Questo è uno dei punti più sensibili della disciplina dei titoli di debito per cui il Legislatore ha sentito l'esigenza di regolamentarlo espressamente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tali soggetti non hanno, per definizione, le competenze e l'esperienza per valutare il grado di rischio sotteso all'investimento di tal che potrebbero finanziare la società e non ottenere il rimborso nel caso di sua insolvenza.

La loro posizione è tutelata dal peculiare regime di responsabilità del soggetto "che abbia trasferito" i titoli di debito.

In merito alla latitudine di tale concetto potrebbero avanzarsi tre ipotesi:

1. responsabilità esclusiva ed individuale del primo investitore professionale che sottoscrisse i titoli al tempo della loro emissione;
2. responsabilità solidale tra tutti gli investitori professionali che abbiano detenuto il titolo di dedito prima della cessione ad un investitore non professionale;
3. responsabilità esclusiva ed individuale dell'investitore professionale che, per ultimo, abbia detenuto il titolo e lo abbia, quindi, ceduto ad un investitore non professionale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Le tecniche di tutela dell'investitore professionale

2.1 L'art. 2483, comma 2° c.c.

Muovendo da quanto sopra osservato, quindi, pare possibile ritenere la responsabilità fissata dall'art. 2483, comma 2°, c.c. ascrivibile solo all'investitore professionale che per primo ebbe a sottoscrivere i titoli di debito posto che tale soggetto dà il via al rapporto di finanziamento ed è quello posto nella migliore posizione per effettuare la valutazione afferente al rischio della medesima.

Bisogna allora capire se esistano dei meccanismi convenzionali idonei a limitare o escludere la responsabilità in commento.

La dottrina ha individuato le modalità che seguono.

2.2 Il divieto di cessione

Al fine di escludere/limitare la predetta responsabilità si potrebbe immaginare di porre convenzionalmente un divieto di circolazione dei titoli di debito.

Tale soluzione, percorribile dal punto di vista giuridico, non sembra economicamente plausibile ove sia assoluta, posto che vincola il primo sottoscrittore professionale ad essere creditore della società sino ad estinzione del rapporto creditizio assumendo su di sé il rischio dell'insolvenza dell'ente.

La medesima, invece, parrebbe maggiormente praticabile nel caso in cui fosse relativa, ossia limitasse la possibilità di cedere i titoli di debito solo ad altri investitori professionali, evitando, per un verso, alterazioni sotto il profilo del regime di responsabilità per l'insolvenza senza, per altro verso, limitare le facoltà di disinvestimento del primo sottoscrittore.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.3 La derogabilità della garanzia legale

Al fine di escludere/limitare la predetta responsabilità si potrebbe, inoltre, immaginare di esentare da responsabilità il primo investitore professionale in caso di successiva cessione del titolo di debito sottoscritto.

Una clausola di esenzione totale dalla responsabilità sarebbe, però, contraria alla legge e, come tale, nulla.

Sarebbe, per converso, ammissibile una clausola che escludesse tale responsabilità nel caso di successiva cessione ad investitori professionali (i quali assumerebbero in proprio tale responsabilità per le successive cessioni), rimanendo, però, ferma quella scaturente dal trasferimento dei medesimi ad investitori non professionali.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Profili di responsabilità

3.1 Caratteristiche della responsabilità della società emittente

Nella vicenda in esame, non bisogna dimenticare, la responsabilità, in primo luogo, si incentra sulla società nel caso in cui, dopo l'emissione di titoli di debito, non riesca a soddisfare la richiesta di rimborso proveniente dai creditori - sottoscrittori.

Questi ultimi potranno chiedere l'ammissione al passivo della società, ma, verosimilmente, otterrano solo una parziale soddisfazione.

In questa circostanza si radica la necessita di prevedere, accanto alla responsabilità dell'ente divenuto insolvente, un regime di responsabilità anche per l'investitore professionale che abbia sottoscritto titoli di debito e poi abbia collocato i medesimi nel mercato secondario a soggetti che investitori professionali non sono.

La responsabilità dell'emittente e quella del sottoscrittore professionale sono solidali.

3.2 Caratteristiche della responsabilità dell'investitore professionale

Il dato normativo di riferimento, per come formulato, ha fatto osservare alla dottrina che il regime di responsabilità che connota la figura del sottoscrittore professionale, per il caso di futura circolazione dei titoli di debito, ha caratterizzazione oggettiva.

Il che val quanto dire che:

- non sussiste alcun legame tra il dissesto finanziario dell'ente e l'insorgere di tale regime di responsabilità;
- non rileva l'elemento soggettivo in capo all'investitore professionale non potendosi valutare il grado di consapevolezza che lo stesso aveva in ordine alla situazione della società di cui si determinò a sottoscrivere i titoli di debito.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La legge afferma, inoltre, che l'investitore professionale garantisce la "solvenza" della società.

La dottrina si interroga in merito alla latitudine di tale concetto non essendo chiaro se il Legislatore, impiegandolo, abbia voluto riferirsi alla sua nozione tecnica oppure abbia voluto evocare una situazione in cui la società non adempia alla propria obbligazione di rimborso pur potendolo fare.

L'opinione che pare essere, allo stato, maggioritaria in dottrina è nel secondo senso ricordato.

L'ultima questione da analizzare in materia attiene alla possibilità di estendere alla garanzia dell'investitore professionale il disposto dell'art. 1267, comma 1°, c.c. dettato in tema di cessione del credito.

La diversa strutturazione della normativa di riferimento e la divergenza della fonte dell'obbligazione di garanzia rendono ardua tale attività esegetica.

Più percorribile, invece, pare la via che conduce all'applicazione analogica dell'art. 1267, comma 2°, c.c. nel caso in cui il creditore garantito non cooperi con il garante al fine della corretta attuazione del rapporto obbligatorio originario.

3.3 Conseguenze relative alla sottoscrizione dei titoli di debito da parte dei soci

L'art. 2483 c.c., in maniera inequivoca, prevede che la sottoscrizione dei titoli di debito emessi dalla società siano sottoscrivibili sono da investitori professionali.

Nel caso in cui, in spregio a siffatto obbligo, provvedano a sottoscrivere i medesimi i soci la dottrina evoca la categoria concettuale della nullità atteso che l'operazione di finanziamento verrebbe così a concludersi contra legem.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

L'erogazione di denaro nei confronti della società, tuttavia, potrebbe conservare validità, in omaggio al principio generale di conservazione del contratto, nell'ipotesi in cui si riqualificasse come spontaneo "finanziamento soci".

3.4 Conseguenze relative alla sottoscrizione dei titoli di debito da parte di investitori non professionali

Ad analoga considerazione giunge la dottrina nel caso in cui, in spregio a siffatto obbligo, provvedano a sottoscrivere i medesimi investitori non professionali atteso che l'operazione di finanziamento, anche in questo caso, verrebbe a concludersi contra legem.

La declaratoria di nullità in esame:

- impone obblighi restitutori alla società, aventi ad oggetto le somme sborsate, verso i sottoscrittori;
- impone a questi ultimi di restituire i titoli di debito ottenuti alla società la quale provvederà ad annullarli.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

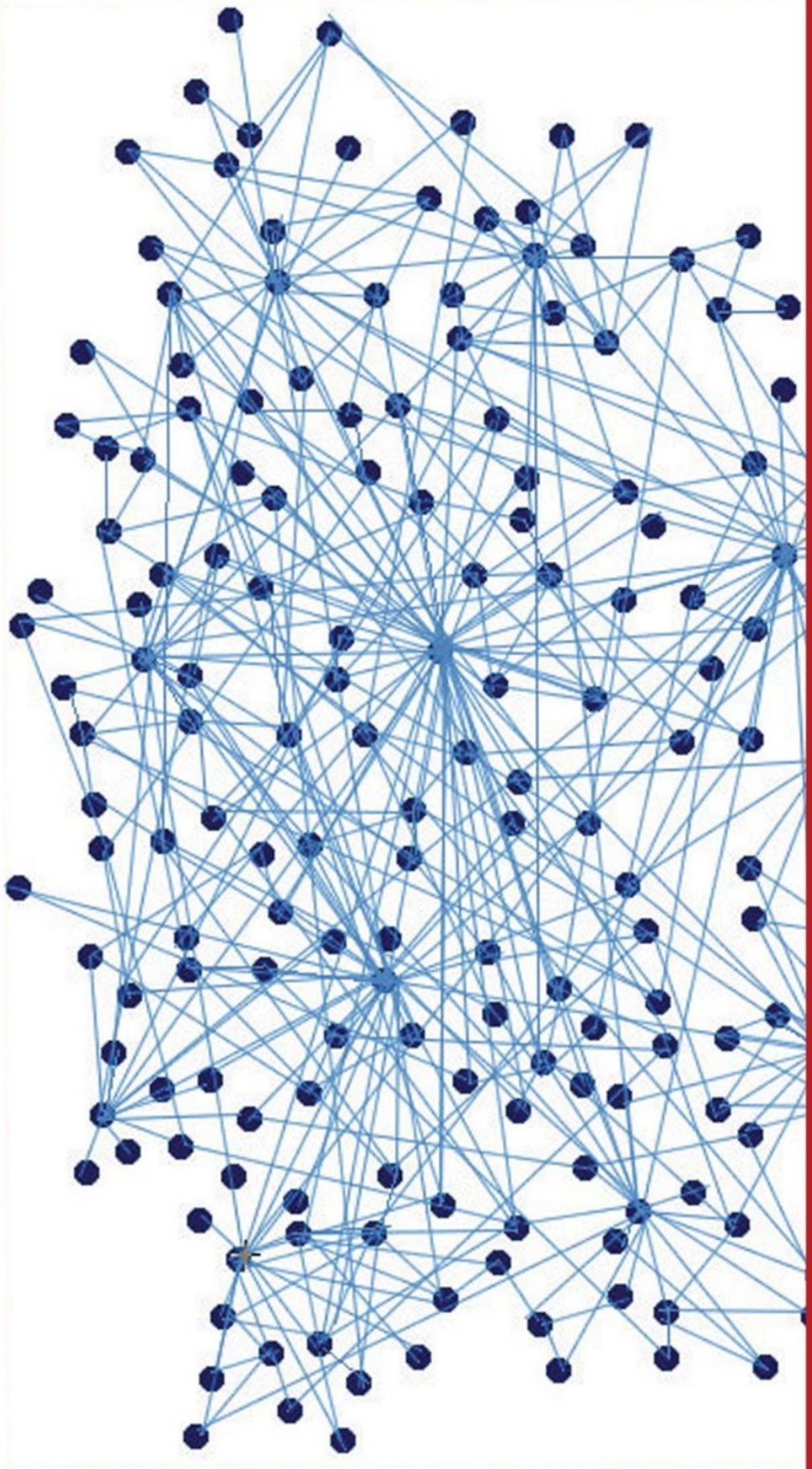
- V. Sangiovanni "Commento sub art. 2483 c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 917-930.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA E A CAPITALE RIDOTTO: EVOLUZIONE NORMATIVA 3

1.1 L'EVOLUZIONE NORMATIVA: L'ORIGINARIA VERSIONE DELLA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA E LA SOCIETÀ A CAPITALE RIDOTTO 3
1.2 LE RAGIONI DELL'INTRODUZIONE DEI NUOVI SOTTOTIPI 6
1.3 LE CARATTERISTICHE DELLA S.R.L.S. 7
1.4 LA S.R.L.S. COME SOTTOTIPO DELLA S.R.L. 7

2. LA COSTITUZIONE DELLA S.R.L.S 8

2.1 MODALITÀ DI COSTITUZIONE. IL MODELLO DI ATTO COSTITUTIVO E LO STATUTO STANDARD 8
2.2 L'ESENZIONE DAI COSTI DI COSTITUZIONE 9
2.3 IL REGIME PUBBLICITARIO 9
2.4 L'IMMODIFICABILITÀ DEL MODELLO STANDARD 10

3. I SOCI NELLA S.R.L.S., LE LORO DECISIONI, PROFILI DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ 11

3.1 I SOCI SOLTANTO PERSONE FISICHE 11
3.2 DIVIETO DI TRASFERIMENTO A PERSONE GIURIDICHE 11
3.3 IL PUNTO 8 DEL MODELLO STANDARD 12
3.4 L'ASSEMBLEA DEI SOCI 12
3.5 I SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE CONSENTITI ALLA LUCE DEL MODELLO STANDARD 13
3.6 LA RAPPRESENTANZA 13

BIBLIOGRAFIA 14

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Società a responsabilità limitata semplificata e a capitale ridotto: evoluzione normativa

1.1 L'evoluzione normativa: l'originaria versione della società a responsabilità limitata semplificata e la società a capitale ridotto

L'attuale modello di s.r.l.s. deriva dalla fusione concettuale tra il sottotipo originario della società semplificata e quello della società a capitale ridotto.

La dottrina, infatti, rinviene nel dettato dell'art. 2463 bis c.c. tratti tipologici di entrambe i predetti modelli societari.

In merito, a fini di chiarezza è bene distinguere:

- La "**società a responsabilità limitata semplificata**".

Nella sua originaria configurazione, risalente al D.L. 24 gennaio 2012 n. 1, poteva essere costituita da persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età mediante scrittura privata la quale doveva indicare, fra l'altro, il capitale minimo di un euro, da conferirsi in denaro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.

Si prevedeva che laddove il socio perdesse il requisito anagrafico egli venisse escluso di diritto salvo che l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori non deliberasse la trasformazione della società; allo stesso modo la perdita, da parte di tutti i soci, del requisito anagrafico era causa di scioglimento della società.

La completa attuazione della previsione normativa era, comunque, collegata ad un decreto ministeriale che doveva essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che avrebbe "tipizzato lo statuto standard della società" e individuato "i criteri di accertamento delle qualità soggettive dei soci".

Per quanto non espressamente previsto nell'art. 2463 bis c.c., la norma rinviava, nei limiti della compatibilità, alla disciplina delle s.r.l.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In sede di conversione del D.L. 1/2012, ad opera della L. 24 marzo 2012, n. 27, la disciplina della società a responsabilità limitata semplificata venne pressoché integralmente riscritta, con la previsione della necessità della forma pubblica per l'atto costitutivo, da redigersi in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro sessanta giorni dalla legge di conversione.

In questa "seconda versione" della s.r.l.s. permane il presupposto indefettibile che i soci non abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione; il requisito di età rileva anche ai fini della cessione delle quote, essendo prevista espressamente la nullità del trasferimento della partecipazione a soggetti che ne siano privi.

Gli amministratori devono essere scelti fra i soci.

L'ammontare del capitale sociale deve essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto per la s.r.l., e deve esser sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione.

Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo.

Vengono, inoltre, previste la non debenza degli onorari notarili ed altre agevolazioni

Inoltre, si prevede che «il Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».

Anche in questa veste la completa attuazione della previsione normativa era rinviata alla definizione del modello standard da parte del Decreto Ministeriale.

- La "**società a responsabilità limitata a capitale ridotto**".

Nell'ambito delle s.r.l. che derogano al requisito del capitale minino di 10.000 euro, con l'obiettivo di estendere tale possibilità anche ad altri soggetti, alla disciplina della s.r.l.s. se ne affianca, nel giugno 2012, un'altra.

L'art. 44 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", introduce nel nostro ordinamento la società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Solo che, anziché introdurre modifiche alla disciplina della società a responsabilità limitata semplificata, il Legislatore preferisce intervenire al di fuori del codice civile, prevedendo uno strumento che si affianca a quello contemplato dall'art. 2463 bis c.c. che pure è evocato, sin dall' incipit della nuova norma.

Che si trattasse di una disciplina diversa emergeva dalla previsione per cui restava " Fermo quanto previsto dall'articolo 2463 bis ".

Disciplina diversa e con destinatari diversi, almeno sino alla conversione del decreto: la società a responsabilità limitata semplificata era riservata a soggetti persone fisiche che non avessero compiuto i 35 anni di età alla data della sua costituzione; laddove la società a responsabilità limitata a capitale ridotto era invece riservata, nel testo originario, a persone fisiche che avessero compiuto i trentacinque anni di età alla data della costituzione, sebbene tale requisito anagrafico non fosse ribadito in alcun modo per le vicende circolatorie.

In sede di conversione, con la legge 7 agosto 2012, n. 134, venne poi introdotta la previsione per cui "al fine di favorire l'accesso al credito dei giovani imprenditori, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un accordo con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto" (art. 44, comma 4 bis).

Disposizione che, secondo l'interpretazione data dal Ministero dello Sviluppo Economico del 30 agosto 2012, consentiva di ritenere possibile il ricorso alla società a capitale ridotto anche per le persone fisiche infra-trentacinquenni.

Quanto all'atto costitutivo, l'art. 44 prevedeva il ricorso all'atto pubblico, senza tuttavia riferirsi a un modello standard tipizzato, che invece connota la società a responsabilità limitata semplificata, pur richiamando di quest'ultima alcuni elementi contenutistici, e cioè gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463- bis.

In sostanza, della società a responsabilità limitata semplificata, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto mutuava, come elemento qualificante, la regola per cui il capitale deve

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

essere pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463 come capitale minimo per una s.r.l. " ordinaria "; nonché quella per cui il conferimento deve farsi necessariamente in denaro ed essere versato all'organo amministrativo (e non alla banca come per la s.r.l. " ordinaria ").

Ma, a differenza della società a responsabilità limitata semplificata, gli amministratori non dovevano essere necessariamente soci e potevano essere scelti, quindi, tra soggetti estranei alla società.

Non era, invece, previsto alcun richiamo alla disciplina dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del D.L. 1/2012 e, quindi, doveva escludersi che per le società a responsabilità limitata a capitale ridotto "l 'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili".

Né era previsto che il Consiglio nazionale del notariato avesse uno specifico compito di vigilanza sulla corretta e tempestiva applicazione della nuova disciplina.

1.2 Le ragioni dell'introduzione dei nuovi sottotipi

Sono ben note le ragioni addotte a giustificazione dell'intervento normativo collegate:

- alla necessità di consentire all'Italia di risalire dal 77° posto in cui si collocava all'interno dell'annuale rapporto della Banca Mondiale "Doing Business";
- alla volontà di incentivare il rinnovamento all'interno della imprenditoriale italiana consentendo ai giovani di avvicinarsi, senza grandi investimenti, al mondo degli affari;
- al desiderio di abbattere i costi di start up onde incentivare l'attività imprenditoriale giovanile;
- alla creazione di una piattaforma normativa sulla quale ricavare la disciplina delle start up innovative e degli incubatori di imprese certificati;
- alla volontà di svincolare, per le ragioni sopra evidenziate, il regime di responsabilità limitata dalla capitalizzazione, entro certi limiti, dell'ente.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.3 Le caratteristiche della s.r.l.s.

L'art. 2463 bis c.c., nella sua ultima versione, si connota, differenziando il modello in commento dalla s.r.l. "tradizionale", per queste caratteristiche fondamentali:

1. i soci devono essere tutte persone fisiche;
2. l'atto costitutivo deve uniformarsi, senza possibilità di deroghe o modifiche, al contenuto del modello Ministeriale;
3. per quanto nel medesimo non contemplato si applicano le comuni regole previste per le s.r.l.;
4. capitale sociale di ammontare compreso tra 1 e 9.999 Euro;
5. abbattimento dei costi di costituzione;
6. denominazione di s.r.l. "semplificata".

Non costituiscono, invece, più elementi caratterizzanti ed esclusivi della s.r.l. semplificata né l'importo del capitale sociale (inferiore a 10.000 euro, ma almeno pari a 1 euro), né il regime dei conferimenti, i quali sono oggi previsti anche per le s.r.l. diverse da quelle semplificate per effetto delle modifiche apportate agli artt. 2463 e 2464 c.c.

1.4 La s.r.l.s. come sottotipo della s.r.l.

In dottrina è sorto il dubbio se tale assetto societario fosse oppure no idoneo a delineare un tipo autonomo di società di capitali.

La dottrina maggioritaria, benché non incontrastata, ha riscontrato l'inidoneità di siffatto assetto ad assurgere a tipo societario autonomo, riconducendo il medesimo entro l'alveo della s.r.l. e qualificandolo come "sottotipo" della s.r.l. tradizionale.

Le peculiarità di disciplina, lungi dell'emancipare tale ipotesi dallo schema societario della s.r.l., si giustificano sulla scorta della ratio che è sottesa alla sua introduzione nell'ordinamento ossia quella di agevolare l'imprenditoria giovanile.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La costituzione della s.r.l.s

2.1 Modalità di costituzione. Il modello di atto costitutivo e lo statuto standard

La disciplina della s.r.l.s. è contenuta nell'art. 2463 bis c.c., il quale stabilisce che quando i soci sono tutti persone fisiche, essi possono costituire s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 euro, ma superiore a 1, con contratto o atto unilaterale redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministro della Giustizia.

Il modello standard tipizzato, infatti, indica:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;
2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro previsto all'articolo 2463, comma 2°, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all'organo amministrativo;
4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell'articolo 2463;
5) luogo e data di sottoscrizione;
6) gli amministratori.

Mancano, tuttavia, molte precisazioni utili al fine di una compiuta regolamentazione dell'ente come, per esempio, la previsione della durata della società o le regole afferenti la decorrenza dell'esercizio sociale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.2 L'esenzione dai costi di costituzione

In presenza dei presupposti richiesti dall'art. 2463 bis c.c. (soci persone fisiche, capitale inferiore a 10.000 euro, atto costitutivo redatto mediante l'utilizzo di un modello standard tipizzato con regolamento ministeriale e denominazione comprendente l'aggettivo "semplificata"), il 3° comma dell'art. 3 del D.L. 1/2012 prevede che "l'atto costitutivo e l'iscrizione nel Registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili".

Sia l'esenzione da diritto di bollo e di segreteria sia la gratuità dell'intervento del notaio corrispondono alla finalità di abbattere i costi di avvio delle nuove imprese semplificate; e, con riferimento alla seconda, la scelta presupponeva necessariamente di ridurre quanto più possibile la prestazione professionale del notaio al solo controllo di legalità, appunto attraverso il ricorso ad un modulo.

2.3 Il regime pubblicitario

L'art. 2463 bis, comma 3°, c.c. prevede che "La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico".

La ratio della disposizione è quella di rendere noto ai terzi quali siano i tratti tipologici della società con la quale entreranno in contatto.

Tale regime pubblicitario coadiuva e non sostituisce quello ordinario di tal che dovranno, comunque, essere indicati anche il numero di iscrizione nel Registro delle imprese l'eventuale stato di liquidazione e l'eventuale presenza del socio unico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.4 L'immodificabilità del modello standard

Una delle questioni più dibattute in materia ha riguardato la possibilità di integrare lo statuto standard tipizzato, il cui contenuto, definito nella tabella allegata al D.M. 138/2012, è stato oggetto di critiche da parte della dottrina a causa delle lacune che lo connotano.

La questione va oggi esaminata tanto alla luce della espressa previsione della sua inderogabilità, introdotta dal D.L. 76/2013, quanto al delinearsi, attraverso la stratificazione delle norme, di una disciplina complessiva delle nuove s.r.l. che inizia ad avere una propria organicità.

L'introduzione da parte del D.L. 76/2013 della previsione di cui al comma 3 dell'art. 2463 bis , c.c., secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, sembra escludere che l'atto costitutivo della s.r.l. semplificata possa avere un contenuto diverso da quello stabilito dall'art. 2463 bis , comma 2°, c.c. al quale deve conformarsi il modello standard di cui al regolamento ministeriale.

Si potrebbe, invero, ipotizzare una diversa interpretazione, in base alla quale la previsione dell'inderogabilità riguardasse le sole clausole del modello tipizzato, la cui formulazione non potrebbe essere modificata, ma non il modello di atto costitutivo in sé, come se fosse, invece, possibile l'inserimento di pattuizioni ulteriori, aventi ad oggetto la regolamentazione di aspetti non disciplinati dalle clausole standard.

Ma tale considerazione, fondata sul piano testuale, pare prestare il fianco a critiche sul piano sistematico di tal che la dottrina maggioritaria non apre dubitare che la norma in commento debba esser interpretata in senso restrittivo, in quanto norma eccezionale, non estensibile a fattispecie diverse rispetto a quella alla quale essa, in maniera espressa, si riferisce.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. I soci nella s.r.l.s., le loro decisioni, profili di amministrazione e rappresentanza della società

3.1 I soci soltanto persone fisiche

Elemento essenziale e caratterizzante tale configurazione societaria è che la base sociale può essere solo costituita da persone fisiche, non rilevando più, a differenza di quanto accadeva nel passato, che età anagrafica abbiano le medesime.

Da ciò consegue che non possono prendere parte a tale società le persone giuridiche e gli enti posto che la finalità della norma è quella di consentire ai privati di fruire di uno strumento agile ed economico per svolgere attività di impresa e non per fare risparmiare soggetti già organizzati a tal fine.

3.2 Divieto di trasferimento a persone giuridiche

Stante quanto osservato sopra la risposta al quesito postosi in dottrina non può che essere negativa onde evitare che una interpretazione strettamente letterale del dato positivo possa consentire il sostanziale aggiramento delle finalità che lo stesso mira a conseguire.

L'eventuale trasferimento a persona non fisica della partecipazione societaria deve ritenersi, dunque, privo di efficacia in àmbito societario.

Il divieto, è bene precisarlo, si estende a tutte le modalità con le quali una quota possa entrare nella titolarità una persona giuridica o di un ente come le operazioni sul capitale o le operazioni straordinarie.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.3 Il punto 8 del modello standard

L'art. 8 del modello standard di atto costitutivo e statuto statuisce che "L'assemblea dei soci, ove sia richiesta deliberazione assembleare per la decisione dei soci, è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione".

La disposizione, allorché letta in combinato disposto con il principio di inderogabilità del contenuto di tale modello, esprime quattro significati normativi ossia:

- il sistema previsto per l'adozione delle decisioni dei soci è quello assembleare;
- ove tale sistema non sia richiesto per l'assunzione della decisione dei soci, in quanto tali, possono esprimersi;
- il sistema assembleare non può essere oggetto di deroga convenzionale;
- l'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione.

Per il resto troveranno applicazione le regole che informano, nel modello s.r.l. "tradizionale", la materia della decisione dei soci.

3.4 L'assemblea dei soci

Sulla scorta di quanto sopra rilevato può ritenersi che:

- l'assemblea debba essere convocata ex art. 2479 bis, comma 1°, c.c.;
- essa si riunisca presso la sede sociale;
- i quorum assembleari siano solo quelli previsti dall'art. 2479 bis, comma 3°, c.c.;
- ai soci competono solo le decisioni di cui all'art. 2479, comma 2°, c.c.;
- non trovi applicazione l'art. 2479, comma 2°, n. 5 c.c.;
- trovino applicazione i commi 1° e 4° dell'art. 2479 c.c.;
- sia ammessa la possibilità per i soci di farsi rappresentare in assemblea;
- sia consentito l'assetto totalitario dell'adunanza.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.5 I sistemi di amministrazione consentiti alla luce del modello standard

L'art. 5 del modello standard di atto costitutivo e statuto statuisce che "l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci scelti con decisione dei soci" e dovrà, ai sensi dell'art. 6 dello stesso, essere da loro accettato l'incarico.

Il divieto di integrazione di tale modello comporta che non possano esser adottate clausole idonee a predisporre un sistema di amministrazione diverso da quello fissato dalla legge ossia quello a struttura unisoggettiva ovvero quello a struttura plusisoggettiva necessariamente organizzato nella forma collegiale.

3.6 La rappresentanza

L'art. 7 del modello standard di atto costitutivo e statuto prevede, inoltre, che "all'organo di amministrazione spetta la rappresentanza generale della società".

La disposizione presenta criticità nel caso in cui l'amministrazione spetti ad un consiglio all'uopo nominato in quanto non è chiaro se il potere rappresentativo spetti all'organo nel suo insieme oppure, come sembra preferibile, disgiuntamente ad ogni amministratore.

Dubbia è, inoltre, la possibilità di concentrare il potere rappresentativo in capo ad amministratori delegati oppure al Presidente del consiglio di amministrazione.

La dottrina maggioritaria, argomentando dall'art. 2475 bis, comma 2°, c.c., ritiene ammissibile tale possibilità specie in caso di disposizione contenuta nella nomina assembleare.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

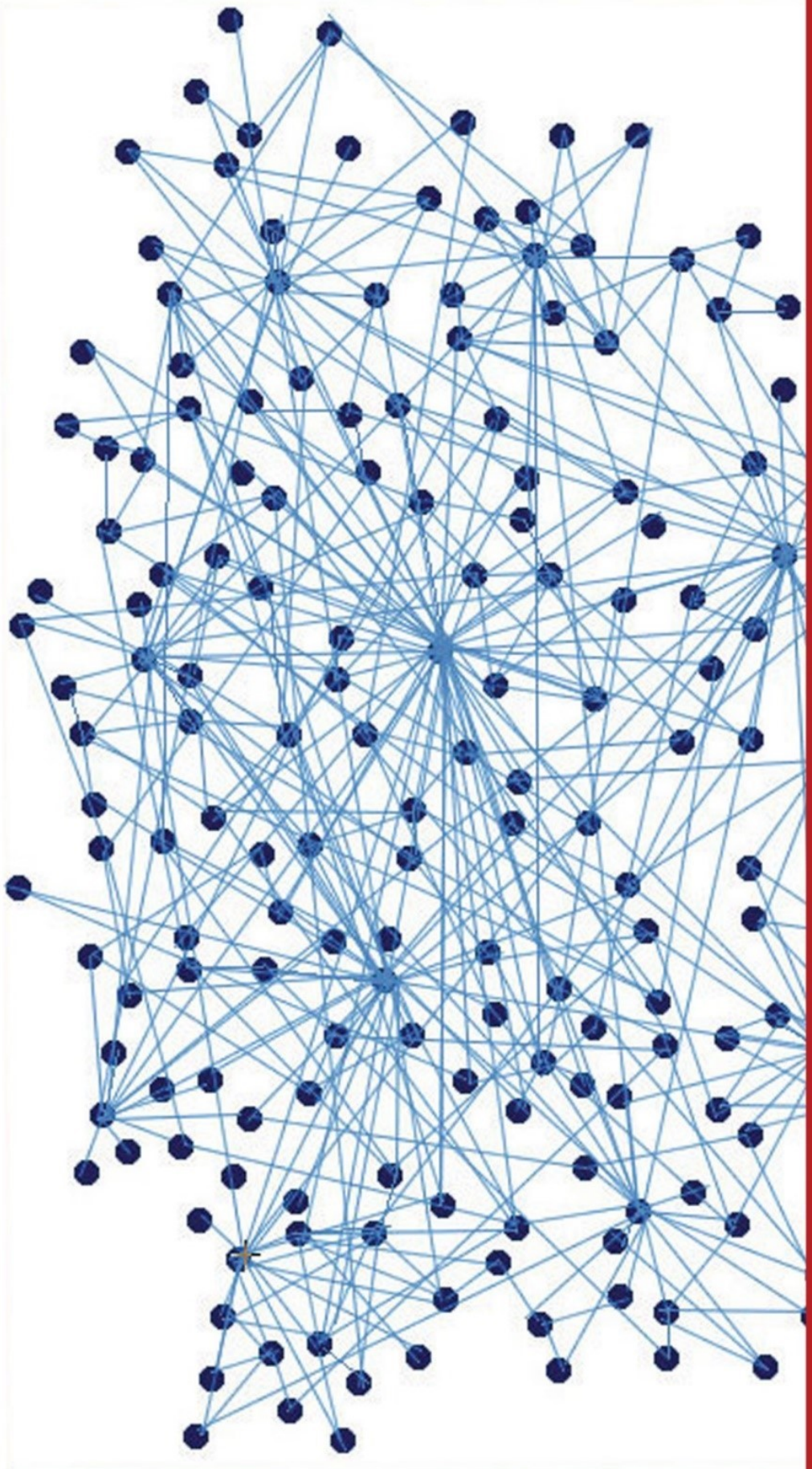
- Mambriani A. "Commento sub art. 2463 bis c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 123-158.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. I CONFERIMENTI ED IL CAPITALE SOCIALE 3

1.1 I CONFERIMENTI 3
1.2 LIBERAZIONE INTEGRALE DEI CONFERIMENTI E VERSAMENTO 3
1.3 FUNZIONI DEL CAPITALE SOCIALE NELLA S.R.L.S. 4

2. QUESTIONI DI APPLICABILITÀ ALLA S.R.L.S. DEGLI ART. 2480, 2481, COMMA 2°, 2481 BIS E TER C.C. 5

2.1 L'AUMENTO DEL CAPITALE A PAGAMENTO 5
2.2 INAPPLICABILITÀ ALLA S.R.L.S. DELL'ART. 2482 C.C. 6
2.3 L'APPLICABILITÀ DELLE NORME SULLA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE 8

3. PASSAGGIO DA S.R.L.S. A S.R.L. E VICEVERSA 10

3.1 IL PASSAGGIO DA S.R.L.S. A S.R.L.: CONSEGUENZE 10
3.2 IL PASSAGGIO DA S.R.L. ORDINARIA A S.R.L.S. 10
3.3 IL PASSAGGIO DA S.R.L. A CAPITALE INFERIORE A 10.00 EURO A S.R.L.S. 11

BIBLIOGRAFIA 12

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. I conferimenti ed il capitale sociale

1.1 I conferimenti

Dal quadro normativo di riferimento si ricava che, nella fase genetica dell'ente, i conferimenti devono avere le seguenti caratteristiche:

- devono avere per oggetto esclusivamente denaro → tale circostanza si giustifica alla luce dell'esiguità del capitale sociale in questa declinazione societaria e della esigenza di semplificazione perseguita dal Legislatore atteso che i conferimenti diversi dal denaro richiedono procedure di valutazione lunghe e dispendiose;
- devono essere interamente liberati, come meglio sarà precisato, al momento della sottoscrizione;
- devono essere versati a mani degli amministratori → tale formalità è stata prevista, sin dal 2013, anche per la s.r.l. ordinaria allo scopo di facilitare le procedure di costituzione sulla scorta del presupposto, spesso riscontrato in concreto, dell'esiguità della somma conferita la quale, ad ogni modo, deve rispettare la disciplina antiriciclaggio.

1.2 Liberazione integrale dei conferimenti e versamento

I conferimenti devono essere integralmente liberati al momento della sottoscrizione.

Anche tale circostanza è connessa alla supposta esiguità del capitale sociale nel caso in esame, ma mal si raccorda con l'art. 2464, comma 4°, c.c. il quale, per la s.r.l. ordinaria, ammette il versamento, in sede costitutiva, del solo 25% del capitale sociale sottoscritto.

Tale rilievo scoraggia, dunque, la capitalizzazione iniziale della s.r.l.s. che difficilmente supererà la soglia dei 2.500 Euro.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.3 Funzioni del capitale sociale nella s.r.l.s.

Il capitale sociale nella s.r.l.s., benché, sotto il profilo quantitativo, possa essere irrilevante, è pur sempre:

- un capitale nominale → previsto nel minimo di 1 Euro;
- un dato fisso → essendo contemplato dall'atto costitutivo e potendo variare solo in esito ad apposita decisione dei soci.

La s.r.l.s., in altri termini, non è una società senza capitale minimo, ma con una dotazione di capitale che può essere esigua.

Tale circostanza determina tre ordini di considerazioni:

- il capitale nella s.r.l.s. non assolve ad una diretta funzione di garanzia nei riguardi dei creditori della società;
- il capitale sociale non pare poter svolgere, dato il suo ammontare, alla funzione produttiva che, al contrario, svolge in altri modelli capitalistici posto che il suo ammontare può essere di gran lunga inferiore alla cifra richiesta per la costituzione dell'ente. Ne deriva che per evitare lo stato di scioglimento immediato è bene dotare la società delle risorse minime per fare fronte alle spese di costituzione:

✓ fissando entro tale soglia il capitale sociale;

✓ imponendo il versamento, per intero, di un sovrapprezzo;

✓ facendo provvedere in prima persona i soci al pagamento delle spese in commento.

- permane, invece, la funzione organizzativa sottesa alla dotazione di capitale minima di tal che si possano estendere, nei limiti della compatibilità, le norme poste a tutela del capitale sociale nelle s.r.l. ordinarie come si avrà modo di precisare nel prosieguo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Questioni di applicabilità alla s.r.l.s. degli art. 2480, 2481, comma 2°, 2481 bis e ter c.c.

2.1 L'aumento del capitale a pagamento

A titolo di premessa occorre precisare che in ordine alle modalità attuative non risultano da segnalare variazioni rispetto alle regole che la informano nel modello ordinario di s.r.l. atteso che, anche in questo contesto, integra una modificazione dello statuto da adottare con le maggioranze previste dall'art. 2479 bis c.c. e non risulta delegabile all'organo amministrativo tramite una clausola statutaria idonea al "travaso" di competenze decisionali sul punto.

Sotto il profilo della disciplina, invece, occorre puntualizzare che le peculiarità di questo assetto organizzativo conducono a ritenere:

- inapplicabile la regola giusta la quale l'aumento del capitale sociale a pagamento può essere riservato a terzi posto che tale opzione necessita di apposita copertura statutaria;
- che sia possibile fissare un sovrapprezzo;
- che sia possibile prevedere che l'inoptato possa essere sottoscritto dai soci sottoscrittori o da terzi purché non persone giuridiche o enti;
- che, ad opinione della dottrina maggioritaria, il divieto di conferimenti in natura è ancorato alla fase genetica dell'ente e può essere superato lungo la vita del medesimo posto che tale limitazione risponde ad una esigenza di semplificazione e speditezza che non pare connotare le fasi successive a quella costitutiva della società;
- che i conferimenti in denaro conseguenti alla sottoscrizione di un aumento oneroso del capitale sociale debbano essere integralmente versati non potendosi applicare, l'art. 2481 bis, comma 4°, c.c.;
- che rimane preclusa, anche in questo assetto societario, la possibilità di effettuare il conferimento di opera e di servizi in sede di aumento del capitale sociale a pagamento;
- che l'operazione possa assumere la veste di aumento scindibile o inscindibile;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- che, quale che sia la su concreta modalità di attuazione, non si possa innalzare il capitale sociale oltra la soglia dei 10.000 Euro, dovendosi, in caso contrario, discorrere di conversione automatica in s.r.l. ordinaria con tutte le conseguenze disciplinari del caso.

2.2 Inapplicabilità alla s.r.l.s. dell'art. 2482 c.c.

La normativa in commento, benché ad una lettura epidermica possa stimolare contrarie sensazioni, sembra orientata verso un regime di tendenziale inapplicabilità dell'art. 2482 c.c. alla s.r.l.s. posto che, come si palesa analizzando la disciplina della riserva di accumulo, parte delle sostanze patrimoniali, in concomitanza con alcune altre circostanze, risultano vincolate all'espletamento dell'attività sociale sino al raggiungimento della soglia di capitalizzazione di 10.000 Euro.

Tale scelta normativa, affinché non venga svuotata di significato, deve condurre, ad opinione di parte della dottrina, a negare che l'operazione di riduzione volontaria del capitale sociale sia compatibile con il fisiologico sviluppo della s.r.l.s. L'art. 2482, comma 1°, c.c., infatti, se applicato nel suo tenore letterale, esclude che le s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 Euro possano ridurre volontariamente il loro capitale, in quanto esso è sempre, per definizione, inferiore al limite previsto dal n. 4) del comma 2° dell'art. 2463 c.c., ossia è sempre inferiore a 10.000 Euro.

A opinione di altra parte della dottrina, però, è possibile formulare una diversa interpretazione ove si tenga presente che il riferimento all'importo di cui al "n. 4) dell'art. 2463 c.c." consiste in un riferimento all'importo minimo legale sancito per le s.r.l. ordinarie, ossia quelle disciplinate dal Legislatore prima delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del D. L. 76/2013, per le quali il minimo legale era pari a 10.000 Euro.

Differentemente, in seguito alle modifiche introdotte con la legge di conversione del D. L. 76/2013, per le società con capitale inferiore a 10.000 Euro, l'art. 2463, comma 4°, c.c. stabilisce espressamente che l'importo minimo legale del capitale è di 1 Euro.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Si può, dunque, ipotizzare che, poiché l'art. 2482 c.c. consente la riduzione volontaria del capitale fino ad una soglia almeno pari a quella del minimo legale e poiché il minimo legale delle s.r.l. è di 1 Euro, la disciplina di cui all'art. 2482 c.c. sarebbe applicabile nella misura in cui la riduzione abbia luogo non più entro il limite dei 10.000 Euro previsto dal n. 4) dell'art. 2463 c.c. - che costituiva il vecchio minimo legale per le società con capitale pari o superiore a tale limite - bensì entro il diverso limite di 1 Euro previsto dall'art. 2463 comma 4° c.c.

Tale conclusione sembra essere coerente con il nuovo sistema del capitale delle s.r.l. delineato dal Legislatore, in cui le società con capitale inferiore a 10.000 Euro si differenziano soltanto per essere soggette a due regole peculiari in tema di composizione del capitale sociale e formazione della riserva legale.

Con riferimento a quest'ultima il Legislatore non impone né un termine di scadenza entro il quale la società sia tenuta a raggiungere, tra capitale e riserva, l'ammontare di diecimila Euro, né l'obbligo di imputare a capitale l'ammontare della riserva legale una volta che questa abbia raggiunto la soglia prevista dalla legge.

Ciò significa che la società, pur avendo a disposizione consistenti mezzi patrimoniali, non ha l'obbligo di imputarli a capitale e che la stessa può continuare ad esistere senza limiti temporali con un capitale compreso tra 1 e 9.999 Euro.

Queste considerazioni sembrano costituire dei dati normativi dai quali appare possibile desumere che la nuova disciplina in tema di capitale minimo delle s.r.l., contenuta nei commi 4° e 5° dell'art. 2463 c.c., non si esaurisca con la fase costitutiva della società, ma possa riguardare anche vicende successive.

Pur dando conto dell'incertezza che deriva dal menzionato difetto di coordinamento e, quindi, dalla possibilità di diverse letture, laddove si accogliesse tale interpretazione, non sembrerebbe possibile negare ad una s.r.l. la facoltà di fissare liberamente il proprio capitale in un importo compreso tra 1 e 9.999 Euro non solo in sede di costituzione, ma anche successivamente alla costituzione, ricorrendo alla riduzione volontaria del capitale, purché essa avvenga nel rispetto delle cautele imposte dall'art. 2482 c.c. e, in particolare, nel rispetto del comma 2° della predetta

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

norma, il quale stabilisce che "la decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione".

2.3 L'applicabilità delle norme sulla riduzione del capitale per perdite

La dottrina, preso atto della applicabilità delle regole che attengono alla tutela del capitale sociale nella s.r.l. tradizionale alle s.r.l.s., non dubita che anche a queste ultime sia estendibile la portata degli artt. 2482 bis e ter c.c. benché occorra adeguare le conclusioni al fatto che il capitale sociale minino per tale configurazione societaria è di 1 Euro.

Al riguardo paiono potersi individuare, sinteticamente, due ipotesi:

- s.r.l.s. con capitale sociale superiore ad 1 Euro che, a causa di perdite rilevanti, veda la propria dotazione di capitale erosa senza però che si scenda la di sotto della soglia fissata dalla legge → in questo caso trova applicazione l'art. 2482 bis c.c. il quale prevede che "in caso di perdite superiori a un terzo del capitale, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. Se, poi, entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve esser convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate;
- s.r.l.s. con capitale sociale superiore ad 1Euro che, a causa di perdite rilevanti, veda la propria dotazione di capitale erosa oltre la soglia fissata dalla legge → in questo caso trova applicazione l'art. 2482 ter c.c. il quale stabilisce che "se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal n. 4) dell'art. 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

minimo (almeno ad 1 Euro). È fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società (il modello di approdo non potrà che essere un modello a vocazione personalistica)". Nel caso in cui, sussistendo le condizioni di cui sopra, i soci non adottino alcuna decisione alla società, trovandosi in stato di scioglimento, saranno applicabili le norme che governano tale fase.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Passaggio da s.r.l.s. a s.r.l. e viceversa

3.1 Il passaggio da s.r.l.s. a s.r.l.: conseguenze

Come in precedenza rilevato la s.r.l. semplificata appartiene al tipo sociale della s.r.l.

Da ciò consegue che il passaggio da s.r.l.s. a s.r.l. ordinaria:

- necessita, comportando una modifica dello statuto, di apposita decisione dei soci ai sensi dell'art. 2480 c.c. [1];
- non costituisce una trasformazione;
- non attribuisce, di conseguenza, ai soci che non abbiano preso parte alla decisione il diritto di recedere;
- deve essere accompagnata da una decisione di aumento del capitale sociale onde adeguare il medesimo al limite minimo fissato dalla legge per le s.r.l. ordinarie ossia 10.000 Euro.

3.2 Il passaggio da s.r.l. ordinaria a s.r.l.s.

Per ciò che concerne la trasformazione in "nuove s.r.l.", è discusso se anche la società a responsabilità limitata semplificata possa costituire punto d'approdo dell'operazione.

Parte della dottrina, muovendo dall'assenza di un divieto espresso e dalla praticabilità concreta dell'operazione, ha sostenuto la tesi favorevole in presenza di tutti i requisiti necessari affinché si possa discorrere di s.r.l.s.

Altra parte della dottrina, osservando che quella della semplificata è una disciplina che attiene alla fase costitutiva della società, ha sostenuto la tesi negativa precisando che tali regole non sarebbero replicabili rispetto ad un soggetto già esistente. Per la società semplificata, infatti, la

[1] Va in tale sede ribadito come le modifiche statutarie, ancorché riguardanti le s.r.l.s., siano al di fuori del perimetro di applicazione dell'art. 3, comma 3, del D. L. 1/2012 che prevede l'esenzione da diritti di bollo e di segreteria e la gratuità della prestazione notarile.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

funzione limitata all'avvio di una "nuova impresa" pare facilmente desumibile da una serie di indici normativi, compresa la riduzione dei costi, che ben si spiega con riguardo a tale fase, sì che laddove la variante s.r.l.s. funga da modello di approdo certamente l'operazione non godrà delle agevolazioni previste dal D.L. 1/2012 per la sola fase genetica.

3.3 Il passaggio da s.r.l. a capitale inferiore a 10.00 Euro a s.r.l.s.

Tale operazione, benché parte della dottrina ne sottolinei l'inopportunità connessa all'eccessiva esiguità del capitale sociale rispetto all'impatto che la stessa produrrebbe, anche in termini di costi, sullo svolgimento dell'attività di impresa, pare tecnicamente ammissibile, integrando una modifica statutaria retta dall'art. 2480 c.c., purché sussistano, per l'ente di risulta, tutti i requisiti affinché si possa discorrere di s.r.l.s. (non sarebbe, quindi, necessario, in questa ipotesi intervenire sull'ammontare del capitale sociale posto che la sua consistenza è congrua rispetto all'operazione divisata).

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

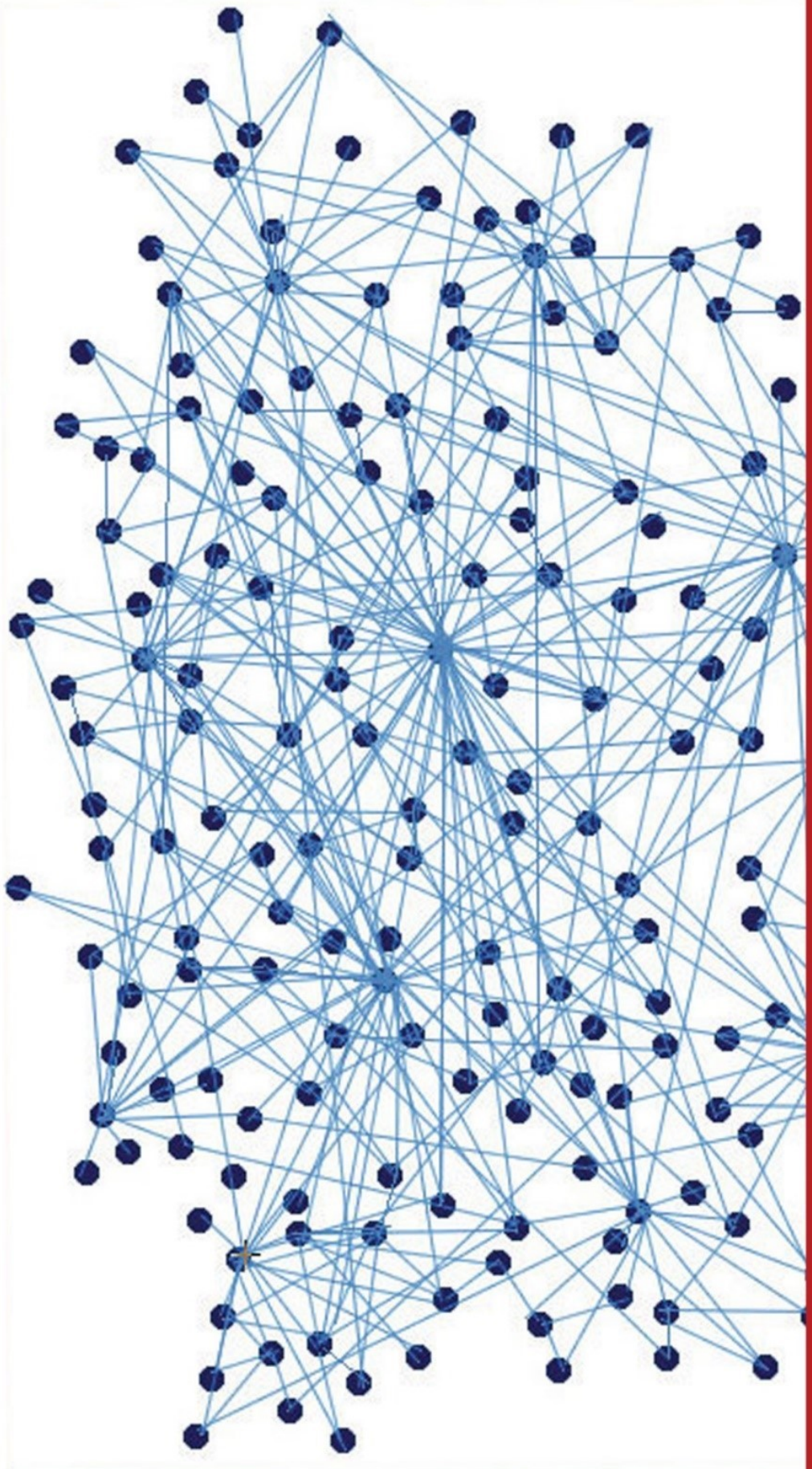
- Mambriani A. "Commento sub art. 2463 bis c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 123-158.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. LE S.R.L. CON CAPITALE INFERIORE A 10.000 EURO 3

2. LA RISERVA DI ACCUMULO NELLA S.R.L.S. E NELLA S.R.L. CON CAPITALE INFERIORE A 10.000 EURO 6

3. LE OPERAZIONI STRAORDINARIE NELLA S.R.L.S. E NELLA S.R.L. CON CAPITALE INFERIORE A 10.000 EURO 8

BIBLIOGRAFIA 11

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Le S.R.L. con capitale inferiore a 10.000 euro

Caratteristiche e natura della s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 Euro.

Detta configurazione del modello societario a responsabilità limitata, per come delineata dall'art. 2463, commi 4° e 5° c.c., si connota per **quattro elementi specializzanti** rispetto alle regole di governo delle s.r.l. ordinarie:

- ammontare del capitale sociale compreso tra 1 e 9.999 Euro;
- conferimenti soltanto in denaro;
- integrale versamento del conferimento;
- riserva di accumulo.

Ogni altro aspetto di disciplina, tanto sul versante genetico quanto su quello regolamentare, segue l'impronta data dal Legislatore al modello s.r.l. tradizionale atteso che tali regole sembrano connaturate alla configurazione in esame del tipo s.r.l.

Dal quadro normativo di riferimento emerge, con una certa nitidezza che l'assetto societario in commento non integra un sotto tipo del modello societario a responsabilità limitata, ma una delle sue possibili varianti selezionabili, a seconda delle esigenze imprenditoriali in campo, dai soci.

Ciò che distingue, pertanto, la configurazione tradizionale da quella a capitale inferiore a 10.000 Euro è solo il regime dei conferimenti, la capitalizzazione e la disciplina della riserva legale.

Disciplina e modalità dei conferimenti della s.r.l. con capitale inferiore a 10.000 Euro.

Il dato positivo in esame rende evidente che il riconoscimento ai soci della possibilità di allestire una struttura societaria con capitale così esiguo deve essere bilanciata da una serie di contromisure normative volte ad evitare che il capitale sociale smetta di assolvere la funzione che gli è propria in ogni struttura societaria capitalistica.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In questa logica si spiegano le misure che seguono:

- conferimenti, in sede costitutiva, solo in denaro → tale circostanza si spiega con la volontà del Legislatore di evitare l'eccessivo appesantimento procedurale, connesso ai conferimenti in natura, per importi di così lieve entità. La portata precettiva della norma in commento si risolve in un'eccezione al disposto dell'art. 2464,comma 2°, c.c. che, tuttavia, non frapporsi alla possibilità di effettuare, anche nella configurazione di s.r.l. in esame, "apporti di quasi capitale" in natura;
- immediata liberazione dei conferimenti sottoscritti → trova la propria ragione d'essere nell'esiguità del capitale sociale, ma mal si raccorda con la regola fissata dall'art. 2464, comma 4°, c.c., scoraggiando, dunque, l'utilizzo di tali regole tutte le volte in cui la capitalizzazione ecceda i 2.500 Euro atteso il diverso regime che informa la liberazione dei conferimenti nei due diversi allestimenti di società a responsabilità limitata;
- corresponsione dei medesimi a mani dell'organo amministrativo → il requisito, inserito dal Legislatore anche nel modello tradizionale in omaggio ad esigenze di speditezza e celerità della procedura costitutiva, non costituisce un tratto caratterizzante della configurazione societaria in esame, ma, in quest'àmbito, si giustifica meglio sulla scorta della tendenziale esiguità della dotazione di capitale dell'ente.

Il capitale minimo.

Dal quadro positivo di riferimento emerge, dunque, che il capitale sociale nominale della s.r.l. possa attestarsi legittimamente in una *range* compreso tra 1 e 9.999 Euro.

Il Legislatore, quindi, ha ritenuto congruo con la causa associativa che domina il modello societario in commento una dotazione di capitale esigua, superando, per molti aspetti, quanto sostenuto, prima del 2013, sulla funzione del capitale sociale nel modello a responsabilità limitata.

Da ciò consegue che, benché l'opinione non sia pacifica in dottrina, il capitale minimo previsto dalla legge per la s.r.l. si attesti, oggi, alla soglia di 1 Euro.

L'ampiezza della dotazione patrimoniale capitalizzata, quindi, oggi integra solo il *discrimen* tra regimi regolamentari differenti, non riuscendo più a fornire un tratto tipologico al modello societario che assiste.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Applicabilità delle norme sull'aumento e sulla riduzione del capitale sociale.

Ciò posto non pare, ad opinione della dottrina maggioritaria, che si possa ritenere completamente superata l'esigenza di una dotazione minima di capitale sociale per l'ente in esame posto che, pur essendosi molto attenuta la sua funzione (assente, infatti, pare essere, data l'esiguità, quella di garanzia e quella produttiva), anche in tale assetto societario tale elemento sembra destinato a svolgere la funzione organizzativa che gli è propria in ogni modello a vocazione capitalistica.

Da questa circostanza consegue che:

- troveranno piena applicazione le norme che regolano, nella configurazione tradizionale, le operazione di aumento del capitale sociale gratuito ed a pagamento;
- troveranno piena applicazione le norme che regolano, nella configurazione tradizionale, le operazione di riduzione del capitale sociale per perdite (nominale) o che, per tale ragione, conducano il medesimo al disotto del minimo legale (1 Euro);
- forse, non essendo chiaro in dottrina se ciò possa accadere, potranno trovare applicazione le regole che informano, nella configurazione tradizionale, l'operazione di riduzione volontaria (reale) del capitale sociale

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. La riserva di accumulo nella S.R.L.S. e nella S.R.L. con capitale inferiore a 10.000 euro

La riserva di accumulo *ex* art. 2463, quinto comma, c.c.

Il dato normativo di riferimento statuisce che: "*La somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del presente comma se viene diminuita per qualsiasi ragione*".

La funzione della riserva di accumulo.

La norna in esame enuclea un meccanismo di accumulo di capitale di rischio che si sostituisce, nei limiti della sua operatività, a quello indicato dall'art. 2430 c.c. e integra un sistema di rafforzamento forzoso della dotazione di capitale dell'ente mercé l'utilizzo di parte degli utili di esercizio.

Tale riserva che, come già detto, entro certi limiti, sostituisce quella legale svolge una funzione ulteriore rispetto alla medesima atteso che essa non integra soltanto l'ultimo baluardo di protezione del capitale sociale, ma assolve all'esigenza di autofinanziamento progressivo della società.

In altri termini, mediante la sua previsione, il Legislatore pare aver voluto fissare un principio di patrimonializzazione progressiva dell'ente allo scopo di evitare che la possibilità di dare corpo al medesimo quasi senza risorse patrimoniali vada a detrimento dell'esercizio associato dell'attività di impresa.

Tale circostanza potrebbe essere interpretata, infatti, come un embrionale sistema per il recupero della funzione di garanzia e di quella produttiva del capitale sociale.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La disciplina della riserva di accumulo.

Quanto alla disciplina della riserva in esame occorre osservare che, sulla falsariga di quanto accade per la riserva legale:

- è alimentata da utili di esercizio in misura almeno pari al 20% di quelli realizzati in ragione d'anno sino a che, unitamente alla somma capitalizzata (e a nessuna altra voce del netto patrimoniale), si raggiuga (non è indicato un limite temporale entro cui ciò debba avvenire) la soglia dei 10.000 Euro;
- è idonea al ripianamento perdite;
- non è distribuibile tra i soci;
- è disponibile, in consonanza con la funzione svolta, per l'aumento gratuito del capitale sociale;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Le operazioni straordinarie nella S.R.L.S. e nella S.R.L. con capitale inferiore a 10.000 euro

"Trasformazione" da s.r.l. a capitale ridotto in s.r.l. ordinaria.

La dottrina maggioritaria, muovendo dalla considerazione per la quale la s.r.l. a capitale inferiore a 10.000 Euro non integra neppure un sotto tipo della s.r.l. ordinaria, ma solo una sua differente configurazione (che si caratterizza sotto il profilo disciplinare), esclude che il passaggio da tale allestimento a quello tradizionale integri un'operazione di trasformazione.

Detto passaggio, in altri termini, integra soltanto una modifica dell'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2480 c.c., idonea a recepire il mutamento disciplinare voluto dai soci e d avente ad oggetto l'aumento del capitale sociale dalla soglia originaria a quella minima fissata dalla legge per la configurazione tradizionale della s.r.l. ossia 10.000 Euro.

A tale incremento potrà giungersi:

- per il tramite di un aumento del capitale sociale a pagamento;
- giusta aumento del capitale sociale gratuito mercé l'utilizzo dell'eccedenza della riserva di accumulo rispetto ai limiti quantitativi fissati per quella legale.

Gli effetti del predetto passaggio possono essere così sintetizzati:

- viene meno l'obbligo di accantonamento utili;
- "liberazione" di risorse dalla riserva di accumulo per valori eccedenti la soglia della riserva legale;
- possibilità, per il futuro, di sottoscrivere aumenti del capitale sociale senza necessità di provvedere al correlativo versamento immediato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

"Trasformazione" da s.r.l. ordinaria a s.r.l. a capitale ridotto.

L'operazione speculare a quella appena descritta:

- è vista con sospetto da larga parte della dottrina posto che, mediante la sua attuazione (*ex* art. 2482 c.c.), si potrebbe aggirare il sistema di patrimonializzazione progressiva imposto dal Legislatore come contraltare della possibilità di costituire un ente societario a responsabilità limitata con esigua dotazione di capitale sociale.

Altra parte, minoritaria, della medesima osserva, al contrario, che nulla impedirebbe di addivenire a siffatto risultato con la precisazione che la deliberazione dovrebbe palesare la continuità aziendale onde escludere la funzione liquidatoria e, dunque, evitare l'applicazione dell'art. 2484, comma 1°, n. 4 c.c.;

- non ha alcuna attinenza con l'ipotesi decritta dall'art. 2482 *bis* c.c. posto che quest'ultimo suppone un capitale residuo di almeno 10.000 Euro;
- può, invece, intrecciarsi, a opinione di ampia parte della dottrina, con la disciplina contenuta nell'art. 2482 *ter* c.c. di tal che l'operazione divisata finisca per implementare il novero delle alternative ivi fissate.

A tal fine sarà necessario precisare che:

- l'operazione non ha funzione liquidativa, ma, al contrario, mira a garantire la continuità di impresa;
- di conseguenza andrà esclusa l'operatività dell'art. 2484, comma 1°, n. 4, c.c.;
- il capitale sociale dell'ente "di risulta" è interamente versato:
- sorgerà , nei limiti di legge, l'obbligo di alimentare la riserva di accumulo.

Fusione e scissione.

La dottrina maggioritaria, muovendo dalla considerazione per la quale la s.r.l. a capitale inferiore a 10.000 Euro non integra neppure un sotto tipo della s.r.l. ordinaria, ma solo una sua differente configurazione (che si caratterizza sotto il profilo disciplinare), ritiene applicabili anche le norme che disciplinano le operazioni di fusione e scissione.

Occorre solo precisare che se l'ente di risulta da tali operazioni è una s.r.l. a capitale inferiore a 10.000 Euro ad essa andranno applicate le particolari regole che informano detto assetto societario prescelto dai soci.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Tale scelta, ad opinione della dottrina maggioritaria, si fa preferire rispetto a quella di dare vita, *ex* novo, per questa via ad una s.r.l.s. posto che a parità di costi si avrebbero meno vincoli e si potrebbero utilizzare gli ampi margini concessi all'autonomia privata nel campo della società a responsabilità limitata senza necessità di sottostare ai rigidi precetti ministeriali.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

(con rifermento alle sole pagine indicate)

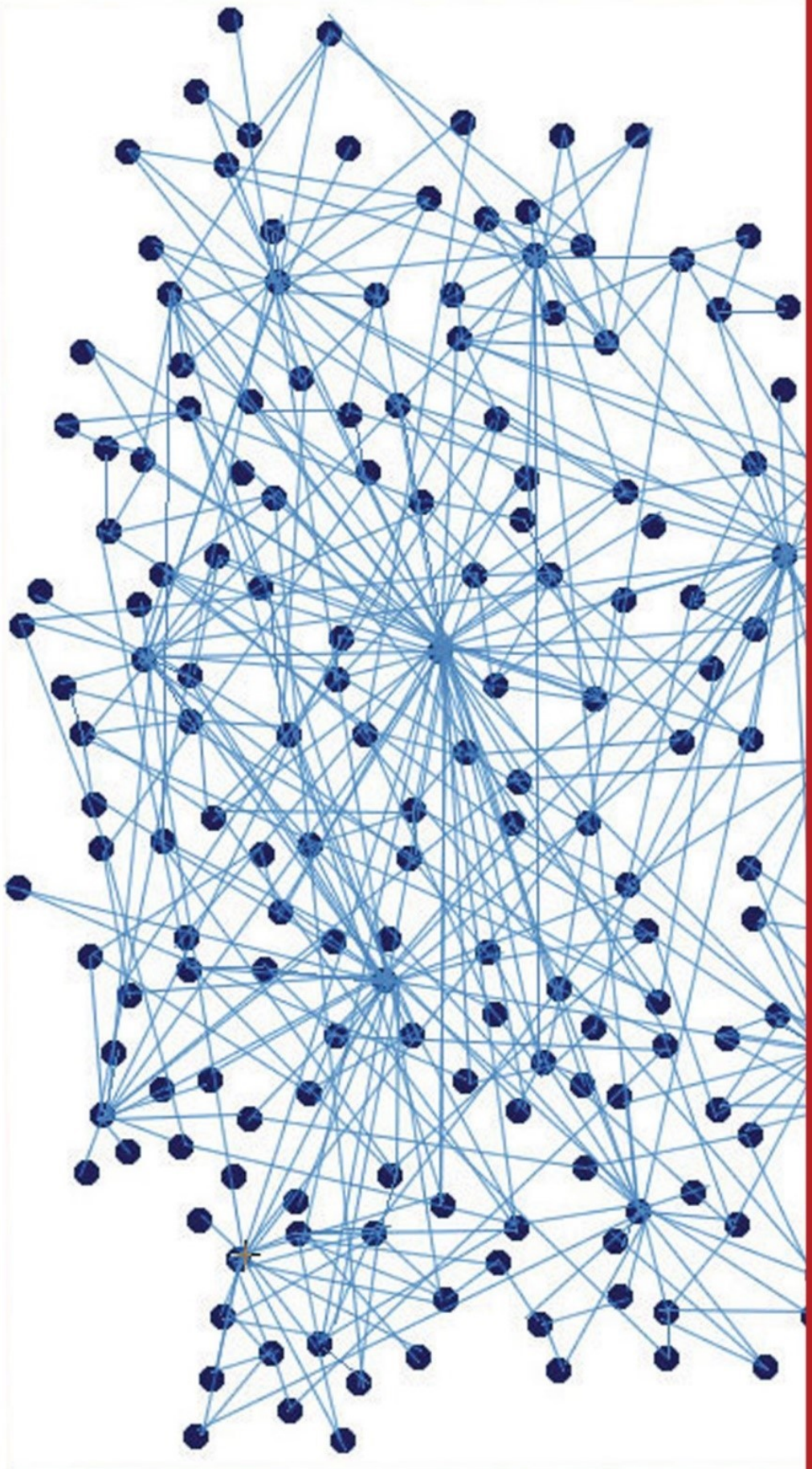
- Mambriani A. "Commento sub art. 2463, commi 4° e 5°, c.c." in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 113-122.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. START UP INNOVATIVA: FINALITÀ E INNOVAZIONE 3

1.1 IL D. L. 179/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 221/2012 3
1.2 START UP INNOVATIVA: FINALITÀ 4
1.3 START UP INNOVATIVA: DEFINIZIONE 4
1.4 START UP INNOVATIVA: I REQUISITI 4
1.5 START UP INNOVATIVA: IL POSSESSO DEL REQUISITO DI SUI AL PUNTO H) N. 1 5
1.6 START UP INNOVATIVA: IL POSSESSO DEL REQUISITO DI SUI AL PUNTO H) N. 2 6
1.7 START UP INNOVATIVA: IL POSSESSO DEL REQUISITO DI SUI AL PUNTO H) N. 3 6

2. INCUBATORE DI START UP INNOVATIVE: FINALITÀ E DEFINIZIONE 7

2.1 L'INCUBATORE DI START UP INNOVATIVE NEL D. L. 179/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 221/2012 7
2.2 INCUBATORE DI START UP INNOVATIVE: DEFINIZIONE 7
2.3 INCUBATORE DI START UP INNOVATIVE: L'AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI 8

3. PROFILI PUBBLICITARI 10

3.1 L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA START UP INNOVATIVA 10
3.2 L'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELL'INCUBATORE DI START UP INNOVATIVE 11
3.3 ART. 25, COMMA 15°, DEL D. L. 179/2012 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 221/2012 12

BIBLIOGRAFIA 13

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Start up innovativa: finalità e innovazione

1.1 Il D. L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012

La letteratura economica è solita suddividere la genesi e il decollo delle iniziative imprenditoriali in quattro fasi ossia:

- discovery;
- validation;
- efficensy;
- scaling.

Ognuna di queste fasi presenta delle criticità che, se non superate grazie ad un business plan efficace, rischiano di attentare alla vita della neonata impresa.

Le statistiche mettono in luce un elevato "tasso di mortalità" dell'imprese italiane, essendo poche quelle che riescono a superare, con successo, tutte e quattro le fasi sopra indicate.

Preso atto di questa tendenza il Legislatore, con il provvedimento normativo di cui in epigrafe, ha voluto offrire alle imprese uno strumento per strutturarsi e, di conseguenza, affermarsi sul mercato, disciplinando un fenomeno già noto alla prassi degli affari.

L'intervento normativo in esame, tuttavia, non ha riguardato tutte le strutture societarie, ma solo quelle a vocazione capitalistica.

Dal suo perimetro, quindi, restano escluse le società di persone.

Dal corpus normativo di riferimento emerge, poi, un forte legame con l'innovazione tecnologica che mira a favorire l'instaurazione di una cultura dell'innovazione.

Da ciò consegue che le società disciplinate dalla normativa in commento dovranno svolgere, in via principale o, comunque, prevalente, attività di ricerca, sviluppo, promozione e commercializzazione di prodotti o servizi ad alto valore aggiunto in àmbito tecnologico.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.2 Start up innovativa: finalità

L'art. 25, comma 1°, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221 statuisce che: "Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero".

1.3 Start up innovativa: definizione

Dalla legislazione in commento si evince che con l'impiego dell'espressione «start-up innovativa» si è voluto assegnare una veste giuridica ad un concetto imprenditoriale sensibilizzando l'interesse pubblico e orientandolo verso le nuove imprese a vocazione innovativa.

1.4 Start up innovativa: i requisiti

Dal quadro normativo di riferimento emerge che i requisiti affinché si possa discorrere di "start-up innovativa" possono suddividersi in "formali e sostanziali" a seconda che debbano essere tutti integrati oppure basti che ne sussista alternativamente uno

In ordine ai primi, l'art. 25, comma 2°, del provvedimento legislativo in esame statuisce che la "start-up innovativa" sia "…la società di capitali", costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci;
b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

1.5 Start up innovativa: il possesso del requisito di sui al punto h) n. 1

In merito ai secondi, invece, la medesima disposizione legislativa precisa, al punto h) che "start-up innovativa" possa essere definita la società, avente i predetti requisiti, a cui si aggiunga "almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti…".

Il primo ad esse indicato come termine dell'alternativa è che "le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 20 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa".

1.6 Start up innovativa: il possesso del requisito di sui al punto h) n. 2

Il secondo termine dell'alternativa invece è dato dall'"impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero".

1.7 Start up innovativa: il possesso del requisito di sui al punto h) n. 3

Il terzo ed ultimo termine dell'alternativa è dato dall'essere "titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa".

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Incubatore di start up innovative: finalità e definizione

2.1 L'incubatore di start up innovative nel D. L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012

Onde mandare ad effetto le finalità della novella Legislativa compendiate nell'art. 25, comma 1°, della Legge 17 dicembre 2012 n. 221, il Legislatore ha promosso l'incubazione di tali attività imprenditoriali all'interno di strutture che possano migliorarne il grado di sviluppo e penetrazione nel mercato.

2.2 Incubatore di start up innovative: definizione

Ai fini della disposizione in commento (art. 25, comma 5°) per «incubatore certificato» deve intendersi "una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative" ed è in possesso dei seguenti requisiti:

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultra-larga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi;
c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7".

2.3 Incubatore di start up innovative: l'autocertificazione dei requisiti

I commi 6° e 7° dell'art. 25 della legge in esame fanno chiarezza in merito all'autocertificazione dei requisiti di cui sopra statuendo che:

- comma 6°: "Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5° è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- comma 7°: "Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6° con riferimento ai seguenti indicatori:

a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;

b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;

c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;

d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;

f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;

g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate;

h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Profili pubblicitari

3.1 L'iscrizione nel Registro delle imprese della Start up innovativa

Il comma 8° dell'art. 25 della predetta legge dispone che" Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione".

Il comma 12° della stessa disposizione normativa precisa, poi, che "La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding, con autocertificazione di veridicità;
f) elenco delle società partecipate;
g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
j) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale".

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.2 L'iscrizione nel Registro delle imprese dell'incubatore di Start up innovative

Il comma 8° dell'art. 25 della predetta legge dispone che" Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione".

Il comma 13° della stessa disposizione normativa precisa, poi, che: "L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:

a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
c) oggetto sociale;
d) breve descrizione dell'attività svolta;
e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative".

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.3 Art. 25, comma 15°, del D. L. 179/2012 convertito con modificazioni dalla Legge 221/2012

Tale previsione normativa si pone quale pendant dell'obbligo di autocertificazione dei requisiti di accesso alla disciplina di settore statuendo che: "Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese".

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

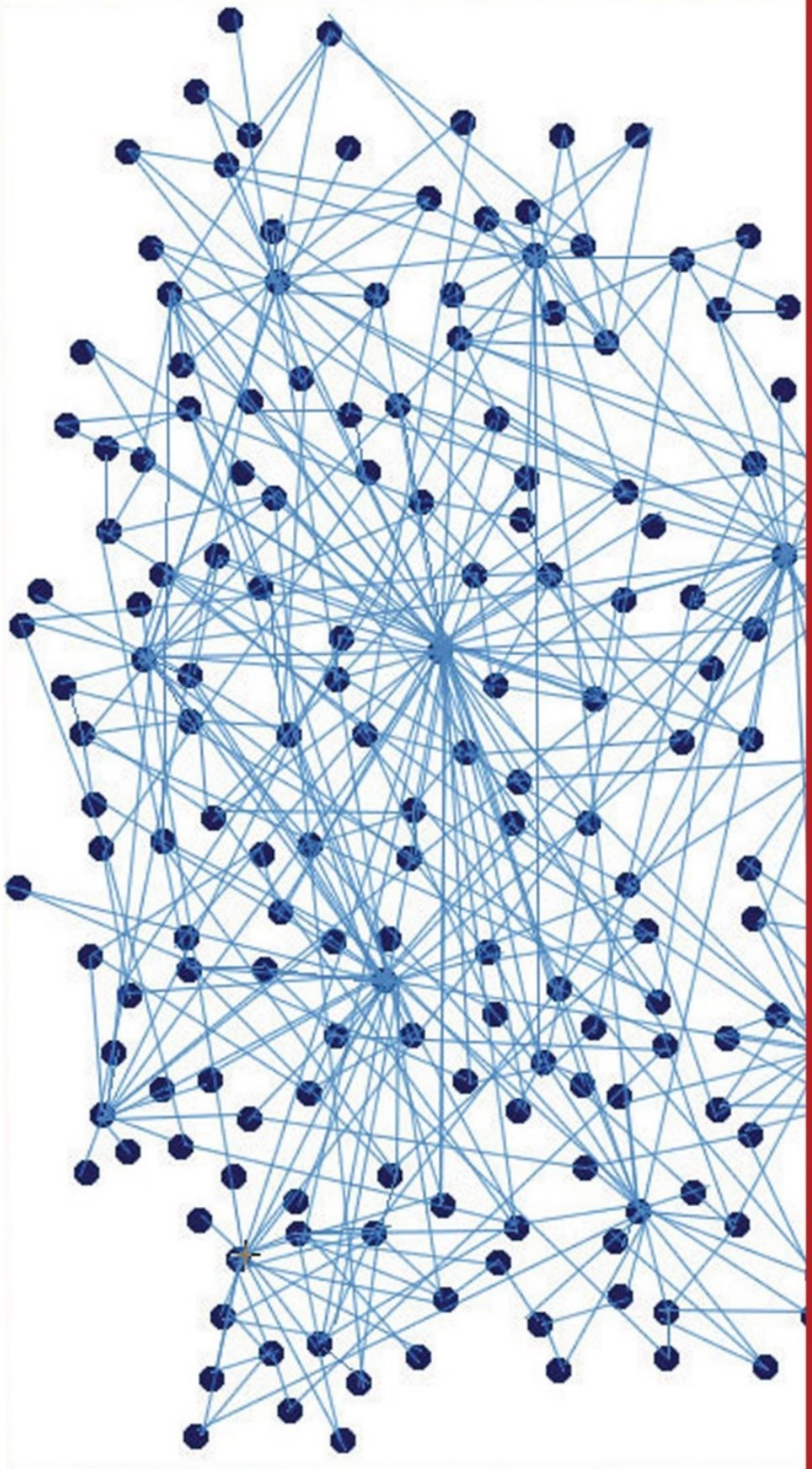
- Bollettinari A. "Disciplina della start-up innovativa" in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 933-988.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. DEROGA AL DIRITTO SOCIETARIO: LA RIDUZIONE DEL CAPITALE PER PERDITE E LA RIDUZIONE SOTTO IL MINIMO LEGALE 3

1.1 La riduzione del capitale per perdite e la riduzione sotto il minimo legale nelle start-up innovative: disciplina 3
1.2 La riduzione del capitale per perdite e la riduzione sotto il minimo legale nelle start-up innovative: ratio e confronto con la disciplina delle s.r.l. e delle s.p.a. 4
1.3 Possibili critiche alla disciplina 5

2. DEROGA IN MATERIA FALLIMENTARE. COMPOSIZIONE E GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO 6

2.1 Esclusione dell'applicazione dalla disciplina relativa alle procedure concorsuali ordinarie ed applicazione della disciplina di cui al capo II della Legge n. 3/2012 6
2.2 Àmbito di applicazione della disciplina 6
2.3 Ratio della scelta del Legislatore 7

3. DEROGHE AL DIRITTO SOCIETARIO PER LE START-UP INNOVATIVE S.R.L. 8

3.1 Libera determinazione di categorie di quote fornite di diritti diversi 8
3.2 Le quote di partecipazione in start-up innovative s.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (in deroga all'art. 2468, primo comma c.c.) 8
3.3 Inoperatività del divieto di cui all'art. 2474 c.c. 9

BIBLIOGRAFIA 10

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Deroga al diritto societario: la riduzione del capitale per perdite e la riduzione sotto il minimo legale

1.1 La riduzione del capitale per perdite e la riduzione sotto il minimo legale nelle start-up innovative: disciplina

L'art. 26, comma 1°, della Legge 221/2012 recita che: "*Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482 bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482 ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482 ter del codice civile*".

Tali regole si connotano per essere "transtipiche" posto che informano lo statuto organizzativo della società che abbia i requisiti per essere qualificata start- up innovativa a prescindere dalla forma societarie prescelta dai privati per l'esercizio dell'attività di quella data attività di impresa.

Costituiscono, in altri termini, deroghe al diritto societario che non risentono del modello organizzativo prescelto e, quindi, di contrappongono a quelle che riguardano le start-up innovative solo nel caso in cui abbiano assunto la veste di società a responsabilità limitata.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Sulla scorta di quanto reso può, dunque, essere compresa la distinzione proposta dalla dottrina in merito alle c.d. deroghe tout court al diritto societario e quelle afferenti solo alle start-up innovative organizzate secondo il modello s.r.l.

1.2 La riduzione del capitale per perdite e la riduzione sotto il minimo legale nelle start-up innovative: ratio e confronto con la disciplina delle s.r.l. e delle s.p.a

L'intento che il Legislatore sembra aver perseguito effettuando le scelte derogatorie in commento pare essere ravvisabile nella volontà di favorire, al massimo grado, la prosecuzione dell'attività di impresa, evitando che le difficoltà imprenditoriali spesso riscontrabili nella sua fase di avvio possano fare disperdere importanti risorse per l'economia nazionale.

Onde assecondare il raggiungimento di tale scopo il Legislatore ha reso peculiari le regole afferenti alla disciplina della riduzione del capitale sociale per perdite, maggiorando la portata conservativa di norme che, come ben osservato dalla dottrina, già parevano orientate al perseguimento dell'obiettivo della continuazione dell'impresa, seppur con minor dotazione di capitale.

Il confronto tra le regole che informano questo specifico settore di disciplina e quelle che dominano i modelli societari capitalistici non lasci dubbi sulla portata fortemente innovativa delle prime, atteso che le stesse, come sottolineato dalla dottrina, sembrano idonee ad un consistente il superamento delle direttive di fondo che governano la procedura di adeguamento del capitale sociale in esito all'insorgenza di perdite rilevanti o, addirittura, la sua ricostituzione per come delineata dalla normativa codicistica.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.3 Possibili critiche alla disciplina

Ciò posto, però, non ci si può esimere dall'osservare che l'intervento innovatore ha derogato in modo simmetrico ad ipotesi normative differenti, determinando un'asimmetria nelle regole di governo delle fattispecie in commento.

La riduzione del capitale sociale in esito all'accertamento di perdite rilevanti, infatti, condivide solo in parte il proprio basamento giustificativo con la diversa ipotesi di riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale a causa dell'accertamento di perdite rilevanti posto che nel primo caso la procedura mira a mettere in allerta i terzi in merito alla situazione in cui viene a trovarsi l'ente, mentre la seconda impone un immediato intervento degli organi sociali allo scopo di eliminare tale situazione e porre le basi per la dissoluzione della società.

La dottrina, quindi, se ha ben compreso le ragioni per le quali il Legislatore si sia determinato ad allargare le maglie della stringente disciplina che assiste l'ipotesi di riduzione del capitale sociale al disotto del minimo legale (fare metabolizzare all'ente le perdite che fisiologicamente possono determinarsi nella fase di avvio dell'attività di impresa), non ha compreso, non essendo la soluzione congruente con la finalità attesa, quale si stato l'intendimento legislativo in merito alla posticipazione dell'assunzione di misure tese ad informare i terzi dello stato di salute finanziaria della società.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Deroga in materia fallimentare. Composizione e gestione della crisi da sovraindebitamento

2.1 Esclusione dell'applicazione dalla disciplina relativa alle procedure concorsuali ordinarie ed applicazione della disciplina di cui al capo II della Legge n. 3/2012

In merito occorre ricordare che l'art. 31, comma 1°, della Legge 221/2012 recita che: "La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3" la quale, tuttavia, è stata anch'essa oggetto di modifica ad opera del c.d. Decreto Crescita bis.

2.2 Àmbito di applicazione della disciplina

In estrema sintesi può rilevarsi come l'ambito di applicazione delle predette procedure sia ricavabile, per esclusione, dall'art. 6, comma 1°, della Legge 27 gennaio 2012 n. 3 il quale recita che: "Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili alle vigenti procedure concorsuali, è consentito al debitore concludere un accordo con i creditori nell'ambito della procedura di composizione della crisi disciplinata dal presente capo".

Allo stato, dunque, i consumatori, gli imprenditori agricoli e gli imprenditori commerciali che soddisfino i requisiti di cui all'art. 25, comma 2°, della Legge 221/2012 non sono soggetti alle procedure concorsuali ordinarie.

Questi ultimi, in particolare, benché superino i limiti quantitativi fissati dall'art. 1 della Legge 16 marzo 1942 n. 267, per i primi quattro anni di vita della società saranno esonerati dal fallimento.

Le start-up innovative, quindi, per fare fronte a situazioni di sovraindebitamento potranno fruire sicuramente dello strumento degli accordi di ristrutturazione del debito e di soddisfazione dei creditori, mentre la dottrina non è univoca nel ritenere che possano accedere alla liquidazione del patrimonio.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.3 Ratio della scelta del Legislatore

L'intervento è atto a disciplinare il fenomeno della crisi aziendale della start-up innovativa tenendo conto dell'elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione.

Si vuole indurre l'imprenditore a prendere atto, il prima possibile, del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa, posto l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up.

La scelta è quella di sottrarre le società start-up alle procedure concorsuali vigenti, prevedendo il loro assoggettamento, in via esclusiva, alle procedure concorsuali previste dal capo II della legge n. 3 del 2012.

L'esenzione in parola opera, naturalmente, in presenza della qualifica di start-up innovativa e in particolare soltanto nel corso dei primi quattro anni dalla costituzione della società.

L'obiettivo perseguito è quello di contrarre i tempi della liquidazione giudiziale della start-up in crisi, approntando un procedimento semplificato rispetto a quelli previsti dalla legge fallimentare fondato non sulla perdita di capacità dell'imprenditore ma, piuttosto, sulla mera segregazione del patrimonio destinato alla soddisfazione dei creditori concorsuali.

Si vuole impedire, in altri termini, che l'imprenditore si veda limitare la possibilità di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale alternativo nel caso in cui quello attuato non abbia dato i frutti sperati.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Deroghe al diritto societario per le start-up innovative s.r.l.

3.1 Libera determinazione di categorie di quote fornite di diritti diversi

L'art. 26, comma 2°, della Legge 221/2012 dispone, in deroga alla disciplina tradizionale del modello societario a responsabilità limitata, che: "L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile".

Tale disposizione integra un c.d. deroga al diritto societario per le start-up innovative organizzate in forma di s.r.l. ossia una deviazione dal paradigma normativo di riferimento per il solo caso in cui l'ente assuma quale statuto organizzativo quello della società a responsabilità limitata.

3.2 Le quote di partecipazione in start-up innovative s.r.l. possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (in deroga all'art. 2468, primo comma c.c.)

L'art. 26, comma 5°, della Legge 221/2012 dispone, in deroga alla disciplina tradizionale del modello societario a responsabilità limitata, che: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali".

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Come quella che precede, anche detta previsione normativa integra una c.d. deroga al diritto societario per le start-up innovative organizzate in forma di s.r.l., riguardando solo la deviazione dal paradigma normativo di riferimento nell'ipotesi in cui l'ente assuma quale statuto organizzativo quello della società a responsabilità limitata.

3.3 Inoperatività del divieto di cui all'art. 2474 c.c.

L'art. 26, comma 6°, della Legge 221/2012 dispone, in deroga alla disciplina tradizionale del modello societario a responsabilità limitata, che: "*Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali*".

Tale disposizione, ovviamente, dà luogo ad una c.d. deroga al diritto societario per le start-up innovative organizzate in forma di s.r.l. posto che siffatto divieto si giustifica sollo sulla scorta di una particolare connotazione del modello societario a responsabilità limitata, non essendo, quindi, giustificabile (come testimoniato dalla disciplina delle azioni proprie in materia di s.p.a.) oltre i confini tipologici di detto schema societario.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

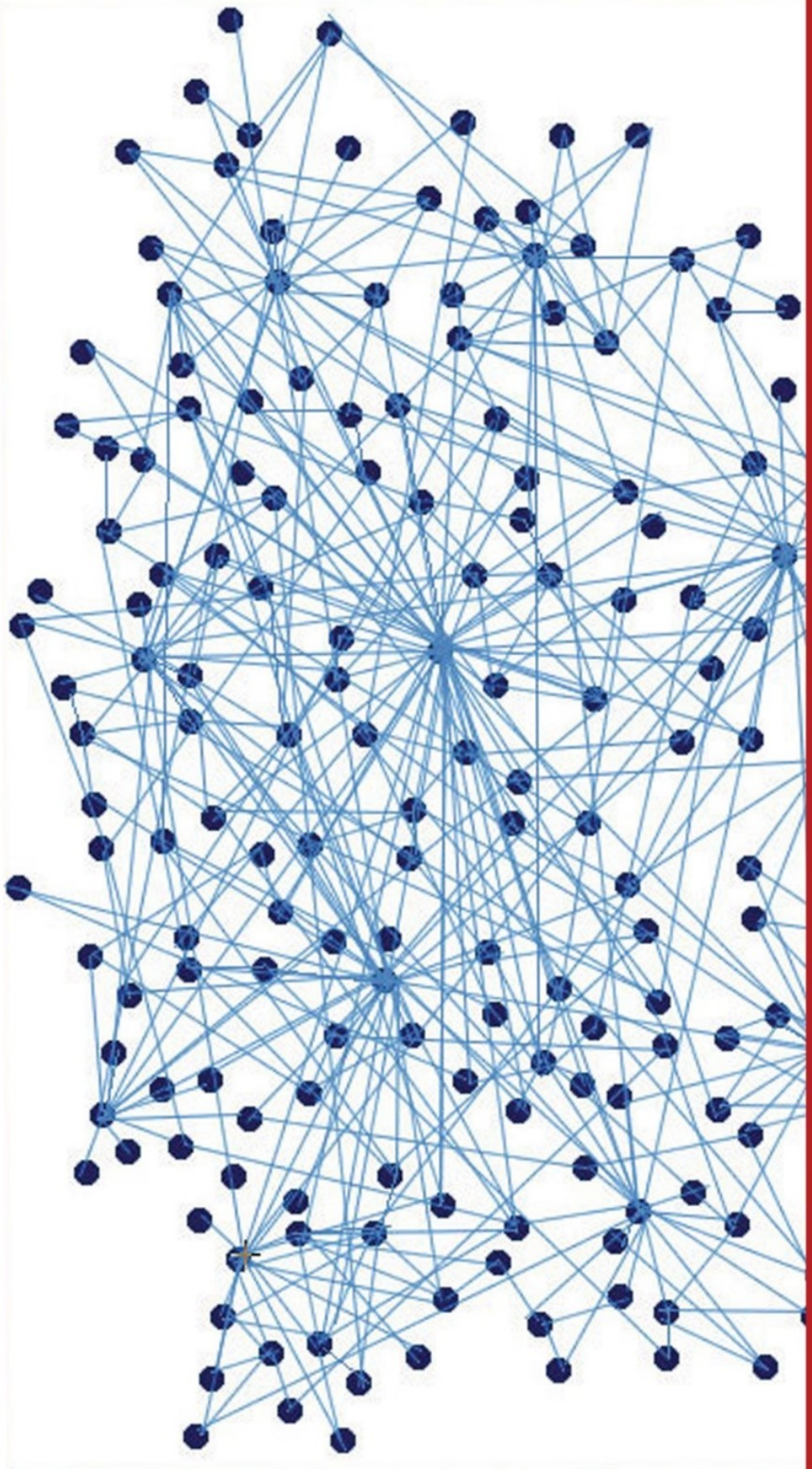
- Bollettinari A. "Disciplina della start-up innovativa" in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 933-988.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. STRUTTURA FINANZIARIA DELLA START-UP INNOVATIVA S.R.L. E DEROGHE ALLA DISCIPLINA ORDINARIA 3

1.1 IL PRIMO GRUPPO DI DEROGHE 3
1.2 IL SECONDO GRUPPO DI DEROGHE 4
1.3 IL TERZO GRUPPO DI DEROGHE 5

2. START-UP INNOVATIVA: PARTICOLARI CASI APPLICATIVI 6

2.1 LA START-UP A "VOCAZIONE SOCIALE" 6
2.2 ALLA LUCE DELLA DISCIPLINA DELLA "S.R.L. EX START-UP INNOVATIVA" IL LEGISLATORE HA ESTESO ALLE S.R.L. ORDINARIE LA POSSIBILITÀ DI CREARE DIVERSE CATEGORIE DI QUOTE? 6
2.3 START-UP S.R.L. MODIFICATA 7

3. START-UP E CROWDFUNDING COME MODALITÀ DI FINANZIAMENTO: L'EVOLUZIONE LEGISLATIVA8

3.1 L'ART. 30 DEL D.L.179/2012 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 221/2012 8
3.2 INTEGRAZIONE AL T.U.F. 8
3.3 LA DELEGA ALLA CONSOB; IL REGOLAMENTO 9
3.4 IL DECRETO DEL FARE: L'ART. 57 9
3.5 IL CONTENUTO DELLA DISCIPLINA 11
3.6 LE SITUAZIONI ESCLUSE DALLA DISCIPLINA 11

BIBLIOGRAFIA 12

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Struttura finanziaria della start-up innovativa s.r.l. e deroghe alla disciplina ordinaria

1.1 Il primo gruppo di deroghe

Tale configurazione societaria presenta, in ossequio alla ratio che ne ha stimolato il riconoscimento normativa, incisive deroghe rispetto alla disciplina ordinaria.

Siffatte deviazioni dal paradigma disciplinare di riferimento sono, come osservato dalla dottrina, ad un tempo:

- facoltative → perché saranno i soci, mediante la predisposizione di un'apposita clausola statutaria, a decidere se valersene oppure no. A seconda che la facoltà loro attribuita sia oppure no, in concreto, sfruttata si distingueranno start-up s.r.l. "modificate" o "non modificate";
- temporanee → come palesato dall'art. 31, comma 4°, del Decreto Crescita bis.

Svolta questa breve premessa è opportuno concentrarsi sulle singole classi di deroghe predisposte dal Legislatore.

La prima è quella delineata dall'art. 26, comma 2°, della Legge 221/2012 il quale statuisce che: "L'atto costitutivo della start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile".

Per questa via il Legislatore ha posto le basi per:

- ❖ consentire un'operazione che, nel modello tradizionale di riferimento, non può essere espletata circondandola, tuttavia, di guarentigie significative quali:
- il necessario rispetto del patto leonino;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- il necessario rispetto del principio di omogeneità dei diritti connessi alle singole categorie di quote (principio di uguaglianza relativo);
- il divieto di emissione di quote a voto plurimo;
- il divieto di emissione di quote che consentano ai titolari di partecipare al riparto dell'utile di esercizio anziché di quello di bilancio.

❖ l'avvicinamento dello schema societario in esame a quello azionario, mediante l'oggettivizzazione della partecipazione sociale.

1.2 Il secondo gruppo di deroghe

La seconda classe di deroghe legislative si ricava:

- dall'esame dell'art. 26, comma 3°, della Legge 221/2012 il quale stabilisce che: "L'atto costitutivo delle società di cui all'articolo 25, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'articolo 25 comma 5 può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile" → la loro regolamentazione è lasciata interamente all'autonomia privata;
- dall'esame dell'art. 26, comma 5°, della Legge 221/2012 il quale stabilisce che: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'articolo 30 del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali" → questa è un'innovazione dirompente rispetto alle modalità tradizionali di reperimento delle risorse nel modello societario a responsabilità limitata ovviamente funzionale a legittimare lo strumento del crowdfunding.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La scelta legislativa, ancòra una volta, pare potersi apprezzare come un tentativo di avvicinamento della normativa di settore a quella dei modelli azionari.

1.3 Il terzo gruppo di deroghe

La terza classe, infine, si rinviene nell'art. 26, comma 6°, della Legge 221/2012 il quale stabilisce che: "Nelle start-up innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali".

Tale blocco di deroghe mira all'incentivazione di dipendenti, collaboratori e amministratori dell'ente societario mediante attribuzione gratuita di partecipazioni sociali, previa acquisizione da parte della società, a siffatti soggetti.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Start-up innovativa: particolari casi applicativi

2.1 La start-up a "vocazione sociale"

Tale concetto evoca una società che, pur avendo i requisiti di cui all'art. 25, comma 2°, della Legge 221/2012, opera in via esclusa nei settori indicati dall'art. 2, comma 1°, del D.lgs. 24 marzo 2006 n.155.

Queste start-up innovative, come ogni latra società che possa definirsi come tale, potranno reperire risorse utili all'espletamento dell'attività di impresa per mezzo di portali on line a ciò adibiti.

2.2 Alla luce della disciplina della "s.r.l. ex start-up innovativa" il Legislatore ha esteso alle s.r.l. ordinarie la possibilità di creare diverse categorie di quote?

Il tema della oggettivizzazione dei particolari diritti all'interno della partecipazione sociale di s.r.l., da tempo controverso in dottrina, potrebbe aver trovato soluzione nella disciplina che regola le start-up innovative ove tale possibilità viene espressamente consentita allorquando venga assunta la veste societaria a responsabilità limitata.

La migliore dottrina, mettendo in guardia da fenomeni estensivi che stanno trovando riscontro nella prassi, ammonisce che una tale interpretazione non pare plausibile sulla scorta del rilievo che, nel mondo delle start-up, le deroga si giustifica alla luce di particolari esigenze che il Legislatore ha ritenuto di dover valorizzare con riguardo esclusivamente alle medesime onde favorire, in un periodo di congiuntura economica sfavorevole, l'iniziativa imprenditoriale privata.

Per queste ragioni, in adesione alla migliore opinione espressa sul punto, sembra doversi negare il carattere "transtipico" di tali innovazioni posto che le medesime, non essendo conformi alle regole di governo del tipo societario a responsabilità limitata, possono solo giustificarsi, in chiave eccezionale, sulla scorta delle argomentazioni sopra riportate.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.3 Start-up s.r.l. modificata

Il Legislatore, mediante la previsione normativa in esame, ha consentito all'autonomia privata, onde facilitare l'affermazione sul mercato di nuove realtà imprenditoriali, ampi margini derogatori rispetto al modello tradizionale di s.r.l.

L'autonomia dei soci, nel modellare l'assetto organizzativo della start-up innovativa s.r.l., potrà, quindi, declinarsi:

- in maniera conforme alle regole di governo del tipo tradizionale;
- in modo eccentrico, allontanando, in concreto, la disciplina della start-up innovativa s.r.l. da quella del tipo societario al quale ci si affida per l'esercizio dell'attività di impresa.

Da ciò consegue che, a seconda della portata del regime derogatorio, risultino individuabili:

- start-up innovative s.r.l. modificate in modo compatibile con il tipo societario di riferimento;
- start-up innovative s.r.l. modificate in modo incompatibile con il tipo societario di riferimento.

L'autonomia privata, quindi, è in grado di alterare, nel rispetto della causa sociale, i tratti fisonomici del modello societario prescelto, introducendo all'interno del medesimo profilo di apertura al mercato e regole di disciplina che, in concreto, possono avvicinarlo allo schema societario per azioni.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Start-up e crowdfunding come modalità di finanziamento: l'evoluzione legislativa

3.1 L'art. 30 del D.L.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 221/2012

La Legge 221/2012, introducendo una significativa innovazione in merito alle modalità di finanziamento per le start-up innovative ha previsto, all'art. 30, peculiari modalità di raccolta di capitali di rischio tramite portali on line.

Si è così riconosciuta la possibilità, mediante l'interpolazione di pregresse disposizioni normative, di evitare il ricorso al sistema creditizio tradizionale dischiudendo le porta a fenomeni di finanziamento privato per il tramite di strumenti telematici.

3.2 Integrazione al T.U.F.

Il predetto art. 30 ha recato, onde raggiungere l'obiettivo sopra evocato, le seguenti modifiche la Testo Unico della Finanza:

- All'articolo 1, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono inseriti i seguenti: «5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale. 5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la società definita dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto decreto è inserito il seguente: «Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative. Articolo 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative).

3.3 La delega alla Consob; il Regolamento

La medesima disposizione, al comma 5°, statuisce che "La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo entro 90 giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto".

In forza di tale delega spetta alla Consob, mediante regolamento, stabilire:

- i criteri e i principi relativi alla registrazione e alla gestione dei portali per la raccolta dei capitali per le start-up innovative;
- le regole di condotta nei rapporti con gli investitori;
- la disciplina applicabile per la raccolta di capitali.

La medesima, in esito ad una indagine conoscitiva promossa dalla Commissione, ha predisposto un documento di consultazione che è, poi, culminato, senza variazioni rilevanti, nella versione definitiva del Regolamento adottato in data 26 giugno 2013.

3.4 Il Decreto del fare: l'art. 57

La materia in esame è, poi, stata presa in considerazione dal Decreto del fare, il cui art. 57, comma 1°, statuisce che: "Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca favorisce interventi diretti al sostegno e allo sviluppo delle attività di ricerca fondamentale e di ricerca industriale, mediante la concessione di contributi alla spesa nel limite del cinquanta per cento della quota relativa alla contribuzione a fondo perduto disponibili nel Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), con particolare riferimento:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

a) al rafforzamento della ricerca fondamentale condotta nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

b) alla creazione e allo sviluppo di start-up innovative e spin-off universitari;

c) alla valorizzazione dei progetti di social innovation per giovani al di sotto dei 30 anni;

d) al sostegno allo sviluppo di capitale di rischio e crowdfunding;

e) al potenziamento del rapporto tra mondo della ricerca pubblica e imprese, mediante forme di sostegno che favoriscano la partecipazione del mondo industriale al finanziamento dei corsi di dottorato e di assegni di ricerca;

f) al potenziamento infrastrutturale delle università e degli enti pubblici di ricerca, anche in relazione alla partecipazione alle grandi reti infrastrutturali europee nell'ambito del programma europeo Horizon 2020;

g) al sostegno agli investimenti in ricerca delle piccole e medie imprese, e in particolare delle società nelle quali la maggioranza delle quote o delle azioni del capitale sia posseduta da giovani al di sotto dei 35 anni;

h) alla valorizzazione di grandi progetti/programmi a medio-lungo termine condotti in partenariato tra imprese e mondo pubblico della ricerca, con l'obiettivo di affrontare le grandi sfide sociali contemporanee;

i) al supporto e alla incentivazione dei ricercatori che risultino assegnatari di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea, ovvero dei progetti finanziati a carico dei fondi per progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) o del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB);

j) al sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese che partecipano a bandi europei di ricerca;

k) al sostegno in favore di progetti di ricerca in campo umanistico, artistico e musicale, con particolare riferimento alla digitalizzazione e messa on line dei relativi prodotti".

Tale disposizione è stata confermata, in sede di conversione, dalla Legge 98/2013.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3.5 Il contenuto della disciplina

Dal variegato quadro normativo, primario e secondario, di riferimento emerge che la portata della normativa dedicata, nel nostro ordinamento, al crowdfunding è limitata atteso che:

- riguarda soltanto l'ipotesi la raccolta di capitale di rischio a fronte dell'attribuzione di strumenti di partecipazione al capitale sociale della start-up finanziata (equity-based crowdfunding);
- la società finanziata deve essere una start-up "innovativa";
- gli strumenti partecipativi emessi a fronte di tale finanziamento non devono superare i limiti fissati dal regolamento Consob.

3.6 Le situazioni escluse dalla disciplina

Muovendo da quanto sopra precisato può, dunque, osservarsi che, pur essendo lodevole l'interesse del Legislatore rispetto a tali fenomeni, rimangono privi di regolamentazione molti aspetti che connotano detta tipologia di finanziamento rispetto agli ordinamenti in cui la medesima ha visto la luce.

In particolare, preso atto della portata della normativa interna, risultano prive di copertura:

- le società che non posseggono i requisiti di cui all'art. 25, comma 2°, della legge 221/2012;
- tutte le altre ipotesi di crowdfunding, sulle quali ci si soffermerà nella successiva lezione, note nell'esperienza anglosassone.

Il silenzio del Legislatore su tali aspetti non può che comportare l'applicazione delle comuni regole vigenti nel nostro ordinamento ai casi sopra indicati.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

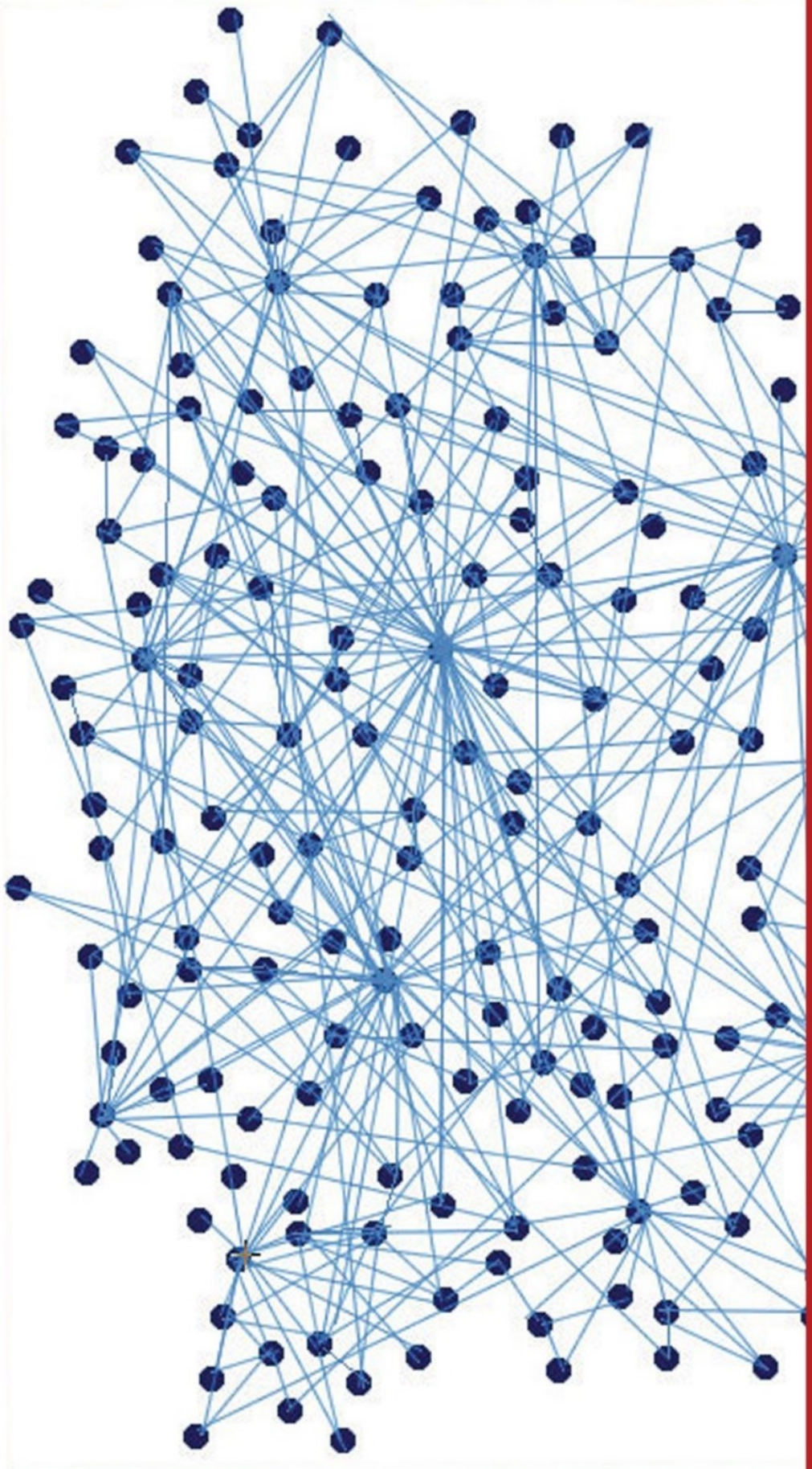
- Bollettinari A. "Disciplina della start-up innovativa" in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 933-988.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Università
Mercatorum

Università telematica delle
Camere di Commercio Italiane



Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. IL CROWDFUNDING: LA DESCRIZIONE DEL FENOMENO 3

1.1 IL CROWDFUNDING: CONTENUTO A CARATTERE INNOVATIVO 3
1.2 LE MODALITÀ DI RACCOLTA DEL CAPITALE 3
1.3 LA NASCITA DI PIATTAFORME ED IL LORO FUNZIONAMENTO; IL RUOLO DEGLI AUTORI/INIZIATORI 4
1.4 IL FUNZIONAMENTO DELLA PIATTAFORMA 4
1.5 EX ANTE CROWDFUNDING 5
1.6 EX POST FACTO CROWDFUNDING 5

2. IL CROWDFUNDING: I MODELLI 6

2.1 IL REWARD-BASED CROWDFUNDING 6
2.2 IL DONATION-BASED CROWDFUNDING 6
2.3 L'EQUITY-BASED CROWDFUNDING 7
2.4 LE PIATTAFORME DI LENDING 7
2.5 IL MICROCREDITO 7
2.6 IL DO-IT YOURSELF CROWDFUNDING 8

3. I MODELLI DI CROWDFUNDING NON REGOLAMENTATI DAL LEGISLATORE 9

3.1 IL REWARD-BASED: LA DISCIPLINA APPLICABILE 9
3.2 IL LENDING-BASED: LA DISCIPLINA APPLICABILE 9
3.3 IL DONATION-BASED: LA DISCIPLINA APPLICABILE 9

BIBLIOGRAFIA 11

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Il crowdfunding: la descrizione del fenomeno

1.1 Il crowdfunding: contenuto a carattere innovativo

Il Decreto Crescita bis ha disciplinato, all'art. 30, il fenomeno della raccolta di capitali di rischio mediante portali telematici con l'intento di favorire un adeguato sostentamento finanziario alle start-up innovative in congruenza con la ratio ispiratrice del provvedimento legislativo in commento.

Tale fenomeno può essere definito come un finanziamento collettivo di progetti, iniziative o start-up ottenuto attraverso piccoli investimenti individuali di denaro o di altre risorse effettuati da persone che nutrano fiducia nel progetto finanziato o che, comunque, ne apprezzino le potenzialità.

L'innovazione tenta, inoltre, di rispondere alla situazione di stallo che, negli ultimi anni, ha caratterizzato l'accesso al credito bancario per le società di piccole e medie dimensioni le quali, proprio per questa ragione, potrebbero trarre un significativo vantaggio dalla possibilità di reperire capitale di rischio per via prima non consentite e regolamentate.

Il tratto di novità, infatti, si ricava dalla connotazione non professionale degli investitori e dal mezzo telematico impiegato per il rastrellamento del capitale necessario a finanziare il progetto.

1.2 Le modalità di raccolta del capitale

Questo è uno degli elementi che contribuisce a delineare la fisionomia del mezzo di finanziamento in esame posto che lo stesso si connota per l'utilizzo, quale termine di mediazione, della rete internet la quale, da luogo di fruizione di contenuti digitali, assume quello di veicolo di sviluppo imprenditoriale in grado di soppiantare, a date condizioni, i tradizionali modi di reperimento di risorse finanziarie.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1.3 La nascita di piattaforme ed il loro funzionamento; il ruolo degli autori/iniziatori

Al fine di sfruttare le potenzialità della rete, nei modi sopra indicati, sono sorte delle "piattaforme" in grado di fare incontrare, in ogni settore del sapere umano, la domanda, spesso veicolata tramite i c.d. social network (la richiesta di finanziamento per un dato progetto) con l'offerta (capitali messi a disposizione dalla "folla").

La spinta propulsiva alla procedura che in seguito sarà esaminata è data dall'iniziativa dei privati, i quali prendono il nome di "autori" o "iniziatori", i quali, avendo idee, ma essendo sforniti delle risorse necessarie alla loro concretizzazione, si rivolgono alla Rete per ottenere, in tempi brevi e con poche formalità, quanto occorre per il raggiungimento del loro obiettivo.

Sarà, in ultima analisi, la Rete a stabilire se un dato progetto abbia oppure no successo, consentendo all'imprenditore di effettuare, in anticipo rispetto alla realizzazione o al collocamento sul mercato del prodotto, una embrionale analisi afferente al grado di interesse suscitato dall'idea prospettata.

1.4 Il funzionamento della piattaforma

Come sopra accennato, quindi, la rete internet è il luogo virtuale in cui si incontrano domanda e offerta con riferimento ad iniziative aventi vari contenuti specifici.

La procedura che culmina con l'incontro di domanda e offerta può essere sintetizzata come segue:

- l'autore/iniziatore pubblicherà il proprio progetto sul sito internet della piattaforma o, in particolari casi, sul proprio sito internet, avendo cura di precisare ogni dettaglio utile al fine di rendere evidenti le caratteristiche dell'iniziativa (portata, durata, spesa da sostenere e tempi di realizzazione) nonché la rimunerativà della medesima per gli investitori;

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- una volta pubblicato il progetto i finanziatori (spesso soggetti privati) potranno decidere se ed in quale misura contribuire alla sua realizzazione;
- la piattaforma tratterà, per ogni contributo ottenuto, una percentuale che costituirà la remunerazione dei servizi dalla medesima resi.

1.5 Ex ante crowdfunding

Tutte le volte in cui il finanziamento mira alla realizzazione di un progetto futuro si discorrerà di ex ante crowdfunding, categoria nella quale è, ancora, possibile distinguere tra:

- pure patronage → in questo caso la ricompensa ai finanziatori si tradurrà in un certo numero di copie del prodotto realizzato;
- patronage plus ex ante crowdfunding → in questa ipotesi, invece, oltre che alle copie, ai finanziatori spetteranno percentuali degli utili derivanti dalla commercializzazione del prodotto finanziato.

1.6 Ex post facto crowdfunding

Tale espressione evoca l'ipotesi in cui la procedura di reperimento di risorse finanziarie, mediante strumenti telematici, qui in esame sia successiva alla realizzazione di un progetto.

La stessa, dunque, non assolve, in questo caso, alla finalità di reperire risorse utili alla buona riuscita del progetto, ma, al contrario, di rientrare dei consti sostenuti per la realizzazione del medesimo o di implementare le risorse finanziarie necessarie al suo collocamento sul mercato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Il crowdfunding: i modelli

2.1 Il reward-based crowdfunding

Le piattaforme che si ispirano al modello della raccolta di fondi dietro corresponsione di utilità costituiscono il paradigma operativo del sistema di finanziamento in esame.

In estrema sintesi tali piatteforme funzionano sulla base di un investimento, antecedente o successivo alla realizzazione del progetto, remunerato da una "ricompensa".

Il fenomeno può, tuttavia, atteggiarsi in due modi:

- quello dell'"all or nothing" → il denaro viene raccolto e destinato al progetto solo se si raccoglie, per intero, la cifra indicate come necessaria la tempo della pubblicazione del medesimo;
- quello dell'"keep it all" → tutte le offerte vengono trattenute dalla piattaforma e riversate, previa decurtazione delle proprie competenze, all'iniziatore, a prescinde dal raggiungimento della cifra indicate al tempo della pubblicazione del progetto.

2.2 Il donation-based crowdfunding

Le piattaforme che si ispirano a tale modello raccolgono offerte allo scopo di finanziare iniziative no-profit.

Per il finanziatore, ovviamente, non è prevista alcuna ricompensa (salvo immaginare piccole e del tutto simboliche attribuzioni) per l'esborso effettuato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2.3 L'equity-based crowdfunding

Con l'impiego di tale espressione si evoca il fenomeno di finanziamento che si sostanzia nella sottoscrizione, da parte di investitori, di regola, non professionali, di strumenti partecipativi al capitale di rischio emessi da una società (nel caso italiano da una start-up innovativa) ed offerti, on line, dalla medesima per il tramite della piattaforma.

L'esperienza continentale ha dato prova che tale modalità di reperimento delle risorse può dare ottimi frutti, contribuendo all'affermazione sul mercato di realtà imprenditoriali che, in caso contrario, avrebbero avuto difficoltà ad imporsi (p.e. il birrificio scozzese Brewdog ed aziende Hi-Tech come Trampoline).

2.4 Le piattaforme di lending

Tali piattaforme, come dimostrato dall'esperienza anglosassone, consentono l'erogazione di prestiti secondo le logiche del "social lending" ossia tra soggetti privati (coloro che non esercitino professionalmente l'attività di finanziamento all'impresa), per il tramite della Rete.

Tale modalità di finanziamento consente di contenere i costi eliminando gli intermediari e avvalendosi di una procedura quasi del tutto automatizzata.

Al "mutuatario" sarà attribuito, preso atto del suo grado di solvibilità, un certo rating ed il medesimo dovrà restituire alla piattaforma, secondo le modalità concordate, quanto ottenuto in prestito. Quest'ultima poi, provvederà, previa decurtazione delle commissioni, a ripartire quanto ottenuto ai "mutuanti" maggiorato degli interessi

2.5 Il microcredito

La tecnica di finanziamento appena sopra descritta altro non è se non una peculiare forma di "microcredito" il cui successo deriva dalla previa condivisone di un progetto da parte dei

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

mutuanti in luogo di valutazioni di matematica finanziaria che spesso possono risultare, in concreto, non veritiere.

Una particolare declinazione del fenomeno è data dalla "microfinanza" giusta la quale si sovvenzionano (con o senza interessi), su scala globale, progetti e iniziative promossi da micro-imprenditori che, per non essere sufficientemente solvibili, non potrebbero fare ricorso ai mezzi tradizionali per l'ottenimento di mutui.

2.6 Il do-it yourself crowdfunding

È una particolare declinazione del fenomeno di finanziamento in esame che non prevede la mediazione delle piattaforme, ma l'autonoma gestione della promozione del progetto, mediante pubblicazione sul sito internet personale, e della raccolta dei fondi da parte dell'iniziatore.

Questo assetto, lungi dall'integrare un ulteriore tipo di finanziamento, rappresenta solo una particolare modalità di raccolta delle offerte che prescinde dall'intermediazione di terzi di tal che si possa dire che il soggetto che cura la raccolta, mediante promozione del progetto sul proprio sito web, sia anche colui che lo ha ideato.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. I modelli di crowdfunding non regolamentati dal legislatore

3.1 Il reward-based: la disciplina applicabile

Al riguardo pare opportuno distinguere:

- l'ipotesi in cui la ricompensa sia meramente simbolica → si rimane entro i confini della causa liberale;
- l'ipotesi in cui la ricompensa non sia meramente simbolica → occorrerà distinguere a seconda che sussista:

✓ un rapporto di scambio → si applicheranno le regole che informano il trasferimento di diritti/beni futuri (combinato disposto degli art. 1348 e 1472 c.c.);

✓ un rapporto di finanziamento → troveranno applicazione le regole sull'associazione in partecipazione (artt. 2549 e ss. c.c.).

3.2 Il lending-based: la disciplina applicabile

A tale forma di reperimento di risorse finanziare, rivolto al perseguimento di una finalità produttiva, pare potersi adattare, in assenza di una specifica normativa di riferimento, lo schema del mutuo.

3.3 Il donation-based: la disciplina applicabile

A tale forma di finanziamento, rivolto al perseguimento di una finalità altruistica, pare potersi, invece, adattare, in assenza di una specifica normativa di riferimento, lo schema donativo.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nel caso di adozione del modello di equity crowdfunding, la cui attività sia svolta in difetto dei requisiti previsti dal Legislatore, rileva il tipo di società a beneficio della quale avviene la raccolta di capitale?

La risposta al quesito, ad opinione della dottrina migliore, pare dover essere positiva in quanto i limiti posti dalla disciplina di settore con riferimento ai servizi e alle attività di investimento nonché all'offerta al pubblico di prodotti finanziari all'attività oggetto di finanziamento presentano connotazioni differenti a seconda che le beneficiarie della raccolta siano oppure no s.r.l.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Bollettinari A. "Disciplina della start-up innovativa" in "Codice delle società a responsabilità limitata" a cura di O. Cagnasso e A. Mambriani, Nel Diritto Editore, Roma, 2015 pagg. 933-988.

Università Mercatorum
Università telematica delle Camere di Commercio Italiane

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).